

Mirela Šarac/Zdravko Lučić

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

Predgovor

Premda na hrvatskom jeziku postoje veoma dobri udžbenici rimskog prava (autori: Eisner/Horvat; Horvat; Romac; Boras/Margetić), već duže vrijeme postoji potreba za knjigom kraćeg opsega, u kojoj bi za studente prava bile izložene osnovne institucije rimskog privatnog prava.

Rimsko privatno pravo zajedno s grčkom filozofijom predstavlja najznačajniju kulturnu baštinu antike, a razdoblje stare rimske države jedno je od najvažnijih razdoblja za povijest države i prava.

Knjiga je namijenjena studentima pravnog studija – početnicima, zbog čega je materija koja predstavlja uvod u suvremeno privatno pravo, prvenstveno materija stvarnog i obveznog prava, obimnije izložena. Knjiga je strukturirana tako da su klasično i Justinijanovo pravo u središtu pozornosti, a instituti preko kojih je rimsko pravo ostvarilo odlučujući utjecaj na europski pravni razvitak detaljnije su i opširnije obrađeni, od onih koji imaju pretežito povijesni značaj. Ipak, da bi studenti mogli shvatiti evoluciju i promjene osnovnih instituta privatnog prava, nužno je izložiti, barem u najkraćim crtama, pregled razvitka rimskog društva, države i prava.

Nakon kratkog pregleda povijesti rimskoga prava, slijedi poglavlje o pravu osoba u kojem je izloženo statusno i obiteljsko pravo: materija o subjektima prava, pravnom položaju raznih kategorija stanovnika, braku i obitelji. Potom su naznačene osnove civilnog postupka, koji u rimskom pravu ima veliku ulogu jer je rimsko pravo u puno većoj mjeri bilo vezano za postupak od suvremenoga. Izlaganje je ograničeno na institute procesnog prava, čije je poznavanje nužno kako bi se mogle shvatiti posebnosti i razvitak instituta stvarnog i obveznog prava. Središnji dio knjige posvećen je materiji stvarnog i obveznog prava (općeg i posebnog dijela), a završni, materiji nasljednog prava. Na kraju knjige nalazi se stvarni registar koji bi studentima trebao olakšati korištenje udžbenikom.

Zbog ograničenog opsega knjige upućuje se tek na najvažnija vrela i literaturu jer bi navođenje različitih mišljenja glede pojedinih problema, ilustriranje instituta tekstovima rimskih pravnika, kao i detaljnije obrazlaganje utjecaja rimskog prava na rješenja pozitivnog prava, znatno povećalo opseg knjige. Navedeni popis literature i vrela obuhvaća djela kojima bi se studenti mogli služiti pri izradi seminarskih i diplomskih radnji.

Cilj je udžbenika na što jednostavniji i pristupačniji način omogućiti studentima da se na početku pravnog studija, kroz nastavu rimskog prava, upoznaju s osnovnim pravnim pojmovima i da steknu fond znanja koji će predstavljati uvod i temelj za izučavanje

suvremenog privatnog prava. Najvažnije odlike suvremenog pravnika: kreativnost, bogatstvo ideja i sposobnost pravničkog razmišljanja i argumentacije najlakše se mogu steći kroz studij rimskog prava, čija je didaktična vrijednost nemjerljiva i nezamjenljiva. Bez obzira na te praktične koristi, poznavanje povijesnih temelja najvažnijih instituta privatnog prava od iznimne je važnosti za očuvanje pravničke kulture.

SADRŽAJ

Predgovor

Kratice

Bibliografija (vrela, literatura, časopisi, pomoćna sredstva)

Uvod

- § 1. Važnost rimskog prava za današnje pravo i razlozi njegova izučavanja
- § 2. Rimsko pravo: pojam i podjela
- § 3. Izvori za rimsku pravnu povijest

PRVI DIO

RAZVITAK RIMSKE PRAVNE POVIJESTI

- § 4. Uvod

I. poglavlje – “Kraljevstvo” (754. p.n.e. – 509. p.n.e.)

- § 5. Osnutak Rima i najstariji organi vlasti
- § 6. Sastav pučanstva
- § 7. Reforma Servija Tulija
- § 8. Pravo razdoblja “kraljevstva” (staro *ius civile*)

- 1. Karakteristike starog civilnog prava
- 2. Zakonik XII ploča (*lex duodecim tabularum*)

II. poglavlje – Republika (509. p.n.e. – 27. p.n.e.)

- § 9. Političke, gospodarske i društvene prilike
- § 10. Pravo razdoblja kasne Republike
(opće karakteristike, *ius honorarium*, *ius gentium*, djelatnost pravnika)

III. poglavlje – Principat (27. p.n.e. – 284. n.e.)

- § 11. Politički, gospodarski i društveni odnosi
- § 12. Pravo razdoblja Principata (klasično rimsko pravo)
 - 1. Kodifikacija pretorskog prava
 - 2. *Senatus consulta*
 - 3. *Constitutiones principum*
 - 4. Klasična jurisprudencija

IV. poglavlje – Dominat (284. – 565.)

- § 13. Gospodarske, društvene i političke prilike

- § 14. Pravo razdoblja dominata (postklasično pravo)
 - 1. *Leges i ius*
 - 2. Zbornici prije Justinijana
 - 3. Justinijanova kodifikacija (*Corpus iuris civilis*)

V. poglavlje – Rimsko pravo nakon Justinijana

- § 15. Glosatori i postglosatori (komentatori)
- § 16. Recepcija rimskog prava

DRUGI DIO

PRAVO OSOBA (*IUS QUOD AD PERSONAS PERTINET*)

I. poglavlje – Statusno pravo

- § 17. Pravna i djelatna sposobnost
- § 18. Fizičke osobe
- § 19. Stupnjevi pravne sposobnosti fizičke osobe (statusi)
 - 1. *Status libertatis*
 - 2. *Status civitatis*
 - 3. *Status familiae*
 - 4. *Capitis deminutio*

§ 20. Deliktna sposobnost

§ 21. Pravne osobe

II. poglavlje – Obiteljsko pravo

- § 22. Pojam obiteljskog prava i evolucija rimske obitelji
- § 23. Srodstvo
- § 24. *Patria potestas*
 - 1. Pojam očinske vlasti; *patria potestas* u osobnom i imovinskopравnom pogledu
 - 2. Postanak očinske vlasti
 - 3. Prestanak očinske vlasti
- § 25. Brak (*matrimonium, nuptiae*)
 - 1. Oblici sklapanja braka; učinci braka u osobnim i imovinskim odnosima
 - 2. Prestanak braka
 - 3. Zaruke (*sponsalia*); miraz (*dos*); darovanje prije braka (*donatio ante nuptias*)

TREĆI DIO
RIMSKI GRAĐANSKI POSTUPAK (*IUS QUOD AD ACTIONES PERTINET*)

I. poglavlje – Razvitak rimskog građanskog postupka

- § 26. Pojam građanskog postupka; specifičnosti rimskog prava
- § 27. Legisakcijski postupak
- § 28. Vrste legisakcija
- § 29. Formularni postupak
- § 30. Formula
- § 31. Ekstraordinarni postupak (*extraordinaria cognitio*)

II. poglavlje – Sredstva za zaštitu subjektivnih prava

- § 32. Tužba (pojam i vrste)
- § 33. Izvanredna sredstva za zaštitu subjektivnih prava
(*condictio, querella, interdictum, restitutio in integrum, exceptio*)

ČETVRTI DIO
STVARNO PRAVO

I. poglavlje – Osnove stvarnih prava

- § 34. Pojam i karakteristike stvarnih prava
(razlike između stvarnopravnog i obveznog odnosa)
- § 35. Pojam i podjela stvari
- § 36. Posjed (*possessio*)
 - 1. Pojam i elementi posjeda; razlika između vlasništva, posjeda i detencije
 - 2. Pravni učinci posjeda
 - 3. Vrste posjeda
 - 4. Stjecanje i gubitak posjeda
 - 5. Zaštita posjeda

II. poglavlje – Vlasništvo (*dominium, proprietas*)

- § 37. Općenito o vlasništvu; vrste rimskog vlasništva
- § 38. Ograničenja vlasništva
- § 39. Suvlasništvo (*condominium*)

III. poglavlje – Načini stjecanja vlasništva

- § 40. Stjecanje vlasništva

§ 41. Originarno stjecanje vlasništva

1. Okupacija (*occupatio*)
2. Nalaz blaga (*thesaurus*)
3. Priraštaj (*accessio*)
4. Miješanje stvari (*commixtio, confusio*)
5. Prerada stvari (*specificatio*)
6. Stjecanje plodova
7. Dosjelost (*usucapio*)

§ 42. Derivativno stjecanje vlasništva:

vlasništvo prednika, *iustus titulus* i *modus acquirendi*

1. *Mancipatio*
2. *In iure cessio*
3. *Traditio*

IV. poglavlje – Zaštita prava vlasništva

§ 43. Vlasničke tužbe

1. *Rei vindicatio*
2. *Actio negatoria*
3. *Actio Publiciana*

V. poglavlje – Stvarna prava na tuđim stvarima (*iura in re aliena*)

§ 44. Služnosti (*servitutes*)

1. Pojam služnosti
2. Opća obilježja služnosti
3. Vrste služnosti
4. Zemljišne služnosti (*servitutes praediorum*)
5. Osobne služnosti (*servitutes personarum*)
 - a) *Ususfructus*
 - b) *Usus*
 - c) *Habitatio*
 - d) *Operae servorum vel animalium*
6. Prestanak služnosti

§ 45. Emfiteuza (*emphyteusis*)

§ 46. Superficies

§ 47. Založno pravo

1. Pojam, svrha i razvitak založnog prava

2. *Fiducia*
3. *Pignus*
4. *Hypotheca*
 - a) Pojam i nastanak hipoteke
 - b) Vrste hipoteke
 - c) Kumulacija hipoteka
5. Postanak i prestanak založnog prava

PETI DIO
OBVEZNO PRAVO

I. poglavlje – Opći elementi obveznog prava

- § 48. Pojam obveznog prava i obveznog odnosa
- § 49. Pravne činjenice
- § 50. Pojam i vrste pravnih poslova
 1. Pojam pravnog posla (*negotium*)
 2. Vrste pravnih poslova
- § 51. Sadržaj pravnog posla
 1. Bitni, naravni i slučajni sastojci pravnog posla
 2. Uvjet (*condicio*)
 - a) Pravi uvjeti
 - b) Učinak pravnog posla pod pravim uvjetom
 - c) Nepravi uvjeti
 3. Rok (*dies*)
 4. Namet (*modus*)
- § 52. Karakteristike obvezne činidbe
- § 53. Očitovanje volje i tumačenje pravnih poslova
- § 54. Nesklad između volje i očitovanja
 1. Svjestan nesklad između volje i očitovanja
 2. Nesvjestan nesklad između volje i očitovanja
- § 55. Nevaljanost pravnih poslova
- § 56. Konvalidacija i konverzija
- § 57. Zastupanje u pravnim poslovima
- § 58. Naknada štete (*reparatio damni; interesse*)

1. Šteta (*damnum*)
 2. Protupravnost
 3. Uzročna veza
 4. Krivnja
 5. Utilitetno načelo
- § 59. Osiguranje ispunjenja obveza
1. Ugovorna kazna (*stipulatio poenae*)
 2. Jamstvo (*adpromissio*)
 3. Kapara (*arrha*)
- § 60. Zakašnjenje (*mora*)
- § 61. Pluralističke obveze
1. Razdijeljene obveze
 2. Solidarne obveze
 3. *Adstipulatio*
- § 62. Učinak obveza prema trećim osobama
1. Ugovori u korist i ugovori na teret trećih osoba
- § 63. Promjena subjekata u obveznim odnosima
1. *Cessio*
 2. *Expromissio*

II. poglavlje – Prestanak obveza

- § 64. Prestanak obveza *ipso iure*
1. Svečani načini prestanka obveza starog prava (*solutio per aes et libram; acceptilatio*)
 2. *Solutio* (ispunjenje)
 3. *Novatio* (obnova obveze)
 4. *Confusio*
 5. Naknadna nemogućnost ispunjenja
 6. Smrt
 7. *Capitis deminutio*
- § 65. Prestanak obveza *ope exceptionis*
1. *Pactum de non petendo* (oprost duga)
 2. *Compensatio* (prijeboj)

III. poglavlje – Obveze iz kontrakta (*obligationes ex contractu*)

- § 66. Pojam i klasifikacija kontrakata

- § 67. Verbalni kontrakti
 - 1. *Stipulatio*
- § 68. Literalni kontrakti
 - 1. *Expensilatio (nomen transscripticium)*
 - 2. *Chirographa i syngraphae*
- § 69. Realni kontrakti
 - 1. *Fiducia*
 - 2. Zajam (*mutuum*)
 - 3. Posudba (*commodatum*)
 - 4. Ostava (*depositum*)
 - 5. Ugovor o zalogu (*pignus, contractus pigneraticius*)
- § 70. Konsenzualni kontrakti
 - 1. Kupoprodaja (*emptio venditio*)
 - 2. Najam (*locatio conductio*)
 - a) *Locatio conductio rei*
 - b) *Locatio conductio operarum*
 - c) *Locatio conductio operis*
 - 3. Ortaštvo (*societas*)
 - 4. Ugovor o nalogu (*mandatum*)
- § 71. Inominatni kontrakti
- § 72. Pakti (*pacta*)
 - 1. *Pacta praetoria*
 - 2. *Pacta legitima*

IV. poglavlje – Obveze iz kvazikontrakata (*obligationes quasi ex contractu*)

- § 73. Poslovodstvo bez naloga (*negotiorum gestio*)
- § 74. Stjecanje bez pravne osnove (*condictio sine causa*)
- § 75. Slučajna zajednica (*communio incidens*)
- § 76. Obveze iz tutorstva (*tutela*)
- § 77. Obveze iz legata *per damnationem* (*legatum per damnationem*)

V. poglavlje – Obveze iz delikata i kvazidelikata

- § 78. Obveze iz delikta (*obligationes ex delicto*)
 - 1. Privatni delikti civilnog prava
 - a) *Furtum* (krađa)
 - b) *Rapina* (razbojstvo)

- c) *Damnum iniuria datum* (protupravno oštećivanje)
- d) *Iniuria* (povreda)
- 2. Delikti honorarnog prava
 - a) *Dolus* (prijevvara)
 - b) *Metus* (prinuda)
 - c) *Alienatio in fraudem creditorum* (prikrata vjerovnika)
- § 79. Obveze iz kvazidelikata (*obligationes quasi ex delicto*)

ŠESTI DIO

NASLJEDNO PRAVO

I. poglavlje – Opći elementi nasljednog prava

- § 80. Pojam i osnovni elementi nasljednog prava
- § 81. Stjecanje nasljedstva
- § 82. Posljedice stjecanja nasljedstva
- § 83. Pravna zaštita nasljednika

II. poglavlje – Intestatno (zakonsko) nasljeđivanje

- § 84. Intestatno nasljeđivanje po civilnom pravu Zakonika XII ploča
- § 85. Intestatno nasljeđivanje po pretorskom pravu (*bonorum possessio intestati*)
- § 86. Carsko pravo
- § 87. Intestatno nasljeđivanje Justinijanovog prava

III. poglavlje – Oporučno nasljeđivanje

- § 88. Pojam i oblici oporuke u starom civilnom pravu
- § 89. Oporučno nasljeđivanje po pretorskom pravu
- § 90. Oporuka u postklasičnom i Justinijanovom pravu
- § 91. Formalno i materijalno nužno nasljedno pravo
- § 92. Supstitucije

IV. poglavlje – Zapisi (legati i fideikomisi) i darovanje za slučaj smrti

- § 93. Legati (*legatum*)
- § 94. Fideikomisi (*fideicommissum*)
- § 95. Darovanje za slučaj smrti (*donatio mortis causa*)

Kratice

ANRW = *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung*, (izd. H. Temporini, W. Haase), Berlin/New York, od 1972. i dalje

C. = *Codex Iustinianus*

D. = *Digesta Iustiniani*

G. = Gajeve Institucije

I. = *Institutiones Iustiniani*

Nov. = *Novellae*

pr. n. e. = prije naše ere

SC. = *senatus consultum*

st. = stoljeće

Tab. = *Tabula*

Ulp. = *Ulpianus*

Bibliografija (vrela, literatura, časopisi, pomoćna sredstva)

Vrela

Corpus iuris civilis, Editio stereotypa, Berlin: I. *Institutiones*, recognovit P. Krüger, *Digesta*, rec. Th. Mommsen, retractavit P. Krüger, 15. izd., 1928.; II. *Codex Iustinianus*, rec. et. retract. P. Krüger, 10. izd., 1929.; III. *Novellae*, rec. R. Schoell, opus absolvit G. Kroll, 5. izd., 1928.

The Digest of Justinian, vol. I-IV, ed. Th. Mommsen – P. Krueger – A. Watson, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Pennsylvania, 1985.

Gaj, Institucije, Beograd 1982, prijevod i predgovor O. Stanojević

Gai Institutiones / Gaj: Institucije, Beograd 2009, prijevod i predgovor O. Stanojević

Julije Paulo, Sentencije, Zagreb 1989., izd. Latina et Graeca, knj. XX, priredio i preveo A. Romac

Justinijan, Institucije, Zagreb 1994., izd. Latina et Graeca, knj. XXVII, priredio i preveo A. Romac

Lenel, O., *Das Edictum perpetuum, ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927.

Zakonik XII ploča (Leges duodecim tabularum), Zagreb 1994., izd. Latina et Graeca, knj. XXXIII, preveo i priredio A. Romac

Literatura

Albanese, B., *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982.

Apathy, P./Klingenberg, G./Stiegler, H., *Einführung in das römische Recht*, Wien 1994.

Arangio-Ruiz, V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1986.

Bonfante, P., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1966.

Boras, M./Margetić, L., *Rimsko pravo*, Zagreb 1998.

Burdese, A., *Manuale di diritto privato romano*, Turin 1993.

Bürge, A., *Römisches Privatrecht*, Darmstadt 1999.

Eisner, B./Horvat, M., *Rimsko pravo*, Zagreb 1948.

Gaudemet, J., *Le droit privé romain*, Paris 1974.

Guarino, A., *Diritto privato romano*, Napoli 1986.

Hausmaninger, H./Selb, W., *Römisches Privatrecht*, Wien 1997.

Horvat, M., *Rimsko pravo*, Zagreb 2002.

- Kaser, M.**, *Das römische Privatrecht*, vol. I, München 1971.; vol. II, München 1975.
- Kaser, M.**, *Römisches Privatrecht*, München 2003.
- Kaser, M./Hackl, K.**, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996.
- Levy, E.**, *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951.
- Levy, E.**, *Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht*, Weimar 1956.
- Mayer-Maly, Th.**, *Römisches Recht*, Wien/New York 1999.
- Pugliese, G.**, *Istituzioni di diritto romano*, Turin 1994.
- Puhan, I.**, *Rimsko pravo*, Beograd 1974.
- Romac, A.**, *Rimsko pravo*, Zagreb 2002.
- Sanfilippo, C.**, *Istituzioni di diritto romano*, Catania 1964.
- Schmidlin, B./Cannata, C. A.**, *Droit privé romain*, I: *Sources – Famille – Biens*; II: *Obligations – Successions – Procédure*, Lausanne 1984/91.
- Schulz, F.**, *Classical roman law*, Oxford 1961.
- Stanojević, O.**, *Rimsko pravo*, Beograd 1986.
- Stanojević, O.**, *Gaivs Noster. Pisac prvog udžbenika prava. Prilog istoriji rimske pravne nauke*, Beograd 2010.
- Stojčević, D.**, *Rimsko privatno pravo*, Beograd 1985.
- Stojčević, D.**, *Rimsko obligaciono pravo*, Beograd 1960.
- Talamanca, M.**, *Elementi di diritto privato romano*, Milano 2001.
- Voci, P.**, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1954.
- Volterra, E.**, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1961.
- Zimmermann, R.**, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town/Wetton/Johannesburg 1990.

Časopisi

- Bulletino dell' Istituto di diritto romano* (skr. BIDR)
- Index. Quaderni camerti di studi romanistici (International Survey of Roman Law)* (skr. Index)
- IURA. Rivista internazionale di diritto romano e antico* (skr. Iura)
- Labeo. Rassegna di diritto romano* (skr. Labeo)
- Revue historique de droit français et étranger* (skr. RH ili RHD)
- Revue internationale des droits de l'antiquité* (skr. RIDA)
- Studia et documenta historiae et iuris* (skr. SD ili SDHI)
- Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis – Revue d'histoire du droit* (skr. TR)

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, romanistische Abteilung (skr. SZ ili ZSS ili ZSSSt ili ZRG)

Pomoćna sredstva

Novissimo digesto italiano, Torino 1957. i dalje

Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, neue Bearbeitung von Georg Wissowa und Wilhelm Kroll, Stuttgart 1894. i dalje

Berger, A., *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953.

Romac, A., *Latinske pravne izreke*, Zagreb 1982.

Romac, A. *Rječnik rimskog prava*, Zagreb 1989.

Stojčević, D./Romac, A., *Dicta et regulae iuris*, Beograd 1984.

UVOD

§ 1 - Važnost rimskog prava za današnje pravo i razlozi njegova izučavanja

Svaka znanost počinje pitanjem zašto se izučava, čemu služi. Zašto danas izučavamo pravo jedne antičke robovlasničke države koja je prestala postojati prije više od 15 stoljeća?

Premda je rimska država prestala postojati prije više od 1500 godina, na velikom broju pravnih fakulteta rimsko se pravo proučava kao poseban predmet, ili u okviru pravno-povijesnih predmeta, odnosno, kao uvod u europsko pravo ili pozitivno građansko pravo na fakultetima gdje ne postoji poseban kolegij rimskog prava. Rimsko je pravo bilo jedna od prvih znanosti koja je postala predmetom sveučilišnog studija, a njegova višestoljetna teorijska obrada od iznimne je važnosti za pravnu znanost uopće.¹

Razdoblje od sredine VIII. st. p.n.e. do sredine VI. st. n.e. obilježeno je usponom, procvatom i propašću Rima, najveće robovlasničke države u povijesti. Tijekom svoga tisućljetnog razvitka rimsko se pravo izgradilo od nacionalnog prava primitivnog poljodjelskog naroda do univerzalnoga prava koje je poznavao gotovo cijeli tadašnji svijet.

U najstarijem razdoblju svoje povijesti rimsko se društvo nalazilo na prijelazu iz višeg stupnja barbarstva ka civilizaciji, državi koja je nastajala. Tijekom vremena, mala siromašna država, osnovana po predanju 754. god. p.n.e. na brežuljcima uz obalu donjeg Tibra, nizom uspješnih ratova, postala je početkom II. st.p.n.e. gospodar Apeninskog poluotoka. Nakon Punskih ratova (II. st.p.n.e.), koji predstavljaju jednu od prekretnica u rimskoj povijesti, Rimljani proširuju svoju vlast van granica Apeninskog poluotoka, osvajaju zapadno Sredozemlje, sjevernu Afriku i šire svoju vlast sve do granica Eufrata i Tigrisa. U Rim se sliva ogromno bogatstvo, razvijaju se robonovčani odnosi, čije su žarište latifundije i gradovi. Koncentracijom zemljišnog posjeda malobrojni robovlasnici stvaraju latifundije, ogromna imanja na kojima se proizvode rentabilne kulture. Rimski ekonomisti preporučuju uzgoj onih kultura čiji se prinosi mogu povoljno unovčiti na tržištu. Tako se prešlo sa zatvorene prirodne proizvodnje, zasnovane na obrađivanju malog i srednjeg zemljišnog posjeda, na robnu proizvodnju za tržište. S tim u vezi počinje bujan procvat trgovine, bankarstva i svih oblika novčarskog poslovanja, kao i obrta.

¹ O važnosti izučavanja rimskog prava i utjecaju rimskog prava kao europskog fenomena na suvremene pravne sustave v. Koschaker, *Europa und das römische Recht*, München, 1947; Stein, P., *I fondamenti del diritto europeo*, Milano, 1987; Isti, *Roman Law in European History*, Cambridge, 1999; Margetić, L., *Rimsko pravo kao europski fenomen i hrvatska pravna povijest*, Rijeka, 1997.

Razvijena robna proizvodnja i robna razmjena i trgovina, koja se nesmetano odvijala između udaljenih provincija, koje su se specijalizirale za određenu proizvodnju, imale su za posljedicu detaljnu i preciznu razradu i reguliranje osnovnih pravnih instituta i odnosa. Zahvaljujući, u najvećoj mjeri, djelatnosti pravosudnih magistrata – pretora i rimskih pravnika, rimsko je pravo u korak pratilo razvitak gospodarskih odnosa uobličujući ustanove privatnog prava koje su, u osnovi nepromijenjene, ostale do danas u upotrebi: kupoprodaju, zajam, najam, posudbu, zalog itd.

Specifični uvjeti rimske robovlasničke države u kojima se razvijalo rimsko pravo, posebno stalna borba za zemlju i nastojanje da se osigura imovina robovlasnika, rezultirali su preciznim reguliranjem osnovnih vlasničkih odnosa i ustanovljenjem neograničenog i neprikosnovenog privatnog vlasništva. Krajem Stare ere proturječnosti u rimskoj državi dosegule su vrhunac. Da bi sredili unutarnje teškoće, Rimljani su bili prinuđeni povući vojsku s granica i prestati sa osvajačkim ratovima. Time je stvoren novi uzrok krize robovlasničkih odnosa – nedostatak radne snage i opća gospodarska kriza, koja je dovela do postupne feudalizacije Carstva i zamiranja robne proizvodnje i robnonovčane razmjene, te vraćanja na naturalnu privredu.

Nakon propasti Zapadnog rimskog carstva u novostvorenim barbarskim državama razvijeno rimsko pravo palo je u zaborav i zamijenjeno je feudalnim pravima. Ipak, kada su se unutar feudalnog društva počeli razvijati buržoaski odnosi, sve razvijenija trgovina i novčarstvo zahtijevali su odgovarajuću pravnu formulaciju, koju siromašna partikularna feudalna prava nisu mogla dati.

Trgovci, bankari i drugi poduzetnici našli su takvu gotovu formulaciju u rimskom pravu koje je pružalo već izgrađen pravni sustav i koje je svojim shvaćanjem o **neograničenosti privatnog vlasništva, slobodi ugovaranja i slobodi oporučnog raspolaganja** odgovaralo potrebama kasnog srednjovjekovnog pučanstva u borbi protiv feudalnih ograničenja.

U XV. i XVI. stoljeću Justinijanovo rimsko pravo, u obliku koji su mu dali glosatori i postglosatori (srednjovjekovni znanstvenici koji su proučavali rimsko pravo), potisnulo je domaća partikularna prava i postalo ponovno važećim pravom u većini država srednje i zapadne Europe. Na temeljima Justinijanove kodifikacije izgrađena su prava buržoaskih zemalja.

Veliki buržoaski kodeksi nastali su pod utjecajem romanističke tradicije: francuski *Code Civil* iz 1804. godine, austrijski *Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch* iz 1811., talijanski *Codice Civile* iz 1865., španjolski iz 1889., njemački *Bürgerliches Gesetzbuch* iz

1896., japanski iz 1898., švicarski iz 1907. godine. Rimsko je pravo jedan od bitnih čimbenika i hrvatske kulture, što se posebno osjeća u statutima srednjovjekovnih dalmatinskih komuna.

Upravo zbog takvog značaja koje je imalo u povijesti prava, kao i zbog uloge koju ima u današnjem pravnom životu, rimsko pravo predstavlja povijesnu podlogu pravnih studija. Proučavanje rimskog prava ima i veliku didaktičnu vrijednost. Rimsko pravo ne sadrži apstraktna pravna pravila, nego se pravo stvara na konkretnim praktičnim slučajevima. Analizom rješenja rimskih pravnika moguće je pratiti postanak, razvitak i promjene pojedinih pravnih instituta, kao i okolnosti koje su izazvale njihovu promjenu, što mladim pravnicima pruža koristi slične onima koje prirodnim znanostima daje pravljenje pokusa ili rad u laboratoriju.

Višestoljetni znanstveni rad na izučavanju rimskog prava, čemu su bili posvećeni najbolji pravници mnogih naroda, rezultirao je izgradnjom pravnih pojmova, definicija i klasifikacija pravnih ustanova koje je prihvatila suvremena pravna znanost. Terminologija rimskog prava postala je međunarodnom znanstvenom terminologijom.

Zbog toga je poznavanje rimskog prava nužno za razumijevanje današnjih građanskih zakonika, ali ono ne predstavlja samo uvod u suvremeno građansko pravo, nego ima značaj uvoda u pravnu znanost uopće.

§ 2 - Rimsko pravo: pojam i podjela

Rimsko pravo (*ius Romanum, ius Romanorum*) je pravni sustav koji je primjenjivan u rimskoj državi od njezina osnutka (po legendi 754. ili 753. god. p.n.e.) do smrti cara Justinijana (565. god. n.e.). Premda je Zapadno rimsko carstvo propalo 476. god., povijest rimskog prava smatra se zaokruženom tek smrću cara Justinijana zbog iznimne važnosti koju ima kodifikacija donesena u vrijeme njegove vladavine.

Rimljani su pravo nazivali ***ius***. Kako su rimski pravници bili prvenstveno praktičari, nisu bili skloni teorijskim i filozofskim uopćavanjima. Izbjegavali su definiranje pojmova i formuliranje općih načela. Zbog toga nisu ostavili ni definiciju prava. Za njih je riječ ***ius*** označavala **pravo u objektivnom smislu**, kao skup pravnih normi koje propisuju određeno ponašanje pojedinaca, ali i **pravo u subjektivnom smislu**, kao skup pravnih ovlasti koje pojedinci steknu na temelju objektivnih pravnih normi. Prvobitno je ta riječ označavala vjersku formulu koja obvezuje, ali već u vrijeme Zakonika XII ploča (V.st.p.n.e.) za religijska pravila koristi se riječ *fas*, dok je termin *ius* vezan isključivo za nereligijska, svjetovna pravila. Ugledni rimski pravници ostavili su više izreka o pravu u kojima su izražene opće ideje o pravu, pravičnosti i pravnoj znanosti. Ulpijan: temeljna načela prava (*iuris praecepta*): “*honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*” (pošteno živjeti, drugoga ne vrijeđati, svakome dati što mu pripada); Celzo: “*ius est ars boni et aequi*” (pravo je umjetnost dobroga i pravičnog) i sl. Te izreke sadrže filozofske konstatacije u kojima se ističe etički karakter prava.

Podjela prava, koju su izvršili rimski pravници, velikim je dijelom prihvaćena i u suvremenoj znanosti.

1. ***Ius civile, ius gentium, ius naturale***

Rimljani su imali dva pravna sustava: *ius civile* i *ius gentium*. Sustavom civilnog prava (***ius civile***) mogli su se koristiti samo rimski građani (*cives*), dok se drugi sustav (***ius gentium***) primjenjivao na sve narode koji su živjeli na teritoriju rimske države. To znači da su usporedo vrijedila oba načela primjene prava: personalno i teritorijalno.

Pravila civilnog prava primjenjivana su *ad personam*, samo na Rimljane (*ius proprium civium romanorum, ius Quiritium*), dok je *ius gentium* primjenjivan *ad territorium*, na sve stanovnike rimske države. Oba pravna sustava sačinjavaju rimsko pravo jer im je rimska država davala sankciju i brinula se o njihovoj primjeni. Rimljani su se u svojim međusobnim odnosima mogli koristiti s oba pravna sustava, a ostali stanovnici (peregrini) samo s *ius gentium*. *Ius civile* je pravni sustav sastavljen od pravila koja su nastala u

najstarijem razdoblju rimske povijesti. Kasnije su ta pravila kodificirana u Zakoniku XII ploča i dopunjavana zakonima (*leges*), djelatnošću gradskog pretora i odlukama senata. Staro civilno pravo bilo je strogo formalistično, konzervativno, siromašno i primitivno jer je nastalo u vrijeme kada je Rim bio siromašna i mala država. Zbog tih karakteristika civilnog prava Rimljani su svoje međusobne odnose radije uređivali pravilima koja je predviđalo *ius gentium* jer je taj pravni sustav bio puno razvijeniji, elastičniji i manje formalan.

Pravila *ius gentium* nastala su u vezi s trgovinom i prometom s peregrinima, koji se zbog načela personaliteta nisu smjeli koristiti civilnim pravom. Za rješavanje odnosa peregrina iz raznih provincija, kao i Rimljana i peregrina bio je nadležan poseban pravosudni magistrat – *praetor peregrinus*, koji nije bio formalno vezan za civilno pravo. Zbog toga je u rješavanju sporova mogao primijeniti najpraktičnija rješenja koja su pružala prava raznih provincija. Zato je *ius gentium* jednostavnije, razvijenije i potpunije od civilnog prava. *Ius gentium* vršilo je snažan utjecaj na *ius civile* jer je cijeli niz ustanova i načela (*bona fides*, konsenzualni kontrakti, . . .) uključen u *ius civile*. Usporedo s odgovarajućim društvenim i gospodarskim promjenama, nestala je razlika između ta dva pravna sustava i sredinom principata došlo je do njihova stapanja. U III. stoljeću n.e. razlika između njih nema više nikakav značaj.

***Ius naturale* obuhvaća one ustanove koje su zajedničke svim živim bićima.** *Ius naturale* se shvaćalo kao pravo koje pripada svakom živom biću već samim njegovim postojanjem i koje postoji van svih ustanovljenih državnih pravnih sustava i bez zakonodavčeva izričitog priznavanja. U Justinijanovim Institucijama *ius naturale* shvaća se kao nepromjenljivo, metafizičko pravično pravo. Slično shvaćanje zastupala je škola prirodnog prava u XVII. stoljeću. Međutim, upravo razvitak rimskog prava najbolje pokazuje da ne postoji metafizičko nepromjenljivo idealno pravo jer je i pravo podvrgnuto stalnim promjenama pod utjecajem raznih čimbenika.

2. *Ius publicum, ius privatum*

Kriterij podjele prava na *ius publicum* i *ius privatum* je **interes koji pravna norma štiti**. Ulpijan objašnjava da je javno pravo ono koje se odnosi na položaj države, a privatno na korist pojedinca. Javno pravo odnosi se na sakralne stvari, svećenike i magistrate, iz čega bi proizilazilo da sva ostala pravna pravila sačinjavaju privatno pravo. Dakle, **pod javnim pravom (*ius publicum*) podrazumijevaju se norme koje se odnose na interes državne zajednice, dok privatno pravo (*ius privatum*) obuhvaća pravne norme koje štite privatne imovinske interese.** Ta je podjela preuzeta i u suvremenu doktrinu premda postoje određeni prigovori da se teorijski ne mogu postaviti granice između javnog i privatnog prava. Kao

norme javnog prava smatraju se danas norme koje se odnose na organizaciju države i djelatnost državnih organa (ustavno, upravno i kazneno pravo, propisi o kaznenom i građanskom sudskom postupku), dok u privatno pravo ulazi građansko, odnosno imovinsko s nasljednim pravom, a po nekima i osobno i obiteljsko pravo.

Rimljani su pojam privatnog prava shvaćali šire jer su u privatno pravo ubrajali ne samo imovinsko i nasljedno, nego i osobno i obiteljsko pravo, te civilni postupak, a i brojne norme kaznenog i upravnog prava koje danas ulaze u područje javnog prava.

3. *Ius cogens, ius dispositivum*

Rimski pravници koristili su se izrazom "*ius publicum*" kako bi označili i **norme prisilne naravi**. To su **norme koje stranke svojim privatnim sporazumom ne mogu izmijeniti niti od njih smiju odstupiti**. Takve su norme u današnjem pravu označene izrazom "*ius cogens*". **Neprisilne (*ius dispositivum*) su norme one od kojih stranke mogu odstupiti, koje mogu svojom voljom promijeniti, prilagoditi konkretnom slučaju, ili njihovu primjenu potpuno isključiti**. Dispozitivne norme primjenjuju se onako kako je zakonodavac predvidio ako stranke u odnosnom slučaju nisu nešto drugo odredile.

4. *Ius commune, ius singulare*

Ta je podjela izvršena s obzirom na **krug subjekata** na koji se odnosi pravni propis. *Ius commune* (opće, redovito pravo) su **norme koje vrijede za sve građane**. *Ius singulare* obuhvaća **pravila koja se odnose samo na užu skupinu građana, ili čak samo na određenog pojedinca**. *Ius singulare* je **iznimka** od općih načela donesena iz razloga svrsishodnosti. Kasnije se naziva ***beneficium*** (povlastica) jer označava povoljniji pravni položaj ili neko posebno pravo, koji se dopuštaju u određenim situacijama ili se priznaju određenoj skupini osoba. Ako se radi o većoj skupini osoba, rabi se termin ***privilegium***.

5. *Ius scriptum, ius non scriptum*

Podjela prava na *ius scriptum* (pisano) i *ius non scriptum* (nepisano) izvršena je s obzirom na **izvore**, tj. kriterij je **podrijetlo pojedine norme, a ne je li napisana ili nije**. *Ius scriptum* **proizilazi od organa javne vlasti sa zakonodavnom funkcijom** i u pravilu je redigirano napismeno. Rimljani u *ius scriptum* ubrajaju: zakone (*leges* i *plebiscita*), magistratske edikte (*magistratum edicta*), zaključke senata (*senatus consulta*), mišljenja i odgovore pravnika (*responsa prudentium*) i carske konstitucije (*constitutiones*).

***Ius non scriptum* obuhvaća običaje i običajno pravo. Običaj (*consuetudo, mores*)** je društvena norma koja se stvara dugotrajnim ponavljanjem određenog ponašanja i obveznu snagu vuče upravo iz tog ponavljanja. **Običajno pravo** nastaje kada običaj dobije državnu sankciju putem pravne zaštite i kada se država pobrine za primjenu sankcije. Običajno pravo

ne stvara se pismenim aktom, niti se karakter tog prava mijenja ako bi ga netko pismeno redigirao.

6. **Personae – res – actiones**

Podjelu privatnog prava na *personae*, *res* i *actiones* izvršio je rimski pravnik **Gaj** u Institucijama. ***Ius quod ad personas pertinet*** (pravo koje se odnosi na osobe) obuhvaća pravne norme kojima su regulirana tzv. osobna prava i osobni odnosi. Unutar tih normi razlikuju se dvije posebne grane prava: **obiteljsko pravo** koje regulira položaj osoba unutar rimske obitelji i **statusno pravo** koje regulira položaj osoba izvan obitelji i koje se odnosi na pitanja pravne i poslovne sposobnosti.

Ius quod ad res pertinet (pravo koje se odnosi na stvari) sadrži pravna pravila kojima su regulirani imovinski odnosi između ljudi. Obuhvaća dvije velike skupine pravila: *inter vivos* (između živih) i *mortis causa* (za slučaj smrti). Pravila *inter vivos* dijele se na dvije skupine: *iura in re* – prava koja neposredno ovlašćuju na korištenje stvari, i *iura in personam* – prava potraživati nešto od drugih osoba. Pravila *mortis causa* označena su kao pravila nasljednog prava. Tako su izdvojena pravila **stvarnog, obveznog i nasljednog prava**.

Ius quod ad actiones pertinet je pravo koje se odnosi na tužbe i na postupak. Ono je od iznimne važnosti za razvitak rimskog prava jer je bilo prožeto pravilima materijalnog prava. Rimljani su smatrali da određeno subjektivno pravo postoji samo ako je za njegovu zaštitu bila predviđena posebna tužba. Ustanovljenjem posebne tužbe stvorene su ili priznate mnoge ustanove materijalnoga prava.

Na taj je način izgrađena osnovna klasifikacija instituta privatnoga prava, koje danas obuhvaća sljedeće grane: Statusno pravo, Obiteljsko pravo, Stvarno pravo, Obvezno pravo, Nasljedno pravo i Građanski postupak.

§ 3 - Izvori za rimsku pravnu povijest

Izvori prava obuhvaćaju **izvore prava u materijalnom smislu** (*fontes iuris essendi*) pod kojima se podrazumijevaju čimbenici koji stvaraju pravo i **izvore prava u formalnom smislu** (*fontes iuris cognoscendi*) pod kojima se podrazumijevaju pojave i oblici iz kojih se može saznati sadržaj nekog prava.

Izvori prava u materijalnom smislu su akti kojima država stvara pravo. U rimskom pravu to su: 1. običajno pravo (*consuetudo, mores*), 2. zakoni (*leges*), 3. magistratski edikti (*magistratum edicta*), 4. djelatnost pravnika (*responsa prudentium*), 5.

mišljenja senata (*senatus consulta*), 6. carske konstitucije (*constitutiones principum*). Tijekom rimske pravne povijesti navedeni izvori imali su različit značaj i ulogu.

Dragocjen materijal za rekonstrukciju pravnog života rimske države pružaju **izvori prava u formalnom smislu**. To su: sačuvana djela rimskih pravnika (Justinijanova kodifikacija, Gajeve Institucije), sačuvane javne i privatne isprave, djela nepravničkih pisaca (ekonomista, povjesničara, književnika, filozofa, govornika, stručnih pisaca itd.). Epigrafski spomenici (natpisi na hramovima, slavolucima, nadgrobnim spomenicima, javnim građevinama) kao i zapisi na papirusima pružaju puno važnih podataka. Za izučavanje rimske pravne povijesti važni su i drugi ostaci materijalne kulture koji se pronalaze prilikom arheoloških istraživanja.

PRVI DIO

Razvitak rimske pravne povijesti

§ 4 – Uvod

Prikaz razvitka instituta rimskog privatnog prava pretpostavlja poznavanje razvitka gospodarskih i društvenih prilika, kao i političkih ustanova rimske države, te poznavanje razvitka vrela rimskog privatnog prava. Prikaz svega toga čini rimsku pravnu povijest.² U ovoj je knjizi dat kratak prikaz rimske pravne povijesti po tzv. klasičnoj periodizaciji.

Prvo razdoblje predstavlja razdoblje stvaranja države. To je doba “kraljevstva” koje traje od pojave Rimljana na povijesnoj sceni (od 754. god. p.n.e. Rimljani računaju svoj kalendar) do svrgavanja „kraljeva“ 509. god. p.n.e.

Drugo razdoblje je razdoblje Republike. Obuhvaća vrijeme do ustanovljenja principata 27. god. p.n.e. Za vrijeme Republike Rim je dostigao svoj vrhunac.

U **trećem razdoblju** koje traje od stupanja na vlast Oktavijana Augusta (27. god. p.n.e.) do Dioklecijana (284. god.n.e.) preživjelost robovlasničkih odnosa dovodi do sve veće gospodarske i političke krize, koja će eskalirati u **četvrtom razdoblju** (284. – 565. god.) i rezultirati propašću Zapadnog rimskog carstva 476. godine. To je razdoblje dominata jer je car neograničeni gospodar (*dominus*). Traje do Justinijanove smrti (565. god.) zbog velikog značaja koji je njegova kodifikacija imala za daljnju sudbinu rimskog prava.

Sa stanovišta razvitka prava može se reći da je razdoblje civilnog prava trajalo do sredine Republike, honorarno pravo poklapa se s razdobljem kasne Republike, klasično pravo s principatom i razdoblje postklasičnog prava s dominatom.

² Važnija literatura o rimskoj pravnoj povijesti: Schulz, F., *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1946; Wenger, L., *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953.; Cavanna, A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti ed il pensiero giuridico*, vol. I, Milano, 1979; Wieacker, F., *Römische Rechtsgeschichte: Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur*, München, 1988; Cannata, C. A./Gambaro, A., *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, vol. II, Torino, 1989; Kunkel, W., *Römische Rechtsgeschichte*, Köln, 1990; Arangio-Ruiz, V., *Storia del diritto romano*, Napoli, 1991; Liebs, D., *Römisches Recht*, Göttingen, 1993; Dulckeit, G./Schwarz, F./Waldstein, W., *Römische Rechtsgeschichte*, München, 1995; Guarino, A., *Storia del diritto romano*, Napoli, 1996; Bretone, M., *Storia del diritto romano*, Roma/Bari, 1999; Amarelli, F./De Giovanni, L./Garbarino, P./Schiavone, A. (a cura di)/Vincenti, U., *Storia del diritto romano*, Torino, 2000; Laffi, U., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001.

Prvo poglavlje

“Kraljevstvo” (754. p.n.e.- 509. p.n.e.)

§ 5 – Osnutak Rima i najstariji organi vlasti

Po predaji Rim su osnovali božanski blizanci Romul i Rem 754. god. p.n.e. U to vrijeme rimsko društvo nalazi se na prijelazu iz višeg stupnja barbarstva ka civilizaciji. Njihovo uređenje ima obilježja vojne demokracije; razoreni su karakteristični elementi prvobitne zajednice i rodovskog uređenja, ali još uvijek nije izgrađena državna organizacija. Po tradiciji rimsku državu stvorilo je 300 rodova (gensova) koji su bili udruženi u 30 bratstava (*curia*). Kurije su bile udružene u tri plemena (*Ramnes*, *Tities*, *Luceres*), a savez ovih plemena sačinjavao je rimski narod (*Populus Romanus*).

Usavršavanje načina proizvodnje, podjela rada, imovinska diferencijacija između članova gensa, postanak ropstva, uspješni pljačkaški pohodi, te pojava plebejaca izvan gensa imali su za posljedicu propadanje gensova i gentilnog uređenja. Stvara se država koja preuzima u svoje ruke političko-upravne funkcije. Iz nekadašnje pripadnosti gensu izvodilo se nasljedno i tutorsko pravo u slučaju kada nije bilo bližih srodnika.

Više gensova (po tradiciji 10) sačinjavalo je kuriju. Kurije su imale političko-upravni, prvenstveno vojni i religijski značaj. Najviši organ vlasti, **narodna skupština (*comitia*)** bila je ustrojena po kurijama (*comitia curiata*). Skupština se sastajala dva puta godišnje. Odlučivala je o ratu i miru, birala “kralja”, pred njom se vršilo posinjenje svojevlasnih osoba (*adrogatio*), te očitovala posljednja volja (*testamentum*). Deset kurija sačinjavalo je tribus. Podjela na plemenske tribuse imala je uglavnom vojni značaj jer je svaki tribus davao po jednu centuriju (100) konjanika i 1000 pješaka.

Drugi organ vojne demokracije je **senat (*senatus*)** u koji su ulazili starješine gensova. Senat je davao odobrenje na odluke skupština (*auctoritas patrum*) i izvršavao ih, a bio je i savjetodavni organ “kralju” (*consilium regis*).

Najstarije razdoblje rimske pravne povijesti naziva se “kraljevstvom” prema institutu “**kralja**” (***rex***) premda se nije radilo o monarhu u klasičnom smislu. *Rex* je biran na skupštinama i objedinjavao je neke političke, vojne, sudske i vjerske funkcije. Rano se izdvojio poseban vjerski poglavar (*pontifex maximus*).

§ 6 - Sastav pučanstva

Već u najstarijem razdoblju rimske povijesti dolazi do diobe pučanstva na slobodne i robove. U kategoriju slobodnih ulazili su patriciji i plebejci. Pored njih postojala je i kategorija zavisnih ljudi, tzv. klijenti.

Patriciji su bili punopravni članovi stare gentilne organizacije. Zbog toga su se samo oni mogli koristiti zajedničkim šumama i pašnjacima (tzv. *ager gentilicius*). Novoosvojena zemlja postajala je njihov plijen. Jedino su njima pripadala sva građanska i politička prava. Kako su sačinjavali vladajući stalež, za sebe su zadržali pravo davati članove senata i kurijatskih skupština, obnašati magistrature i svećeničke službe (*ius honorum*), obožavati kult predaka, imati gentilno nasljedno pravo. Bavili su se zemljoradnjom, što im je omogućilo gospodarsku prevlast.

Plebejci su bili slobodni ljudi čije podrijetlo nije sa sigurnošću utvrđeno. U odnosu na patricije bili su diskriminirani u političkom i gospodarskom pogledu jer nisu pripadali staroj gentilnoj organizaciji. Bavili su se obrtom i trgovinom koji u ono vrijeme nisu bili unosni zbog općeg siromaštva. Imali su pravo sklapati pravne poslove civilnog prava (*commercium*) da bi mogli trgovati s patricijima. Nisu mogli obnašati državne ni svećeničke funkcije (nisu imali *ius honorum*), niti su mogli sklopiti zakonit brak s patricijima (nisu imali *ius conubii*). Premda su teret ratovanja podjednako snosili s patricijima, najveći dio ratnog plijena i osvojena zemlja pripadali su patricijima. Zbog toga su bili prinuđeni zaduživati se pod nepovoljnim uvjetima kod patricija sklapajući ozloglašeni oblik starinskog zajma (*nexum*) koji je dužnika, koji ne bi vratio dug, pretvarao u roba. To su bili razlozi zbog kojih su plebejci vodili ogorčenu borbu za političku emancipaciju i dodjeljivanje zemlje. Položaj plebejaca donekle je popravljen reformom Servija Tulija, donošenjem Zakonika XII ploča, uvođenjem novih magistratura (plebejski tribuni), ukidanjem dužničkog ropstva, smanjenjem kamatne stope i agrarnim reformama.

Klijenti su bili slobodni siromašni pučani koji su se stajali pod zaštitu nekog patricija (*patronus*). Odnos klijent - *patronus* predstavljao je osobnu vezu s obostranim pravima i obvezama. Klijenti su imali pravo glasa u kurijatskoj skupštini.

Robovi u ovom razdoblju nemaju veliku ulogu u gospodarskom životu. Svi su članovi obitelji prinuđeni raditi. Zato ropstvo ima patrijarhalni karakter. Izvori ropstva su ratovi i dužničko ropstvo. Položaj robova u ovo vrijeme nije bio puno gori od položaja klijenata.

§ 7 - Reforma Servija Tulija (555. p.n.e.)

Pretposljednem rimskom “kralju” Serviju Tuliju pripisuje se reforma kojom je definitivno uništena stara organizacija rimskog društva bazirana na gensovima. Tom reformom izvršena je nova organizacija vojske i skupštine. Svo pučanstvo, bez obzira radi li se o patricijima ili plebejcima, svrstano je prema bogatstvu u pet razreda. Svaki razred davao je određeni broj centurija, s tim da su najbogatiji imali najveći broj centurija. Uskoro su centurijatske skupštine potisnule kurijatske komicije i postale najvažniji organ odlučivanja. Kako je svaka centurija imala po jedan glas, većina je uvijek bila osigurana za bogate.

Nešto kasnije učinjen je posljednji korak ka stvaranju državne organizacije: izvršena je podjela zemlje na teritorijalne jedinice (tribuse) i podređivanje građana upravnoj vlasti po teritorijalnom, a ne gentilnom načelu. Tom podjelom favorizirani su patriciji koji su posjedovali zemljišta izvan grada jer im je dodijeljen puno veći broj tribusa. Premda su uvrštenjem u tribuse i centurije plebejci dobili pravo glasa u narodnim skupštinama, ostali su i dalje zapostavljeni u političkom, društvenom i gospodarskom pogledu. I dalje nisu imali *conubium* ni *ius honorum*, a njihovo pravo glasa ovisilo je o zemljišnom posjedu, odnosno imetku.

Tijekom vremena plebejci su se izborili za pravo obnašanja magistratura i ostalih državnih i svećeničkih funkcija, a završetak borbe za političku i gospodarsku ravnopravnost s patricijima predstavlja donošenje Hortensijeva zakona (*lex Hortensia*) 287. god. p.n.e., kojim je određeno da zaključci plebejskih skupština obvezuju cijeli narod.

§ 8 - Pravo razdoblja “kraljevstva” (staro *ius civile*)

Ius civile je pravo razdoblja “kraljevstva” i rane Republike. U prvom razdoblju rimske pravne povijesti vrijedi staro *ius civile*, čiji su osnovni izvor običaji. Novonastala država formirala je svoje pravo tako što je iz običaja preuzela, sankcionirala i prilagodila ona pravila koja su odgovarala njenim interesima i potrebama.

1. Karakteristike starog civilnog prava

Staro civilno pravo nastalo je u vrijeme kada je **gospodarsku osnovu rimskog društva činila zatvorena kućna privreda**. Osnovne djelatnosti bile su poljodjelstvo i stočarstvo, kojima su se bavili svi članovi domaćinstva. Svaka je obitelj zadovoljavala svoje potrebe radom na vlastitom gazdinstvu. Višak proizvoda bio je minimalan, zbog čega su

slučajevi razmjene bili rijetki. Opće siromaštvo, još uvijek nedovoljno razvijene funkcije države i primitivan mentalitet stvorili su **nerazvijen i primitivan pravni sustav**. Još uvijek postoje elementi društvenog vlasništva naslijeđeni iz gentilnog uređenja. Privatno vlasništvo tek se razvija i učvršćuje, posebno preko obiteljskog starješine, čija vlast nad članovima obitelji i obiteljskom imovinom postaje neograničena. Kako je razmjena dobara nerazvijena, i obvezno pravo je siromašno.

Pravo ovog razdoblja u uskoj je **vezi s religijom**. Jedini poznavatelji i čuvari pravnih pravila bili su svećenici (*pontifices*), a vrhovni svećenik (*pontifex maximus*) bio je nadležan za autentično tumačenje pravnih propisa. Državni i privatnopravni poslovi, kao i razne svečanosti, skupštinska zasijedanja i suđenja mogli su se vršiti samo u dane kada je religija dopuštala, a kalendar je čuvan kao religijska tajna. Ipak, već u ovom razdoblju počinje se odvajati pravo od religije, odnosno svjetovna pravila (*ius*) od religijskih (*fas*).

Primitivni uvjeti u kojima se odvijao pravni život imali su za posljedicu da je **forma** u kojoj je pravni posao poduziman bila od presudne važnosti za njegovu valjanost. Pravnu zaštitu uživali su samo oni poslovi koji su bili sklopljeni u unaprijed propisanoj formi. Ta forma sastojala se u izgovaranju svečenih riječi i vršenju određenih gestova. Najmanje nepoštivanje forme dovelo je do ništavosti poduzetog posla. Pravne poslove obilježava izraziti **formalizam i simbolika**.

Učinak pravnog posla nastaje ispunjenjem propisanih formalnosti. Dužnik mora ispuniti obvezu jer ga na to prisiljavaju izgovorene riječi i geste, koje se smatraju glavnim čimbenikom i tvorcem pravnog posla. Nije se uvažavala volja stranaka, kao ni ekonomski cilj (*causa*) koji su stranke htjele postići pravnim poslom. Zato pravne poslove ovog razdoblja karakterizira **apstraktnost**.

Rimljani su smatrali da su božanski preci i religija stvorili svečane formule kojima su sklapani pravni poslovi, te da ih zbog toga nije moguće mijenjati niti lako stvarati nove. Rimsko pravo u najstarijem razdoblju bilo je **konzervativno**.

Staro *ius civile* bilo je nedostupno pokorenim narodima ne samo zbog njegove konzervativnosti nego i zbog **načela personaliteta** koje je vrijedilo u starim pravima. Propisima civilnog prava mogli su se koristiti samo Rimljani. **Personalnost** je još jedno bitno obilježje civilnog prava.

Rimsko pravo najstarijeg razdoblja karakterizira **primitivizam** koji se najviše očitovao u oblasti zaštite prava. Sve do II. st.n.e. bila je dopuštena samopomoć kao način zaštite privatnih prava. Rimski su građani putem samopomoći i vlastitom snagom prinuđivali

sugrađane na ispunjenje obveza. Tek kada sami u tome ne bi uspjeli, tražili su intervenciju državnih organa.

2. Zakonik XII ploča (*lex duodecim tabularum*)

Zakonik XII ploča donesen je 451. i 450. god. p.n.e. Premda je to već vrijeme rane Republike, Zakonik XII ploča je kodifikacija (zakonski tekst koji na iscrpan način regulira cijelu oblast društvenih odnosa) starog civilnog prava nastalog u najstarijem razdoblju. Donošenje Zakonika XII ploča rezultat je nastojanja plebejaca da se pravo popiše i objavi, ali je ujedno i normalna posljedica osnivanja i učvršćivanja državne vlasti. Premda je smatran osnovom cjelokupnog javnog i privatnog prava, Zakonik najveću pozornost posvećuje onim pravilima običajnog prava koja su izazivala sporove i različita tumačenja. Sakupljena pravila napisana su na dvanaest ploča i objavljena na forumu. Izvorni tekst Zakonika nije sačuvan jer su izložene ploče izgorjele. O sadržaju Zakonika znamo na osnovi fragmentarnih navoda u djelima pravnih i nepravnih pisaca.

Prema uobičajenim današnjim rekonstrukcijama **sadržaj Zakonika** po pločama raspoređen je na sljedeći način: I. pozivanje pred sud, II. raspravljanje pred sudom, III. ovrha (*manus iniectio*), IV. obiteljsko pravo, V. tutorstvo i nasljedno pravo, VI. vlasništvo i pravni poslovi, VII. susjedovni i međašni odnosi, VIII. delikti (uglavnom privatni), IX. *ius publicum* (javni delikti i kazneni postupak), X. *ius sacrum* (pravila o religijskim obredima i redarstveni propisi), XI. i XII. nadopune ostalim pločama.

Pitanje postupka bilo je od iznimne važnosti kako za plebejce, koji su nastojali smanjiti samovolju patricijskih magistrata, tako i za državu, koja je osnivanjem sudova i uzimanjem pravosuđa u svoje ruke, nastojala spriječiti potpunu samovolju u zaštiti prava. Koliko je položaj plebejaca bio težak, vidljivo je iz propisa koji reguliraju ovršni postupak. Dužnik, koji ne bi vratio dug, bacan je u okove i konačno prodavan u ropstvo ili usmrćen (*Tab.* III, 5 i 6). **Primitivna i barbarska obilježja** ogledaju se i u kaznenopravnim propisima. Zakonik predviđa kaznu taliona (“oko za oko, zub za zub”) za neke teže delikte (*Tab.* VIII, 2). Ipak, predviđena je mogućnost da se kazna taliona zamijeni nagodbom ili sporazumom o oprost. Kako je nastao u primitivnoj i praznovjernoj sredini, Zakonik sadrži i propise o čarolijama za koje su predviđene najstrože kazne. Za neka kaznena djela predviđene su religijske sankcije, npr. kazna saceriteta za patrona koji izigra klijenta (*Tab.* VIII, 20).

Ima **malo propisa iz oblasti ugovornog obveznog prava**, što je posljedica siromašnog gospodarstva, nerazvijene razmjene dobara i slabog pravnog prometa. Zakonik

poznaje mali broj ustanova obveznog prava: kupoprodaju, zajam (*nexum* i *stipulatio*), neke obvezne odnose nastale iz protupravnih radnji - delikata, ali i one su vrlo nerazvijene. Obvezno pravo još uvijek nije u potpunosti izdiferencirano od ostalih grana prava. Obvezne odnose karakterizira javnost i formalizam. Moraju biti zaključeni u strogo propisanoj formi u nazočnosti svjedoka ili pred magistratom, a ispunjenje svih formalnosti je bitan i konstitutivni element ugovora. Veća je pozornost posvećena privatnim deliktima, čijim izvršenjem nastaje obvezni odnos između delinkventa i oštećenog. U nizu slučajeva Zakonik propisuje da je delinkvent obavezan platiti oštećenom određenu sumu novca. Npr. kod tjelesne povrede (*iniuria*): ako netko slobodnom čovjeku slomi kost, mora platiti kaznu u iznosu od 300 asa, za roba 150 asa (*Tab. VIII, 3 i 4*), za laku povredu 25 asa; kod krađe (*furtum*): kradljivac koji nije uhvaćen na djelu morao je platiti dvostruki iznos, na trostruki iznos kažnjavao je onaj kod koga bi bila nađena ukradena stvar i onaj koji bi drugome podmetnuo ukradenu stvar (*Tab. VIII, 14*); kod oštećenja tuđih stvari: naknada se morala platiti za nehatnu paljevinu (*Tab. VIII, 9*), a za sječu tuđeg drveća bila je predviđena kazna od 25 asa za svako stablo (*Tab. VIII, 10*) itd.

Na temelju **stvarnopravnih propisa** očito je da Zakonik posebnu pozornost posvećuje pitanjima vlasništva na nekretninama, te susjedovnim i međašnim odnosima. Kako se u to vrijeme formira i učvršćuje privatno vlasništvo na nekretninama, Zakonik propisuje uvjete za stjecanje vlasništva putem dosjelogosti, pa u *Tab. VI, 3* predviđa rok dosjelogosti za nekretnine od dvije godine, a za sve ostale stvari jednu godinu. Puno propisa pokazuje **seljačko – poljodjelski karakter** ondašnjeg rimskog društva. Velika je pozornost posvećena uređenju međa (*Tab. VII, 2, 4, 5*), regulira se pravo sakupljanja plodova koji padnu na susjedno zemljište (*Tab. VII, 10*), visina grana sa susjednog zemljišta (*Tab. VII, 9*), predviđeno je da onaj tko bi noću preorao ili posijekao tuđe plodove bude obješen u čast boginje Cerere (*Tab. VIII, 8*); ako netko zapali kuću ili stog blizu kuće, vezan i išiban treba da se spali ako je to učinio umišljajno i pri čistoj svijesti (*Tab. VIII, 9*); za ukradene plodove predviđena je smrtna kazna (*Tab. VIII, 24*) itd.

Pored obilježja primitivnog prava Zakonik sadrži mnoge **napredne misli**. Na području privatnog prava proklamira se **načelo tzv. privatne autonomije**: dopušteno je slobodno ugovaranje i udruživanje uz uvjet da se ne povrijedi pravni poredak; sklopljeni ugovori moraju se poštivati ("kako izgovore riječi, neka to bude zakon") (*Tab. VI, 1; VIII, 27*). U području nasljednog prava uvodi se **ideja o slobodi raspolaganja imovinom za slučaj smrti** (pravo na sastavljanje oporuke) (*Tab. V, 3*: "Kako odredi o svojoj imovini i tutorstvu, tako neka bude pravo."). U slučaju da je *pater familias* umro bez oporuke,

predviđen je zakonski red nasljeđivanja utemeljen na agnatskom srodstvu. U oblasti kaznenog prava naslućuju postojanje **subjektivnog elementa krivnje**. Propisano je da za nehotično ubojstvo treba samo izvršiti ritualno žrtvovanje ovna, što znači da u takvom slučaju osveta nije bila dopuštena (*Tab. VIII, 24*). Smatra se da je već zakon legendarnog kralja Nume Pompilija određivao da: “Ako netko slobodna čovjeka u zloj namjeri ubije, smatra se ubojicom.” To vjerojatno treba tumačiti da se ubojstvom treba smatrati samo ono oduzimanje tuđeg života koje je učinjeno svjesno i namjerno. Takvo ubojstvo rođaci su mogli osvetiti ako ne bi došlo do nagodbe.

Zakonik proglašava načelo legaliteta u izvršavanju smrtne kazne zabranjujući da se ubije čovjek koji nije bio prethodno suđen (*Tab. IX, 6*). O smrtnoj kazni građana mogla je odlučivati samo najviša skupština. Zabranjeno je donošenje propisa koji bi bili na štetu određenog pojedinca (*Tab. IX, 1*). Jedna od velikih vrijednosti Zakonika je u tome što je, izuzev robova, na sve jednako primjenjivan. Čudno je da je zadržana zabrana sklapanja braka između patricija i plebejaca, ali je i to uskoro ukinuto Kanulejevim zakonom iz 445. god. p.n.e.

Zakonik XII ploča nije nikada ukinut i vrijedio je sve do Justinijanove kodifikacije. Čak i u vrijeme Justinijana navođen je s poštovanjem jer je smatrano da su u Zakoniku XII ploča postavljena načela koja su razvijali svi kasniji zakoni. Donošenjem Zakonika XII ploča omogućen je razvitak rimskog prava na čvrstoj osnovi, ali elastično jer su se njegove odredbe interpretacijom mogle prilagođavati promijenjenim okolnostima. Tako su zastarjele odredbe tumačenjem, analogijama i fikcijama dobijale novi sadržaj koji je odgovarao drukčijim uvjetima u obitelji, društvu i gospodarstvu. Već je Zakonik XII ploča pokazao pravni smisao Rimljana i njihovu sposobnost konciznog i jasnog pravnog izražavanja. Donošenje Zakonika XII ploča dokaz je da je **stara gentilna organizacija zamijenjena državnom organizacijom**, a **stari običaji religijskog karaktera svjetovnim državnim pravom**.

Drugo poglavlje

Republika (509. p.n.e. – 27. p.n.e.)

§ 9 – Političke, gospodarske i društvene prilike

Razdoblje Republike obuhvaća gotovo pet stoljeća, od ustanovljenja Republike 509. god. p.n.e. do dolaska na vlast Oktavijana Augusta 27. god. p.n.e. To je vrijeme najvećih promjena u teritoriji, društvenom, gospodarskom i pravnom životu. Uzimajući kao granicu

Punske ratove razdoblje Republike može se podijeliti na dva podrazdoblja: razdoblje rane Republike koje traje do završetka drugog punskog rata 201. god. p.n.e. i razdoblje kasne Republike do 27. god. p.n.e.

U razdoblju **rane Republike** Rimljani su postali gospodari Apeninskog poluotoka. Neki od naroda pokorenih u tom razdoblju bili su na višoj kulturnoj razini od Rimljana. Etrušćani su poznavali razvijene robovlasničke odnose i imali visoku tehničku kulturu, naročito u obradi metala. Grci, koji su nastanjivali jug Apeninskog poluotoka, bili su majstori prekomorske trgovine. U Kampaniji su bili razvijeni obrti. Osvajanjem Apeninskog poluotoka Rimljani su dobili široku sirovinsku bazu. Pokoravanjem naroda koji su živjeli na tom području Rimljani nisu uništili njihove kulture, nego su ih uključili u svoj ratni i državni stroj. Time su proizvodne snage Rimljana i njihova opća kulturna razina jako podignute, što je omogućilo daljnja osvajanja. Ipak u ovom razdoblju nije došlo do korjenitih promjena u gospodarskoj i društvenoj strukturi države. Osnovu gospodarstva i dalje čini zatvorena kućna privreda zasnovana na malom i srednjem zemljišnom posjedu. Plebejci se još uvijek nisu izjednačili u pravima s patricijima. Svrgavanje "kralja" i ustanovljenje republike nije dovelo do temeljitog preuređenja državnog aparata. Zadržani su postojeći organi vlasti, a na čelu države su dva konzula. *Ius civile* dopunjavano je zakonima (*leges*), djelatnošću gradskog pretora i odlukama senata.

U razdoblju **kasne Republike** Rim širi svoju vlast van granica Apeninskog poluotoka, da bi krajem tog razdoblja obuhvaćao ogromni teritorij koji se protezao od Britanije, preko Rajne i Dunava, Crnog Mora, Kavkaza, Kaspijskog mora, Tigrisa, Perzijskog zaljeva, Arabije, Egipta, Sjeverne Afrike, Gibraltara, Španjolske do Britanije. Robovlasnički odnosi s klasičnim oblicima ropstva, veličina i snaga Rima dostižu vrhunac. Razvijaju se robonovčani odnosi, čije su žarište latifundije i gradovi. Mali broj privatnika uzima u zakup od države, za minimalnu zakupninu, velike komplekse novoosvojene zemlje, koja je najvećim dijelom proglašavana za državnu zemlju (*ager publicus*) i na kojima je uz nemilosrdnu eksploataciju robova organizirana proizvodnja za tržište. Mali i srednji zemljoposjednici propadaju zbog dugog odsustvovanja s parcela zbog ratovanja, prezaduženosti i nemogućnosti da konkuriraju jeftinijoj robi s latifundija. Zbog velikih potreba latifundija za oruđima za rad, vojske za oružjem i drugom ratnom opremom, države u izgradnji putova i javnih građevina, kao i potreba samih rimskih građana brzo se razvijaju rudarstvo i obrt. Provincije se specijaliziraju za određenu proizvodnju. Opskrba vojske i organizacija obrtničkih poduzeća potaknule su trgovačku i zelenašku aktivnost Rimljana. Razvijaju se bankarstvo i svi oblici novčarskog poslovanja i špekulacija. Skoro cijeli antički

svijet postaje jedinstveno trgovinsko područje, na kojem se trgovalo najviše robovima, žitom, luksuznim predmetima, zemljom i mnogim drugim proizvodima.

Dolazi do korjenitih promjena u društvenoj strukturi. Robovi i pokoreni narodi daju osnovno obilježje strukturi rimskog društva u ovom razdoblju. Uspješni ratovi imali su za posljedicu veliku ponudu robova na tržištu. Cijena im je bila niska zbog čega o njihovim životnim uvjetima nitko nije vodio računa. Pravni položaj **robova** sveden je na položaj objekata prava – stvari.

Poseban položaj imali su **Latini**, stanovnici Lacijuma. Mogli su zaključivati poslove civilnog prava i sklapati brakove s Rimljanima. Premda su od davnina bili s Rimljanima u Latinskom savezu, imali su podređenu ulogu u raspodjeli plijena, a nisu bili ravnopravni ni u političkim pravima. To je rezultiralo tzv. “savezničkim ratom” nakon kojeg im je u I. st. p.n.e. dodijeljeno rimsko građanstvo. Tako se postupno širio krug punopravnih rimskih građana. U zajednici s Latinima Rimljani su osnivali kolonije učvršćujući svoju vlast i šireći svoju kulturu.

Peregrini su slobodni stanovnici osvojenih provincija, čiji je položaj ovisio najviše o stupnju otpora koji su pružili prilikom pokoravanja. Položaj novoosvojene provincije određivan je putem tzv. *lex data*, koji je izdavao rimski vojni zapovjednik, te odlukama skupštine, senata i upravitelja provincije. Kako se nisu mogli koristiti rimskim civilnim pravom, u poslovima s Rimljanima postupali su po načelima *ius gentium*. Sporove s Rimljanima i s peregrinima iz drugih provincija rješavao je poseban magistrat – *praetor peregrinus*, uveden polovicom III. st. p.n.e. Kada je nakon 212. godine putem *constitutio Antoniniana* svim slobodnim stanovnicima Carstva bilo priznato rimsko pravo građanstva, pojam *peregrinus* označava barbara, stranca u pravom smislu riječi.

Rimski narod u ovom razdoblju čine nobili, ekvestri, gradski plebs i seljaci. Više ne postoji podjela na patricije i plebejce. Najbogatiji poduzetnici podrijetlom su plebejci. Patriciji se uglavnom nisu uključili u trgovinu i druge poslove smatrajući ih nedostojnim i neotmenim. Potomci slavnih patricija zatvaraju se u uski krug nazvan **nobilitas**. Ipak su u svojim rukama uspjeli zadržati senat, koji je u ovom razdoblju faktično imao najviše vlasti i upravljao državom. Obogaćeni plebejci: trgovci, bankari, vlasnici latifundija, poslovni ljudi obrazuju poseban sloj – **ordo equester** (“konjanički red”) jer su kao najbogatiji razvrstavani u konjaničke centurije. Uporište ekvestara bile su centurijatske skupštine.

Plebejci koji se nisu uspjeli obogatiti, propali patriciji i bivši sitni zemljišni posjednici obrazuju novi sloj – **gradski plebs**. Premda siromašni, ti su ljudi prezirali fizički rad živeći

od besplatne podjele hrane i novčane pomoći koju je davala država ili kandidati za magistrature.

Slobodni seljaci, koji su velikim dijelom u procesu stvaranja latifundija izgubili zemlju, pretvaraju se u gradski plebs ili u vojnike.

Najvažniji organi vlasti u ovom razdoblju su skupštine, senat i magistrati. Formalno najviši organ vlasti je **centurijatska skupština**, koja donosi zakone i bira najviše funkcionare – magistrate. **Senat** sačinjavaju po nasljedstvu *nobiles* i bivši visoki magistrati. Premda u ovom razdoblju nije bio zakonodavni organ, imao je važan utjecaj na zakonodavnu djelatnost narodnih skupština jer su skupštine mogle glasovati samo o onom prijedlogu koji je usvojen u senatu. Senat je imenovao vojne zapovjednike i upravitelje provincija i upravljao državnom blagajnom. Postupno je u svoje ruke koncentrirao svu važniju unutarnju i vanjsku politiku. Mišljenje koje bi glasovanjem bilo prihvaćeno u senatu zvalo se ***senatus consultum***.

Upravnu vlast vršili su **magistrati**. Njihov mandat trajao je godinu dana, s iznimkom cenzure koja je trajala 18 mjeseci i diktature, koja je trajala dok ne prođe opasnost, a najduže 6 mjeseci, nakon čega je uspostavljan raniji sustav vlasti. Bitno obilježje rimskih magistratura je besplatnost (*ius honorum*) zbog čega su ih mogli obnašati samo bogati građani. Izuzev diktature to su bili kolegijalni organi vlasti, a svaki funkcionar imao je pravo veta na odluke svog kolege u magistraturi. Konzuli su imali pravo veta na odluke svih drugih magistrata. “Viši” magistrati imali su *imperium*, tj. vlast vojnog zapovijedanja i kažnjavanja za nepoštivanje odredbi. Za razliku od njih “niži” magistrati imali su samo *potestas*, tj. ovlasti za obavljanje određenih državnih poslova, ali bez prava vojnog zapovijedanja i kažnjavanja.

Vrhovna vojna, građanska i političko-upravna vlast pripadala je dvojici **konzula**. Pravna pravila donesena za vrijeme njihova mandata imala su snagu zakona. Za razvitak privatnog prava posebno su značajni **pretori** i **kurulski edili**.

Pretori su u početku bili zamjenici konzula sa istim ovlastima. Vremenom je njihova djelatnost usmjerena na organiziranje pravosuđa i stvaranje pravnih pravila. Gradski pretor primjenjivao je i stvarao *ius civile*, dok je peregrinski pretor primjenjivao i stvarao *ius gentium*. Poseban položaj imali su cenzori. **Cenzori** su birani svakih pet godina sa zadaćom da izvrše popis senatora i rimskih građana i njihove imovine, te da ih razvrstaju po centurijama. **Kurulski i plebejski edili** vršili su redarstvenu službu u gradu Rimu i određeno kazneno sudovanje. **Kurulski edili** imali su jurisdikciju u sporovima na tržnicama. Zaslužni su za razvitak privatnog prava, posebno ugovora o kupoprodaji. Brinuli su i za opskrbu grada hranom i za priređivanje javnih igara i svečanosti.

§ 10 - Pravo razdoblja kasne Republike

(opće karakteristike, *ius honorarium*, *ius gentium*, djelatnost pravnika)

Promjene u društvu i gospodarstvu, prvenstveno razvitak robne proizvodnje i robonovčane razmjene praćeni su nastankom i razvitkom velikog broja novih pravnih ustanova. Staro *ius civile* nije moglo dati rješenja za veliki broj odnosa koji su se javljali u praksi. Kako su bili vezani tradicijom i neprikosnovenošću Zakonika XII ploča, rimski su pravници bili prinuđeni stvarati nova pravna pravila s puno studioznosti i elastičnosti tumačeći, zaobilazeći, dopunjavajući i izigravajući propise starog civilnog prava. Tako je nastao izvanredno elastičan, dobro prostudiran i praktično riješen sustav privatnog prava. Pravnici traže načine da se pravni poslovi obavljaju brzo i jednostavno kako bi pravni promet bio što efikasniji. Svečane riječi i simbolične geste, učinjene pri sklapanju pravnih poslova ne smatraju se više tvorcem učinka pravnog posla nego samo kao zahtjev forme u kojoj treba uobličiti volju stranaka da bi se osigurala utuživost po civilnom pravu. Sve više se uvažava volja stranaka, pa se u sukobu volje stranaka i forme daje prednost volji. Pravo postaje manje formalno i apstraktno; stvaraju se neformalni kauzalni pravni poslovi.

Sve te promjene izvršene su najvećim dijelom zahvaljujući djelatnosti pretora³ i kurulskih edila. Funkcija pretora uvedena je 367. god. p.n.e. kao zamjenika konzula s pravom vojnog zapovijedanja. Ubrzo je njihova glavna zadaća postala organiziranje pravosuđa i s tim u vezi stvaranje pravnih pravila. Godine 242. p.n.e. uveden je još jedan pretor, pa je funkcija između njih podijeljena tako da je **gradski pretor (*praetor urbanus*)** bio nadležan za rješavanje sporova između rimskih građana, dok je **peregrinski pretor (*praetor peregrinus*)** bio nadležan za sporove između rimskih građana i peregrina i sporove između peregrina iz raznih provincija. Započinjući svoju jednogodišnju dužnost pretori su izdavali proglas (***edictum***), u početku usmeno, a kasnije u pisanom obliku (*album*), o tome kako će postupati u određenim slučajevima. Ta su pravila za trajanja pretorova mandata imala snagu zakona i građani su im se morali pokoravati, pod prijetnjom sankcije koju je pretor mogao izreći temeljem svog *imperiuma*. Međutim, ta pravila nisu obvezivala sljedećeg pretora jer je novi magistrat morao izdati novi edikt. Najčešće bi sljedeći pretor preuzeo pravila svog prethodnika ukoliko su se u praksi pokazala kao dobra, ispravio bi njihove nedostatke i

³ Važnija literatura o djelatnosti pretora: Wenger, L., *Praetor und Formel*, München, 1926; Serrao, F., *La "iurisdictio" del pretore peregrino*, Milano, 1954; Buti, I., *Il "praetor" e le formule introduttive del processo formulare*, Camerino, 1984; Brennan, T. C., *The praetorship in the Roman Republic down to 81 B. C.*, Harvard University, Diss., 1990; Gallo, F., *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto: corso di diritto romano*, Torino, 1997; DeMartino, F., *Individualismo e diritto romano privato*, Torino, 1999.

dopunio ih. Tako su pretorovi edikti stalno mijenjani i prilagođavani svakodnevnim potrebama pretvorivši se vremenom u kompleksan sustav privatnog prava – *ius honorarium*. Premda sustav starog civilnog prava nije nikada formalno ukinut, *ius honorarium* ga je u potpunosti potisnuo iz prakse.

Pretor nije bio zakonodavac. Nije smio ukinuti stare, niti donositi nove zakone. To se posebno odnosi na gradskog pretora koji je bio formalno vezan za *ius civile*. Njegova prvobitna funkcija bila je tumačenje, a ne stvaranje prava. Pretor je utjecao na razvitak prava pružajući pravnu zaštitu onim odnosima koji nisu bili priznati po starom civilnom pravu, ili odbijajući pravnu zaštitu odnosu koji je bio poznat i zaštićen civilnim pravom ako bi smatrao da je taj odnos u suprotnosti s načelima pravičnosti i dobre vjere. Pretor nije neposredno odlučivao u sporovima. Donošenje presude prepuštao je sucu kojeg bi stranke izabrale. Prethodno bi na temelju navoda stranaka utvrdio postoje li pretpostavke za vođenje spora, te bi odobrio tužbu (*actionem dare*), ili bi je uskratio (*actionem denegare*). Pri tome pretor nije smio postupati samovoljno jer je po prestanku mandata mogao odgovarati zbog zloupotrebe vlasti.

Kriterij kojim se pretor rukovodio bilo je **načelo pravičnosti** (*aequitas*). Primjenom tog načela stvarana su nova pravna pravila i zaštićeni novonastajući odnosi u koje su stranke ulazile oslanjajući se na savjesnost i poštenje suugovaratelja. Sve više se uvažava *bona fides* (**dobra vjera**)⁴ koja se u pravnim poslovima *bonae fidei* pretvara u pravni pojam.

Često se događalo da stranke, koje nisu željele osigurati pravo na podizanje tužbe, sklope posao ne poštivajući propisane formalnosti pouzdavajući se u međusobno poznanstvo, prijateljstvo i povjerenje. Premda te neformalne prijateljske usluge nisu imale karakter pravnih poslova, svakodnevnom su praksom dobijale ustaljenu fizionomiju namećući potrebu za pravnom zaštitom, koju im je počeo pružati pretor. Tako su pretorovom intervencijom mnogi važni instituti obveznog prava poput zajma, posudbe, ostave i drugih postali tipični pravni poslovi. Tijekom posljednja dva stoljeća Republike stekli su utuživost, na temelju samog neformalnog sporazuma (*consensus*), ugovori na kojima počiva robnonovčani promet: kupoprodaja, najam, društvena pogodba. Ti ugovori, koje je *ius gentium* već ranije priznavalo, bili su prve iznimke od formalizma ranog civilnog prava.

⁴ Horvat, M., *Bona fides u razvoju rimskog obveznog prava*, Zagreb, 1939; Lombardi, L., *Dalla "fides" alla "bona fides"*, Milano, 1961; Carcaterra, A., *Intorno ai bonae fidei iudicia*, Napoli, 1964.

Važnu ulogu u razvitku rimskog prava, posebno u procesu priznavanja tipičnih ugovora obveznog prava, imalo je ***ius gentium***.⁵ *Ius gentium* je pravni sustav koji je nastao djelatnošću peregrinskog pretora. Primjenjivao se u odnosima između peregrina iz raznih provincija ili između Rimljana i peregrina. Stvarajući taj pravni sustav peregrinski je pretor postavljene probleme i sporove rješavao prilagođavajući ustanove *ius civilea* peregrinima ili uzimajući najbolja rješenja iz pravnih sustava provincija. Za razliku od gradskog pretora, peregrinski pretor nije bio vezan civilnim pravom pa je bio u mogućnosti davati jednostavna i elastična rješenja i stvarati nove ustanove. Tako je nastao pravni sustav koji je bio puno jednostavniji, praktičniji i potpuniji od rimskog civilnog prava. Zbog toga su se i sami Rimljani u svojim međusobnim odnosima sve više koristili pravilima *ius gentiuma*. Pod utjecajem tog pravnog sustava, čije ustanove i načela (konsenzualni kontrakti, *bona fides*) postupno prodiru u *ius civile*, od sredine III. st. p.n.e. počinju popuštati formalizam, strogost i apstraktnost civilnog prava. Tako su se sustav honorarnog prava (u *ius honorarium* u širem smislu spada i *ius gentium*) i sustav civilnog prava postupno počeli zbližavati, da bi sredinom Principata, usporedo s nestajanjem razlike između Rimljana i peregrina, došlo do njihovog stapanja.

Uz pretorski edikt, razvitku rimskog privatnog prava uvelike su doprinijeli pravnici, čija aktivnost sve više dolazi do izražaja. Najvažnija **djelatnost pravnika** bila je “**respondere**” tj. davanje pravnih mišljenja i odgovora na pitanja postavljena u pravnim sporovima; “**cavere**” – sastavljanje obrazaca za pojedine pravne poslove i “**agere**” – zastupanje u parnicama, premda su to češće obavljali govornici (*oratores, advocati*), kojima bi pravnici davali pravne upute. Mišljenja i odgovori pravnika nisu bili obvezni za suce, ali suglasna mišljenja pravnika (*communis opinio*) sudac je prihvatao.

Tako je običajnopравnim putem stvoren još jedan izvor prava (***responsa prudentium***). Pravnici su djelovali i kao učitelji omladine, te kao članovi savjetodavnog vijeća jurisdikcijskih magistrata i sudaca – porotnika jer oni nisu morali imati pravničku naobrazbu. Važna je i njihova literarna djelatnost. Na početku ovog razdoblja *Sextus Aelius Paetus Catus* napisao je prvo poznato djelo o privatnom pravu pod naslovom *Tripertita*. Sastojalo se od teksta Zakonika XII ploča, interpretacije njegovih odredaba i procesnih formula (*legis actiones*). Najugledniji pravnik kasnijeg republikanskog razdoblja bio je *Quintus Mucius Scaevola* (*pontifex*), koji je prvi pokušao svesti privatno pravo u neki sustav. Najvažnije mu je djelo *Libri iuris civilis* u 18 knjiga. Kasniji su pravnici svoje komentare o civilnom pravu

⁵ Lombardi, G., *Sul concetto di “ius gentium”*, Roma, 1947.; Nörr, D., *Die Fides im römischen Völkerrecht*,

nazivali “*Libri ad Quintum Mucium*”. Važniji pravници potkraj Republike bili su *G. Aquilius Gallus*, *S. Sulpicius Rufus* i *P. Alfenus Varus*.

Treće poglavlje

Principat (27. p.n.e. – 284. n.e.)

§ 11 – Politički, gospodarski i društveni odnosi

Nakon burnih događaja s kraja razdoblja Republike (ustanci robova, pobune u provincijama, Sulina diktatura, prvi i drugi trijumvirat, borba za zemlju) postalo je očito da se uređenje rimske države, postavljeno u vrijeme kada je Rim bio mali grad – država, mora promijeniti i prilagoditi gospodarskim, društvenim i političkim promjenama. Dolaskom na vlast Oktavijana Augusta 27. god. p.n.e. započinje novo razdoblje rimske povijesti – Principat, koji traje do dolaska na vlast Dioklecijana 284. godine. Završetkom građanskih ratova i uspostavljanjem mira na granicama omogućena je određena stabilizacija rimskog gospodarstva. Na ogromnom prostranstvu rimske države cvjeta trgovina koja prelazi granice Carstva, sve do obala Baltika, Indije, Kine i centralne Afrike. Država je povezana mrežom dobrih putova, pomorskih luka i mostova. Na Zapadu se razvija graditeljstvo s luksuznim građevinama od kamena i mermera. Pored malih obrtnika, udruženih u korporacijama, u Italiji, Galiji i Španjolskoj nastaju velike radionice i tvornice luksuzne metalurgije, keramike i tekstila. Iz Afrike i provincija uvozi se jeftino žito za prehranu Rima, zbog čega zemljoradnja u Italiji postaje nerentabilna, pa se prelazi na gajenje vinove loze. Uvodi se zlatni novac, a kovanje zlatnog i srebrnog novca postaje monopol cara.

Dolazi do promjena i u društvenoj strukturi. Zbog romanizacije provincija i decentralizacije gospodarskog i političkog života nestaje razlike između rimskih građana, latina i peregrina. Car Karakala podijelio je 212. godine slobodnim stanovnicima carstva rimsko pravo građanstva. Vremenom je i gradski plebs prestao postojati kao poseban sloj društva. Gradska sirotinja, propali seljaci i isluženi vojnici odlaze u provincije kao kolonisti, gdje dobijaju parcele zemlje. Pripadnici viših slojeva (nobili i ekvestri) formiraju novu klasu tzv. *honestiores* ili *potentiores*, koji su u odnosu na siromašne niže slojeve pučanstva (*humiliores*) uživali mnogobrojne privilegije. Još uvijek postoji i veliki broj robova premda su prestali osvajački ratovi. Oslobađanje robova je sve češća pojava, a neki od njih prevode

se u status kolona, čime se potkopavaju robovlasnički odnosi i trasira put ka novom načinu proizvodnje – kolonatu.

Na početku Augustove vladavine nije bilo velikih promjena u državnoj upravi. August prividno nije dirao u republikanske tradicije i republikansko uređenje, ali je stvarno svojim položajem princepsa, koji mu je davao samo pravo prvi govoriti u senatu, sve više potiskivao vlast senata, narodnih skupština i magistrata. Postupno je u svoje ruke preuzeo funkcije republikanskih magistrata; bio je vrhovni zapovjednik vojske, vrhovni svećenik, odlučivao je o ratu i miru. U I. st. n.e. prestaje djelatnost narodnih skupština jer su njihove zakonodavne, izborne i sudske funkcije prešle na senat i princepsa. Senat, čije su odluke u razdoblju Republike imale karakter preporuka i mišljenja, dobija zakonodavnu vlast. To je bio još jedan od načina na koje je princeps koristio republikanske organe vlasti za sprovođenje svoje volje. Od II. stoljeća senat postaje mehaničko oruđe u princepsovim rukama, pa se senatske odluke više ne nazivaju *senatus consulta*, nego *oratio* (govor).

Princeps je postupno organizirao vlastitu plaćeničku vojsku – pretorijansku gardu i vlastiti činovnički aparat, na čijem je čelu *praefectus praetorio*. Od prihoda s velikih zemljišnih posjeda, do kojih je došao konfiskacijama, stvara vlastitu državnu blagajnu – *fiscus*. Tako je stvaranjem usporednog sustava vlasti princeps marginalizirao i uklanjao stare republikanske institucije od kojih u razdoblju dominata neće više biti ni traga.

§ 12 - Pravo razdoblja Principata (klasično rimsko pravo)

Unutarnja stabilnost i mir na granicama omogućili su da u ovom “mirnom razdoblju” rimske povijesti (*pax romana*) dođe do procvata svih oblika kulturnog života, posebice pravne znanosti. Mnogi pravni instituti dobili su svoj završni oblik, a rimsko privatno pravo svoj najviši, klasični stupanj. Podjeljivanjem rimskog prava građanstva svim slobodnim stanovnicima države, nestala je osnova odvajanja sustava civilnog i honorarnog prava, pa su se oni brzo stopili u jedinstveni sustav klasičnog prava.

Izvori prava

1. Kodifikacija pretorskog prava

Nakon prestanka zakonodavne aktivnosti skupština krajem I. stoljeća, postupno se gasi i pretorova pravosudna i zakonodavna djelatnost. Više nije bilo potrebe za donošenjem pretorova edikta jer je princeps potpuno potisnuo pretorovu pravosudnu aktivnost.

Veliki pravnik *Salvius Iulianus* po Hadrijanovu nalogu oko 130. godine izvršio je kodifikaciju pretorskog edikta. Taj stalni i jedinstveni tekst edikta proglašen je nepromjenljivim, zbog čega se zove *edictum perpetuum* i primjenjivan je kao obvezni zakonodavni akt. Time je višestoljetna aktivnost pretora na stvaranju prava potpuno prestala. *Edictum perpetuum* ("vječiti edikt") nije izravno sačuvan, ali je izvršena njegova rekonstrukcija na temelju navoda i komentara rimskih pravnika i sačuvanih odlomaka u Justinijanovim Digestama.

2. **Senatus consulta**

U razdoblju Republike senat nije imao zakonodavnu vlast, a njegove odluke imale su karakter preporuka koje magistrati nisu bili obvezni slušati. Počev od I. st. n. e. senat počinje izdavati obvezne upute magistratima, a od II. stoljeća njegove odluke dobijaju zakonsku snagu. *Senatus consulta* označavaju se imenom njihova predlagatelja (npr. *SC Tertulianum*). Već u II. st. uobičajeno je da senat samo sasluša princepsov govor, pa su se senatske odluke počele nazivati *oratio* (govor, npr. *oratio Severi*, *oratio Antonini*).

3. **Constitutiones principum**

Na stvaranje prava princeps je utjecao i putem različitih odluka obuhvaćenih zajedničkim nazivom *constitutiones principum*. Te su odluke uskoro zbog careva ugleda (*auctoritas*) dobile snagu zakona. Javljaju se u četiri oblika: *edicta*, *decreta*, *rescripta* i *mandata*.

Edicta su općenite obvezne naredbe koje je car izdavao jer je imao *ius edicendi* (pravo izdavanja edikata). Odnosile su se na sve građane i magistrate. Vrijedile su i nakon careve smrti, sve dok ne bi bile izrijekom ukinute. Poznat je edikt cara Karakale (*constitutio Antoniniana*) iz 212. godine kojim je podijeljeno rimsko pravo građanstva slobodnim stanovnicima carstva.

Decreta su usmene careve rješidbe sporova pred carskim sudom. Imale su karakter precedenta jer su bile obvezne i u budućim takvim slučajevima. Takav je dekret Marka Aurelija kojim je zabranjena samopomoć (*decretum divi Marci*).

Rescripta su carevi odgovori na postavljena pitanja ili molbe. Na pitanja i izvještaje činovnika, općina ili udruženja odgovarao bi car u obliku posebnog pisma (*epistula*), a na pitanja i molbe privatnika napisao bi odgovor na samoj molbi kao *subscriptio*.

Mandata su upute carskim činovnicima i namjesnicima provincija u pogledu vršenja njihove službe.

Navedeni će se oblici carskih konstitucija u razdoblju dominata stopiti u *leges* (zakone) koji će postati jedini oblik zakonodavne aktivnosti.

4. Klasična jurisprudencija

U razdoblju principata pravnička djelatnost doživljava veliki procvat. To je razdoblje u kojem žive najveći rimski pravници⁶ čijom je zaslugom klasično rimsko pravo dobilo onaj savršeni oblik zbog kojeg je i danas slavno. Glavna pozornost pravnika posvećena je izgradnji privatnog, u prvom redu imovinskog prava u centru sa ustanovom privatnog vlasništva.

Pravo se i dalje oslobađa formalizma i apstraktnosti; stvaraju se novi neformalni oblici pravnih poslova; daju se elastična i razrađena rješenja konkretnih sporova i slučajeva koji se javljaju u praksi. Rimski su pravnici izbjegavali opće definicije i teoretiziranje. Za njih je pravo prefinjena vještina i sposobnost davanja sažetih i jasnih rješenja određenog slučaja. I u razdoblju Principata njihova djelatnost ogledala se u davanju stručnih mišljenja i odgovora, poučavanju omladine i pisanju knjiga. Počev od Augusta, princepsi su najuglednijim i njima odanim pravnicima podjeljivali posebnu ovlast za davanje stručnih mišljenja tzv. ***ius publice respondendi ex auctoritate principis***. Mišljenja i odgovori autoriziranih (privilegiranih) pravnika imali su ugled i autoritet samog cara, te su postali obvezni za sudove. Suglasni odgovori (***responsa***) autoriziranih pravnika postali su **izvor prava sa zakonskom snagom**. Tako je najprije putem odgovora i mišljenja, a kasnije i kroz literarnu djelatnost, rimska jurisprudencija postala izvor prava. Osnovni razlozi zbog kojih je pravna znanost postala izvor prava su: kompliciranost pravnog sustava, laičko suđenje i nastojanje princepsa da osigura ujednačenost i kontrolu pravosuđa.

Pravnici su svojim mišljenjima pomagali i sucima jer su oni često bili građani bez pravničke naobrazbe kojima se bilo teško snaći u složenom pravnom sustavu kakav je bio rimski. Osim toga, tadašnji formularni postupak dopuštao je sucu – laiku dosta široku mogućnost tumačenja pravnih normi i suđenja po osjećaju pravičnosti, što je princeps

⁶ D'Ippolito, F., *I Giuristi e la città*, Napoli, 1978; Isti, *Studi sulla giurisprudenza mediorepubblicana*, Napoli, 1978; Isti, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*, Roma/Bari, 1986; Casavola, F. P., *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980; Falchi, G. L., *Le controversie tra Sabiniani e Proculiani*, Milano, 1981; Bretone, M., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1982; Guarino, A., *Le ragioni del giurista. Giurisprudenza e potere imperiale nell'età del principato*, Napoli, 1983; Liebs, D., *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, ANRW II. 15, 197-286; Cenderelli, A., *Digesto e predigesti: riflessioni e ipotesi di ricerca*, Milano, 1983; Frier, B. W., *The Rise of the Roman Jurists*, Princeton, 1985; Schiavone, A., *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana*, Roma/Bari, 1992; Mantovani, D. (a cura di), *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio*, Torino, 1996; Isti (a cura di), *Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini*, Torino, 1997; Cannata, C. A., *Per una storia della scienza giuridica europea*. Vol. I, *Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino, 1997; Kunkel, W., *Römische Juristen: Herkunft und soziale Stellung*, Köln, 2001.

nastojao eliminirati vezujući sudove za mišljenja njemu najodanijih pravnika. U razdoblju dominata, sa uvođenjem ekstraordinarnog postupka, koji su vodili caru podređeni školovani pravници, *ius publice respondendi* se izgubilo.

Početak Principata spominju se dvije struje ili **dvije pravne škole** – **Prokulovci** i **Sabinovci**. Osnivač **Prokulovske škole** bio je *M. Antistius Labeo*, ali je škola dobila ime po njegovu sljedbeniku Prokulu, a osnivačem **Sabinovske škole** smatra se *C. Ateius Capito*, ali škola nosi ime njegova sljedbenika Masurija Sabina. Istaknuti predstavnici Prokulovaca bili su: *Proculus*, *Nerva pater* i *filius*, *Pegasus*, *Neratius*, *Celsus pater* i *filius*. Kao najugledniji Sabinovci spominju se: *Massurius Sabinus*, *Cassius Longinus*, *Iavolenus Priscus* i *Salvius Iulianus*. Te “škole” ne treba shvatiti kao pedagoške institucije u klasičnom smislu nego se radi o metodi poučavanja i načinu razmišljanja i uvođenja u pravnu znanost.

Danas je teško odrediti u čemu su bile doktrinarne razlike između pristaša navedenih škola. U preko trideset slučajeva sačuvane su razlike u rješenjima pojedinih pitanja iz svih oblasti prava, ali se na temelju njih ne može otkriti opće i polazno načelo koje je dovelo do stvaranja tih pravaca. Škole su se održale do Hadrijanove vladavine (II. st.) kada djeluje jedan od najvećih klasičnih pravnika *Salvius Iulianus*. On je izvršio redakciju pretorskog edikta i sa uvjerljivom jednostavnošću riješio mnoga sporna pitanja.

Nakon Hadrijanove vladavine nestaje opreke između tih škola. Značajni pravници tog razdoblja su *Sextus Caecilius Africanus*, *Sextus Pomponius* i *Gaius*. Naročito je značajan pravnik **Gaj (Gaius)**, čije puno ime i podrijetlo nisu poznati. Među mnogobrojnim Gajevim djelima posebno su važne **Institucije (*Institutionum commentarii quattuor*)** u kojem je pružen sustavni prikaz rimskog prava (osobno, imovinsko i procesno pravo). Djelo, koje je stoljećima služilo kao udžbenik prava u pravnim školama, obuhvaća statusno i obiteljsko pravo, stvarno i oporučno nasljedno pravo, intestatno nasljedno i obvezno pravo, kao i osnovna pitanja iz građanskog postupka. Gajev sustav triparticije (***personae – res – actiones***) ostao je do danas podlogom za izlaganje materije u građanskim zakonicima i udžbenicima.⁷

Druga polovica Principata obilježena je djelovanjem velikih rimskih pravnika koji su najviše navođeni u Justinijanovim Digestama. **Aemilius Papinianus** smatra se najvećim rimskim pravnikom. Napisao je veliki broj knjiga. Među najplodnije rimske pravnike spadaju **Iulius Paulus**, čija djela zauzimaju oko 1/6 Justinijanovih Digesta i **Domitius Ulpianus**, čija djela sačinjavaju oko 1/3 Justinijanovih Digesta. Kao posljednji klasični pravnik spominje se **Herennius Modestinus**.

Kriza carstva do koje dolazi sredinom III. stoljeća i sve veća koncentracija vlasti u carevim rukama postupno onemogućavaju daljnju pravničku djelatnost koja se očituje u sve slabijim kompilatorskim radovima postklasičnih pravnika.

Četvrto poglavlje

Dominat (284. – 565.)

§ 13 – Gospodarske, političke i društvene prilike

Razdoblje Dominata započinje stupanjem na vlast Dioklecijana 284. godine i traje do smrti Justinijana 565. godine. U III. stoljeću rimski robovlasnički sustav doživljava veliku krizu koja će rezultirati propašću Zapadnog Rimskog Carstva 476. godine.

S prestankom osvajačkih ratova nestala su dva osnovna čimbenika gospodarskog prosperiteta rimske države: stalna opskrba velikim brojem jeftinih robova i ratni plijen i kontribucije kao glavni izvor za podmirivanje državnih potreba. Glomazni birokratski aparat i veliki broj vojnika uvjetovali su znatno povećanje državnih troškova koji su podmirivani isključivo sve većim i težim porezima nametnutim pučanstvu.

Zbog nedostatka radne snage bilo je nužno izmijeniti organizaciju proizvodnje na latifundijama, koja je do tada počivala na masovnoj eksploataciji robovske radne snage. Vlasnici latifundija počeli su dijeliti latifundije na male parcele pretvarajući ih u samostalne proizvodne jedinice i povjeravati ih robovima, oslobođenim robovima, slobodnim zakupcima i gradskoj sirotinji. Svi su oni samostalno organizirali proizvodnju na uzetoj parceli obvezujući se vlasniku zemlje dati dio prihoda u novcu ili u proizvodima. Tako je trasiran put ka novom načinu proizvodnje – kolonatu, a potom feudalizmu čiji su se elementi u razdoblju Dominata razvili do visokog stupnja. Osim gospodarske krize snagu rimske države slabile su stalne borbe oko carskog prijestolja, sve češći i snažniji upadi barbara, pobune robova, kolona i pokorenih naroda.

Rasulo carstva privremeno je spriječio **Dioklecijan (284. – 305.)** reformom državnog ustroja u pravcu apsolutne monarhije. Vladar više nije princeps nego *dominus et deus* (gospodar i bog) i sve što se njemu sviđa ima snagu zakona (*quidquid principi placuit habet legis vigorem*).

⁷ Stanojević, O., *Gaivs Noster. Pisac prvog udžbenika prava. Prilog istoriji rimske pravne nauke*, Beograd 2010.

Da bi riješio problem nasljeđivanja Dioklecijan je sukladno sustavu tetrarhije uzeo sebi još jednog augusta i dva cezara i tako podijelio državu na četiri dijela – prefekture (Orijent, Ilirik, Italiju s Afrikom i obje Galiје). Najviši organi uprave u prefekturama su *praefecti praetorio* koji su imali široke ovlasti premda su od Konstantina izgubili vlast vojnog zapovijedanja. Odlučivali su u sudskim stvarima kada je bio izjavljen priziv protiv odluka provincijskih namjesnika. Prefekture su se dijelile na dijeceze kojima su upravljali *vicarii*. Osnovne upravne jedinice bile su provincije, na čijem je čelu carski namjesnik (*rector* ili *praeses*). *Rector* je obavljao upravne poslove, odgovarao za ubiranje poreza i imao pravosudnu funkciju. Jedinstvo carstva ponovno je uspostavio Konstantin još više pojačavajući apsolutizam. Do definitivne podjele carstva došlo je 395. godine nakon smrti Teodozija Velikog.

Premda je Dioklecijan donio energične mjere o saniranju novca i maksimiranju cijena, nedostatak robe, nesigurnost na putovima i nestabilnost novca upropaštavaju trgovinu i dovode do skoro potpunog vraćanja na naturalnu privredu. Vlasnici zemlje proizvode na vlastitim imanjima gotovo sve što im je potrebno za obradu zemlje i život obitelji. Čak su i porezi i plaće državnih činovnika određivani u naravi.

Počev od Konstantina (306. – 337.) svi ljudi koji su obrađivali zemlju, bez obzira na podrijetlo, dobili su status kolona (*colonus*). Nisu smjeli napustiti zemlju koju obrađuju, niti ih je vlasnik zemlje mogao od nje odvojiti. Time su koloni dobili status posebnog staleža, a njihov položaj postao je sličan položaju feudalno zavisnog kmeta. Uskoro su formirani i drugi staleži: obrtnika, vojnika, trgovaca, vlasnika brodova, gradskih i državnih službenika. Krupni zemljoposjednici, nekadašnji članovi senatorskog reda, formirali su poseban najviši stalež (*clarissimi*).

Sve te mjere ipak nisu uspjele spriječiti raspad klasične robovlasničke privrede i propast rimske robovlasničke države.

§ 14 - Pravo razdoblja Dominata (postklasično pravo)

1. *Leges i ius*

Apsolutistička vlast vladara bila je izražena i u oblasti stvaranja općeobveznih pravnih normi. Car je bio jedini državni organ ovlašten aktivno stvarati pravna pravila. Zbog brze feudalizacije rimskog društva došlo je do velikih promjena u pravnom životu koje su iziskivale vrlo živu zakonodavnu djelatnost careva.

Nova pravna pravila car je izdavao putem konstitucija koje su bile upućene senatu, narodu ili činovnicima. Takve konstitucije nazivane su ***leges edictales (leges generales)*** i imale su snagu općeobveznog pravnog pravila. Pored njih car je izdavao i ***leges speciales (leges personales)*** na zahtjev sudaca ili državnih činovnika. Te konstitucije sadržavale su naredbe kako riješiti pojedine sporove, ali su često sadržavale pravila općeg karaktera, pa su primjenjivane na sporove iste vrste. Bez obzira na formu u kojoj je izdata, svaka careva naredba zove se ***lex*** (zakon), pa se pravo koje je nastajalo na temelju carskih konstitucija naziva ***leges***.

Osim prava koje je izviralo iz carskih konstitucija, obveznu snagu imalo je klasično rimsko pravo sadržano u djelima najistaknutijih pravnika. Taj dio pravnog sustava naziva se ***ius*** (pravničko pravo). Djela klasičnih rimskih pravnika korištena su kao izvor prava jer su u njima bila obrađena sva dotadašnja pravna vrela (običajno pravo, zakoni, edikti, senatski zaključci i odgovori pravnika), pa ih je u praksi bilo lakše koristiti na posredan način. Problem je predstavljala ogromna masa ove literature, koja je zbog prerada često bila nepouzdana.

Upotreba djela klasičnih pravnika i rješavanje sukoba u slučajevima različitih mišljenja regulirano je **Zakonom o citiranju (*Lex citationis*)** donesenim 426. godine. Prema tom Zakonu izvorom prava smatrana su sva djela Papinijana, Paula, Gaja, Ulpijana i Modestina, kao i djela onih pravnika na čija su se mišljenja navedena petorica pozivali. Ako njihova mišljenja nisu bila suglasna, sudac je morao usvojiti mišljenje većine, a ako se ona nije mogla utvrditi, morao je uvažiti Papinijanovo mišljenje; ako ga nije bilo, mogao je slobodno odlučiti kako će postupiti. Zbog takve primjene njihovih djela ti su pravници nazivani “senat mrtvih” ili “vijeće mrtvih”.

Razdoblje postklasičnog prava je razdoblje **vulgarizacije prava**. Gašenje robne proizvodnje i robnonovčane razmjene i povratak na naturalnu privredu imali su za posljedicu da su feudalni elementi, nepoznati klasičnom pravu, prodrli u sve grane privatnog prava.

Zbog sve većeg utjecaja grčkog jezika i istočnih provincija, kao i zbog opće kulturne dekadencije, unose se orijentalna pravna shvaćanja na Istoku i primitivni germanski instituti na Zapadu. **Napuštaju se klasični pojmovi i shvaćanja** koji više ne odgovaraju primitivnijoj sredini sa slabo razvijenim gospodarstvom.

Sve je veći utjecaj kršćanstva koje je 353. godine postalo državnom religijom. Carevi donose konstitucije nadahnute kršćanskim idejama i feudalnim tendencijama. U njima sankcioniraju i institute koji su nastajali među nerimskim pučanstvom. Tako se u IV. i V. stoljeću razvilo pravo koje se uvelike udaljilo od klasičnih načela i koje je zbog prihvatanja

pravnih pravila svih naroda koji su živjeli na teritoriju carstva postalo jezgrom budućeg europskog feudalnog prava.

Zbog pravne svemoći cara i nove organizacije države i pravosuđa **gubi se samostalna aktivnost** pravnika. Počev od Dioklecijana pravnici više nemaju *ius respondendi*. Smanjuje se interes za teorijsku obradu prava. *Archadius Charisius* i *Hermogenianus* su jedini pravnici ovog razdoblja čija su djela navođena u kasnijim zbornicima. Pravnici se sada školuju u pravnim školama sa utvrđenim nastavnim planom, programom i režimom studija i profesionalnim nastavnicima. Najpoznatije su bile u Beritu, Rimu i Konstantinopolju. Njihova je zasluga što su doprinijele prikupljanju, sređivanju i prepisivanju rimskog klasičnog prava stvarajući uvjete za kasnije kodifikacije.

2. Zbornici prije Justinijana

Premda je Zakon o citiranju uveo neki red u upotrebi pravničkog prava, veliko mnoštvo, raznolikost i kompliciranost pozitivnog prava razdoblja Dominata i dalje su stvarali velike poteškoće u praksi. Radi otklanjanja tih teškoća profesori pravnih škola sastavljali su izvode iz djela klasičnih pravnika i zbornike konstitucija. Već za vladavine Dioklecijana objavljene su **privatne zbirke carskih konstitucija: *Codex Gregorianus***, koji je obuhvaćao uglavnom reskripte od Hadrijana do Dioklecijana i ***Codex Hermogenianus***, koji je bio dopuna prethodnog i sadržavao uglavnom Dioklecijanove reskripte iz 293. i 294. godine.

Codex Theodosianus bio je **prvi službeni zbornik** koji su izdali carevi Teodosije II i Valentinijan III 438. godine. Podijeljen je na 16 knjiga, knjige na titule (naslove) koji su kronološkim redom sadržavali oko 3000 konstitucija izdatih od Konstantina pa dalje. Nije sačuvan u cjelini. Primjenjivan je u istočnom dijelu carstva do donošenja Justinijanove kodifikacije, a u zapadnom dijelu sve do 12. stoljeća jer su njegovi dijelovi bili uključeni u barbarske zbornike.

Zbornici koji sadrže samo pravničko pravo (*ius*) su uglavnom izvodi iz djela klasičnih pravnika ili njihove prerade. Najznačajnije su Ulpijanove Regule i Paulove Sentencije, koje su sastavili nepoznati postklasični pravnici u istočnom dijelu carstva na osnovi Ulpijanovih i Paulovih djela i Gajeve Epitome, nastale u zapadnom dijelu carstva, koje obuhvaćaju izvode iz prve tri knjige Gajevih Institucija.

Pored tih zbornika, sastavljani su i **zbornici koji su sadržavali izvode iz carskih konstitucija i odlomke iz djela najpoznatijih klasičnih pravnika**. To su: *Fragmenta Vaticana*, *Collatio legum mosaicarum et romanarum* i *Liber syro-romanus*.

Veliku važnost za poznavanje postklasičnog rimskog prava imaju i **zbornici koji su izdavani u barbarskim državama nastalim na teritoriju Zapadnog Rimskog Carstva**. Najvažniji su vizigotski zbornici *Lex Romana Visigothorum* i *Edictum Theodorici*, te burgundska zbirka *Lex Romana Burgundionum*.

3. Justinijanova kodifikacija (*Corpus iuris civilis*) (528. – 534.)

Justinijan (527.-565.) je bio posljednji car koji je uspio ujediniti najveći dio zemalja istočnog i zapadnog dijela carstva.⁸ Već na početku vladavine odlučio je kodificirati cjelokupno rimsko pravo: *ius* i *leges*. Kodifikatorni posao povjeren je komisiji koju su sačinjavali istaknuti pravници i profesori na čelu s Tribonijanom, predstojnikom carskog ureda. Rad na kodifikaciji započeo je 528. godine, da bi već 529. godine stupio na snagu **Codex Iustinianus**, zbirka carskih konstitucija izdatih prije Justinijana i prilagođenih novim potrebama. Taj kodeks nije sačuvan.

Kompilatorski rad nastavljen je kodifikacijom pravničkog prava (*ius*). Nakon intenzivnog rada od tri godine i pregledanih približno 2 000 knjiga četrdesetak rimskih pravnika, krajem 533. godine konstitucijom Tanta proglašena su **Digesta ili Pandectae**, veliki **zbornik pravničkog prava** podijeljen na 50 knjiga. Sve knjige osim 30., 31. i 32. dijele se na titule s označenim sadržajem. Tituli se sastoje od fragmenata koji su uzeti iz djela rimskih pravnika. Veći fragmenti podijeljeni su na uvod (*principium*) i paragrafe. Tekst iz Digesta navodi se tako da se pored velikog slova D stave odgovarajući brojevi koji označavaju knjigu, titul, fragment i paragraf. Digesta imaju posebnu vrijednost jer su Justinijanovi kompilatori u naslovu svakog fragmenta označili ime pravnika i naziv djela iz kojeg je tekst uzet. Zahvaljujući takvom sustavu rada moguće je izvršiti djelomičnu rekonstrukciju djela klasičnih pravnika koja su upotrebljavana prilikom sastavljanja Digesta. Najveći broj tekstova uzet je od pravnika koji su činili "senat mrtvih": od Ulpijana (više od 40 %), Paula

⁸ Archi, G. G., *Giustiniano legislatore*, Bologna, 1970; Isti, *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*, Cagliari, 1990; Bonini, R., *Introduzione allo studio dell' età giustininea*, Bologna, 1985. Guarino, A., *La compilazione dei 'Digesta Iustiniani'*, u: *Pagine di diritto romano*, Vol. IV, Napoli, 1994; Mazal, P., *Justinian I. und seine Zeit*, Köln, 2001.

(17 %), Papinijana (6 %), nešto manje od Scevole, Pomponija, Julijana i Gaja. Na ostalih tridesetak autora otpada samo oko 600 fragmenata.

Zadaća komisije bila je uskladiti pravničko pravo s pravom konstitucija i prilagoditi ga suvremenim potrebama. Zato su u preuzetim tekstovima starih pravnika izvršene brojne promjene koje se nazivaju interpolacijama. Zastarjele pravne institucije, koje su bile iščezle iz prakse, zamijenjene su novima; npr. kompilatori su umjesto *mancipatio* stavljali *traditio*, umjesto *in iure cessio* novi institut *cessio*, *fiducia* je zamijenjena terminom *pignus* itd.

Digesta su najvažniji i najopsežniji dio Justinijanove kodifikacije. Najveći dio Digesta odnosi se na privatno pravo zbog čega su bila glavnim izvorom za recipirano (pandektno) pravo.

Zajedno s Digestama stupile su na snagu **Institutiones**, priručnik rimskog prava sa **zakonskom snagom**. Napisane su po uzoru na Gajeve Institucije sa sličnom podjelom materije na četiri knjige koje se dijele na titule i paragrafe. Ukratko je obrađeno statusno, obiteljsko, stvarno, obvezno i nasljedno pravo, kao i pitanja građanskog i kaznenog postupka.

Nakon objavljivanja Kodeksa Justinianusa Justinijan je donio 50 novih konstitucija koje su zajedno s prerađenim tekstom prvog kodeksa objavljene 534. godine pod nazivom **Codex repetitae praelectionis**. Kodeks obuhvaća 12 knjiga podijeljenih na titule. U okviru titula kronološkim redom sakupljeno je preko 4500 konstitucija. Na početku svake konstitucije naznačeno je koji ju je car izdao i kome je upućena.

Nakon završetka rada na kodifikaciji Justinijan je izdao preko 150 novih konstitucija koje se nazivaju **Novellae**. Odnose se na sva područja pravnog života, a nekima od njih izvršene su važne reforme na području nasljednog i obiteljskog prava. Nisu sakupljene u službenu zbirku, nego su sačuvane samo u privatnim zbirkama (*Epitome Iuliani* i *Authenticum*).

Kodeks, Digesta, Institucije i Novele obuhvaćeni su zajedničkim nazivom ***Corpus iuris civilis***.

Peto poglavlje

Rimsko pravo nakon Justinijana

§ 15 - Glosatori i postglosatori (komentatori)

Nakon Justinijanove smrti i osvajanja Italije od strane Langobarda u drugoj polovici VI. stoljeća, u bivšim zapadnim dijelovima Carstva Justinijanova kodifikacija i rimsko pravo potiskuju se feudalnim pravima novostvorenih barbarskih država. Za razliku od Zapada, u

Bizantu je sačuvan kontinuitet primjene rimskog prava premda su zbog brze feudalizacije bizantskog društva mnoge ustanove sadržane u Justinijanovoj kodifikaciji izmijenjene ili ukinute u zbornicima koje su donosili bizantski vladari.

Počev od XI. stoljeća Europa se počinje buditi iz srednjovjekovne obamrlosti. Početak pravne renesanse vezuje se za Bolonju, gdje je pravnik i filolog **Irnerius** počeo izučavati i komentirati Justinijanova Digesta. Osnovao je školu koja se po bilješkama (glosama) koje su pravili uz rubove ili između redova u tekstu zove **glosatorska**. Osnovna obilježja glosatorske škole su skolastički metod i veliko poštovanje prema rimskom pravu. Veliki broj glosa svojih prethodnika sabrao je i objavio pod nazivom **Glossa ordinaria** (preko 62 000 glosa) posljednji glosator **Accursius**. Rad glosatorske škole od ogromne je važnosti za kasniji razvitak prava premda je njihova djelatnost bila potaknuta znanstvenom radoznalošću, a ne potrebama prakse. Ipak, njihovi su učenici unosili u pravo svojih zemalja ili gradova način mišljenja i izražavanja koji su stekli u Bolonji i tako širili utjecaj glosatorske škole i rimskog prava.

Na djelatnost glosatora nadovezuje se od sredine XIII. do XVI. stoljeća novi pravac u izučavanju rimskog prava - **škola postglosatora ili komentatora**. Predmet njihova komentiranja bila je prvenstveno Akursijeva *Glossa ordinaria*. Za razliku od glosatora, cilj njihove djelatnosti bio je ponovno osposobiti rimsko pravo za potrebe prakse. Uspoređivali su glose s tada važećim pravom: gradskim statutima, langobardskim pravom, kanonskim pravom i feudalnim običajima. Analizirajući i povezujući pojedine pravne institute izvodili su opća pravila i načela kojih u rimskom pravu nije bilo. Velika vrijednost njihova rada je u tome što su prilagođavali rimsko pravo potrebama sve razvijenije lokalne i prekomorske trgovine. Na taj način stvorili su preduvjete za recepciju rimskog prava u tom djelomično novom ruhu kao pozitivnog prava najprije u Italiji, a potom i u drugim državama zapadne i srednje Europe. Najznačajniji postglosatori bili su *Cinus de Pistoia*, *Bartolus de Sassoferrato* i *Baldus de Ubaldis*. Posebno se ističe **Bartolus** koji je najviše doprinio stvaranju srednjovjekovnog općeg prava na bazi rimskog prava i koji je tvorac tzv. teorije statuta o rješavanju kolizija između prava raznih gradova, čime je postavio temelje modernog međunarodnog privatnog prava.

§ 16 - Recepcija rimskog prava

Sve brži razvitak trgovine, novčarstva i buržoaskih odnosa zahtijevali su pravnu formulaciju koju siromašna feudalna partikularna prava nisu mogla dati. Zbog toga se rimsko

pravo, u obliku kakav su mu dali glosatori i postglosatori, tijekom XV. i XVI. stoljeća počelo ponovno primjenjivati kao pozitivno pravo u mnogim državama srednje i zapadne Europe.

Ta pojava naziva se **receptijom rimskog prava**,⁹ a takvo recipirano rimsko pravo zove se “opće pravo” jer je vrijedilo na području cijelih država, ili pandektno pravo prema najvažnijem dijelu Justinijanove kodifikacije čiju je osnovu činilo privatno, prvenstveno obvezno pravo. Do recepcije je došlo faktičnim, a ne pravnim putem. Nakon povratka sa školovanja na sveučilištima u sjevernoj Italiji (Bolonji, Padovi, Perudi, Paviji, Pizi) pravnici su u svojim gradovima u srednjoj i zapadnoj Europi sve više primjenjivali rješenja koja nudi Justinijanova kodifikacija, odnosno *Glossa ordinaria*. Takva je recepcija bila postupna i posredna, kao što je bio slučaj u Italiji, Francuskoj, našim dalmatinskim gradovima. U Njemačkoj je do recepcije došlo neposrednim putem, na temelju naredbe vladara. Car Maksimilijan I. je 1495. godine odredbom o osnivanju vrhovnog carskog suda naredio i regulirao primjenu rimskog prava. Nasuprot navedenim zemljama, u Engleskoj je u XIII. st. izričito zabranjena recepcija rimskog prava zbog čega je englesko pravo stvorilo svoje “opće pravo” (*Common law*) koje se uvelike razlikuje od europskoga.

Recipirano rimsko pravo dopunjavano je u svakoj zemlji običajnim pravom i prilagođavano konkretnim potrebama. Pravnici koji su proučavali rimsko pravo sa aspekta praktične primjene dopunjavajući ga i prilagođavajući ga potrebama prakse nazivaju se kameralisti ili pandektisti, a pravo koje je stvoreno na takav način naziva se pandektnim pravom. Takav način pristupa rimskom pravu naziva se *usus modernus Pandectarum*, tj. suvremena upotreba Pandekata ili **pandektistika**.

Veliki značaj za izučavanje rimskog prava imaju pravne škole koje su počev od XVI. stoljeća nastajale pod utjecajem humanizma i renesanse. **Francuska historijska škola (škola elegantne jurisprudencije)** inzistirala je na originalnim tekstovima i čistim izvorima rimskog prava odbacujući tumačenja glosatora i postglosatora. Pripadnik te škole *Dionysius Gothofredus* priredio je i prvi objavio prečišćeno, autentično izdanje Justinijanove kodifikacije pod nazivom *Corpus iuris civilis*.

U XVI. i XVII. st. u Nizozemskoj se javlja **škola prirodnog prava** koja smatra da treba stvoriti vječiti i nepromjenljivi pravni poredak zasnovan na načelima ljudskog razuma. Zalagali su se da se umjesto pravnog poretka sastavljenog iz dva sloja pravnih pravila:

⁹ Koschaker, P., *Europa und das römische Recht*, München, 1947.; Fried, J., *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*, Köln/Wien, 1974; Coing, H., *Europäisches Privatrecht*, Vol. I, München, 1985; Cortese, E., *Il diritto nella storia medievale*, Rom, 1995; Lange, H., *Römisches Recht im Mittelalter*, Vol. I, Die Glossatoren, München, 1997; Solidoro Maruotti, L., *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, Torino, 2001.

domaćeg prava i recipiranog rimskog (općeg) prava donesu zakonodavnim putem jedinstvena pravna pravila. Pod utjecajem te škole tijekom XVIII. i XIX. stoljeća doneseni su zakони u Bavarskoj (1756.), Pruskoj (1794.), Francuskoj (1804.), Austriji (1811.) i Njemačkoj (1896.). U tim zakonicima recipirane su one odredbe rimskog prava koje su odgovarale potrebama liberalne buržoazije i razvitku robne proizvodnje i razmjene.

Kao reakcija na školu prirodnog prava početkom XIX. st. javlja se **njemačka historijska škola** koja smatra da pravo nije uvjetovano objektivnim društvenim odnosima nego mističnim narodnim duhom, zbog čega se pravni poredak ne može mijenjati zakonodavnom intervencijom. Zasluga je te škole što je ponovno veliku pozornost posvetila izučavanju vrela rimskog prava s modernim aparatom svih pomoćnih znanosti.

Stupanjem na snagu jedinstvenog njemačkog građanskog zakonika 1900. godine (Bürgerliches Gesetzbuch) opće (pandektno) pravo izgubilo je snagu pozitivnog prava, čime je pandektistika u potpunosti potisnuta suvremenom romanističkom školom.

DRUGI DIO

PRAVO OSOBA (*IUS QUOD AD PERSONAS PERTINET*)

Prvo poglavlje

STATUSNO PRAVO

§ 17 – Pravna i djelatna sposobnost

Pravo osoba (*ius quod ad personas pertinet*)¹⁰ u rimskom pravu obuhvaća dvije osnovne skupine pravnih pravila: **statusno** i **obiteljsko pravo**. Statusno pravo regulira pitanja pravne i djelatne sposobnosti subjekata prava kao sudionika u javnom i privatnom životu Rima koji se odvija izvan kruga obitelji. Obiteljsko pravo uređuje pravni položaj pojedinih osoba unutar rimske obitelji.

Suvremeni pojam “osoba” označava sposobnost biti nositelj prava i obveza. Današnje pravo smatra svakog čovjeka osobom premda, na žalost, i danas u nekim zemljama postoje odnosi slični ropskim. Rimski pravници koristili su se raznim terminima da bi označili osobu, odnosno, njen položaj u pravu ili društvu, ali ni jedan od tih termina ne odgovara suvremenom pojmu osobe, odnosno današnjim pojmovima pravne i djelatne sposobnosti. Izrazom “*persona*” označavali su “čovjeka” bez obzira radi li se o slobodnom ili robu. U nekim slučajevima rabili su izraz “*capacitas*”, ali je on ukazivao samo na sposobnost stjecanja nekih prava iz nasljedstva. Termin “*caput*” ima cijeli niz značenja, a često označava položaj pojedinca u pravu, npr. “*caput liberum*” – slobodan čovjek, “*caput servile*” – rob. Izraz “*status*” korišten je za oznaku položaja u društvu i obitelji. Status čovjekov je takav da je on slobodan čovjek ili rob – *status libertatis*; da je rimski građanin, latin ili peregrin – *status civitatis*; ili je svojevlasna osoba (*persona sui iuris*) ili je podložna vlasti obiteljskog starješine (*persona alieni iuris*) – *status familiae*.

Rimski pravници nisu dali definicije pravne i djelatne sposobnosti. Ti su termini u apstraktnome obliku nastali tek u vremenu pandektistike. Ipak, iz brojnih fragmenata je očito da su Rimljani pod pojmom pravna sposobnost (*capacitas iuridica*) podrazumijevali svojstvo biti nositeljem prava i obveza. Čim je netko vjerovnik, dužnik, nasljednik, vlasnik itd., on je pravno sposoban. **Za osobu koja ima pravnu sposobnost kažemo da je subjekt**

¹⁰ Watson, A., *The law of persons in the later Roman republic*, Oxford, 1967; Isti, *Rome of the XII Tables: persons and property*, Princeton, 1975; Albanese, B., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979; Franciosi, G., *Famiglia e persone in Roma antica*, Torino, 1989.

prava. Subjekt prava je nositelj prava i obveza. Subjekt prava je prije svega čovjek, pojedinac, **fizička osoba (*persona physica*)** jer pravo i postoji zbog ljudi: *hominum causa omne ius constitutum est* (D.1.5.2.). U današnjim pravnim sustavima svako ljudsko biće je subjekt prava, a pravnu sposobnost stječe rođenjem. Rimsko je pravo bilo daleko od takvih shvaćanja jer je pravnu sposobnost imao samo ograničeni broj ljudi. Punu pravnu sposobnost imao je samo *pater familias*, svojevlasna osoba (*persona sui iuris*) koja je stajala na čelu rimske obitelji. Osobe koje su bile podložne njegovoj vlasti (*personae alieni iuris*) nisu imale pravnu sposobnost bez obzira na to koliko su bile stare i kakav su položaj u društvu zauzimale. Ipak, krajem razdoblja Republike, usporedo s promjenama u obiteljskim odnosima i slabljenjem očinske vlasti, počeo se mijenjati položaj osoba *alieni iuris*, tako da su one postupno stekle pravnu i poslovnu sposobnost i bile, ne formalno, nego faktično, tijekom klasičnog i postklasičnog razdoblja, skoro potpuno izjednačene s osobama *sui iuris*. Pravna sposobnost prestajala je prirodnom smrću i građanskom smrću (gubitkom slobode i gubitkom rimskog prava građanstva).

Počev još od Zakonika XII ploča pravni subjektivitet priznavan je i određenim kolektivima kao izdvojenim masama dobara koje su služile za podmirivanje potreba šireg ili užeg kruga osoba. Ti kolektivi predstavljaju **skup fizičkih osoba i imovine s posebnom namjenom kojem pravni poredak priznaje svojstvo subjekta prava**. Rimljani ih nazivaju *universitates*, a pandektna znanost je kasnije izgradila pojam **pravne osobe (*persona iuridica, persona moralis*)**. Prema tome, kao **subjekti prava** pojavljuju se ljudi pojedinci – **fizičke osobe** i društvene tvorevine kojima je pravni poredak priznao pravnu sposobnost – **pravne osobe**.

Rimski pravnici nisu dali ni definiciju djelatne sposobnosti. Ipak je iz njihovih tekstova očito da su pod djelatnom sposobnošću podrazumijevali sposobnost subjekta prava da samostalno istupa u privatnopravnom prometu, osobno poduzima pravne poslove, osobno odgovara za primljene obveze i učinjene protupravne radnje. Dakle, **djelatna sposobnost (*capacitas agendi*) je sposobnost subjekta prava vlastitim očitovanjem volje proizvoditi pravne učinke**. Obuhvaća poslovnu sposobnost i deliktну sposobnost.

Poslovna sposobnost je sposobnost poduzimati pravne poslove, tj. pravnim poslovima proizvoditi pravne učinke.

Deliktна sposobnost (ubrojivost) je sposobnost odgovarati za svoje protupravne radnje.

Pravna sposobnost nije nužno spojena s djelatnom sposobnošću. Osoba može imati pravnu sposobnost, a da nije djelatno sposobna (npr. nedorasli Rimljanin *sui iuris*; duševno

bolesna osoba), ili može biti djelatno sposoban bez pravne sposobnosti (npr. doroasli Rimljanin *alieni iuris*); pravnu i djelatnu sposobnost ima doroasli Rimljanin *sui iuris*. Dakle, samostalno raspolagati svojim pravima i samostalno odgovarati za vlastita protupravna djelanja može samo ona fizička osoba koja je dostigla određeni stupanj fizičke i psihičke zrelosti. Kako je osnovna funkcija poslovne sposobnosti u zaštiti pravnih subjekata, pravni sustavi suvremenog prava određuju dobnu granicu kod koje se predmnijeva da je osoba fizički i psihički zrela, pa time i svjesna posljedica svojih djelanja. Rimski pravници vezivali su nastup punodobnosti, odnosno pune djelatne sposobnosti za spolnu zrelost (***pubertas***). **Za žene se smatralo da dostižu spolnu zrelost s 12 godina života, a za muškarce je do principata utvrđivana individualno, a kasnije se tražila starost od 14 godina.**

Djeca do sedme godine života (*infantes*) bila su potpuno djelatno nesposobna. Njihovom imovinom, ako su bile osobe *sui iuris*, upravljao je tutor.

Osobe od 7. do 12. odnosno 14. godine (*impuberes infantia maiores*) imale su ograničenu djelatnu sposobnost. Mogle su poduzimati pravne poslove koji su im donosili korist, a samo uz tutorovo odobrenje (*auctoritas*) poslove kojima bi pogoršali imovinu. To je odobrenje tutor morao dati odmah prilikom sklapanja pravnog posla. **Tutorstvo nad nedoraslim (*tutela impuberum*)** pripadalo je najbližim agnatima, a ako njih nije bilo gentilima. To je bilo zakonsko tutorstvo (*tutela legitima*). Tutor je bio zakonski nasljednik šticienika (*pupillus*) zbog čega je njegova osnovna obveza bila u upravljanju šticienikovom imovinom (*administratio*), a od III. st. p.n.e. više se vodi računa o osobnim i imovinskim interesima samoga pupila. Tutora je mogao odrediti *pater familias* u oporuci (oporučno tutorstvo – *tutela testamentaria*), a mogao je biti određen od strane magistrata (*tutela dativa*).

Osobe starije od 12 odnosno 14 godina smatrane su punodobnim (*puberes*) i potpuno djelatno sposobnim.

Kada je pravni promet postao puno komliciraniji i oslobođen formalizma, ta se dobna granica pokazala preniskom jer su mlade i neiskusne osobe često zaključivale pravne poslove na svoju štetu. Zato je početkom II. st. p.n.e. donesen Pletorijev zakon (***lex Plaetoria***) kojim su predviđena dva pravna sredstva za zaštitu tih osoba: tužba koju je mogao podići svaki građanin bez obzira na svoj pravni interes ukoliko bi saznao da je prevarena doroasla osoba ispod 25 godina starosti (tzv. ***minores viginti quinque annorum***) i prigovor (***exceptio legis Plaetoriae***) kojim je prevareni minor mogao odbiti ispunjenje obveze zaključene pod utjecajem prijekave. Ipak, tako zaključeni pravni posao nije poništavan nego bi osoba koja je prevarila minora bila kažnjena u javnom kaznenom postupku, a u redovitom građanskom postupku bila bi na temelju ***actio legis Plaetoriae*** osuđena na naknadu štete.

Pretor je pošao korak dalje dopuštajući povrat u prijašnje stanje (*restitutio in integrum*) kojim se postizalo ukidanje pravnog posla s povratnim učinkom. Zbog navedenih pravnih sredstava nitko više nije htio s minorima zaključivati pravne poslove jer je uvijek postojala mogućnost njihova poništenja. Zato se uobičajilo pozivati skrbnika (*curator, cura minorum*) koji je trebao ustvrditi da prilikom sklapanja pravnog posla nije bilo prijevara. Tijekom vremena razvilo se shvaćanje da je suglasnost skrbnika (*consensus curatoris*) obvezatna u svim važnijim poslovima.

Tako je faktično djelatna sposobnost minora izjednačena s djelatnom sposobnošću koju su imali *impuberes infantia maiores*, s tim da su minori mogli sklopiti brak i napraviti oporuku.

Djelatna sposobnost bila je ograničena i ženama, rasipnicima i osobama s duševnim i tjelesnim nedostacima. **Žena**¹¹ *sui iuris* starija od 12 godina stajala je pod tutorstvom (*tutela mulierum*) koje je ograničavalo njezinu poslovnu sposobnost. Bez tutorova odobrenja žena nije mogla zaključiti brak s manusom, otuđiti *res Mancipi*, voditi sporove, primiti nasljedstvo, osloboditi robove, svečano oprostiti dug i dati miraz. Već u klasičnom pravu postavljanje tutora ženama postalo je pukom formalnošću, da bi krajem Principata nestalo iz upotrebe.

Rasipnikom (*prodigus*) smatrana je osoba koja pretjerano rasipa imovinu zbog čega je stavljana pod starateljstvo (*cura prodigi*). Rasipnik je dobijao pravni položaj osobe između 7. i 14. godine, što znači da je samostalno mogao zaključivati poslove koji uvećavaju njegovu imovinu, a one koji je umanjuju samo uz skrbnikovu suglasnost.

Duševno bolesne osobe (*furiosi*) bile su potpuno djelatno nesposobne samo u vrijeme rastrojenosti. Poslovi koje bi poduzele u tzv. svijetlim trenucima (*lucida intervalla*) bili su valjani. Starateljstvo nad duševno oboljelim osobama zove se *cura furiosi*.

Osobe s tjelesnim nedostacima (slijepi, gluhonijemi, paralizirani) faktično su bile onemogućene u vršenju pravnih poslova jer je formalizam starog civilnog prava zahtijevao izgovaranje svečanih riječi i određene geste. Zbog toga je i njima određivan skrbnik (*cura debilium personarum*).

¹¹ O pravnom položaju žene u starom Rimu v.: Herrmann, C., *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine*, Bruxelles, 1964; Söllner, A., *Zur Vorgeschichte und Funktion der actio rei uxoriae*, Köln/Wien, 1969; Vêrilhac, A.-M./Vial, C., *La femme grecque et romaine. Bibliographie*, Lyon/Paris, 1990; Gardner, J. F., *Women in Roman Law and Society*, London, 1986; Ista, *Frauen im antiken Rom. Familie, Alltag, Recht*, München, 1995; Dixon, S., *The Roman Mother*, London, 1988; Eichenauer, M., *Untersuchungen zur Arbeitswelt der Frau in der römischen Antike*, Frankfurt a. M./Bern/New York/Paris, 1988; Krause, J.-U., *Witwen und Waisen im römischen Reich*, Vol. I-IV, Stuttgart, 1994/96; Arjava, A., *Women and Law in Late Antiquity*, Oxford, 1996; Cantarella, E., *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, 1998; Johlen, M., *Die vermögensrechtliche Stellung der weströmischen Frau in der Spätantike*, Berlin, 1999; Evans-

§ 18 – Fizičke osobe

Budući da postanak i prestanak fizičke osobe izazivaju važne posljedice u pravu, rimski su pravници potanko razradili pretpostavke potrebne za postanak fizičke osobe. To su:

1. dijete mora potpuno biti odvojeno od majčine utrobe;
2. dijete se moralo roditi živo jer mrtvorodenče nije smatrano ni začetim ni rođenim. Prema stanovištu Sabinijanske škole, koju je prihvatilo Justinijanovo pravo, bio je dovoljan bilo kakav znak života (puls, micanje, disanje);
3. dijete je moralo biti nošeno najmanje šest mjeseci, inače se smatralo pobačajem;
4. dijete je moralo imati ljudski oblik. Nakazno dijete (*monstrum*, *prodigium*) trebalo je, kako propisuje Zakonik XII ploča (IV. 1) odmah ubiti, a izlaganje deformirane i za život nesposobne djece bilo je dopušteno i u klasičnom i u postklasičnom razdoblju.

Začetak nije smatran subjektom prava, ali je rimsko pravo vodilo računa o njemu kao o budućoj osobi (*nasciturus*). Iznimno, ako se radilo o zaštiti prava i interesa nerođenog djeteta, ipak se priznavao pravni subjektivitet *nasciturus*. To je osobito bio slučaj u nasljednom pravu. Zbog zahtjeva da nasljednik mora biti živ u momentu ostaviteljeve smrti, dijete rođeno nakon očeve smrti (*postumus*), bilo bi lišeno nasljedstva. Da se ne bi dogodila takva nepravda, stvoreno je pravilo prema kojem se smatra **da je začeto dijete već rođeno ako se radi o zaštiti njegovih interesa (*nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur*)**. Zahvaljujući toj **fikciji**¹² dijete će moći naslijediti oca koji je umro prije njegova rođenja. *Nasciturus* je mogao biti postavljen nasljednikom u oporuci, a u međuvremenu, za zaštitu njegovih budućih prava, pretor je mogao odrediti posebnog staratelja (*curator ventris*).

Glede pitanja je li rođeno dijete slobodno ili rob, smatralo se slobodnim ako je majka djeteta bila slobodna u času začeća ili ako je tijekom trudnoće, makar kratko vrijeme, bila slobodna (*favor libertatis*).

Rimsko pravo nije imalo posebne propise o smrti, koja izaziva važne posljedice u pravu. Ako je netko izvodio neka prava na temelju nečije smrti, morao je tu okolnost dokazati. Postavilo se pitanje, kako riješiti slučaj smrti više osoba, koje su međusobno zakonski nasljednici, a život su izgubile istodobno u nekoj nesreći (*commorientes*).

Grubbs, J., *Women and the Law in the Roman Empire*, London, 2002; Jensen, A., *Frauen im frühen Christentum*, Bern/Berlin, 2002.

Klasično pravo pretpostavljalo¹³ je da su život izgubile istodobno, dok se ne bi drukčije dokazalo. Justinijanovo je pravo za slučaj kada su u istom događaju poginuli preci (*ascendentes*) i potomci (*descendentes*) pretpostavljalo da su dorasli descendent i preživjeli ascendent, i obrnuto, da su ascendenti preživjeli svoje nedorasle descendente. Suvremeno pravo poklapa se sa stanovištem klasičnog rimskog prava.

§ 19 – Stupnjevi pravne sposobnosti fizičke osobe (statusi)

S obzirom da je pojedinac mogao biti slobodan ili rob, rimski građanin, latin ili peregrin, na čelu obitelji ili samo njen član razlikovala su se tri statusa: ***status libertatis***, ***status civitatis*** i ***status familiae***.

1. *Status libertatis*

Rimski pravnik Gaj započinje izlaganje o statusnom pravu konstatacijom da su svi ljudi ili slobodni ili robovi (D.1.5.3). Ipak, rimski pravници ističu da su se ljudi po prirodnom pravu rađali slobodni (*Ulpianus*, D.1.1.4), a da je ropstvo ustanova *ius gentium* po kojem se netko, suprotno prirodi, podvrgava tuđoj vlasti (*Florentinus*, D.1.5.4.1).

Rob (*servus, homo, puer*) nije pravni subjekt, nego samo objekt prava (stvar). Nema ni pravnu, ni poslovnu sposobnost. Rob može poboljšati položaj svog gospodara, ali ga ne može pogoršati. Ako napravi delikt, ne obvezuje svog vlasnika jer gospodar može platiti štetu, ali ako to ne želi, može na temelju noksalne odgovornosti predati roba u vlasništvo oštećenoga. Prema Akvilijevom zakonu o šteti (287. god. p.n.e.) ubojstvo, odnosno povreda roba jednako su tretirani kao ubojstvo životinje, odnosno oštećivanje stvari. Rob nije sposoban imati imovinska, niti obiteljska prava. Nije mogao tužiti niti biti tužen. Spolna zajednica roba i ropkinje (*ancilla*) nema značaj braka, nego samo faktičnog zajedničkog života (*contubernium*). Sve što bi rob stekao, ma na koji način, pripadalo je njegovu vlasniku.

¹² *Fictio* je pravna činjenica koja se smatra istinitom, premda stvarno nije istinita i ne postoji u određenom trenutku.

¹³ *Praesumptio* je pravna činjenica za koju se smatra da postoji, premda njeno postojanje nije utvrđivano niti dokazivano. U ovom slučaju radi se o oborivoj pretpostavci (*praesumptio iuris*) kod koje je dopušteno izvoditi protudokaz i koja se protudokazom može oboriti. Za razliku od nje postoji neoboriva pretpostavka (*praesumptio iuris et de iure*) kod koje se nešto smatra dokazanim i zabranjuje protudokaz (npr. pretpostavka o djelatnoj nesposobnosti djece do sedme godine).

Osnovni **izvori ropstva** bili su: rođenje od majke ropkinje, zarobljavanje u ratu i oduzimanje slobode radi kazne. Ropstvo je moglo prestati puštanjem na slobodu (**manumissio**) koje je po starijem pravu imalo sljedeće oblike: *manumissio vindicta* (u obliku legisakcijskog postupka), *manumissio censu* (upisom u listu građana) i *manumissio testamento* (na temelju oporuke). Pretorsko pravo uvelo je manje formalne oblike puštanja na slobodu: *manumissio inter amicos* (usmenim očitovanjem pred svjedocima), *manumissio per epistulam* (puštanje pismom) i *manumissio per mensam* (pozivanjem roba za gospodarev stol). Kako civilno pravo nije poznavalo te oblike puštanja na slobodu, oslobođeni je po civilnom pravu ostajao rob, ali ga je pretor štitio uskraćujući gospodaru tužbu kojom je mogao zahtijevati vraćanje u ropski položaj (*vindicatio in servitute*). Robovi pušteni na slobodu na takve načine nisu postajali rimski građani nego su samo stjecali pravo latiniteta (*Latini Iuniani*). Oslobođeni rob (**libertus, libertinus**) ostajao je u odnosu zavisnosti prema bivšem gospodaru (*patronus*) obvezujući se na mnogobrojne dužnosti. Kršćanski carevi uveli su crkveni oblik puštanja na slobodu *manumissio in ecclesia* (pred sakupljenom općinom i svećenicima) na temelju kojeg je oslobođenik postajao rimski građanin.

Obveze koje zaključio rob nemaju nikakva značaja i ne obvezuju gospodara. Takvo shvaćanje bilo je uvjetovano zatvorenim kućnim gospodarstvom kada su slučajevi razmjene bili rijetki pa ih je *pater familias* mogao sam obaviti. Međutim, promjenom gospodarske strukture u drugoj polovici razdoblja Republike, poslovi bogatih robovlasnika postajali su sve bogatiji i raznovrsniji, tako da ih više nisu mogli sami obaviti. Zato su za obavljanje određenih poslova bili prinuđeni koristiti se robovima i podčinjenim osobama. Osim toga, često su robovima i podčinjenim osobama¹⁴ davali **određeni dio imovine na samostalno upravljanje i raspolaganje, tzv. peculium**. Premda je gospodar pravno i dalje ostajao vlasnikom te imovine, smatrao se pekulij stvarno ipak imovinom roba. Na temelju činjenice da je rob samostalno raspolagao

¹⁴ O imovinskopravnom položaju osoba *alieni iuris*, robova i oslobođenika v. Micolier, G., *Pécule et Capacité Patrimoniale. Étude sur le pécule, dit profectice, depuis l'édit "de peculio" jusqu'à la fin de l'époque classique*, Lyon, 1932; Mantello, A., "Beneficium" servile – "debitum" naturale I, Milano, 1979; Fabre, G., *Libertus. Recherches sur les rapports patron – affranchi à la fin de la République Romaine*, Paris, 1981; Di Porto, A., *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica* (II se. a.C. – II sec. d. C.), Milano, 1984; Waldstein, W., *Operae libertorum. Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven*, Stuttgart, 1986; Kirschenbaum, A., *Sons, Slaves and Freedmen in Roman Commerce*, Jerusalem/Washington, D.C., 1987; Aubert, J.-J., *Business Managers in Ancient Rome. A social and Economic Study of Institores*, 200 B. C. – A. D. 250, Leiden, 1994; Melluso, M., *La schiavitù nell'età Giustiniana – disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris, 2000; Chiusi, T. J., *Contributo allo studio dell'editto "de tributaria actione"*, Roma, 1993; Ista, Die *actio de in rem verso im römischen Recht*, München, 2001; Rainer, J. M./Söllner, A., *Corpus der römischen*

povjerenim mu pekulijem, u razdoblju klasičnog prava razvilo se shvaćanje da iz robovih ugovora s gospodarom ili s trećim osobama nastaje za roba barem naravna obveza.

Naravna obveza (*obligatio naturalis*) je plativa, ali civilnopravno neutuživa obveza.

Rob je mogao platiti iz pekulijarne imovine ono što je dugovao, ali nije mogao biti tužen. Slično je bilo i s osobama *alieni iuris* koje nisu mogle biti tužene jer nisu imale vlastite imovine. Takvo shvaćanje otvorilo je novi problem u poslovanju jer su osobe koje bi sklopile posao s robom ili s osobom *alieni iuris* bile u nepovoljnom položaju jer nisu mogle sudskim putem naplatiti potraživanje iz tog posla. Izlaz iz takve situacije našlo je pretorsko pravo tako što je u najčešćim i točno određenim slučajevima dopustilo vjerovniku tužbe protiv gospodara. Nazvane su **actiones adiecticiae qualitatis** (*adiecticius* – dodan) jer se pored odgovornosti osobe koja je sklopila posao, uvodi i odgovornost imatelja vlasti.

To su: 1. ***actio de peculio*** koja se mogla podići protiv gospodara za obveze koje rob ili podčinjeni sklopi u vezi s pekulijem koji je dobio od gospodara;

2. ***actio tributoria*** ako je pekulij upotrijebljen za vođenje trgovine;

3. ***actio de in rem verso*** ako je *pater familias* imao koristi od posla iz koga je nastala obveza. U navedena tri slučaja *pater familias* odgovarao je do visine pekulija. Odgovornost imatelja vlasti bila je neograničena na temelju:

4. ***actio quod iussu*** ako je *pater familias* naložio trećoj osobi da sklopi pravni posao s njegovim sinom ili robom;

5. ***actio institoria*** ako je rob ili osoba *alieni iuris* bila postavljena za poslovođu trgovine (*institor, factor*);

6. ***actio exercitoria*** ako je vlasnik broda (*exercitor navis*) postavio za zapovjednika broda (*magister navis*) roba ili podčinjenu osobu za obveze sklopljene u vezi s poslovanjem broda.

2. Status civitatis

S obzirom na *status civitatis* slobodni stanovnici Rima mogli su biti: **rimski građani (*cives*)**, **Latini i peregrini**. Vremenom se rimsko pravo građanstva širilo tako da je krajem razdoblja Republike Latinima priznat civitet, a car Karakala je 212. godine svim slobodnim stanovnicima carstva podijelio pravo građanstva.

Rimski građanin postaje se rođenjem od roditelja Rimljana ili od oca Rimljanina i majke Latinke s *ius conubii*, manumisijom po civilnom pravu, dodjeljivanjem građanstva pojedinačnom odlukom ili zakonom (*donatio civitatis*). Gubi se: progonstvom, preseljenjem u provincije i dobijanjem prava građanstva u drugom gradu.

Punopravni rimski građani uživali su sva prava predviđena civilnim pravom uz uvjet da su svojevlasne osobe (*personae sui iuris*), odnosno da se nalaze na čelu rimske obitelji (*pater familias*). **Građanin koji ima punu pravnu sposobnost (*civis optimo iure*) je *pater familias*** koji ima: rimsku obiteljsku vlast (*patria potestas, manus, tutela*); na području javnog prava pripadaju mu aktivno biračko pravo (*ius suffragii*) i pasivno biračko pravo (*ius honorum*); na području privatnog prava ima: pravo stjecati imovinska prava civilnog prava, osobito pravo vlasništva (*dominium ex iure Quiritium*); oporučnu sposobnost, tj. pravo napraviti oporuku po civilnom pravu i biti imenovan nasljednikom (*testamenti factio activa et passiva*); sposobnost sklapati imovinskopravne poslove civilnog prava (*ius commercii*); svojstvo biti stranka u civilnom postupku (*ius agendi*); pravo sklopiti valjani brak po civilnom pravu (*ius conubii*); *tria nomina* (*praenomen* – osobno ime, *nomen* – obiteljsko ime, *cognomen* – nadimak).

Navedenim pravima mogli su se koristiti povlašteni slojevi rimskog društva (patriciji, nobili, *honestiores*). Konkretni sadržaj prava građana zavisio je od razdoblja u razvitku rimske države i od **klasnog i društvenog položaja pojedinca**. Pripadnici nižih slojeva (*humiliores*) bili su vezani za svoja zanimanja, nisu mogli sklopiti brak s građanima drugih zanimanja, bili su podvrgnuti pooštrenoј kaznenoј odgovornosti, njihovo svjedočanstvo na sudu manje je vrijedilo od svjedočanstva *honestiora*. Čak su i pripadnici najviših klasa bili ograničavani u nekim pravima: određeni dio imovine morali su ulagati u italska zemljišta, nisu smjeli posjedovati brodove nosivosti veće od 300 amfora, ženiti se libertinima; pokrajinskim magistratima bilo je zabranjeno stjecati nekretnine, primati darove i ženiti se u pokrajini.

Nakon pobjede kršćanstva **Židovi, heretici, pogani** bili su ne samo kazneno proganjani već i građanskopravno ograničavani posebno u oblasti nasljednog prava.

Žene nisu nikada smatrane ravnopravnima s muškarcima. Trajno su bile lišene prava sudjelovanja u političkom i javnom životu jer nisu imale ni aktivno ni pasivno biračko pravo. Položaj žena bio je bolji u oblasti privatnog prava premda su i na tom području postojala ograničenja: žena nije mogla stajati na čelu obitelji, nije mogla biti

svjedok kod formalističnih poslova, nije mogla biti postavljena nasljednicom najbogatijih građana, zastupati nekoga na sudu i sl.

Gubitak, odnosno umanjeње građanskih prava bilo je predviđeno kao **sankcija zbog nedopušteneog i nečasnođ ponašanja**. U starije vrijeme nečasno ponašanje povlačilo je cenzorsku primjebu (*nota censoria*) zbog koje je građanin gubio *ius honorum* i bio brisan iz liste senatora i vitezova. Osobama koje su sudjelovale pri zaključenju svečanih formalističnih poslova, pa kasnije o tome odbile svjedočiti (*personae intestabiles*) ograničavano je *ius commercii* jer više nisu mogle biti svjedoci kod sklapanja pravnih poslova niti su mogle druge pozivati za svjedoke.

Nečasnim osobama smatrani su građani koji su učinili nečasno djelo zbog kojeg su *ipso iure* ili na temelju odluke suda proglašeni nedostojnim određenih prava. **Infamia immediata (neposredna nečasnost)** nastupala je *ipso iure* u slučajevima lažnog stečaja, bigamije, dvostrukih zaruka, bluda kod žena, sramotnog otpusta iz vojske, bavljenja ozloglašanim zanimanjima (gladijatora, poduzetnika gladijatorskih igara, glumaca). **Infamia mediata (posredna nečasnost)** bila je posljedica osude za delikte *furtum*, *rapina*, *iniuria*, *dolus*, kao i za osude iz odnosa tutorstva, ostave, fiducije, mandata i ortaštva jer je smatrano da su iznevjereni odnosi posebnog povjerenja. Za razliku od infamije koja se temeljila na pravnim propisima (*infamia iuris*), postojala je i **infamia facti ili turpitudoe**, koja je dovođila do umanjivanja građanskih prava po odluci državnih organa. Posljedice infamije bile su gubitak aktivnog i pasivnog biračkog prava, nemogućnost sklapanja braka s osobama rođenim u slobodi, nesposobnost biti odvjetnikom ili zastupnikom u sporu. U Justinijanovoj kodifikaciji iščezla je infamija koja se temeljila na pravnim propisima, a *infamia* i *turpitudoe* imale su još za posljedicu zapostavljanje po sučevu rasuđenju.

3. Status familiae

Pored *statusa libertatis* i *statusa civitatis* za određivanje pravne i poslovne sposobnosti rimskih građana veliku važnost imao je **položaj osobe unutar obitelji (status familiae)**. S obzirom na obiteljski status rimski građani dijelili su se na svojevlasne osobe (*personae sui iuris*) i osobe podložne očinskoj vlasti (*personae alieni iuris*). Podjela članova obitelji na osobe *sui iuris* i osobe *alieni iuris* predstavlja jedno od bitnih obilježja rimske patrijarhalne obitelji zasnovane na izraženoj vlasti obiteljskog starješine (*patria potestas*). *Pater familias* bio je jedina osoba *sui iuris* u obitelji, a svi

ostali članovi obitelji bez obzira na spol i uzrast bili su osobe *alieni iuris*. Podčinjene osobe mogle su zaključiti brak, imale su aktivno i pasivno biračko pravo, ali sve dok im je *pater familias* bio živ, bile su bitno prikraćene u pravu sklapanja pravnih poslova. Zavisne osobe nisu mogle stjecati imovinu za sebe i sve što bi stekle, ma na koji način, pripadalo je po civilnom pravu obiteljskom starješini. Nisu mogle obvezivati imatelja vlasti. *Pater familias* mogao je platiti njihove dugove, ali nije morao jer su njihove obveze imale karakter naravnih obveza.

4. *Capitis deminutio*

Pravni položaj pojedine osobe (*status*) nije morao biti isti tijekom cijelog života; mogao se i poboljšati i pogoršati. **Gubitak i neke oblike promjene statusa rimski pravnici nazivaju *capitis deminutio*.**

Najteži gubitak je ***capitis deminutio maxima*** (gubitak slobode, odnosno gubitak statusa *libertatis*) ili građanska smrt koja je povlačila potpuni gubitak pravne sposobnosti, što uključuje gubitak svojstva rimskog građanina i gubitak pripadnosti rimskoj obitelji. Nastajala je kao posljedica osude na najteže kazne po kojima je osuđenik postajao robom države (*servus poenae*), a državi je pripadala i njegova imovina. Rimski građanin gubio je slobodu zarobljavanjem od strane neprijatelja. Ako bi umro u zarobljeništvu, uzimalo se po *fictio legis Corneliae* kao da je umro u času zarobljavanja da bi ga se moglo naslijediti kao rimskog građanina. Ako bi se uspio osloboditi iz zarobljenišтва, priznavano mu je *ius postliminii*, što znači da su svi njegovi pravni odnosi oživljavali, izuzev braka i posjeda koji su smatrani faktičnim situacijama koje je zarobljavanje prekinulo.

Capitis deminutio media (gubitak rimskog prava građanstva) nastupila bi kada bi se rimski građanin iselio u latinsku koloniju, te osudom na kaznu progonstva (*aquae et ignis interdictio*), koja je kasnije ublažena deportacijom (*deportatio*) i relegacijom (*relegatio*) kojima je određivano prinudno mjesto boravišta.

Capitis deminutio minima (gubitak, odnosno promjena obiteljskog statusa) nastupala je kao posljedica usvojenja (*adoptio* i *arrogatio*), zaključenjem *manus* braka i emancipacijom. Dovodila je do gašenja kontraktnih obveza i nekih osobnih prava (osobnih služnosti).

Podjeljivanjem rimskog prava građanstva svim slobodnim stanovnicima Carstva i potiskivanjem agnatskog srodstva kognatskim, izgubile su *capitis deminutio media* i *capitis deminutio minima* u Justinijanovom pravu svaki značaj.

§ 20 - Deliktna sposobnost

Rimski pravници razmatrali su pitanje deliktne sposobnosti (sposobnost odgovarati za vlastite protupravne radnje) neovisno o pitanju pravne i poslovne sposobnosti. Za njih je **deliktno sposoban svatko tko ima fizičku osobu**, bez obzira radi li se o osobama *sui iuris* ili *alieni iuris*, robovima ili životinjama. Zato su obveze nastale iz delikata vezivane za fizičku osobu počinitelja delikta.

Ako je delikt počinila pravno i poslovno sposobna osoba, oštećeni je morao protiv nje podići tužbu i zahtijevati odgovarajuću naknadu. Međutim, po pravilima o **noksalnoj odgovornosti**, za delikte podčinjenih osoba i robova odgovarao je njihov *pater familias*. Tužba se podizala protiv gospodara, odnosno imatelja vlasti pod čijom su se vlašću rob ili osoba *alieni iuris* nalazili u trenutku podizanja tužbe, a ne u trenutku počinjenja delikta. Takvo shvaćanje posljedica je načela da deliktna odgovornost prati počinitelja, bez obzira na eventualne promjene u njegovu statusu (***nox caput sequitur***). Imatelj vlasti morao je platiti novčanu kaznu predviđenu za taj delikt, ili, ukoliko to nije htio, mogao je počinitelja izručiti oštećenome (*noxae deditio*). *Noxae deditio* izvršavana je mancipacijom. Rob bi dolazio u vlasništvo oštećenog, a osoba *alieni iuris* u odnos sličan ropskom (*mancipium, in causa mancipii*) u kojem bi se nalazila dok ne bi odradila dug, tj. novčanu kaznu. Slično se primjenjivalo i u slučajevima kada bi životinja nanijela štetu. Vlasnik je mogao platiti njen iznos ili predati životinju. Tužba se zvala *actio de pauperie*.

§ 21 – Pravne osobe

Pravna osoba (*persona iuridica, persona moralis*) je društvena tvorevina kojoj je pravni poredak priznao svojstvo subjekta prava. Za postojanje pravne osobe kao subjekta u pravu potrebno je da postoje: **skupina ljudi, određena imovina s određenom namjenom (ciljem) i priznanje svojstva subjekta prava od strane pravnog poretka.** Premda rimsko pravo nije razradilo opću teoriju o pravnim osobama, posebne društvene tvorevine tj. pravne osobe postojale su po propisima rimskog prava još od najstarijih vremena. Rimski su pravnici uočili nezavisnost subjektiviteta pravne osobe od subjektiviteta osoba koje je čine naglašavajući da: “Ako se nešto duguje udruženju, ne duguje se pojedincima; niti pojedinac

duguje ono štouguje udruženje.” (*Ulpianus*, D.3.4.7.1). Da bi ostvarila cilj radi kojeg je osnovana, pravna osoba mora se uključiti u pravni promet. Da bi joj to bilo omogućeno, pravni joj poredak priznaje svojstvo nositelja određenih prava i obveza, tj. pravni subjektivitet s posebnom pravnom sposobnošću ograničenom njezinom prirodom i svrhom. Zajedno s pravnom sposobnošću, preko svojih organa sastavljenih od fizičkih osoba, pravna osoba stječe i poslovnu sposobnost u granicama svrhe za koju je osnovana.

S obzirom na supstrat stvaranja i djelovanja (temelj, podlogu) pravne osobe dijele se na: *universitates personarum* (korporacije) i *universitates rerum* (zavode i zaklade).

Korporacija (*universitas personarum*) je organizirani kolektiv fizičkih osoba koji je samostalni pravni subjekt različit od pojedinaca koji su članovi korporacije. Premda i korporacija ima svoju imovinu, njezin je supstrat **udruženje fizičkih osoba**. Promjenom članova ne mijenja se identitet korporacije. Rimljani su državu (*populus Romanus*), gradske općine (*municipia*) i mnoga udruženja (*collegia*) tretirali kao osobe obuhvaćajući ih najčešće nazivom *universitas*. Rimska država bila je subjekt javnog prava kao nositelj državne vlasti, ali i subjekt privatnog prava kao nositelj privatnopravnih imovinskih ovlasti; mogla je stjecati imovinu i nasljeđivati. Gradske općine (*municipia*) postale su također subjekti privatnog prava. Mogle su tužiti i biti tužene u vezi s poslovima oko njihove imovine, oslobađati robove, primiti nasljedstvo. Zastupao ih je *actor* ili *syndicus*. Nakon Konstantina i kršćanska je crkva stekla svojstvo pravne osobe.

U Rimu su djelovala razna udruženja (*collegia*) osnovana u poslovne, političke, društvene, religijske svrhe. Zakonik XII ploča predviđao je široku slobodu udruživanja uz jedini uvjet da se poštuje pravni poredak (načelo autonomije), a od vremena Cezara i Augusta bilo je potrebno prethodno odobrenje državnih organa (načelo koncesije). Za osnivanje udruženja bila su potrebna najmanje trojica članova (*tres faciunt collegium*, D.50.16.85), ali je ono ostajalo ako je palo samo na jednoga ako je bilo još imovine i imena udruženja. U razdoblju Dominata država osniva stručna udruženja obrtnika, radnika i trgovaca u kojima je članstvo bilo obvezno i doživotno. U Justinijanovom pravu *universitates personarum* su sve pravne osobe koje su imale vlastitu imovinu, izdvojeno članstvo i određeni gospodarski, politički, društveni, humanitarni ili religijski cilj.

Universitates rerum (zaklade i zavodi) su imovinske mase namijenjene određenoj svrsi kojima je pravni poredak priznao svojstvo subjekta prava. Supstrat njihove pravne osobnosti je sama **imovinska masa**. Imovinom zaklada upravljaju njihovi organi. To su bile državne ustanove namijenjene raznim društvenim i dobrotvornim svrhama: bolnice, sirotišta,

starački domovi, skloništa za siromašne. U kršćansko doba takve institucije nazivaju se *piae causae*. Njihovom imovinom upravljala je crkvena općina.

Drugo poglavlje

Obiteljsko pravo

§ 22 – Pojam obiteljskog prava i evolucija rimske obitelji

Obiteljsko pravo je skup pravnih normi koje reguliraju pravni položaj pojedinih osoba unutar rimske obitelji. Obitelj (*familia*)¹⁵ u rimskom pravu je skupina osoba koje su po prirodi (rođenjem) ili po pravu (usvojenjem, *manus* brakom) podređene vlasti obiteljskog starješine (*pater familias*).

Nakon raspada gentilnog uređenja smijenila su se tri oblika obitelji: konzorcijum, patrijarhalna agnatska obitelj i kognatska obitelj.

Konzorcijum (*consortium*) čini više braće sa svojim užim obiteljima: ženama i potomstvom. Odgovara obiteljskim zadrugama ostalih naroda. To je zajednica imovine, života i rada, na čijem je čelu jedan od odraslih muškaraca. Vlasništvo u konzorciju je kolektivno zbog čega šef konzorcija nije imao samostalno pravo raspolaganja imovinom. Konzorcij se raspadao i gasio ako su braća mogla opstati svaki za sebe sa svojim ženama i potomcima. Proces raspadanja konzorcija počeo je puno prije donošenja Zakonika XII ploča, koji potvrđuje pravo podjele obiteljske zajednice putem *actio familiae erciscundae*.

Diobom braće u konzorciju nastaju manje obiteljske skupine – patrijarhalne obitelji agnata. **Agnatsku obitelj (*familia, familia pecuniaque*) čine roditelji s potomcima.** Takva obitelj karakteristična je za razdoblje prve polovice Republike kada je Rim postao velika država, ali su još uvijek zadržani patrijarhalni elementi u društvu i zatvorena kućna privreda. **Temelji te obitelji su agnatsko srodstvo i neograničena i doživotna vlast obiteljskog starješine.** Članovi obitelji zvali su se agnati. **Agnatio (*adgnatio*) je pravna veza koja je spajala sve osobe podređene istoj očinskoj vlasti (*patria potestas*).** Agnatska obitelj (*familia*) obuhvaćala je, osim obiteljskog starješine, ženu u *manus* braku, njihovu neemancipiranu djecu, usvojene osobe, osobe *in mancipio* i robove. Pod pojmom *familia pecuniaque* podrazumijevaju se ne samo osobe koje žive i rade u okviru obitelji, nego i obiteljska imovina, koja je postupno s jačanjem ovlasti glave obitelji postala njegovo

¹⁵ Andreau, J./Bruhns, H., *Parenté et stratégies familiales dans l' antiquité romaine*, Rom, 1990; Volterra, E., *Scritti giuridici*, Vol. I-II, *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991; Bradley, K. R., *Discovering the Roman Family*, New York/Oxford, 1991; Krause, J.-U., *Die Familie und weitere antropologische Grundlagen*, Stuttgart, 1992; Dixon, S., *The Roman Family*, Baltimore/London, 1992; Evans Grubbs, J., *Law and Family in Late Antiquity*,

individualno vlasništvo. Osobe i imovina su u takvoj međusobnoj vezi da je opstanak osobe koja bi napustila obitelj bio ozbiljno ugrožen.

Raskidom agnatske veze sa svojom obitelji (emancipacijom ili udajom u *manus* brak) gubilo se svako pravo prema obiteljskoj imovini i za života i nakon smrti šefa obitelji. Smrću glave obitelji raspadala se obitelj na onoliko posebnih obitelji koliko je sinova ili daljnjih neposrednih muških potomaka iza njega ostalo. Svaki od njih postajao je osoba *sui iuris* i *pater familias* nove obitelji. Na agnatsko srodstvo nadovezivale su se važne pravne posljedice, osobito zakonsko tutorstvo i zakonsko nasljedno pravo.

U drugoj polovici razdoblja Republike dolazi do bitnih promjena u obiteljskim odnosima. Tržišna privreda i klasično ropstvo omogućili su opstanak pojedinaca izvan obitelji. Više nije bilo potrebe za postojanjem obiteljske skupine s čvrstom unutarnjom kohezijom. Ograničava se vlast obiteljskog starješine zbog čega opada značaj agnatskog srodstva. Sve više se uvažava krvno srodstvo (*cognatio*) koje je u Justinijanovom pravu u potpunosti potisnulo agnatsko srodstvo, a **kognatska obitelj** kao zajednica krvnih srodnika, koju sada sačinjava bračni par i njihovi potomci, zamjenjuje agnatsku.

§ - 23 Srodstvo

U starom rimskom pravu srodstvo se računalo po činjenici zajedničkog života unutar jedne obitelji, a ne po krvi i po podrijetlu. Srodnici su osobe koje su zajedno živjele i radile u istoj obitelji, a osobe koje su živjele izvan obitelji, makar bile u bliskoj krvnoj vezi s članovima obitelji, nisu smatrane srodnicima. Običaji su poštovali krvnu vezu tretirajući blisko krvno srodstvo kao smetnju za zaključenje braka, ali u svim drugim slučajevima uvažavalo se samo agnatsko srodstvo. Takvo shvaćanje uvjetovano je zatvorenom kućnom privredom, zavisnošću članova konzorcija od zajedničke imovine i nastojanjem da se ta imovina sačuva za buduće generacije. Blizina agnatskog srodstva u konzorciju određivana je po generacijama: najbliži srodnik (*agnatus proximus*) je brat; djeca sve braće sačinjavaju sljedeću generaciju i međusobno su najbliži srodnici bez obzira što potječu od raznih roditelja i podjednako su bliski srodnici članovima prethodne generacije.

Raspadanjem konzorcija i nastajanjem agnatske obitelji sa izraženom vlašću kućnog starješine, **agnatskim srodnicima smatraju se osobe koje su podčinjene vlasti istog šefa obitelji (*pater familias*)**. Samo su se na agnatsko srodstvo nadovezivale pravne posljedice,

prvenstveno zakonsko tutorstvo i zakonsko nasljedno pravo. Agnatskim srodnikom postajalo se dolaskom pod očinsku vlast istog kućnog starješine, a agnatsko srodstvo prestajalo je oslobođanjem, odnosno izlaskom iz očinske vlasti.

Slabljenjem vlasti glave obitelji opada značaj agnatskog srodstva. Sve više se uvažava krvno srodstvo koje dobija prevagu i u imovinskim odnosima. Zahvaljujući djelatnosti pretora na nasljeđivanje se poziva emancipirani sin, koji to pravo, zbog raskida agnatske veze, ranije nije imao. Krug kognatskih srodnika puno je širi od agnatskog jer je majka izvor srodstva jednako kao i otac. Zato se krvni srodnici dijele na srodnike po očevoj i po majčinoj lozi.

Krvnim srodstvom (*cognatio*) naziva se odnos (veza) između osoba koje potječu jedna od druge, ili imaju zajedničkog pretka, a ne potječu jedna od druge.

Krvni srodnici dijele se na srodnike u ravnoj i srodnike u pobočnoj liniji. Srodnici u **ravnoj liniji (*linea recta*)** su osobe koje potječu jedna od druge, izravno ili **neizravno**. Linija je **ushodna** ako se imaju u vidu **preci (*ascendentes*)**, a **nishodna** ako se promatraju **potomci (*descendentes*)** iste osobe.

Srodnici u **pobočnoj liniji srodstva (*linea transversa, linea collateralis*)** su osobe koje potječu od zajedničkog pretka, a ne potječu jedna od druge (*collaterales cognates*: braća, sestre, ujaci, stričevi, sestrične, bratići).

Postklasično i Justinijanovo pravo razlikuju krvne srodnike koji imaju zajednička oba roditelja (***germani***), one koji imaju zajedničkog oca (***consanguinei***) i one koji imaju zajedničku samo majku (***uterini***). Polukrvni srodnici (polubraća i polusestre) su kognati drugog reda i na nasljedstvo se pozivaju tek poslije punokrvne braće i sestara. Značajna podjela kognatskih srodnika bila je na **bračne (*legitimi*)** i **izvanbračne (*spurii, vulgo concepti*)**. Veza jednog bračnog druga sa srodnicima drugog bračnog druga naziva se **tazbina (*adfinitas, affinitas*)** i računa se po blizini kognatskog srodstva.

Bliskost srodničkog odnosa između dviju osoba izražava se stupnjevima srodstva. Stupanj srodstva kognatskih srodnika računa se po broju poroda, po načelu: koliko poroda, toliko stupnjeva srodstva (*tot gradus, quot generationes*). Kognatski srodnici istoga stupnja, ravne ili pobočne linije, su osobe koje su od nekog zajedničkog pretka udaljene istim brojem rođenja, npr. otac (majka) je sa sinom (kćerkom) u prvom stupnju srodstva ravne linije; djed (baka) s unukom u drugom stupnju srodstva ravne linije itd.; u

pobočnoj liniji srodstva braća i sestre su u drugom, stric i nećak u trećem, bratučedi u četvrtom stupnju srodstva itd.

§ 24 – *Patria potestas*

1. Pojam očinske vlasti; *patria potestas* u osobnom i imovinskopравnom pogledu

Očinska vlast (*patria potestas*)¹⁶ je doživotna i u najstarije vrijeme neograničena vlast kućnog starješine (*pater familias*) nad osobama i obiteljskom imovinom.

Tijekom vremena došlo je do diferenciranja tog pojma tako da se vlast nad robovima označavala kao *dominica potestas*, vlast nad slobodnima koje bi *pater familias* ustupao drugima na određeno vrijeme - *mancipium*, vlast nad ženom – *manus*, a pojam *patria potestas* ograničen je na vlast nad djecom (rođenom i usvojenom) i daljim potomcima. *Patria potestas* rimskog prava ne može se uspoređivati sa suvremenim pojmom roditeljskog prava jer je rimska očinska vlast trajala sve do smrti obiteljskog starješine i nije završavala punodobnošću podčinjenih; zavisne osobe bile su imovinskopравno nesposobne i sve što bi stjecale, pripadalo je kućnom starješini; *pater familias* mogao je podčinjene osobe prodati (*ius vendendi*), a u najstarije vrijeme odlučivao je o njihovom životu i smrti (*ius vitae ac necis*), kao i o njihovom kažnjavanju.

***Filii familias* nisu mogli raspolagati imovinom, niti su mogli ugovorima obvezivati imatelja vlasti. Njihove obveze imale su karakter naravnih obveza. SC *Macedonianum* iz I. st. zabranjivao je pozajmljivati novac sinovima u vlasti predviđajući *exceptio senatus consulti Macedoniani* protiv zajmodavčeve tužbe. Takav senatski zaključak donesen je nakon što je neki Macedo ubio oca kako bi iz nasljedstva isplatio vjerovnike.**

Velike promjene u društvenom i gospodarskom životu, do kojih je došlo u drugoj polovici razdoblja Republike, bitno su utjecale na položaj osoba *alieni iuris*. *Pater familias* ih uključuje u poslovni promet, a da bi se trećim osobama omogućilo stupiti s podčinjenima u ugovorne odnose, pretor je uveo ***actiones adiecticiae qualitatis*** na temelju kojih je *pater familias* postao u određenim slučajevima odgovoran za obveze kućne djece. Imatelj vlasti

¹⁶ Rabello, A. M., *Effetti personali della "patria potestas"*, Milano, 1979; Saller, R. P. *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge, 1994. Fayer, C., *La Familia Romana, Aspetti giuridici ed antiquari*, Vol. I, Rom, 1994.

odgovarao je i za obveze nastale iz poslovanja pekulijem na temelju *actio de peculio*. Imovina koju su podčinjeni dobijali od oca na samostalno upravljanje i raspolaganje zvala se *peculium profecticium*, za razliku od imovine koju bi stekli u vojnom pohodu i kojom su od početka Principata mogli oporučno raspolagati – *peculium castrense*. Sličan pravni položaj priznat je u postklasičnom pravu imovini stečenoj u državnoj službi – *peculium quasi castrense*. Imovinsko osamostaljivanje sina u vlasti nastavljeno je kada je imovini naslijeđenoj od majke ili majčinih predaka priznat karakter pekulijarne imovine – *bona materna*. Vlasnik te tri skupine imovine, kasnije nazvane *bona adventicia*, bilo je kućno dijete, a *pater familias* je imao pravo uprave i uživanja, koje je ograničeno u Justinijanovom pravu po kojem je osoba *alieni iuris* mogla slobodno raspolagati tom imovinom.

Justinijanovo pravo svelo je očinsku vlast na sasvim uske okvire.

2. Postanak očinske vlasti

Očinska vlast (*patria potestas*) zasnivana je rođenjem djeteta u valjanom braku i pravnim poslovima.

Rođenjem su pod očinsku vlast dolazila djeca rođena u zakonitom rimskom braku i to najranije 182. dan po sklapanju braka, a najkasnije 300. dan po prestanku braka. Za očinstvo je vrijedila oboriva pretpostavka (*praesumptio iuris*) da je otac djeteta muž majke (*Paulus D.2.4.5: Pater is est quem nuptiae demonstrant*) dok se ne bi drukčije dokazalo. Ipak, samim rođenjem nije se postajalo članom agnatske obitelji nego tek kada bi *pater familias*, uz određeni religijski ceremonijal, prihvatio novorođenče (*tollere liberum*). Ako to ne bi uradio, dijete je moglo biti izloženo (odbačeno) i tako osuđeno na smrt. Ograničavanjem očinske vlasti *pater familias* je izgubio *ius vitae ac necis*, tako da su od razdoblja klasičnog prava pod očinsku vlast ulazila sva djeca čiji su roditelji bili rimski građani i koja su rođena za trajanja zakonitog rimskog braka (*matrimonium legitimum*).

Pod očinsku vlast su, voljom obiteljskog starješine, mogle doći i osobe koje nisu rođene u obitelji. Očinska vlast se u tim slučajevima zasnivala **putem pravnih poslova**, odnosno usvojenjem. **Usvojenje** je način zasnivanja očinske vlasti na temelju **pravnog posla**. Vršilo se u obliku adrogacije i adopcije. **Adrogatio** (*arrogatio*) je stariji oblik usvojenja, vršen na svečani način pred kurijatskom skupštinom, kojom je predsjedao vrhovni svećenik (*pontifex maximus*). Mogao se adrogirati samo odrasli muškarac *sui iuris*, koji bi aktom adrogacije pretrpio *capitis deminutio minima*. Time bi adrogirani

zajedno sa ostalim članovima obitelji i obiteljskom imovinom potpadao pod očinsku vlast adroganta. Ujedno bi se gasio njihov obiteljski kult. Akt adrogacije imao je značajne posljedice za imovinske odnose adrogiranoga prema trećim osobama. Sve su to bili razlozi zbog kojih se adrogacija obavljala na svečan način u nazočnosti skupštine. Nakon iščezavanja kurijatskih skupština postupak se odvijao pred 30 liktora, a Dioklecijan je odredio da se vrši carevom dozvolom (*per rescriptum principis*).

Adoptio je usvojenje osobe *alieni iuris*. Kako se adoptirani već nalazio pod očinskom vlašću, njegov pravni položaj nije se mijenjao dolaskom u novu obitelj. Adopcija se vršila privatnim aktom starog i novog obiteljskog starješine: adoptirani je najprije putem prividne prodaje (trostruke prividne mancipacije ako se radilo o muškoj osobi, odnosno jednostruke prividne mancipacije za žensku osobu) osobađan ranije očinske vlasti i obiteljskog kulta, a potom je, pred magistratom u formi *in iure cessio*, donošena odluka o zasnivanju nove očinske vlasti. Kasnije se adopcija vršila na temelju carevog reskripta ili pred nadležnim državnim organom. Justinijanovo pravo uvelo je dobnu razliku od 18 godina između adoptanta i adoptiranoga.

Legitimatio (pozakonjenje) je način zasnivanja očinske vlasti uveden u postklasičnom razdoblju za vladavine Konstantina. Izvanbračna djeca mogla su dobiti položaj bračne djece na tri načina: naknadnim sklapanjem braka izvanbračnih roditelja, stupanjem izvanbračnog djeteta u službu kurijala (*curiales* ili *decuriones* su svojom imovinom odgovarali državi za porez koji je njihova općina morala prikupiti) i carevim reskriptom.

3. Prestanak očinske vlasti

Očinska vlast prestajala je zbog prirodne ili građanske smrti imatelja vlasti ili podčinjenoga, emancipacije i zbog položaja u državnoj službi koji bi postigla osoba *alieni iuris*.

Smrću imatelja vlasti sinovi su postajali osobe *sui iuris* i time dobijali status obiteljskog starješine, bez obzira koliko su bili stari. *Pater familias* može biti čovjek bez djece, pa i novorođenče ako je *sui iuris*. Žena u *manus* braku postajala je također *sui iuris*, ali je potpadala pod tutorstvo. Isti učinak kao prirodna smrt imala je *capitis demunitio maxima, media i minima*.

Najčešći slučaj prestanka očinske vlasti za života obiteljskog starješine bila je emancipacija ili otpuštanje iz očinske vlasti po volji imatelja vlasti. **Emancipatio je poseban, dragovoljan način prestanka očinske vlasti u obliku pravnog posla.** Tumačenjem odredbe

Zakonika XII ploča po kojoj je sin nakon treće prodaje oslobađan od očinske vlasti (*Tab. IV, 2: “si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto”*), stvorena je mogućnost dragovoljnog otpuštanja iz očinske vlasti u formi trostruke prividne prodaje muškarca i jednostruke prodaje ženske osobe (G.1.32). U postklasičnom razdoblju emancipacija je vršena carevim reskriptom i izjavom imatelja vlasti pred nadležnim državnim organom, uz pristanak djeteta. Emancipirani je postajao *sui iuris* i raskidao agnatsku vezu s bivšim imateljem vlasti, zbog čega je po civilnom pravu gubio sva imovinska i nasljedna prava prema ranijoj obitelji. Dok je emancipacija u starije vrijeme predstavljala vid teške kazne, u prilikama razvijenog tržišnog gospodarstva postala je put ka većoj osobnoj i imovinskoj samostalnosti podčinjenih osoba.

U Justinijanovom pravu *patria potestas* prestaje ako sin obnaša visoke javne funkcije.

§ 25 – Brak (*matrimonium, nuptiae*)

1. Oblici sklapanja braka; učinci braka u osobnim i imovinskim odnosima

Rimski brak (*matrimonium, nuptiae*) je pravnim propisima uređena monogama zajednica života između muškarca i žene.

Za zaključenje pravovaljanog rimskog braka¹⁷ (*matrimonium iustum, iustae nuptiae*) morali su biti ostvareni sljedeći **konstitutivni elementi: *ius conubii*, *affectio maritalis*, *pubertas* bračnih drugova i pravom predviđena forma.**

Pravo zaključiti zakoniti rimski brak imale su samo osobe kojima je bilo priznato ***ius conubii***, a to su bili samo rimski građani i stari Latini (*Latini veteres*). Valjani brak mogle su zaključiti samo osobe koje su imale namjeru zasnovati upravo bračnu zajednicu (*affectio maritalis*). ***Affectio maritalis* je volja živjeti kao muž i žena.** Nije bilo dovoljno očitovati tu volju samo pri sklapanju braka, nego je ona morala biti **trajna**, kao i **činjenica zajedničkog življenja**. U razdoblju klasičnog prava traži se da tu volju očituju i budući bračni drugovi, a ne samo njihovi obiteljski starješine kao što je tražilo staro pravo, a u postklasičnom pravu dovoljna je suglasnost zaručnika. U brak su mogle stupiti samo **djelatno sposobne osobe**: žene s navršених 12 i muškarci sa 14 godina starosti. **Brak je bio zabranjen između krvnih**

¹⁷ Gaudemet, J., *Le mariage en occident*, Paris, 1987; Treggiari, S., *Roman Marriage. Iusti coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*. Oxford, 1991; Piro, I., “Usu” in *manum convenire*, Napoli, 1994; Evans Grubbs, J., *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine’s Marriage Legislation*, Oxford, 1995; Eisenring, G., *Die römische Ehe als Rechtsverhältnis*, Wien, 2002; Astolfi, R., *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, Padova, 2000.

srodnika u ravnoj liniji srodstva, a u pobočnoj liniji u staro doba bio je isključen između srodnika u sedmom stupnju srodstva, a u klasičnom razdoblju do četvrtog stupnja.

Oblik sklapanja braka zavisio je od toga je li se brakom namjeravala zasnovati muževljeva vlast (odnosno vlast njegova šefa obitelji) nad ženom (*matrimonium cum manu*), ili te namjere nije bilo (*matrimonium sine manu*).

Brak s manusom (*matrimonium cum manu*) zaključivan je u formama: *confarreatio*, *coemptio* i *usus*. ***Confarreatio*** je bio svečani način sklapanja braka dostupan samo patricijima. Nazočili su mu najviši rimski svećenici i najmanje desetorica svjedoka. ***Coemptio*** je prividna kupnja žene u formi mancipacije. Pred libripensom i petoricom svjedoka nevjestin *pater familias* predavao je nevjestu, a mladoženja (ili njegov *pater familias*) predavao je novčić (*nummus unus*) na ime simbolične cijene. Time bi bio zaključen valjani brak.

Najčešći i najjednostavniji način zaključenja braka bio je ***usus*** (činjenica zajedničkog života). Nakon što bi žena provela godinu dana u muževljevoj kući, zasnivan je *manus* muža ili njegova kućnog starješine. Ako se to željelo preduprijediti, žena je morala prije isteka propisanoga roka provesti tri dana izvan muževljeve kuće (*usurpatio trinoctii*). Taj način zaključenja braka prevladavao je u klasičnom pravu.

Zaključenje braka izazivalo je određene posljedice i u osobnim i u imovinskim odnosima bračnih drugova. U **braku *cum manu*** žena je raskidala agnatsku vezu sa svojom obitelji i potpadala pod očinsku vlast muža, odnosno muževljeva imatelja vlasti ako je taj bio *alieni iuris*. Dobijala je isti položaj kao i ostala ženska djeca (agnatske kćeri - *filiae loco*), čime joj je omogućeno nasljedno pravo u muževljevoj obitelji. Kao osoba *alieni iuris*, žena u *manus* – braku bila je imovinskopravno nesposobna. Imovina koju je imala prije braka i sve što bi stekla za trajanja braka, pripadalo je novom imatelju vlasti. *Pater familias* nije smio prodati u ropstvo ženu koja je bila pod njegovom vlašću, a mogao ju je usmrтитi samo u slučaju preljuba i pijanstva.

Počev od razdoblja principata sve više prevladava **brak bez manusa (*matrimonium sine manu*)**. Za nastanak tog braka pravo nije tražilo ispunjenje nekih formalnosti. Bila je dovoljna **faktična zajednica života bračnih drugova i njihova želja (*affectio maritalis*) da se ta zajednica smatra brakom**. Da bi se takva zajednica razlikovala od konkubinata, koji je također bio trajna veza između muškarca i žene, u razdoblju Dominata uvedena je pretpostavka po kojoj se smatralo da su u braku muškarac i žena istog društvenog položaja koji žive zajedno. **Brak *sine manu* nije utjecao na pravnu i poslovnu sposobnost žene**. Ona je i dalje zadržavala agnatsku vezu s ranijom obitelji, odnosno ostajala je *sui iuris* ako je

to bila u času zaključenja braka. Zadržavala je zakonsko nasljedno pravo u staroj obitelji. Imovinska samostalnost žene potaknuta je režimom odvojenih dobara. U braku *sine manu* vrijedilo je **načelo razlučene imovine**. Ako je žena bila *sui iuris*, zadržavala je i dalje svoju imovinu, a ako je bila *alieni iuris* stjecala je za svog imatelja vlasti. Žena je samostalno upravljala tom imovinom (*bona parapherna*). U slučaju spora o podrijetlu imovine u ženinu posjedu, vrijedila je *praesumptio Muciana* po kojoj ta imovina potječe od muža dok se drukčije ne dokaže. Ipak je i brak bez manusa proizvodio određene pravne posljedice: muž i žena bili su obvezni na uzajamno poštovanje, pomaganje i vjernost; žena je dobijala društveni položaj i domicil muža i pravo na uzdržavanje; morali su izbjegavati svaki akt kojim bi bilo dovedeno u pitanje postojanje bračne zajednice (nisu se smjeli uzajamno tužiti, nisu morali svjedočiti jedno protiv drugoga). Muž je upravljao miraznim dobrima, a prema ostaloj imovini žene nije imao nikakvih prava.

2. Prestanak braka

Brak je prestajao smrću, uslijed *capitis deminutio maxima i media* i razvodom. Ako je brak prestao smrću muža, žena je morala čekati najmanje 10 mjeseci prije sklapanja novog braka (*tempus lugendi* – vrijeme tugovanja) kako bi se spriječilo miješanje krvi (*turbatio sanguinis*), tj. dvojba glede mogućeg očinstva djeteta rođenog u novom braku. Kršćanski su carevi proširili *tempus lugendi* i na slučaj razvoda braka i produžili rok na 12 mjeseci.

Već od starih vremena brak je mogao biti razriješen **razvodom (*divortium*)**. Brak s manusom imali su pravo razvesti muž ili njegov *pater familias*. Za razvod nisu zahtijevani nikakvi posebni razlozi ni uvjeti osim što je forma raskida braka morala biti analogna formi zaključenja: brak zaključen u formi *confarreatio* razrješavan je u formi *diffareatio*, brak sklopljen putem *coemptio* razrješavan je prividnom prodajom žene, tj. putem *remancipatio*, a brak zaključen u formi *ususa* stvarnim prekidanjem bračne zajednice. Kada je u razdoblju kasne Republike prevladalo shvaćanje da brakovi moraju biti slobodni (C.8.38.2), samo su se supruzi smatrali ovlaštenima razvesti brak. Kršćanska je crkva nastojala učvrstiti bračnu zajednicu zbog čega se počev od Konstantina propisuju razlozi zbog kojih se može razvesti brak, a potom i kazne za razvod bez zakonom priznatog razloga.

3. Zaruke (*sponsalia*); miraz (*dos*); darovanje prije braka (*donatio ante nuptias*)

Premda za sklapanje braka bez manusa nije tražena nikakva forma, u praksi su često zaključenju braka prethodili određeni obredi i svečanosti, koji su na vidan način obilježavali *affectio maritalis*. Među najraširenijima bile su zaruke (*sponsalia*).

Zaruke (*sponsalia*) su uzajamno obećanje budućeg zaključenja braka. U starije vrijeme zaruke su sklapane u svečanom obliku stipulacije zvanom *sponsio*, koju su zaključivali obiteljske starješine budućih supružnika, na temelju koje je nastajala utuživa obveza na zaključenje ugovorenog braka. Kada je prevladalo načelo o potrebi slobode pri zaključenju braka, zaruke su sklapane prostim sporazumom iz kojeg je nastajala obveza na naknadu štete od osobe koja je zaruke bezrazložno raskinula. U istočnom dijelu Carstva bilo je uobičajeno ugovoriti posebno obeštećenje za slučaj raskida zaruka u vidu kapare (*arra sponsalicia*): strana koja bi bez zakonskih razloga odbila stupiti u brak gubila je datu kaparu, a primljenu je morala vratiti u četverostrukom iznosu po postklasičnom, odnosno dvostrukom iznosu po Justinijanovom pravu.

Još od najstarijih vremena postojao je običaj davanja miraza (*dos*). **Miraz (*dos*) je imovinski doprinos koji su žena, njezin *pater familias* ili srodnici davali mužu radi lakšeg uzdržavanja obitelji.** U početku je to bila moralna obveza, a od Augusta je postala pravna obveza žene ako je bila *sui iuris*, odnosno njezinih predaka. Miraz koji je davao *pater familias* nazivao se *dos profecticia*, dok je *dos adventicia* bio miraz iz drugih izvora. Miraz se mogao ugovoriti na različite načine: *dos aut datur aut dicitur aut promittitur*. Obveza davanja miraza potjecala je iz stipulacije nazvane *promissio dotis*, a zatim je u istu svrhu služilo svečano jednostrano obećanje miraza - *dotis dictio*, uvršteno u verbalne kontrakte. Kasnije je uvedena *datio dotis* – jednostavno prenošenje miraznih dobara na muža, a u postklasičnom pravu miraz se mogao obećati neformalnim ugovorom – *pactum dotis*. U starijem razdoblju kada je prevladavao brak *cum manu*, miraz je postajao muževljevo vlasništvo, ali je kasnije, zbog čestih razvoda i obiteljskih promjena, bilo osigurano vraćanje miraza putem posebne stipulacije *cautio rei uxoriae*. Daljnjim razvitkom miraz je morao biti vraćen i bez posebnog ugovaranja, a muž je mogao biti tužen s *actio rei uxoriae*. U Justinijanovom je pravu u korist žene bila ustanovljena prešutna hipoteka na cjelokupnoj muževljevoj imovini radi osiguranja miraza, a pripadala joj je i vlasnička tužba (*rei vindicatio*) za potraživanje miraznih stvari.

Za vladavine cara Konstantina raširen je običaj darovanja prije braka. ***Donatio ante nuptias* (u Justinijanovom pravu *donatio propter nuptias*) je dar koji je zaručnik ili njegov *pater familias* davao zaručnici očekujući da će namjeravani brak biti zaključen.**

Darovana imovina odgovarala je vrijednosti miraza, služila je istoj svrsi kao i miraz i bila izjednačena s režimom miraza, zbog čega se nazivala *contrados*. Darovanom imovinom upravljao je muž, njegovom smrću pripala bi djeci, ali je žena imala pravo uživanja. Justinijan je odredio da se taj dar može ustanoviti i za trajanja braka (*donatio propter nuptias*).

TREĆI DIO
RIMSKI GRAĐANSKI POSTUPAK
(*IUS QUOD AD ACTIONES PERTINET*)

Prvo poglavlje
RAZVITAK RIMSKOG GRAĐANSKOG POSTUPKA

§ 26. - Pojam građanskog postupka; specifičnosti rimskog prava

Radi ostvarenja osnovnih vrijednosti i načela u pravu: zakonitosti, pravne sigurnosti i svrsishodnosti, mora postojati mogućnost prinudnog ostvarenja prava. Ukoliko se pravni subjekti ne ponašaju u skladu s dispozicijama sadržanima u pravnim normama (tj. u skladu s normama **materijalnog prava**, npr. obveznog, obiteljskog, kaznenog, radnog prava) primjenjuje se sankcija kao način prinudnog ostvarenja prava. U tu svrhu razvile su se institucionalizirane procesne forme - kazneni i građanski postupak: kazneni postupak za ostvarenje kaznenog, a građanski postupak za ostvarenje pravosuđa na području građanskopravnih odnosa. **Kazneni postupak** primjenjuje se za kaznena djela koja goni i kažnjava država jer ih smatra društveno opasnim, odnosno napadom na osnove državnog i društvenog uređenja. **Građanski postupak**¹⁸ primjenjuje se u slučaju kada pravni sustav smatra nepoštivanje pravne norme povredom privatnih interesa pojedinaca koja izaziva samo spor između građana kao pojedinaca. Građanski postupak pokreće se isključivo na inicijativu titulara ugroženog ili povrijeđenog subjektivnog građanskog prava, a nikad na inicijativu suda. To znači da titulari odlučuju hoće li tražiti pravnu zaštitu putem suda: *nemo iudex sine actore* (nema suda bez tužitelja); *ne procedat iudex ex officio* (sud ne pokreće postupak po službenoj dužnosti). Pokretanje postupka

¹⁸ Važnija literatura o rimskom građanskom postupku: Wenger, L., *Institutionen des römischen Zivilprozeßrechts*, München, 1925; Magdelain, A., *Les actions civiles*, Paris, 1954; Pugliese, G., *Il processo civile romano*, Vol. I-II, Roma, 1962/3; Jahr, G., *Litis contestatio: Streitbezeugung und Prozeßbegründung im Legisaktionen – und im Formularverfahren*, Köln, 1960; Zilletti, U., *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano, 1965; Luzzatto, G. I., *Il problema d'origine del processo extra ordinem*, Bologna, 1965; Biscardi, A., *Lezioni sul processo romano antico e classico*, Torino, 1968; Wolf, J. G., *Die litis contestatio im römischen Zivilprozeß*, Karlsruhe, 1968; Simon, D., *Untersuchungen zum Justinianischen Zivilprozeß*, München, 1969; Behrends, O., *Der Zwölftafelprozeß: zur Geschichte des römischen Obligationenrechts*, Göttingen, 1974; Selb, W., *Formeln mit unbestimmter intentio iuris: Studien zum Formelaufbau*, Wien, 1974; Kelly, J. M., *Studies in the civil judicature of the Roman Republic*, Oxford, 1976; Nicosia, G., *Il processo privato romano*, Torino, 1986; Albanese, B., *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palermo, 1987; Lemosse, M., *Cognitio. Étude sur le rôle du juge dans l'instruction du procès civil antique*, Paris, 1994; Kaser, M./Hackl, K., *Das*

obilježeno je općim načelom građanskog prava - **načelom dispozitivnosti** (načelom slobodne inicijative stranaka ili načelom stranačke autonomije). U tradicionalnom značenju pod “građanskopravnim sporom” podrazumijevaju se sporovi koji nastaju iz pravnih odnosa koji su bili predmet reguliranja velikih građanskih kodifikacija u XIX. stoljeću: imovinskopravni, nasljedni, obiteljski, radni i drugi građanskopravni odnosi.

Građanski postupak predmet je posebne grane prava koja se naziva građansko procesno pravo. **Građansko procesno pravo** obuhvaća norme kojima se regulira postupak kao pravni metod po kojem postupaju sudovi u vršenju sudske funkcije, kao i norme kojima se regulira organizacija i nadležnost sudova. Pravilima o građanskom postupku propisuju se forme za zaštitu postojećih prava: to su pravila **formalnog prava**.

U suvremenom pravu materijalno pravo odvojeno je od formalnog prava, što se za rimsko pravo ne može nikako reći jer je rimsko pravo bilo u puno većoj mjeri vezano za postupak od današnjega. **Pravna zaštita povrijeđenog prava mogla se ostvariti samo ako je za takav slučaj postojala posebna tužba (*actio*). Bez unaprijed predviđene konkretne tužbe, materijalnopravni zahtjev nije smatran ni postojećim ni opravdanim po civilnom pravu.** Rimsko pravo nije poznavalo tužbu u današnjem smislu kao općenito procesualno sredstvo pravne zaštite koje se može upotrijebiti za realizaciju bilo kojega prava. Stav rimskog prava bio je obratan: tužba je imala prioritet i bila podlogom materijalnom pravu. Klasični pravnik *Celsus* definirao je tužbu u smislu procesualno ostvarivog zahtjeva, tj. kao mogućnost da sudskim putem zahtijevamo ono pravo koje nam pripada (D.44.7.51: “*Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur iudicio persequendi*.”). Mnogi instituti stvarnog i obveznog prava stekli su karakter pravnih ustanova tek kada su dobili pravnu zaštitu, tj. svoje posebne tužbe. Dakle, procesualno ostvarivanje prava moglo se tražiti samo onda kada je zakon ili pretorov edikt predviđao tužbu, određenu u tu svrhu, ili ako bi pretor za konkretni slučaj odobrio i uveo novu tužbu. U razdoblju honorarnog prava pretori su stvarali nove mogućnosti za vođenje sporova i pružali pravnu zaštitu institutima i odnosima koje civilno pravo nije poznavalo ni štitilo. Tako se putem postupka rimsko pravo razvijalo i prilagođavalo novim potrebama. Zbog toga je za razumijevanje instituta materijalnog prava nužno poznavanje osnovnih načela i ustanova rimskog građanskog postupka.

Rimski građanski postupak prošao je kroz tri oblika: legisakcijski, formularni i ekstraordinarni. U starom pravu vrijedio je legisakcijski postupak; od II. st. p.n.e.

usporedo je do Augusta u upotrebi i formularni postupak, a u razdoblju postklasičnog prava postupno se uvodi ekstraordinarni postupak, koji je od III. stoljeća postao jedini način presuđivanja u građanskim parnicama.

Postojala je mogućnost rješavanja sporova mimo suda. Da bi izbjegle formalnosti i neugodnosti redovitog postupka, stranke su se mogle dogovoriti da će spor riješiti polaganjem prisege (*pactum iurisiurandi*), te da će spor dobiti ona strana koja prisegne o postojanju svog prava. Drugi način rješenja spora izvan sudskog postupka odvijao se na taj način da su stranke najprije međusobno sklapale kompromis (*compromissum*) da će njihov spor riješiti građanin u kojeg su imale povjerenja, a potom bi s tim građaninom sklopile novi sporazum (*receptum arbitrii*) kojim se taj obvezivao riješiti spor.

§ 27 – Legisakcijski postupak

Stvaranjem rimske države potiskuju se samopomoć, osveta i sila kao načini zaštite subjektivnih prava. Ipak, zbog nerazvijenih funkcija državnog aparata dugo vremena su građanski postupak i samopomoć postojali kao alternativne mogućnosti prepuštene slobodnom izboru građana pojedinaca. Vremenom su uvidjeli da će ugrožene interese lakše ostvariti obraćanjem za zaštitu državnim organima, prvenstveno reksu koji je uživao najveći ugled. U tim situacijama državni organi nisu postupali po vlastitoj inicijativi nego tek po pozivu stranaka u sporu, koje bi od njih tražile da utvrde koja je stranka u pravu i koliku naknadu na ime otkupa od prava na osvetu mora platiti krivac (sustav dragovoljne kompozicije zamijenjen je sustavom zakonske kompozicije kada je država počela propisivati visinu tog otkupa). Premda su vršili ulogu suca, nositelji državne vlasti postupali su u ime društva samo kao privatni građani, a ne u funkciji državnih organa. Zato presuda nije izvršavana prinudom državnih organa, nego je njezina snaga počivala na običajima i moralnim shvaćanjima. Građanski postupak postao je jedinim sredstvom za zaštitu ugroženih prava tek nakon što je samopomoć zabranjena i reprimirana kao javni delikt (*crimen vis*) na temelju Augustovih zakona (*leges Iuliae de vi publica et de vi privata*). *Decretum divi Marci* donesen za vladavine Marka Aurelija u II. stoljeću zabranio je i nasilno naplaćivanje dugova (I.4.21; C.8.4.7; D.48.7.7). Primjena sile dopuštena je samo u slučajevima samoobrane i krajnje nužde (D.9.2.45.4), a i tada samo u granicama nužnim za odbijanje napada ili za spasavanje ugroženog dobra.

Najstariji oblik rimskog građanskog postupka bio je **legisakcijski postupak**. Njegova **osnovna obilježja** su: dvodioba, samopomoć, strogi formalizam, arbitrarnost, nepostojanje pravnih lijekova (nemogućnost žalbe) i osobna ovrha.

Dvodioba postupka posljedica je nekadašnjeg običaja rimskih građana da se za pravnu zaštitu obraćaju reksu. Početkom Republike postupak se odvijao kao **postupak in iure** i **postupak apud iudicem (in iudicio)**. U **postupku in iure** stranke su išle pred magistratu (koji su zamijenili rekse na čelu države) čija je zadaća bila utvrditi je li zahtjev stranaka zakonit i dopušten i jesu li pravilno poduzete procesne radnje. U početku su se pravosudnim poslovima bavili konzuli, ali je ubrzo pravosudna funkcija prešla na njihove zamjenike pretore koji su postali najvažniji pravosudni organi. Gradski pretor bio je nadležan u sporovima između rimskih građana, a peregrinski u sporovima između rimskih građana i peregrina i sporovima između peregrina. Stranke su se mogle obratiti pretoru samo u one dane koji su po rimskom kalendaru bili predviđeni za suđenje, morale su doći na određeno mjesto na rimskom forumu koje se zvalo “*ius*” i morale su točno izvršiti propisane radnje jer je najmanja greška dovođila do gubitka spora. Postupak pred pretorom obilježava izraziti **formalizam**. **Samopomoć** se ogledala u tome što je tužitelj (*actor*) sam, bez intervencije državnih organa, dovodio tuženika (*reus*) pred pretora. Ta obveza tuženika bila je utvrđena u početnim odredbama Zakonika XII ploča: “*si in ius vocat, ito* (Tab. 1.1: Ako je netko pozvan na sud, neka ide.). Ako tuženik ne bi dragovoljno pošao pred pretora, tužitelj ga je mogao uhvatiti pred svjedocima i silom dovesti. Tužitelj je također sam osiguravao dokaze i najzad sam izvršavao presudu.

Nakon što bi pretor utvrdio da je tužbeni zahtjev zakonit, stranke su iznosile svoje zahtjeve i na kraju postupka *in iure* biran je sudac sa sudačkog popisa (*album iudicum*) kojem je pretor davao ovlast da donese presudu (*iussus iudicandi*). Zbog toga suđenje ima **arbitrarni**, izborni karakter jer je presudu donosio građanin – laik, a ne unaprijed određeni državni organ. Sustav rimskog postupka starijeg razdoblja naziva se *ordo iudiciorum privatorum* (poredak privatnog sudovanja) jer se postupak *apud iudicem* odvijao pred privatnim sucem – laikom (osobom koja nije imala stručnu pravničku naobrazbu).

Svečani završni akt postupka in iure kojim je utvrđivan predmet spora i spor upućivan sucu na presudu naziva se litis contestatio (*lis* – parnica, *contestatio* – osvjedočenje o postojanju parnice) jer je vršen pred svjedocima koji su trebali u postupku *apud iudicem* svjedočiti o čemu se vodi spor i da je izvršena litiskontestacija. **Najvažnije pravne posljedice litiskontestacije su: procesualna konsumpcija i novatio necessaria.**

Konsumptivni učinak litiskontestacije izražen je načelom *ne bis in idem*, što znači da između istih stranaka, povodom istog predmeta i po istoj osnovi nije moguće ponovno voditi spor koji je već jednom doveden do litiskontestacije. Čak i u slučaju da nije donesena presuda u sporu koji je doveden do litiskontestacije, tuženik je svakoj novoj tužbi mogao suprotstaviti prigovor litiskontestacije (*exceptio rei in iudicium deductae*) kojim je odbijana svaka tužba između istih osoba, povodom istog predmeta i po istoj osnovi.

Novacijski učinak litiskontestacije znači da se osnovna obveza zbog koje je pokrenut spor aktom litiskontestacije ugasila, tj. do litiskontestacije tužitelj (vjerovnik) mogao je zahtijevati od tuženika (dužnika) ispunjenje dužne činidbe (*dare, facere, praestare*), nakon litiskontestacije ranija obveza pretvara se u obvezu na donošenje presude (*condemnari oportere*), a nakon izricanja presude gasi se obveza nastala litiskontestacijom i pretvara u obvezu na ispunjenje presude (*iudicatum facere oportere*). Dakle, prije litiskontestacije dužnik duguje iz osnovne obveze (najčešće iz ugovora), aktom litiskontestacije obveza iz ugovora gasi se *ipso iure* i pretvara u obvezu “iz postupka”, a donošenjem presude ta se obveza zamjenjuje obvezom “iz presude” na osnovi koje nad tuženikom može biti provedena ovrha. U svim tim situacijama nužno dolazi do prestanka jedne obveze i njenog pretvaranja u novu obvezu. Zato se takav institut naziva ***novatio necessaria***.

Daljnje važne posljedice litiskontestacije ogledaju se u tome što je dovođila do **pretvaranja vremenskih obveza** (obveza vezanih za rok) u **trajne obveze** na *condemnari oportere*, kao i do **pretvaranja strogo osobnih i nenasljedivih obveza u prenosive i nasljedive** (*perpetuatio iudicii*). Litiskontestacija je bila **odlučujući trenutak** za utvrđivanje potraživanja vjerovnika u pogledu predmeta, vremena, mjesta i pravne osnove. Postojeće stanje odnosa u momentu litiskontestacije, služilo je kao osnova za odluku suda. Bilo kakve promjene koje bi poslije toga nastupile, nisu bile od značaja za donošenje presude u konkretnom slučaju.

Dva dana nakon završenog postupka *in iure* obavljan je **postupak *apud iudicem***: stranke su dolazile pred izabranog suca (*iudex*), čija je zadaća bila provesti glavnu raspravu i utvrditi istinitost činjenica koje su stranke navodile. Zajedno sa strankama dolazili su i svjedoci koji su nazočili prvom dijelu postupka kako bi potvrdili da je izvršena litiskontestacija i izjavili u čemu je suština spora. Ako jedna od stranaka ne bi došla pred suca ugovorenoga dana do podne, donošena je kontumacijska presuda u korist nazočne stranke. U prvoj ploči Zakonika XII ploča propisano je da zalazak sunca treba biti posljednji rok za donošenje presude, iz čega se može zaključiti da su Rimljani poštivali **načelo ekonomičnosti** postupka, nastojeći provesti postupak bez odugovlačenja. Dokazni postupak bio je

neformalan. Bila su dopuštena sva racionalna dokazna sredstva. Sukladno **načelu kontradiktornosti** sudac je morao saslušati obje stranke koje su se izjašnjavale o svim elementima spora. Dokazi su se izvodili neposredno. Kao osnovu odlučivanja sud je mogao uzeti samo ono što je bilo predmet usmenog raspravljanja: *quod est in actis non est in mundo* – ono što je u pismenim podnescima za sud ne postoji. Vrijedila su načela **usmenosti, neposrednosti i javnosti.**

Sukladno **raspravnom načelu** stranke su prezentirale sudu pravno relevantne činjenice: *da mihi facta dabo tibi ius* – sud je bio vezan za činjenice koje mu stranke ponude. Sudac nije mogao narediti izvođenje pojedinih dokaza nego je samo pratio dokaze koje bi izvodile stranke. Također, sudac nije smio odlučivati ni preko ni mimo tužbenog zahtjeva – *ne eat iudex ultra petita partium*. Sudac nije bio vezan nikakvim formalnostima u utvrđivanju dokazne snage pojedinih dokaznih sredstava. Dosljedno su poštivana načela **slobodne ocjene dokaza i materijalne istine:** nakon što bi potpuno i istinito utvrdio sporne činjenice od kojih je zavisila osnovanost tužbenog zahtjeva, sudac je donosio presudu po svom slobodnom uvjerenju kada bi zaključio da su navodi neke od stranaka istiniti i da odgovaraju činjeničnom stanju. U ocjeni izvedenih dokaza sudac nije bio vezan nikakvim dokaznim pravilima. Sučeva zadaća završavala je izricanjem presude (*sententiam dicere*).

Presuda (sententia, iudicium) je kratka neobrazložena svečana sučeva odluka kojom se konačno rješava sporno pitanje među strankama. Presuda je odmah po izricanju postajala pravomoćna i konačna, što znači da protiv presude nije bilo moguće upotrijebiti neko pravno sredstvo (nije bilo redovitog pravnog lijeka, tj. nije postojala mogućnost žalbe). Presuda je imala **konsumptivan učinak**, jednako kao i litiskontestacija: tužitelj koji bi pokrenuo novu tužbu o istoj stvari, protiv istog dužnika i po istoj osnovi bio bi odbijen **prigovorom presuđene stvari (exceptio rei iudicatae)**. Zbog tog prigovora nije se mogao ponovno pokrenuti spor koji je već jednom okončan donošenjem presude (*ne bis in idem*). Vrijedilo je načelo da se presuđena stvar (*res iudicata*) smatra točnom i istinitom (*res iudicata pro veritate accipitur*). Presuda je imala i **novacijski učinak** jer je obveza stranaka na *condemnari oportere*, nastala u litiskontestaciji, prestajala i pretvarala se u obvezu *iudicatum facere oportere*.

Osuđenom je ostavljan rok od 30 dana (*tempus iudicati*, paricijski rok) u kojem je morao ispuniti obvezu koja mu je naložena u presudi (platiti određenu sumu novca, vratiti stvar). Ako to ne bi uradio, tužitelj je imao pravo na postupak prinudne ovrhe (***manus iniectio***) na **dužnikovoj osobi:** odvodio bi dužnika u svoj privatni zatvor, okivao ga i u idućih 60 dana izvodio na forum u tri pazarna dana ne bi li se našao netko tko bi obnovio spor

(*vindex*) ili platio dug. Ako takve osobe nije bilo, osuđeni dužnik prodavan je u ropstvo preko Tibra (jer rimski građanin u Rimu nije mogao postati rob) ili je kažnjavao smrtnom kaznom.

§ 28 – Vrste legisakcija

Legisakcije su na zakonu zasnovane formalistične stroge tužbe starog prava.

Deklaratorne legisakcije (*legis actio sacramento*, *per iudicis postulationem* i *per conductionem*) imale su za cilj utvrditi postoji li neko pravo, tj. riješiti spor osudom. Egzekutorne legisakcije (*legis actio per manus iniunctionem* i *per pignoris capionem*) služile su ovrši.

Legis actio sacramento bila je opća tužba starog prava koja je imala dva oblika: ***legis actio sacramento in rem*** koja je služila za zaštitu stvarnih (najčešće prava vlasništva) i drugih apsolutnih prava (sporovi o nasljedstvu, o slobodi, o očinskoj vlasti) i ***legis actio sacramento in personam*** za zaštitu prava s učinkom *inter partes*, tj. za zaštitu obveznih prava.

Ako se radilo o stvarnopravnoj tužbi, stranke su u postupku *in iure* morale donijeti pred magistrata sporni predmet ili neki njegov dio. Tužitelj bi stavio štap (*vindicta* ili *festuca*) kao simbol koplja, odnosno prisvajanja, na sporni predmet i izgovorio svečanim riječima tvrdnju da je stvar njegova. Taj čin naziva se *vindicatio*. Tuženik, koji je osporavao tužiteljevo pravo, morao je odmah izvršiti kontravindikaciju, tj. ustvrditi da stvar njemu pripada. Nakon toga stranke su polagale određeni iznos oklade (*sacramentum*) koji je, u ovisnosti o vrijednosti predmeta spora, iznosio 500 ili 50 asa (u starije vrijeme 5 volova ili 5 ovnova). Tako visoka suma oklade onemogućavala je siromašne građane u traženju sudske zaštite, a možda je zakonodavac htio na taj način spriječiti nepotrebne sporove ili prinuditi stranke da sporove rješavaju izvansudskim putem. Nakon što bi obje stranke položile okladu, pretor bi odlučio kod koje će se stranke nalaziti stvar do okončanja spora (interimerni posjed – *vindiciae*). Ta stranka morala je imenovati jamce (*praedes litis et vindiciarum*) da će stvar čuvati i predati je protivniku u sporu ako izgubi parnicu. Nakon toga biran je sudac i zaključivana je litiskontestacija. U postupku *apud iudicem* sudac je nakon provedenog postupka određivao čiji je *sacramentum* valjan (*iustum*) i ta bi stranka dobila spor. Jamci su bili obvezni predati predmet ili platiti vrijednost predmeta spora (*aestimatio litis*).

Legis actio per iudicis postulationem primjenjivana je za sporove iz stipulacije i u diobnim parnicama (dioba obiteljske imovine, utvrđivanje međa, dioba suvlasništva). Kod te legisakcije nije polagana oklada i postupak je bio znatno jednostavniji. Ukoliko bi tuženik

poricao postojanje duga, pretor bi, na tužiteljev zahtjev, odmah imenovao suca, nakon čega bi bila zaključivana litiskontestacija.

Legis actio per condictionem uvedena je sredinom III. st. p.n.e. radi davanja pravne zaštite novonastalim obvezama, koje nisu bile utužive putem prethodnih legisakcija (jer je tužitelj kod *legis actio sacramento* i *per iudicis postulationem* morao navesti pravnu osnovu potraživanja i dokazati da se ono zasniva na pravnom odnosu priznatom po civilnom pravu). Zahvaljujući legisakciji *per condictionem* dobio je pravnu zaštitu zajam koji je zaključen na neformalan način. Kasnije je ta legisakcija primjenjivana ne samo za obveze koje su glasile na određenu sumu novca (*certa credita pecunia*) već i na obveze koje su glasile na određenu stvar (*certa res*).

Legis actio per manus iniunctionem je najstariji ovršni postupak. Zbog teških posljedica osobne ovrhe ta je legisakcija ukinuta u drugoj polovici IV. st. p.n.e. Petelijevim zakonom (*lex Poetelia Papiria*), a osobna ovrha zamijenjena je imovinskom.

Legis actio per pignoris capionem služila je za imovinsku ovrhu. Mogla se primijeniti samo u iznimnim slučajevima za posebne vrste potraživanja kada je vjerovniku bilo dopušteno da bez intervencije pretora zaplijeni neku dužnikovu stvar i zadrži je kao zalog dok mu ne bude vraćen dug.

Da bi se izbjegle nezgodne posljedice plaćanja okladne sume pri stvarnopravnim sporovima, uveden je **postupak per sponsionem**. Stranke bi zaključile stipulaciju kojom se tuženik obvezivao da će tužitelju platiti određenu sumu novca ako se dokaže da stvar nije njegova. Na osnovi te stipulacije tužitelj je mogao upotrijebiti legisakciju *per iudicis postulationem* i tako izbjeći skupu okladu. Taj način suđenja zvao se *per sponsionem* jer je *sponsio* najstariji oblik stipulacije.

§ 29 - Formularni postupak

Zbog velike strogosti i formalizma legisakcijski postupak postao je nepodesan u drugoj polovici razdoblja Republike. Sve složeniji pravni i gospodarski promet, veliki broj novih ustanova koje su tražile pravnu zaštitu, učestalost sporova, porast nelatinskog pučanstva, kao i interes ojačale države za većom ulogom pretora u postupku bili su razlozi zbog kojih je u II. stoljeću p.n.e. s *lex Aebutia* uveden novi postupak, koji je od Augusta postao obavezan za sve sporove. Velike zasluge za nastanak formularnog postupka imao je peregrinski pretor koji je pri suđenju sporova primjenjivao načelo *bonae fidei* dopuštajući

strankama da u slobodnom govoru iznesu sve činjenice koje su pratile zaključenje spornog odnosa. Otuda je osnovno obilježje ovog postupka bila **neformalnost**. Bitna novost bila je i **izmijenjena uloga pretora koji je stvarajući formulu aktivno stvarao nove pravne odnose i kvalifikacije i time osiguravao razvitak rimskog prava u skladu s društvenim potrebama**. Novi je postupak ipak zadržao i neke karakteristike starog: organi formularnog postupka bili su gotovo isti kao i organi legisakcijskog postupka; država i dalje ne poziva na suđenje, ne donosi presudu niti brine za ovrhu; i dalje postoji dvodioba postupka; presudu donosi sudac kojeg biraju stranke.

U postupku ***in iure*** tužitelj je slobodno, ne upotrebljavajući nikakve svečane riječi ni geste, iznosio tužbeni zahtjev. Spor je mogao završiti već u tom dijelu postupka ako bi tuženik izvršio tužiteljev zahtjev, ako bi priznao opravdanost zahtjeva, ako bi šutio ili se loše branio, ili ako ne bi htio prihvatiti formulu (*confessus et indefensus pro iudicato est*: tko prizna ili se ne brani, smatra se osuđenim). Ako bi tuženik osporio opravdanost tužiteljeva zahtjeva, pretor je trebao odlučiti hoće li tužitelju priznati ili odbiti pravo na tužbu. Uskratio bi pravo na tužbu (***denegatio actionis***) ako tužbeni zahtjev nije bio zasnovan na zakonskim propisima ili na propisima edikta magistrata ili ako bi se protivio načelima dobre vjere (*bona fides*) i pravičnosti (*aequitas*). Nakon što bi odobrio tužbu, pretor je sastavljao kratku pismenu bilješku koja je sadržavala pravnu kvalifikaciju spora i podatke o čemu se spor vodi, ime suca, tužiteljev zahtjev, moguće prigovore tuženika i replike tužitelja, kao i ovlasti koje je sudac dobijao. **Ta kratka zabilješka, sastavljana na kraju postupka *in iure*, nazivala se formula**. Magistrat je formulu predavao tužitelju, a tužitelj tuženiku. Tim činom bila bi izvršena **litiskontestacija**. Litiskontestacija je dobila značaj formalnog procesnog ugovora jer su se stranke, uz sudjelovanje pretora, sporazumijevale da će njihov spor riješiti izabrani sudac. Na temelju formule, pomoću koje je izvršena litiskontestacija, pretor je davao nalog sucu (*iussum iudicandi*) da donese presudu držeći se upute u formuli. Time je završavao postupak *in iure*, nakon čega je mogao započeti drugi dio postupka - *apud iudicem*, tj. počinjala bi teći parnica.

Postupak pred izabranim sucem – ***apud iudicem*** bio je u osnovi isti kao i legisakcijski. Dokaze su izvodile same stranke. Tužitelj je morao dokazati ono što je tvrdio (*actori incumbit probatio*). Isto je vrijedilo i za tuženika ako bi iznio neki prigovor (*in excipiendo reus fit actor*: prigovor dokazuje tuženik). Sučeva zadaća bila je ispitati točnost činjeničnih navoda stranaka i poštujući načela materijalne istine i slobodnog uvjerenja, do kojeg je dolazio nakon usmenog, javnog, neposrednog i kontradiktornog dokaznog postupka, donijeti presudu. Presuda je odmah po izricanju postajala pravomoćna jer ni u formularnom

postupku nije postojala mogućnost žalbe. Bila je nepromjenljiva (formalna pravomoćnost) i svojim je sadržajem stvarala pravo među strankama (materijalna pravomoćnost). Svaka presuda u formularnom postupku glasila je na određeni iznos novca (*condemnatio pecuniaria*). Ako je tužbeni zahtjev glasio na određenu stvar (*certam rem*), tuženik je mogao prije donošenja presude predati stvar (*clausula arbitraria*).

Osuđenom je ostavljan paricijski rok (*tempus iudicati*) od 30 dana da izvrši obvezu koja mu je u presudi naložena. Ako to ne bi uradio, presuda je postajala ovršna i vjerovnik je mogao tražiti prinudnu ovrhu putem *actio iudicati* (tužba na osnovi presude). Magistrat bi dosuđivao dužnika vjerovniku da bude u njegovom privatnom zatvoru dok ne odradi dug ili dok netko drugi za njega ne plati. Kasnije je osobna ovrha zamijenjena imovinskom: vjerovniku je predavana cjelokupna dužnikova imovina (*missio in bona*) koja je prodavana putem javnog nadmetanja (*venditio bonorum*). Taj način ovrhe ublažen je uvođenjem instituta *distractio bonorum* – prodaje pojedinih dužnikovih stvari do iznosa dugova.

§ 30 – Formula

Formula je kratka pismena zabilješka koju je sastavljao pretor pred kraj postupka *in iure*. Sadržavala je bitne elemente spora i uputu sucu kako će donijeti presudu s obzirom na rezultat dokaznog postupka. Za formulu se često koristio naziv “*iudicium*”, a kasnije i “*actio*”. U početku razvitka formularnog postupka sastavljana je posebna formula za svaki konkretni spor. Vremenom je formula postala pismeni tipizirani akt, tako da je za svaku vrstu spora postojao poseban obrazac koji je pretor popunjavao specifičnim elementima konkretnog spora (npr. formula iz kupoprodaje, iz najma, iz posudbe itd.). Spisak formula (*album*) bio je izložen na forumu i obnavljan je svake godine u skladu s promijenjenim uvjetima i potrebama stranaka. Svaka nova formula stvarala je novu tužbu (*actio*), a svaka *actio* imala je svoju formulu (npr. ediktalna formula za tužbu o vlasništvu, ediktalna formula za prodavateljevu tužbu iz kupoprodajne pogodbe itd.). Svakom materijalnopравnom zahtjevu, tj. pravu odgovarala je njegova formula odnosno akcija.

Svaka formula imala je **obvezne (nužne, bitne) dijelove**. To su: *intentio*, *demonstratio*, *condemnatio* i *adiudicatio*. Formula je započinjala imenovanjem suca (*iudicis nominatio*) kojem je formula upućivana (*Titius iudex esto*).

Intentio je dio formule koji je sadržavao tužbeni zahtjev. To je bio temeljni dio svake formule. Tužiteljev zahtjev mogao je biti određen (*intentio certa*), npr. kada je tuženik dugovao određenu sumu novca ili određenu stvar, a mogao je biti i neodređen (*intentio*

incerta) kada je ostavljano sucu da sam procijeni na koliki iznos će osuditi. Za oznaku tužitelja korištena je skraćenica *A.A.* (*Aulus Agerius*, od *agere* – tužiti), a za tuženika *N.N.* (*Numerius Negidius*, od *numerare* – odbrojati, isplatiti i *negare* – poricati: onaj koji poriče da mu je isplaćeno).

Neke formule sadržavale su uz imenovanje suca samo intenciju. To su prejudicijski tužbeni zahtjevi (***intentiones praeiudiciales***), kod kojih se radi o pitanju bez čijeg prethodnog rješenja nije moguće donijeti odluku u nekom drugom, glavnom sporu. Naime, ponekad odlučivanje o osnovanosti tužbenog zahtjeva može zavisiti od odgovora na pitanje, postoji li ili ne postoji određena činjenica, pravo ili pravni odnos koji nije predmet spora, ali posredno utječe na odlučivanje o predmetu spora. Zbog toga je ***praeiudicium*** (prethodno pitanje, prethodno suđenje, prethodna odluka) u funkciji odlučivanja o tužbenom zahtjevu u glavnom sporu (npr. zahtjev za isplatu kamata zavisi od rješenja prejudicijskog pitanja, postoji li glavna obveza iz koje kamate izvire; zahtjev za isplatu zakupnine zavisi od rješenja prejudicijskog pitanja, postoji li ugovor o zakupu).

Demonstratio je dio formule u kojem je pobliže pojašnjavao predmet spora kod obveznih tužbi s *intentio incerta* (u tužbama s neodređenim zahtjevima). Navode se pravni i činjenični fakti koji mogu poslužiti sucu da točno utvrdi tužiteljev zahtjev. Mogla je biti navedena pravna osnova (*causa*) iz koje proizlazi tužiteljev zahtjev (npr. ugovor o kupoprodaji, ugovor o ostavi) i ta je formula *in ius concepta*, a moglo je biti samo opisano činjenično stanje (npr. kod inominatnih kontrakata), i ta je formula bila *in factum concepta*.

Condemnatio je nalog sucu da u skladu s rezultatima dokaznog postupka oslobodi ili osudi tuženika. Ako se radilo o tužbi na određeni iznos (*actio certa*), tuženik je osuđivan na taj iznos, a ako se radilo o tužbi na neodređeni iznos (*actio incerta*), sudac je imao ovlasti sam procijeniti na koliki će iznos osuditi tuženika. U svakom slučaju presuda je glasila na određeni iznos novca (*condemnatio pecuniaria*).

Adiudicatio je dio formule u diobnim tužbama. Javljala se umjesto kondemnacije i predstavljala je sučevu ovlast da razriješi suvlasničke odnose (podjela konzorcija, razgraničenje međa, dioba suvlasništva).

Neobvezni (izvanredni, nebitni) dijelovi formule služili su za ograničavanje ili otklanjanje tužbenog zahtjeva. Uvrštavani su u formulu na zahtjev zainteresiranih osoba. To su *praescriptiones* i *exceptiones*. ***Praescriptio*** je stavljana na početak formule i sudac se trebao uvjeriti u njezinu ispravnost prije započinjanja glavne rasprave. *Praescriptio pro actore* umetana je u formulu na zahtjev i u korist tužitelja. Tom je preskripcijom u tzv. sukcesivnim obvezama naglašavano da se spor vodi samo za dospelje dugove (npr. kamata na

novac, zakupnina za zemlju), čime je izbjegavan konsumptivni učinak litiskontestacije za nedospjela potraživanja, kao i negativne posljedice tzv. *plus petitio* (smatralo bi se da tužitelj traži više nego što mu pripada ako bi utužio i nedospjela potraživanja). *Praescriptio pro reo* uvrštavana je u formulu u korist tuženika, a sadržavala je uglavnom prigovore, pa je kasnije izjednačena s *exceptio*.

Exceptiones ili prigovori su činjenice na koje se tuženik pozivao i koje su činile tužbeni zahtjev neopravdanim premda je on možda uistinu postojao. Ukoliko se tužitelj ne bi suglasio s prigovorom, mogao je iznijeti prigovor na tuženikov prigovor koji se naziva *replicatio*. Na replikaciju je tuženik mogao istaći *duplicatio* (prigovor na repliku, *exceptio replicationis*).

§ 31 – Ekstraordinarni postupak (*extraordinaria cognitio*)

Centralizam i birokratizam rimske države razdoblja Dominata uvjetovao je ukidanje ranijih formi zaštite subjektivnih prava i konstituiranje **potpuno podržavljenog postupka**. Već u razdoblju Principata stranke su se u nekim slučajevima mogle neposredno obratiti vladaru radi zaštite svojih prava. Kako se to sve češće događalo, princeps je svom činovničkom aparatu prepuštao rješavanje tih parnica. Tako je pored redovitog formularnog postupka uveden novi, izvanredni (*extra ordinem*) postupak. Taj je postupak od vremena Dioklecijana postao jedinim obveznim postupkom. Sve procesne radnje obavljane su pred državnim činovnicima u zatvorenom prostoru bez nazočnosti javnosti. Suci su od stranaka bili odijeljeni zavjesama i rešetkama. Nema više dvodiobe postupka na *in iure* i *apud iudicem*. Napuštena je usmenost i kontradiktornost postupka jer se gotovo sve radnje vrše pismenim putem. Zbog skupog i glomaznog birokratskog aparata znatno su povećani troškovi suđenja pa je za svaku radnju u postupku trebalo platiti unaprijed predviđenu pristojbu.

Ekstraordinarni postupak započinjao je tako što je tužitelj podnosio pismenu tužbu sudu ili bi je izložio u sudski zapisnik. Sud je tužbu dostavljao tuženiku obvezujući ga da na nju odgovori i da se pojavi na raspravi. Ako jedna od stranaka ne bi došla pred suca, sudac je nakon tri odlaganja mogao provesti postupak i donijeti presudu. Takva je presuda postajala odmah ovršna jer stranka koja se nije pojavila na raspravi nije imala pravo žalbe (*contumax non appellat*). Nakon što bi utvrdio svoju stvarnu i mjesnu nadležnost, sudac je proglašavao da je postupak počeo. Taj trenutak nazivao se ***litis contestatio***. Litiskontestacija u ekstraordinarnom postupku nije imala ni konsumptivni ni novacijski učinak.

Stvarna nadležnost suda, tj. pitanje koja vrsta suda ima pravo i obvezu riješiti određeni spor rješavano je s obzirom na vrstu i visinu pravnog zahtjeva i s obzirom na stranke u sporu. Sporove manje vrijednosti rješavali su niži sudovi (*iudices pedanei*), a za sporove vrijednosti veće od 300 zlatnih solida bili su nadležni upravitelji provincija i gradski prefekti. Najviši sudski organ bio je car, odnosno prefekt pretorijanske garde (*praefectus praetorio*) koji je sudio u carevo ime. Postojali su i sudovi s posebnom stvarnom nadležnošću: vojni, crkveni, financijski.

Mjesna nadležnost suda, tj. pitanje koji je od više istovrsnih sudova nadležan presuditi određeni spor, mogla je biti određena voljom stranaka (*forum prorogatum*); ukoliko se stranke nisu sporazumjele, mjesna nadležnost suda određivana je prema domicilu tuženika (*actor sequitur forum rei*), a u pojedinim slučajevima mogli su biti mjesno nadležni drugi sudovi, npr.: u sporovima o nekretninama, mjesno nadležan bio je sud mjesta gdje se nekretnina nalazila (*forum rei sitae*); ili sud mjesta gdje je trebalo izvršiti ugovor (*forum adimpleti contractus*); kada se radilo o deliktima mjesno nadležan sud bio je sud mjesta gdje je delikt počinjen (*forum delicti commissi*).

Nakon izvršene litiskontestacije započinjao je **dokazni postupak** u kojem su bila dopuštena sva dokazna sredstva. Sudac je bio ovlašten zahtijevati i druge dokaze osim onih koje su stranke iznijele. Raspravno načelo potiskuje se **inkvizitornim (istražnim) načelom**, a načelo kontradiktornosti zamjenjuje se pismenim podnescima (načelima posrednosti, pismenosti i tajnosti). Zbog velike korupcije u pravosuđu napuštena su načela materijalne istine i slobodnog sudačkog uvjerenja. Carevi su donijeli pravila o ocjeni dokazne vrijednosti pojedinih dokaznih sredstava po kojima je sudac, bez obzira na svoje uvjerenje, morao smatrati nešto dokazanim ili nedokazanim (tzv. **teorija formalnih dokaza**, odnosno **načelo legalne ocjene dokaza**). Svjedočenje samo jednog svjedoka nije smio uzeti u obzir (*testis unus testis nullus* – jedan svjedok kao nijedan), javna isprava imala je prednost pred privatnom, kao i izjava svjedoka koji je pripadao višem društvenom položaju; morao je vjerovati suglasnim izjavama dvojice ili više svjedoka; zakletva stranaka imala je veliku dokaznu snagu.

Nakon završenog dokaznog postupka sudac je morao donijeti presudu najkasnije u roku od tri godine od započinjanja postupka. **Presuda (sententia)** morala je biti u pisanom obliku i sadržavati obrazloženje u kojem je sudac iznosio osnovne razloge koji su ga rukovodili u donošenju presude. Presuda više nije morala uvijek glasiti na određenu sumu novca. Ako se radilo o potraživanju točno određene stvari, mogla je glasiti na samu stvar (*ad ipsam rem*).

U ekstraordinarnom postupku stranke su dobile **pravo žalbe (*appellatio*)** hijerarhijski višem organu (izuzev za presudu koju bi donio car ili *praefectus praetorio*). Po proteku paricijskog roka od četiri mjeseca u kojem je dužnik trebao dragovoljno izvršiti obvezu iz presude, tužitelj je bio ovlašten zahtijevati ovrhu sudskim putem s *actio iudicati*. Odluka suda kojom je odobravana ovrha predstavljala je ovršni naslov (*titulus executionis*) i bila je obvezna za državne ovršne organe (*executores*). **Ovrha** se mogla obaviti oduzimanjem stvari silom (*manu militari*) kada je presuda glasila na predaju određene stvari, ili zaplijenom i prodajom pojedinih dužnikovih stvari ako je presuda glasila na određenu sumu novca. Insolventnom dužniku mogla je biti zaplijenjena cjelokupna imovina, a ako i nakon njezine prodaje vjerovnici ne bi bili namireni, insolventni dužnik mogao je biti upućen u javni zatvor.

Drugo poglavlje

Sredstva za zaštitu subjektivnih prava

§ 32 – Tužba (pojam i vrste)

Tužba je sredstvo za zaštitu subjektivnog interesa. Bez tužbe nema parnice (*Nemo iudex sine actore*). Tužba je parnična radnja kojom tužitelj zahtijeva pružanje pravne zaštite određenog sadržaja. Tužitelj traži pravnu zaštitu od suda s obzirom na tuženika za koga tvrdi da se prema njemu nalazi u određenoj građanskopravnoj obvezi koju neće dragovoljno da ispuni. Rimski pravnik *Celsus* definirao je **tužbu (*actio*) kao pravo da sudskim putem zahtijevamo ono što nam pripada** (D.44.7.51).

1. Osnovna podjela tužbi u vrijeme formularnog postupka bila je na ***actiones civiles*** i ***actiones honorariae***.

Civilne tužbe (*actiones civiles*) su tužbe koje su ustanovljene Zakonikom XII ploča i kasnije donesenim zakonima. Tužbeni zahtjev zasnovan je na propisima civilnog prava. Te tužbe bile su *in ius conceptae*.

Pretorske ili honorarne tužbe (*actiones honorariae*) ustanovljene su pretorskim ediktom ili ediktom kurulskih edila. Bilo je četiri vrste honorarnih tužbi: *actiones utiles*, *actiones ficticiae*, *actiones in factum* i *actiones per transpositionem*.

Actiones utiles su proširene civilne tužbe koje je pretor po analogiji iz razloga korisnosti (*utilis causa*) primjenjivao i na slične slučajeve premda za njih nisu bile predviđene. Tužbe koje su im služile kao uzor nazivale su se ***actiones directae***.

Actiones ficticiae su tužbe kod kojih je magistrat nalagao sucu da smatra kao da postoji neki važan element, koji uistinu nije postojao i zbog čega nije bila moguća primjena civilne tužbe (npr. kod *actio Publiciana* fingiralo se da je protekao rok dosjeloosti premda uistinu nije protekao).

Actiones in factum su tužbe koje je pretor dopuštao već na osnovi neke činjenice, ne pozivajući se na civilno pravo. Zato su te tužbe *in factum conceptae*. Mogle su se upotrijebiti u svim slučajevima kada je na osnovi nekog faktičnog odnosa, koji nije bio priznat po civilnom pravu, jedna od stranaka izvršila svoju činidbu (npr. kod inominatnih kontrakata). To je najvažnija skupina pretorskih tužbi jer ih je pretor davao u svim slučajevima kada su načela poštenja i povjerenja (*bona fides*) i pravičnosti (*aequitas*) nalagali da se pruži pravna zaštita određenom odnosu koji nije bio predviđen po civilnom pravu.

Actiones per transpositionem (tužbe s promijenjenim subjektima) su tužbe kod kojih se u intenciji pojavljivala jedna osoba, a u kondemnaciji druga. Tim tužbama izbjegnuta je stroga primjena načela da nitko ne može u tuđe ime pokrenuti sudski postupak (*Nemo alieno nomine lege agere potest*), omogućeno je zastupanje u postupku i promjena subjekata u obveznom odnosu.

2. **Actiones in rem – actiones in personam**. Jedna od osnovnih podjela tužbi u rimskom pravu bila je na *actiones in rem* i *actiones in personam*. **Actiones in rem** su tužbe kojima su bila zaštićena apsolutna prava (npr. pravo vlasništva) i mogle su se podići protiv svakoga. **Actiones in personam** su tužbe kojima su bila zaštićena obvezna (relativna) prava i mogle su se podići samo protiv određene osobe.

3. **Actiones stricti iuris – actiones bonae fidei**. **Actiones stricti iuris** su tužbe za zaštitu formalističnih apstraktnih kontrakata starog civilnog prava. Sudac je samo trebao utvrditi je li pravni posao zaključen u propisanoj formi i koliko je potraživanje vjerovnika, a nije vodio računa zbog čega dužnik duguje i jesu li stranke pravnim poslom postigle cilj (*causa*) zbog kojeg su ga zaključile. **Actiones bonae fidei** su tužbe kojima su zaštićeni obvezni odnosi zasnovani na načelima dobre vjere (*bona fides*) i pravičnosti (*aequitas*). Sudac je kod presude povodom takvih odnosa morao ispitati sve okolnosti koje su pratile zaključenje pravnog posla: što su stranke htjele postići stupanjem u obvezni odnos, kakvi su bili njihovi međusobni odnosi, je li u konkretnom slučaju postignuta *causa* (pravni i ekonomski cilj) zaključene obveze, da nije bilo prijevarnih ili prinudnih radnji, da nije bilo bludnje, postoje li neki sporedni sporazumi itd.

4. **Actiones poenales – actiones reipersecutoriae – actiones mixtae**. **Actiones poenales** su tužbe koje su imale kazneni karakter jer je putem njih tužitelj zahtijevao od

dužnika isplatu kazne zbog učinjenog delikta. Glasile su na dvostruki, trostruki ili četverostruki iznos vrijednosti stvari. Mogle su se upotrijebiti u određenom vremenskom razdoblju (najčešće od jedne godine), nakon čega su gubile penalni i dobijale reipersekutorni karakter. ***Actiones rei persecutoriae*** su tužbe kojima se tražilo vraćanje stvari, odnosno njezina jednostruka vrijednost. ***Actiones mixtae*** su tužbe kojima se tražila i stvar (odnosno njezina vrijednost) i kazna.

5. **Actiones privatae – actiones populares.** ***Actiones privatae*** služile su za zaštitu privatnih interesa, tj. mogle su ih podići samo one osobe koje su zahtijevale zaštitu vlastitih subjektivnih prava. ***Actiones populares*** su tužbe koje je mogao podići svaki građanin radi zaštite javnih interesa, bez obzira na svoj neposredni osobni interes.

6. **Actiones perpetuae – actiones temporales.** ***Actiones perpetuae*** su vremenski neograničene tužbe. To su bile civilne tužbe jer *ius civile* nije predviđalo rokove u kojima je trebalo podići tužbu. ***Actiones temporales*** su tužbe koje su ograničene na određeni rok. To su bile tužbe koje su nastale na osnovi honorarnog prava jer su pretori predviđali stroge (prekluzivne) rokove u kojima je trebalo podići tužbu. Protekom prekluzivnog roka u kojem je trebalo podići tužbu za zaštitu povrijeđenog prava, gasilo se i samo pravo.

§ 33 – Izvanredna sredstva za zaštitu subjektivnih prava (*condictio, querella, interdictum, restitutio in integrum, exceptio*)

Izvanredna pravna sredstva za zaštitu subjektivnih prava uvedena su kada se pokazalo da tužbe (*actiones*) nisu dovoljne za zaštitu svih legitimnih interesa, te da ih treba upotpuniti, poboljšati ili otkloniti njihove nedostatke novim pravnim sredstvima, među kojima su najznačajnija: *condictio, querella, interdictum, restitutio in integrum, exceptio*.

Condictio je tužba koja je nastala iz legisakcije *per conductionem*. Služila je za vraćanje stvari koja bi se našla u tuđoj imovini bez pravne osnove u slučajevima kada tužitelj to vraćanje nije mogao postići nijednom postojećom tužbom jer se njegov zahtjev nije zasnivao na valjanom pravnom poslu ili deliktu za koji su bile predviđene posebne tužbe. Kondikcije su bile apstraktne tužbe jer nije navođen pravni razlog spora kod potraživanja na *certum* (određene stvari ili određene sume novca). U razdoblju klasičnog prava služile su za ostvarivanje tužbenih zahtjeva iz literalnih kontrakata, stipulacije i zajma, a kasnije je njihova primjena proširena i na *incertum* (neodređene zahtjeve). Posebno su značajne za institut bezrazložnog obogaćenja (*condictiones sine causa*).

Querella je pretorsko sredstvo čiji je cilj utvrditi postojanje ili nepostojanje neke pravno relevantne činjenice, a nema za cilj dokazivanje nekog prava (npr. *querella inofficiosi testamenti* utvrđuje da je oporuka nevažeća).

Interdictum je kratki nalog ili zabrana koji je izdavao pretor na zahtjev jedne stranke bez prethodnog postupka i ispitivanja dokaza u cilju zaštite postojećih faktičnih odnosa. **Interdiktom se ne rješava pitanje tko ima neko pravo nego je cilj interdikta jedino ponovno uspostavljanje narušenog faktičnog odnosa. Bilo je važno spriječiti svojevršno ostvarivanje prava i zaštititi javni red i mir od samosile, smetnji i nasrtaja.** Zbog toga je postupak izdavanja interdikta brz i ekonomičan. Interdikti se izdaju u uvjetnom i apstraktnom obliku, pod određenim pretpostavkama, jer pretor nije provjeravao istinitost činjenica koje je navodio tražitelj interdikta. Ako stranka ili stranke ne izvrše zapovijed ili zabranu iz interdikta, nadovezuje se na interdikt redovita parnica u kojoj je trebalo riješiti sporno pitanje. Kako je ta parnica bila vrlo skupa i komplicirana, stranka na koju se interdikt odnosio ipak bi se najčešće pokorila zapovijedi iz interdikta.

S obzirom na različite svrhe za koje su korišteni, interdikti se mogu podijeliti na više skupina. Ako je interdiktima trebalo zasnovati, očuvati ili uspostaviti raniji odnos, dijeljeni su na *interdicta prohibitoria*, *restitutoria* i *exhibitoria*. ***Interdicta prohibitoria*** zabranjivali su nasilne promjene postojećih odnosa između određenih osoba. ***Interdicta restitutoria*** imali su za cilj uspostavljanje ranijeg stanja ako je ono bilo poremećeno protupравnim putem. ***Interdicta exhibitoria*** naređivala su zasnivanje novih odnosa ako je za to postojao odgovarajući pravni razlog.

U zavisnosti od toga je li interdikt upućen samo jednoj ili objema strankama, interdikti se dijele na *interdicta simplicia* i *interdicta duplicia*. ***Interdicta simplicia*** naređuju ili zabranjuju određeno ponašanje samo jednoj stranci. Za razliku od njih, ***interdicta duplicia*** zabranjuju objema strankama narušavanje postojećih odnosa.

Interdikti su najčešće primjenjivani u svrhu posjedovne zaštite. ***Interdicta adipiscendae possessionis*** imali su za cilj stjecanje posjeda. Ovim je interdiktima naređivano dosadašnjem posjedniku da posjed stvari prenese na novog posjednika. ***Interdicta retinendae possessionis*** izdavani su radi otklanjanja smetanja posjeda. Pretor je naređivao da posjedovni odnosi među strankama moraju ostati onakvi kakvi su bili u momentu traženja interdikta. ***Interdicta recuperandae possessionis*** služili su za vraćanje izgubljenog posjeda. Putem tih interdikata naređivano je uspostavljanje onakvog posjedovnog stanja kakvo je bilo prije traženja interdikta.

Restitutio in integrum (povrat u prijašnje stanje) je izvanredno sredstvo kojim je pretor poništavao učinak pravnih akata koji su bili valjani po civilnom pravu, ali su se protivili načelima dobre vjere i pravičnosti: *restitutio in integrum ob etatem* (zbog uzrasta – minor je bez skrbnika zaključio štetan pravni posao); *r. in integrum ob absentiam* (stranka nije ostvarila svoje pravo zbog opravdane odsutnosti ili spriječenosti); *r. in integrum ob dolum* (stranka je pretrpjela štetu jer je zaključila posao pod utjecajem prijevare); *r. in integrum ob metum* (posao je zaključen pod prinudom). Stranke su bile obvezne uspostaviti stanje kakvo je bilo prije poduzimanja pravnog akta jer se polazilo od fikcije da takav akt nije ni postojao.

Exceptio (prigovor) su činjenice i okolnosti koje ističe tuženik suprotstavljajući se tužiteljevu zahtjevu zbog kojih će tužba, u potpunosti ili djelomično, privremeno ili trajno, biti odbijena. Postoji više vrsta prigovora koji se mogu podijeliti na nekoliko skupina.

Exceptiones civiles – exceptiones honorariae. *Exceptiones civiles* su prigovori koji su imali osnovu u civilnom pravu (npr. *exceptio legis Plaetoriae*; *exceptio senatus consulti Macedoniani*). *Exceptiones honorariae* su prigovori koji su nastali zahvaljujući pretorovoj djelatnosti. Tim je prigovorima pretor ograničavao ili sprečavao učinak poslova valjanih po civilnom pravu kada su to nalagali razlozi pravičnosti (npr. *exceptio doli*; *exceptio rei venditae ac traditae*; *exceptio quod metus causa*).

Exceptiones peremptoriae – exceptiones dilatoriae. *Exceptiones peremptoriae* (ili *exceptiones perpetuae*) su prigovori koji su zauvijek odbijali tužbeni zahtjev (npr. *exceptio pacti de non petendo in perpetuum*). *Exceptiones dilatoriae* (ili *exceptiones temporales*) su prigovori koji su štitili tuženika samo privremeno, kroz određeno vrijeme (npr. *exceptio pacti de non petendo ad tempus*).

Exceptiones in rem – exceptiones in personam. *Exceptiones in rem* su prigovori koji su se mogli upotrijebiti protiv svake osobe koja iz određenog pravnog odnosa podiže tužbeni zahtjev (npr. *exceptio quod metus causa* djeluje prema svakome tko bi tužio na temelju strahom iznudenog posla, bez obzira je li on sam taj posao iznudio ili netko drugi). *Exceptiones in personam* su prigovori koji se mogu suprotstaviti samo točno određenoj osobi (npr. *exceptio doli* – prigovor prijevare imao je učinak samo protiv onoga tko je izvršio prijevaru)

Exceptiones personae cohaerentes – exceptiones rei cohaerentes. *Exceptiones personae cohaerentes* su prigovori kojima se mogla poslužiti samo točno određena osoba (npr. *exceptio pacti de non petendo in personam*). *Exceptiones rei cohaerentes* su prigovori

koje mogu upotrijebiti sve osobe koje se nađu u određenom pravnom odnosu povodom neke stvari (npr. *exceptio pacti de non petendo in rem* mogao je upotrijebiti i glavni dužnik i jamci).

ČETVRTI DIO

STVARNO PRAVO

Prvo poglavlje

OSNOVE STVARNIH PRAVA

§ 34 – Pojam i karakteristike stvarnih prava (razlike između stvarnopravnog i obveznog odnosa)

Stvarno pravo zajedno s obveznim i nasljednim pravom spada u skupinu pravnih pravila kojima se uređuju imovinski odnosi među ljudima (*ius quod ad res pertinet* – imovinsko pravo).

Stvarno pravo (u objektivnom smislu) je skup pravnih pravila kojima se uređuju odnosi koji nastaju među ljudima povodom stvari.

Stvarno pravo (u subjektivnom smislu) su različite ovlasti glede stvari koje subjektima u stvarnopravnim odnosima priznaju norme objektivnog prava.

Rimski pravници nisu dali pojam stvarnog prava, ali iz njihovih tekstova je očito da su dijelili stvarna od obveznih prava određujući tu razliku s procesualnog stanovišta: **za zaštitu stvarnih prava** predviđene su *actiones in rem*, a za zaštitu **obveznih prava** *actiones in personam*.

Osnovne značajke stvarnih prava su: učinak *inter vivos*, stvarnopravnost, apsolutnost, obveza na pasivnost, trajnost, vezanost za stvar, ograničenost broja.

Stvarna i obvezna prava služe za uređivanje imovinskih odnosa za vrijeme života subjekata prava, što znači da imaju **učinak *inter vivos***. Pravila nasljednog prava imaju **učinak *mortis causa*** jer uređuju imovinskopravne odnose za slučaj smrti.

Stvarnopravni odnos je odnos između ljudi povodom stvari. Objekt stvarnopravnog odnosa je stvar, iz čega proistječe **stvarnopravnost** kao bitna značajka stvarnog prava. Za razliku od stvarnopravnog odnosa, objekt obveznopravnog odnosa je uvijek dužnikova činidba koju se određeni dužnik obvezuje izvršiti određenom vjerovniku.

Osnovni smisao djelovanja tužbe *in rem* je u tome što titular stvarnog prava može podići tužbu protiv bilo koje osobe koja ga neovlašteno onemogućiti ili ograničiti u vršenju stvarnopravnih ovlasti. To znači da su stvarna prava **apsolutna** jer djeluju **prema svakome**

(*erga omnes*). Obvezno pravo je relativno jer djeluje samo između stranaka (*inter partes*) koje se nalaze u određenom obveznom pravnom odnosu.

Stvarna prava stvaraju **obvezu na pasivnost** kod svih drugih osoba naređujući im da ne poduzimaju nikakve radnje kojima bi omeli ovlaštenika stvarnog prava. Dok stvarna prava sadrže **negativan zahtjev prema trećima**, sadržaj obveznog odnosa određen je pozitivno jer obvezna prava stvaraju obvezu za dužnika na izvršenje činidbe.

Stvarno pravo je u pravilu **trajno** jer promatra subjekte kao uživatelje prava. Obvezna prava su vremenita jer uglavnom kratko traju. Obveze nastaju u procesu razmjene dobara i usluga koji treba biti što brži i efikasniji.

Stvarno pravo je **vezano za stvar i prati stvar bez obzira kod koga se ona nalazi – načelo slijedenja** (npr. vlasništvo kao stvarno pravo prati stvar bez obzira što je ona ukradena; založno pravo prati stvar i u slučaju kada je vlasnik proda; titular prava služnosti puta i dalje ima pravo prelaziti preko tuđe livade premda je promijenjen vlasnik livade, itd.)

Broj stvarnih prava u svakom pravnom sustavu je **ograničen** (*numerus clausus*). Stranke ne mogu svojom voljom stvoriti neko novo stvarno pravo, niti mogu nekom pravu poreći stvarnopravni karakter. U rimskom pravu bilo je **pet stvarnih prava: vlasništvo, služnosti, emfiteuza, superficies i založno pravo**. **Vlasništvo** je najvažniji institut ne samo stvarnog prava nego i cijelog pravnog sustava. To je sadržajem najopsežnije stvarno pravo (*plena in re potestas*) na temelju kojeg se titular može neograničeno služiti sa stvari i njome raspolagati. Posebnu skupinu stvarnih prava čine **stvarna prava na tuđim stvarima (*iura in re aliena*)** koja omogućavaju korištenje tuđom stvari samo na točno određeni i ograničeni način. To su: služnosti, dugoročni zakupi nekretnina sa stvarnopravnim učinkom (emfiteuza i superficies) i založno pravo.

§ 35 – Pojam i podjela stvari

Svi udžbenici rimskog prava, počev još od Gajevog, započinju izlaganje o stvarnom pravu pojmom i podjelom stvari, po kojima je ta grana prava dobila ime.

Pod pojmom stvari (*res*) podrazumijeva se sve ono što može biti predmetom pravnog prometa i pripadati nečijoj imovini. U starije vrijeme rimski su pravници pod terminom “stvar” podrazumijevali samo tjelesne stvari kao prostorno ograničene dijelove prirode dostupne ljudima koji služe zadovoljenju neke ljudske potrebe. Postupno pojam “stvar” počinje obuhvaćati i netjelesne stvari – prava. U rimskom pravu predmetom pravnih

odnosa bili su i ljudi, i to ne samo robovi, nego u nekim situacijama i slobodne osobe (npr. prodaja prezaduženog dužnika u ropstvo; prodaja osobe *alieni iuris* u *mancipium*).

S obzirom na različita i specifična svojstva koja imaju u pravnom i gospodarskom prometu, stvari se mogu podijeliti u više skupina .

Res in commercio – res extra commercium. Predmet privatnog prava su samo stvari *in commercio*, dok su stvari *extra commercium* predmet javnog prava. ***Res in commercio* su stvari koje mogu biti predmet pravnih poslova, pa time i privatnog vlasništva. *Res extra commercium* su stvari koje zbog svojih pravnih ili fizičkih svojstava ne mogu biti predmet privatnog vlasništva i pravnih poslova.** Izuzete su iz pravnog prometa bilo “božanskim zakonima” (*res extra commercium divini iuris*) bilo “ljudskim zakonima” (*res extra commercium humani iuris*).

Res extra commercium divini iuris su: ***res sacrae*** (stvari posvećene bogovima: hramovi, oltari, žrtvenici, odjeća svećenika), ***res religiosae*** (stvari posvećene kultu pokojnika, među kojima su najznačajniji grobovi), ***res sanctae*** (svete stvari: gradski zidovi i vrata i gradske luke Rima i italjskih gradova).

Res extra commercium humani iuris su: ***res communes*** (stvari zajedničke svim ljudima: zrak, voda, more, morska obala), ***res publicae*** (stvari koje su namijenjene općoj upotrebi, a pripadaju državi: putovi, pristaništa, rijeke), ***res universitatis*** (stvari gradskih općina: kazališta, stadioni, gradska kupatila).

Res in patrimonio – res extra patrimonium. Pojam ***res in patrimonio*** obuhvaća stvari koje se nalaze u imovini neke osobe, dok u ***res extra patrimonium*** ulaze stvari koje u određenom momentu nisu uključene u nečiju imovinu, npr. ***res derelictae*** (stvari koje je vlasnik napustio u namjeri odreknuća od prava vlasništva), ***res nullius*** u užem smislu (stvari koje još nisu bile ni u čijem vlasništvu, npr. divlje životinje, plodovi u prirodi).

Pod pojam *res extra patrimonium* u širem smislu ulaze i *res extra commercium*.

Res Mancipi – res nec Mancipi. Ovo je specifično rimska podjela stvari i jedina koju nije preuzelo pozitivno pravo jer je u klasičnom pravu zastarjela, a u Justinijanovom pravu potpuno ukinuta. Podjela na *res Mancipi* i *res nec Mancipi* nastala je u starom razdoblju rimske pravne povijesti kada je tek nastajalo individualno privatno vlasništvo. Kao trag nekadašnjeg kolektivnog vlasništva ostale su formalnosti koje su morale biti ispunjene kada se htjelo prenijeti pravo vlasništva na stvarima koje su predstavljale osnovna sredstva za proizvodnju. To su bile ***res Mancipi***: **italska zemljišta, zgrade, radna stoka, alat, robovi i stare poljske služnosti** (*iter, actus, via* i *aquaeductus*). Pravo vlasništva na tim stvarima moglo se prenijeti samo formalističnim načinima starog civilnog prava, putem ***mancipatio*** ili

in iure cessio. Sve ostale stvari spadale su u *res nec Mancipi* i mogle su se prenositi neformalnom predajom (*traditio*).

Res corporales – res incorporales. *Res corporales* (tjelesne stvari) su stvari koje se mogu dodirnuti, a one koje se ne mogu dodirnuti su *res incorporales* (netjelesne stvari). Za rimske pravnike pojam “*res*” odnosio se prvenstveno na tjelesne stvari, a vremenom su proširili pojam “*res*” i na prava kao predmete imovine (npr. potraživanje, pravo na nasljedstvo). U netjelesne stvari ubrajaju sva imovinska prava osim prava vlasništva, tj. stvarna prava na tuđoj stvari i potraživanja. Vlasništvo su poistovjećivali sa samom stvari zbog čega su pravo vlasništva ubrajali u *corpora*, tj. tjelesne stvari, a ne u prava. Podjela stvari na tjelesne i netjelesne od velike je praktične važnosti jer su posjed i svi načini stjecanja vlasništva temeljeni na posjedu (npr. *traditio*, *occupatio*) bili mogući samo na tjelesnim stvarima. Kako klasično pravo nije dopuštalo posjed netjelesnih stvari, prava nisu mogla biti prenošena faktičnom predajom niti mancipacijom, nego samo putem instituta *in iure cessio*. U Justinijanovom pravu omogućen je posjed prava (*iuris quasi possessio*), tj. faktično vršenje prava, prvenstveno prava služnosti.

Res mobiles – res immobiles. *Res mobiles* (pokretne stvari) su one koje mogu mijenjati položaj u prostoru, a da se pri tome ne uništi njihova bit. *Res immobiles* (nepokretne stvari) su one stvari koje se ne mogu premjestiti, a da se time ne uništi njihova bit, ili ne promijeni dosadašnja struktura. Rimski su pravnici svojstvo nekretnine pridavali zemlji i svemu onome što je sa zemljom bilo čvrsto vezano, pa su kao nepokretnosti promatrane građevine (*inaedificatio*), sve što je na zemljištu posijano (*inseminatio*) i zasađeno (*implantatio*). Ti sastavni dijelovi zemljišta nazvani su *superficies* (zemljišna površina) i za njih vrijedi načelo *superficies solo cedit* (načelo pravne jedinstvenosti nekretnine: sve što je sa zemljištem trajno povezano slijedi pravnu sudbinu zemljišta što znači da vlasniku zemljišta pripada sve ono što se na njemu sagrađi, posadi ili posije).

Režim nepokretnosti primjenjuje se ponekad po **kriteriju pertinencije** i na stvari koje su po svojim naravnim fizičkim svojstvima pokretne ako služe gospodarskim svrhama nekretnine (npr. alat i robovi u obrtničkoj radionici; stoka, sjeme, gnojivo namijenjeni poljodjelskoj proizvodnji na poljodjelskom imanju). Zemljištu pripada ne samo tlo, nego i zračni prostor nad njim, kao i zemljišni prostor pod površinom. Razlikuju se *praedia rustica* (poljska zemljišta - namijenjena poljodjelskoj obradi) i *praedia urbana* (gradska zemljišta - namijenjena za gradnju kuća za stanovanje i poslovne prostorije, za vrtove i parkove).

Podjela stvari na pokretne i nepokretne ima višestruke pravne posljedice: razlikovali su se rokovi za dosjelost, posjedovna zaštita, neformalna predaja stvari; neka prava mogla su

imati za predmet isključivo nekretnine (npr. zemljišne služnosti); u određenim sporovima mjesna nadležnost suda određivana je prema mjestu gdje se nalazi nekretnina koja je predmet parnice (*forum rei sitae*), itd.

Res fungibiles – res non fungibiles. *Res fungibiles* (zamjenljive stvari) su stvari koje se u prometu određuju vaganjem, brojanjem i mjerenjem (*res quae pondere, numero, mensura constant*). Njihov individualitet nije važan zbog čega se **određena količina tih stvari može zamijeniti jednakom količinom istovrsnih stvari** (npr. 100 kg pšenice može se zamijeniti sa 100 kg pšenice). Nazivaju se i generične stvari (*genus; genera*) jer su najčešće određene po vrsti (žito, vino, ulje, novac). ***Res non fungibiles* (nezamjenljive stvari) pojavljuju se u prometu kao strogo određena pojedinost, individualnost** (npr. određena umjetnička slika; određeni konj u određenom domaćinstvu; rob određenog imena). Stvari koje imaju svoju individualnost nazivaju se *species*.

Stranke mogu svojom voljom odrediti da zamjenljiva stvar u konkretnom slučaju bude tretirana kao *species* (npr. kupac u skladištu krumpira izdvoji određenu vreću krumpira kao *species*).

Podjela stvari na zamjenljive i nezamjenljive od značaja je za obvezno pravo: predmet ugovora o zajmu i neredovitom depozitu su zamjenljive stvari; pitanje odgovornosti dužnika zbog slučajne (neskrivljene) propasti stvari ovisilo je o svojstvu zamjenljivosti ili nezamjenljivosti stvari. Dužnik koji je dugovao zamjenljivu stvar morao je izvršiti svoju obvezu sve dok postoji još ijedna stvar istog roda premda su zamjenljive stvari koje je pripremio radi izvršenja obveze propale uslijed slučaja (npr. vlasnik skladišta žita neće biti oslobođen obveze premda je žito u skladištu uništeno uslijed poplave ili požara). Za zamjenljive stvari vrijedi načelo ***genus non perit*** (zamjenljiva stvar ne može propasti). Međutim, ako je dužnik dugovao individualno određenu stvar pa ona propadne uslijed slučaja, biti će oslobođen obveze po načelu ***species perit ei cui debetur*** (*species* propada onome kome se duguje; npr. prodavatelj koji je bio dužan predati određenog konja, oslobađa se obveze ako konja ubije grom; ali ako stvar propadne dužnikovom krivnjom, dosadašnja se obveza pretvara u odgovornost za štetu).

Res consumptibiles – res non consumptibiles. *Res consumptibiles* (potrošne stvari) su one stvari koje se uništavaju **prvom** redovitom upotrebom. ***Res non consumptibiles* (nepotrošne stvari) su one koje se ne troše prvom normalnom upotrebom.** Kod pitanja potrošnosti važna je **prva redovita** (uobičajena jednokratna) upotreba. Potrošne stvari (npr. žito, vino, novac u pravnom i ekonomskom smislu) i zamjenljive stvari nisu sinonimi iako je većina zamjenljivih stvari potrošna. Ima zamjenljivih nepotrošnih stvari (npr. igla) i potrošnih

nezamjenljivih (npr. rođendanska torta; jedina preostala boca vina iz određene berbe). Ta dioba stvari važna je sa stanovišta obveznog prava (npr. u posudbu, najam, *ususfructus* mogu se dati u pravilu samo nepotrošne stvari).

Res divisibiles – res indivisibiles. *Res divisibiles* (djeljive stvari) su one stvari koje se mogu rastaviti na više istovrsnih dijelova tako da im se ne uništi prvobitna bit ili im se nerazmjerno ne umanji vrijednost (npr. zemljište, truba štofa, tabla čokolade). *Res non divisibiles* (nedjeljive stvari) su stvari čija bi se bit uništila diobom, ili bi im se nerazmjerno umanjila vrijednost (npr. rob, živa životinja, dijamant). Za pitanje djeljivosti ili nedjeljivosti stvari bitan je ekonomsko - socijalni kriterij, a ne fizički ili kemijski.

Navedena podjela stvari važna je naročito kod suvlasništva i kod obveza s više dužnika i vjerovnika.

Postoji nekoliko načina diobe stvari: fizička (stvar se može podijeliti mehaničkim putem, npr. kolut sira, tabla čokolade); geometrijska (primjenjuje se kod podjele zemljišta na parcele, čestice); civilna (dioba po vrijednosti: nedjeljiva stvar može se prodati i onda podijeliti cijenu); idealna (svaka se stvar, bez obzira je li fizički djeljiva ili nije, može pravno razdijeliti na sadržajno jednake idealne dijelove, čija se veličina najčešće određuje u obliku razlomka ili postotka, tj. računski u određenom razmjeru prema cijeloj stvari).

Jednostavne stvari, sastavljene stvari i skupine stvari.

Jednostavne stvari (jedinstvene ili proste) su stvari koje predstavljaju posebnu prirodnu cjelinu (npr. rob, životinja, kamen, greda).

Sastavljene (složene) stvari nastaju spajanjem jednostavnih stvari u novu cjelinu s posebnom namjenom (npr. zgrada, brod). Pri tome jednostavne stvari, koje postaju sastavni dio nove cjeline, gube svoju samostalnost i prestaju biti samostalni objekti prava sve dok taj spoj traje.

Skupina stvari (*universitas rerum*) predstavlja zbroj fizički samostalnih i međusobno koordiniranih stvari koje su ujedinjene zajedničkom gospodarskom svrhom ili organizacijskom funkcijom i u prometu se pojavljuju pod zajedničkim nazivom (npr. stado ovaca, biblioteka, skladište robe). Premda je svaka od stvari koje sačinjavaju *universitas* sačuvala svoju individualnost, skupina kao cjelina može biti predmet nekih pravnih odnosa (npr. kupoprodaje, založnog prava) i tužbe. Identičnost skupine stvari ne mijenja se unatoč eventualnoj promjeni njezinih sastavnih dijelova. U pandektnoj znanosti pod skupinom stvari podrazumijevaju se ne samo skupine jednovrsnih tjelesnih stvari (*universitas facti*), već i kompleksi raznovrsnih imovinskih objekata, kako tjelesnih, tako i prava (*universitas iuris*, npr. *peculium*, *dos*, *hereditas*).

Glavna stvar i pripadak (pertinencija). Predmet pravnog odnosa može se sastojati iz više stvari koje se ne nalaze u koordiniranom, ravnopravnom položaju nego jedna sadržava obilježja cijele stvari, dok druga služi njezinom ekonomskom iskorištavanju. **Pripadak (pertinencija) je samostalna pokretna sporedna stvar koja omogućuje ili olakšava upotrebu glavne stvari i ispunjenje njezinog ekonomskog cilja** (npr. stoka, robovi i alat uz zemlju, ključ uz bravu, gudalo uz violinu). Podređenost pripadka očituje se kako u gospodarskom pogledu (gospodarsku svrhu cjeline određuje glavna stvar) tako i u pravnom pogledu (pripadak slijedi pravnu sudbinu glavne stvari). Pravni posao o glavnoj stvari obuhvaća i pripadak, prema načelu *accessorium sequitur principale* (pripadak prati pravnu sudbinu glavne stvari), ali je sporno je li to vrijedilo u rimskom, ili je uvedeno tek u pandektnom pravu.

Plodonosna stvar i plodovi. Plodonosna stvar (*res fructifera*) je ona stvar koja je po prirodi ili po pravnim propisima sposobna stvarati nove ekonomske vrijednosti. Plod (*fructus*) je nova ekonomska vrijednost nastala iz plodonosne stvari djelovanjem prirodnih zakona ili zakona ekonomskog prometa.

Plodovi nastali iz plodonosne stvari djelovanjem prirodnih zakona nazivaju se **prirodni plodovi (*fructus naturales*)**. Rimski su pravници kao organske proizvode stvari smatrali i drva posječena u šumi, kamenje iz kamenoloma, pijesak iz riječnog korita, rudu iz rudnika. Rano su uočili da određeni plodovi mogu nastati i sudjelovanjem ljudi u ekonomskom prometu. Takvi plodovi nazivaju se građanski plodovi (*fructus civiles*). ***Fructus civiles*** su prihodi koji se dobiju od neke stvari posredstvom pravnih poslova (najamnina, zakupnina, kamata).

U rimskom je pravu detaljno razrađeno pitanje prisvajanja prirodnih plodova jer su i nevlasnici mogli sudjelovati u ubiranju plodova na temelju različitih pravnih odnosa. S tim u vezi razlikuje se nekoliko situacija.

Fructus pendentes (stantes – viseći plodovi) su plodovi koji još nisu odvojeni od plodonosne stvari. Za njih vrijedi pravilo *fructus pendentes pars fundi videntur* (neodvojeni plodovi smatraju se sastavnim dijelom zemlje).

Fructus separati (odvojeni plodovi) – tek odvajanjem (separacijom) od glavne stvari plodovi postaju samostalne stvari i samostalni objekti prava.

Fructus percepti su plodovi koje je ubrala ovlaštena osoba, dok su ***fructus percipiendi*** zanemareni plodovi, tj. plodovi koji su trebali biti prikupljeni, ali je držatelj stvari to uslijed svoje nemarnosti propustio učiniti.

Fructus extantes su odvojeni, ali još nepotrošeni plodovi (**fructus non consumpti**), a **fructus consumpti** su ubrani i potrošeni plodovi.

Razlikovanje plodova od posebne je važnosti u reivindikacionoj parnici kada se rješava pitanje naknade plodova od strane neovlaštenog držatelja stvari. Osim toga, budući da i nevlasnici u određenim situacijama mogu ubirati plodove stvari, važno je utvrditi momente prisvajanja plodova. Vlasnik, emfiteuta i poštenu posjednik stječu vlasništvo već separacijom, pri čemu emfiteuta i poštenu posjednik imaju prednost pred vlasnikom, dok uživatelj (uzufruktuar) i zakupnik stječu vlasništvo na plodovima tek percepcijom (uzimanjem u posjed).

§ 36 – Posjed (*possessio*)

1. Pojam i elementi posjeda; razlika između vlasništva, posjeda i detencije

Premda posjed¹⁹ nije pravo nego samo faktično stanje, izučava se u okviru stvarnih prava jer izaziva veoma važne pravne posljedice i jer često predstavlja temelj za stjecanje stvarnih prava.

Posjed (*possessio*) je faktična vlast na tjelesnoj stvari (*corpus*), s voljom stvar držati za sebe (*animus possidendi*; *animus rem sibi habendi*).

Budući da rimsko pravo usvaja subjektivističku konstrukciju posjeda, **elementi posjeda u rimskom pravu su *corpus* i *animus possidendi*.**

Često se u svakodnevnom govoru instituti vlasništvo i posjed poistovjećuju i shvaćaju kao sinonimi. To je velika greška jer su vlasništvo i posjed potpuno različiti pravni instituti. Rimski su pravници isticali da se mora dijeliti posjed od vlasništva (D.43.17.1.2: “*separata esse debet possessio a proprietate*”) i da **vlasništvo i posjed nemaju ništa zajedničko** (D.41.2.12.1: “*nihil commune habet proprietate cum possessione*”).

Vlasnik je osoba koja je na pravom propisani način zasnovala pravnu vlast na stvari, dok je posjednik svaka osoba koja ima faktičnu vlast na stvari, tj. mogućnost njezina korištenja, bez obzira na način na koji je došla do stvari (na temelju pravnog posla

¹⁹ Kaser, M., *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*, Köln, 1956; Cannata, C. A., “*Possessio*” “*possessor*” “*possidere*”: nelle fonti giuridiche del basso impero romano; contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell’ epoca postclassica, Milano, 1962; Gordon, W. M., *Studies in the transfer of property by traditio*, Aberdeen, 1970; Wacke, A., *Das Besitzkonstitut als Übergabesurrogat*, Köln, 1974; Zamorani, P., *Possessio e animus*, Milano, 1977; Albanese, B., *Le situazioni possessorie nel diritto privato romano*, Palermo,

zaključenog s vlasnikom, ili na protupravan ili nedopušten način) i volju stvar imati za sebe. Vlasništvo je najvažnije stvarno pravo, a posjed je samo faktično stanje koje postoji neovisno od bilo kakvog prava. Najčešće je vlasnik ujedno i posjednik stvari jer se stvar u pravilu nalazi u njegovoj faktičnoj vlasti. Ali, mogu se dogoditi situacije u kojima vlasnik izgubi faktičnu vlast na stvari bilo svojom voljom (stvar je dao u najam, zakup, zalogu, posudbu, ostavio ju je na čuvanje kod nekoga; zasnovao je pravo plodouživanja u korist određene osobe, itd.), bilo protiv svoje volje (stvar je ukradena, silom oteta, izgubljena). U svim tim slučajevima, premda je izgubljena materijalna vlast na stvari, vlasništvo je ostajalo neokrnjeno jer kao stvarno pravo prati stvar ma u čije ruke ona došla.

Faktična ili materijalna vlast na stvari (*corpus*), dakle, predstavlja mogućnost da se stvar koristi i upotrebljava, ili drukčije rečeno vlast na stvari treba shvatiti kao **mogućnost faktičnog raspolaganja sa stvari.** Dugo vremena u rimskom je pravu vrijedilo shvaćanje da je posjed moguć samo na onim stvarima koje su se mogle imati u fizičkoj vlasti, tj. na tjelesnim stvarima jer se tražila mogućnost fizičkog držanja stvari. Tek Justinijanovo pravo poznaje posjed netjelesnih stvari – *quasi possessio*.

Za rimske pravnike nije bio dovoljan samo faktični element posjeda (*corpus possessionis*) nego su tražili da onaj koji ima materijalnu vlast na stvari, pokazuje i volju stvar zadržati za sebe i raspolagati s njom onako kako sa stvari raspolaže vlasnik (*animus rem sibi habendi*). **Animus je akt volje koji se ogleda u određenom vanjskom ponašanju.** Držatelj stvari mora na jasan način pokazati da želi stvar zadržati za sebe i druge osobe isključiti iz njezina korištenja. Tako, ako je npr. vlasnik dao stvar na posudbu ili na čuvanje, posudovnik, odnosno depozitar, ako žele postati posjednici, moraju na jasan način pokazati da su pored faktične vlasti stekli i *animus* (stvar preraditi, sakriti, odbiti vratiti je).

Ako držatelj stvari nema volju stvar imati za sebe, onda se ne radi o posjedniku nego samo o detentoru. **Detentio je faktična vlast bez volje stvar imati za sebe.** U rimskom pravu razlikuju se posjed (*possessio*) koji je zaštićen interdiktima (pretorskim sredstvima za zaštitu posjeda) i puko držanje stvari (*detentio* ili *possessio naturalis*) koje ne uživa posjedovnu zaštitu. **Detentori su osobe koje drže stvar na temelju nekog obveznog odnosa** (najmoprimci, zakupnici, posudovnici, depozitari, založni vjerovnici), **odnosno na temelju odobrenog stvarnog prava na tuđoj stvari** (založno pravo; *ususfructus*). Oni ne drže stvar u svoje ime (*suo nomine*), nego u ime osobe koja im je dala stvar (*alieno nomine*) i kojoj će je vratiti. Zato je ta druga osoba, koja je detentoru ustupila faktičnu vlast na stvari, i dalje

posjednik, uživa posjedovnu zaštitu jer ima *animus*, a *corpus* vrši posredstvom detentora. Iznimno je rimsko pravo priznalo posjedovnu zaštitu nekim detentorima zbog naročitih osobina njihovih ovlasti i jer im pravna zaštita nije mogla biti pružena ni na koji drugi način. To su: založni vjerovnik (jer ručni zalog – *pignus* ispočetka nije bio priznat za stvarno pravo pa založni vjerovnik nije imao na raspolaganju tužbu *in rem*); sekvestar (osoba kojoj je povjeravana stvar o kojoj se vodi vlasnički spor); prekarist (osoba kojoj je stvar ustupljena na besplatno korištenje do opoziva); interdiktnu zaštitu dobili su i plodouživatelj (*usufructuarius*) i držatelji zemljišta po osnovi ugovora o dugoročnom zakupu.

2. Pravni učinci posjeda

Premda predstavlja samo faktičnu ili materijalnu vlast na stvari, posjed je veoma važan pravni institut jer povlači određene pravne posljedice.

Posjedovanjem stvari kroz određeno vrijeme moguće je putem instituta dosjeloosti (*usucapio*) **zasnovati pravo vlasništva**.

Drugi važan učinak posjeda je što posjednik **u reivindikacijskoj (vlasničkoj) parnici** ima ulogu tuženika. U vlasničkoj je parnici uvijek aktivno legitimiran vlasnik koji je izgubio posjed stvari, dok je pasivno legitimiran posjednik stvari, tj. u ulozi tužitelja je vlasnik – neposjednik, a **u položaju tuženika je posjednik – nevlasnik**. Zato je važno utvrditi kod koga se stvar nalazi da bi se mogao odrediti položaj stranaka.

Budući da ima ulogu tuženika, **posjednik u formularnom i ekstraordinarnom postupku ne mora ništa dokazivati** zbog čega je njegov položaj povoljniji od tužiteljeva, koji mora dokazati svoje pravo vlasništva i način na koji ga je stekao. Ako tužitelj ne uspije dokazati svoje pravo vlasništva, a to je ponekad veoma teško, stvar će ostati kod tuženika, tj. posjednika.

Posjednik je u povoljnijem položaju jer se i **mjesna nadležnost suda određuje prema prebivalištu tuženika**, prema načelu *actor sequitur forum rei* (C.3.13.2: Za tužbu je mjesno nadležan sud prebivališta tuženika.)

Jedna od najvažnijih pravnih posljedica posjeda je što posjed, zahvaljujući djelatnosti pretora, uživa **samostalnu pravnu zaštitu putem interdikata**. Uvođenjem posjedovne zaštite država je nastojala spriječiti svojevlasnu zaštitu prava i samovoljno mijenjanje postojećeg posjedovnog stanja. Nitko ne smije nasilnim putem remetiti nečiju faktičnu vlast

na stvari, pa makar stvar bila i kod kradljivca. Interdiktnu zaštitu uživali su posjednici (uključujući i kradljivca) i prema vlasniku stvari koji je svoju stvar pokušao uzeti na nedopušten način. Posjedovna zaštita uvedena je u interesu javnog reda i mira radi sprečavanja nasilnih djela i promjena. Osoba koja misli da smije narušiti postojeće posjedovno stanje, mora svoje pravo ostvariti u redovitom sudskom postupku, tj. na pravno propisani način, a ne putem samopomoći i sile.

3. Vrste posjeda

Possessio ad interdicta (juristički, juridički ili interdiktni posjed) je posjed koji sadrži oba konstitutivna elementa, *corpus* i *animus*, zbog čega je zaštićen pretorskim interdiktima. Bez obzira radi li se o poštenom ili nepoštenom ili vicioznom posjedniku, interdiktni će posjednik uživati posjedovnu zaštitu protiv trećih, ali neće i protiv onoga od koga je na protupravan način stekao stvar.

Possessio civilis; possessio ex iusta causa; possessio ad usucapionem je juristički posjed koji se temelji na nekom pravnom razlogu (*iusta causa*, npr. kupoprodaja, darovanje) i koji će na temelju predaje stvari (*traditio*) ili putem dosjelosti (*usucapio*) dovesti do zasnivanja prava vlasništva.

Possessio vitiosa – possessio non vitiosa. Ta je podjela posjeda izvršena s obzirom na način stjecanja. Posjed koji je stečen silom (*vi*), potajno, tj. krađom (*clam*) ili zloupotrebom povjerenja (*praecario*, stvar je data na besplatnu upotrebu do opoziva, pa na opoziv nije vraćena) je viciozni posjed (*possessio vitiosa*). Ako posjed nije stečen na navedene načine, radi se o nevicioznom posjedu (*possessio non vitiosa*). Viciozni posjednik uživa posjedovnu zaštitu jer ima oba elementa posjeda i biti će zaštićen protiv svakoga, samo neće protiv onoga od kojeg je stvar stekao na navedene načine (to ne mora biti vlasnik stvari).

Possessio bonae fidei – possessio malae fidei. *Possessio bonae fidei* (poštenu posjed) postoji kada posjednik stvari u momentu zasnivanja posjeda nije znao niti je mogao znati da razlog (*titulus, causa*) njegova stjecanja sadrži mane zbog kojih ne može postati vlasnik stvari. On je sve vrijeme bio u oprostivoj bludnji da je njegov posjed zakonit i da ne vrijeđa ničija prava (npr. nije znao niti mogao znati da je stekao posjed od nevlasnika, ili da njegov prednik nije imao poslovnu sposobnost).

***Possessio malae fidei* (nepošteni posjed) postoji u slučaju kada je posjednik već u momentu stjecanja posjeda znao ili je mogao znati za nedostatke koji će ga onemogućiti da postane vlasnik stvari** (npr. znao je, ili je mogao znati, da je upotrijebio dužnu pažnju, za nedostatke u pravima i ovlastima druge stranke)

Razlikovanje posjeda na poštenu i nepoštenu nije bitno sa stanovišta posjedovne zaštite jer oba posjeda uživaju interdiktnu zaštitu, nego je od velike važnosti kod rješavanja pitanja odgovornosti za eventualne plodove, pogoršanje stvari i naknadu troškova u reivindikacijskoj parnici, kao i za institut dosjeloosti (*usucapio*), te upotrebu Publicijanske tužbe (*actio Publiciana*) i prigovora prodane i predane stvari (*exceptio rei venditae ac traditae*). *Possessio bonae fidei* naziva se i kvalificirani posjed (*possessio qualificata*) jer je zaštićen s *actio Publiciana*.

Quasi possessio (posjed prava) postoji kada netko faktično vrši sadržaj nekog prava (*corpus*) s voljom da postupa kao da se radi o njegovom pravu (*animus*).

Prema klasičnom rimskom pravu netjelesne stvari ili prava nisu mogle biti predmetom posjeda. Međutim, kako se u praksi često događalo da se netko faktično koristi nekim pravom s voljom da postupa kao ovlaštenik tog prava, premda ono nije bilo ustanovljeno na uobičajeni način, pretori su počeli štititi i takve slučajeve putem tzv. *interdicta utilia*. To se uglavnom odnosilo na faktično vršenje prava služnosti, tj. na slučajeve kada se netko ponašao kao ovlaštenik prava služnosti iako služnost nije bila konstituirana redovitim putem (npr. prelazi preko tuđeg dvorišta, goni stoku preko tuđe livade, a da nije ustanovljeno pravo služnosti puta).

4. Stjecanje i gubitak posjeda

Za stjecanje posjeda po rimskom pravu bila su nužna oba konstitutivna elementa, i *corpus* i *animus*. Samo jedan od tih elemenata nije bio dovoljan za zasnivanje posjeda.

Način na koji će biti zasnovana faktična vlast na stvari ovisio je, s jedne strane o tome, radi li se o stjecanju posjeda na nepokretnim ili pokretnim stvarima, te, s druge strane, radi li se o originarnom ili derivativnom stjecanju.

Originarno se posjed stjecao neovisno od volje dosadašnjeg posjednika. Ako se radilo o stjecanju **posjeda na nekretninama**, trebalo je na očit način pokazati da je stečena faktična vlast: ograđivanjem, obrađivanjem, omeđivanjem, useljenjem u zgradu i slično. I za stjecanje **posjeda pokretnih stvari** originarnim putem, tražilo se vidljivo materijalno zahvaćanje

stvari (*aprehensio*), npr. pohranjivanjem, odvođenjem trebalo je pokazati da je stečena isključiva mogućnost raspolaganja i korištenja sa stvari.

Derivativno se posjed stječe sporazumom s ranijim posjednikom koji predaje stvar novom posjedniku.

Za **derivativno stjecanje posjeda nekretnina** vrijedili su strožiji zahtjevi za **zasnivanje faktične vlasti**. Po starijem pravu trebalo je običi zemljište i pokazati granice; vremenom je zahtjev da predaja posjeda mora uslijediti na samom zemljištu i da stjecatelj mora stupiti na zemljište ublažen, tako da je bilo dovoljno pokazati zemljište npr. s obližnje uzvisine (tzv. *traditio longa manu*). U postklasičnom i Justinijanovom pravu napušten je zahtjev za faktičnim uzimanjem zemljišta u posjed jer je u praksi zaživjelo shvaćanje da je i sam sporazum o predaji posjeda dovoljan za zasnivanje materijalne vlasti na zemljištu.

Za stjecanje posjeda pokretnih stvari derivativnim putem bio je dovoljan bilo koji akt kojim bi bilo nedvojbeno pokazano da je izvršen prijenos posjeda. Bilo je moguće prenijeti posjed pokretnih stvari aktima koji su imali karakter simbolične predaje (tzv. *traditio symbolica*, npr. predajom ključeva skladišta smatralo se da je predana sama roba u skladištu), kao i putem *traditio longa manu* (npr. stjecatelj je kupljenu stvar obilježio podesnim znakovima kao svoju).

Klasično pravo poznavalo je dva načina prijenosa posjeda stvari već samim sporazumom stranaka. To su: *traditio brevi manu* i *constitutum possessorium*.

Traditio brevi manu postoji u slučaju kada se stranke dogovore da će dosadašnji detentor stvar ubuduće držati kao posjednik (npr. posudovnik kupi stvar koju je već držao na temelju ugovora o posudbi). Time je detentor (koji je imao samo *corpus*) naknadno sporazumom stranaka stekao i drugi element posjeda – *animus* i postao juristički posjednik.

Constitutum possessorium je suprotan slučaj od navedenog: dosadašnji posjednik će na temelju sporazuma stranaka ubuduće držati stvar samo kao detentor (npr. prodavatelj proda kuću, ali ostane u njoj stanovati kao najamnik).

Glede stjecanja posjeda u rimskom pravu treba podsjetiti da su osobe *alieni iuris* i robovi mogli stjecati posjed za svog imatelja vlasti, ali se uvijek tražio njegov *animus*, tj. njegovo znanje ili naređenje. Klasično pravo dopustilo je stjecanje posjeda putem slobodnog čovjeka ako se radilo o stalnom upravitelju imovine (*procurator*), a Justinijanovo je pravo dopustilo stjecanje posjeda za drugoga po svakom zastupniku (tj. mandataru ili *negotiorum gestoru*). Upravo je kod stjecanja posjeda rimsko pravo počelo odstupati od stava o nemogućnosti neposrednog zastupanja, što se može obrazložiti shvaćanjem posjeda kao faktičnog stanja, a ne prava.

Kao faktično stanje posjed je prestajao gubitkom konstitutivnih elemenata - *corpore et animo* (npr. kada posjednik napusti stvar, tj. svojom se voljom odrekne vršenja faktične vlasti), ili samo *corpore* - kada posjednik mimo svoje volje izgubi faktičnu vlast na stvari (npr. izgubio je stvar koju više neće naći; odlutala životinja neće se vratiti; stvar je ukradena ili oteta).

U praksi su se događali mnogobrojni slučajevi kada je posjed bilo moguće sačuvati *solo animo*, sve dok su postojali razumni izgledi za ponovnim stjecanjem faktične vlasti na stvari (npr. kod sezonskog korištenja zimskih i ljetnih pašnjaka; u slučaju odbjeglog roba; kod stvari koje je napustio ratni zarobljenik). U literaturi postoje mišljenja da je Justinijan proširio te slučajeve i uopćio ih u pravilo da se posjed, unatoč gubitku faktične vlasti, može sačuvati samo voljom (*solo animo*), te da je za prestanak posjeda potrebno izgubiti oba konstitutivna elementa. Gubitkom faktične vlasti mimo svoje volje posjednik stječe pravo zahtijevati posjedovnu zaštitu i sve dok ima to pravo, smatra se posjednikom premda je izgubio *corpus*.

5. Zaštita posjeda

Sredstva za zaštitu posjeda nazivaju se interdikti (*interdicta*, opširnije vidi u § 33). **Interdikti su kratki i uvjetni nalozi koje je izdavao pretor na zahtjev zainteresiranih osoba bez prethodnog ispitivanja ili provođenja dokaza i kojima je određenoj osobi naređivano da nešto uradi ili propusti uraditi.**

Osnovni razlozi uvođenja interdiktne zaštite nalaze se u potrebi očuvanja reda i mira, u nastojanju države da eliminira samopomoć i samovoljno mijenjanje postojećeg posjedovnog stanja, kao i u pružanju mogućnosti samim vlasnicima da putem interdiktne zaštite dobiju brža i jednostavnija pravna sredstva za zaštitu posjeda, a time posredno i za zaštitu prava vlasništva.

U posjedovnim sporovima rješava se samo o činjenici faktične vlasti na stvari, a ne i o pitanjima prava, zbog čega su u interdiktnom postupku bili zabranjeni svi petitorni prigovori, tj. prigovori kojima bi se stranke pozivale na svoje pravo na stvar.

Postojale su dvije osnovne vrste interdikata za zaštitu posjeda: *interdicta retinendae possessionis* i *interdicta recuperandae possessionis*.

Interdicta retinendae possessionis služili su za zaštitu posjeda od smetanja. Klasično pravo poznavalo je dva takva interdikta: *interdictum uti possidetis* i *interdictum utrubi*.

Interdictum uti possidetis služio je za zaštitu posjeda na nekretninama i njime se štitilo zadnje faktično posjedovno stanje ukoliko ono nije bilo postignuto na viciozan

način (*vi, clam, precario*). Viciozan posjed škodio je samo prema onoj osobi od koje je posjed stečen na protupravan način, a ne i prema trećim osobama. To znači da osoba koja traži izdavanje interdikta ne smije imati viciozan posjed u odnosu na stranku u sporu jer ona može istaknuti prigovor vicioznog posjeda. **Prigovor vicioznog posjeda (*exceptio vitiosae possessionis*) je prigovor kojim tuženik odbija interdikt navodeći da je osoba koja traži izdavanje interdikta imala viciozan posjed, tj. da je došla u posjed stvari tako što ju je od njega silom oduzela, ukrala, ili je nije vratila na opoziv.** Dakle, interdiktnu zaštitu neće dobiti onaj koji je, od iste osobe protiv koje sada traži izdavanje interdikta, ranije na nedopušten način došao do stvari.

Interdictum utrubi služio je za zaštitu posjeda pokretnih stvari od uznemiravanja. Za razliku od prethodnog interdikta, nije se izdavao u korist posljednjeg posjednika, nego u korist onog posjednika koji je **u posljednjoj godini dana**, računajući od dana izdavanja interdikta, **duže posjedovao stvar**, uz pretpostavku da taj posjed nije stekao od protivnika na nedopušten način (*vi, clam* ili *precario*). Neviciozni posjednik mogao je svom posjedu priračunati posjed svog prethodnika, npr. prodavatelja ili ostavitelja (*accessio temporis*).

U postklasičnom i Justinijanovom pravu oba navedena interdikta (*uti possidetis* i *utrubi*) izdavala su se u korist posjednika koji je u vrijeme početka parnice imao stvar u nevicioznom posjedu. Tužbeni zahtjev bio je upravljen na uklanjanje učinjenih promjena, na zabranu daljnjih smetanja, a tuženik je mogao biti obavezan i na davanje jamstva da ubuduće neće više uznemiravati posjednika (*cautio de non amplius turbando*). Tužbeni zahtjev trebalo je podići u roku od jedne godine. Rok se računao *utiliter* (prema mogućnosti stranke da traži zaštitu od pretora).

Interdicta recuperandae possessionis služila su za ponovno uspostavljanje izgubljenog posjeda na nekretninama.

Interdictum unde vi mogli su upotrijebiti posjednici koji su iz posjeda nekretnine **izbačeni silom**. Klasično pravo razlikuje dva takva interdikta: *interdictum de vi privata* i *interdictum de vi armata*.

Interdictum de vi privata (ili *de vi non armata*) mogao je upotrijebiti posjednik koji je **lišen posjeda na nasilan način putem tzv. obične sile** (*vis quotidiana*) ukoliko on od protivnika nije oduzeo posjed na viciozan način. Posjedovna zaštita mogla se tražiti u roku od godine dana računajući od dana izgubljenog posjeda.

Interdictum de vi armata pretpostavlja da je izbacivanje iz posjeda izvršila skupina naoružanih ljudi u posebno teškom obliku. U takvom slučaju pretor je štitio čak i

posjednika koji je do posjeda nekretnine došao na viciozan način u odnosu na uzurpatora. Traženje tog interdikta nije bilo vezano za rok.

U Justinijanovom pravu oba navedena interdikta spojena su u jedan ***interdictum unde vi***. Justinijanovo pravo zabranilo je svaku upotrebu sile u posjedovnim odnosima uz prijetnju gubitkom prava vlasništva, povratom otete stvari i novčanom kaznom u visini njezine vrijednosti.

Interdictum de precario je još jedan restitutorni interdikt koji je stajao na raspolaganju osobi kojoj prekarist nije htio vratiti stvar koju je dobio na besplatnu upotrebu do opoziva.

U razdoblju Justinijanovog prava interdiktni postupak prelazi u nadležnost redovitih sudova jer se djelatnost pretora ugasila. Zbog toga se interdikt sve više približava tužbi i naziva *actio ex interdicto*. Ipak su zadržana osnovna obilježja klasičnog interdiktnog postupka: on je sumaran i brz i ne raspravlja o pitanju prava tuženika na stvar.

U Justinijanovom pravu uvedeno je još jedno pravno sredstvo za zaštitu posjeda. To je *actio momentariae possessionis* koju je u roku od 30 godina bilo moguće podići protiv osobe koja bi, koristeći duže odsustvo legitimnog posjednika, ušla u posjed zemljišta.

Drugo poglavlje

VLASNIŠTVO (*DOMINIUM, PROPRIETAS*)

§ 37 – Općenito o vlasništvu; vrste rimskog vlasništva

Vlasništvo²⁰ je najvažniji institut prava jer predstavlja pravni izraz za ekonomski proces prisvajanja. Premda rimski pravници nisu ostavili definiciju vlasništva, može se reći, u skladu s njihovim shvaćanjima, da je **vlasništvo (*dominium, proprietas*) potpuna i isključiva pravna vlast na tjelesnoj stvari (*plena in re potestas*)**. Potpuna i isključiva vlast znači da vlasnik može sa stvari raspolagati po svojoj volji, čak je i uništiti, i sve druge subjekte isključiti od bilo kakvog utjecaja na stvar. Premda je u rimskom pravu vlasništvo bilo ograničavano bilo u interesu susjeda bilo na temelju zakona u javnom interesu, time se nije diralo u bit vlasništva kao potpune i isključive vlasti. Na osnovi pravne vlasti vlasnik može, pravnim sredstvima koja mu stoje na raspolaganju, ponovno steći i faktičnu vlast na stvari ako ju je izgubio. Ukoliko su eventualno postojala ograničenja na pravu vlasništva (npr. ustanovljeno je pravo plodouživanja u korist određene osobe), ono se automatski vraća u svoj prvobitni obujam, čim ta ograničenja otpadnu (*ius recadentiae*, načelo elasticiteta vlasništva).

Sve do razdoblja klasičnog prava nije postojao precizan termin za vlasništvo nego je ono opisno označavano (*meum esse; rem in bonis meis esse*). U klasičnom pravu koristi se za vlasništvo izraz “***dominium***” u kojem dolazi do izražaja bit vlasništva kao vlasti. Krajem klasičnog razdoblja uobičajio se termin “***proprietas***” koji označava pripadnost, a nastao je apstrakcijom od prisvojne zamjenice *meus*, *proprius*).

Tipične ovlasti u sadržaju prava vlasništva su: posjedovanje, upotreba, korištenje i raspolaganje (***possidere, uti, frui, abuti***). Na osnovi pravne vlasti na stvari vlasnik ima i faktičnu vlast na stvari, a u pravilu su vlasništvo i posjed spojeni u osobi vlasnika. Pravo vlasništva ovlašćuje titulara da može stvar upotrebljavati i izvlačiti ekonomske koristi iz nje (***usus***), da ima pravo stjecati sve naravne i građanske plodove od stvari (***fructus***) i da ima pravo raspolagati sa stvari pravnim poslovima *inter vivos* i *mortis causa* (***abusus***: stvar može napustiti, uništiti, prodati, darovati, konstituirati na njoj stvarna prava, ostaviti oporukom). Polazeći upravo od prava raspolaganja sa stvari postglosator *Bartolus*, tumačeći tekst

²⁰ Watson, A., *The law of property in the later Roman Republic*, Oxford, 1968; Rainer, J. M., *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Graz, 1987; Pennitz, M., *Der “Enteignungsfall” im römischen Recht der Republik und des Prinzipats*, Wien, 1991.

D.41.2.17, dao je u XIV. stoljeću prvu definiciju vlasništva označavajući ga kao potpuno pravo raspolaganja na tjelesnoj stvari ukoliko to raspolaganje nije zabranjeno zakonom.

Vlasništvo je po svojoj prirodi trajno pravo. Moglo se prenijeti na drugoga pravnim poslovima *inter vivos* i *mortis causa*. U nekim slučajevima moglo se ugasiti ne prelazeći na novog titulara: propašću stvari, proglašenjem stvari za *res extra commercium* i derelikcijom. Vlasništvo je prestajalo ako je titular izgubio svojstvo subjekta prava, do čega je dovodila smrt i *capitis deminutio* (u Justinijanovom pravu *capitis deminutio maxima i media*).

Rimski je pojam vlasništva imao veoma različit sadržaj s obzirom na različite stupnjeve i razdoblja svog razvitka.

U najstarijem razdoblju rimske pravne povijesti još uvijek postoje oblici vlasništva s izrazitim osobinama društvenog vlasništva iz prvobitne zajednice. Sve stvari koje su kasnije obučene terminom "*res Mancipi*", prvenstveno zemlja, bile su u kolektivnom vlasništvu gensa. Predmetom individualnog vlasništva postale su najprije pokretne stvari. Na jednoj vrsti kolektivnog vlasništva temelji se i *consortium*, najstariji oblik rimske obitelji.

Vlasnički odnosi u agnatskoj obitelji imaju odlike i kolektivnog i privatnog vlasništva. Izraz "*familia pecuniaque*" pokazuje da odnosi vlasti nisu odvojeni od vlasničkih odnosa jer su tim terminom bili obuhvaćeni i ukućani i robovi, kao i pokretne i nepokretne stvari. Ipak, nositelj tih ovlasti je individualiziran, što je bio bitan korak ka privatnom vlasništvu. Od posebne su važnosti vlasnički odnosi na osvojenoj zemlji (*ager publicus*, državna zemlja). Na jednom dijelu novoosvojene zemlje država je organizirala proizvodnju žita, a drugi dio uzimale su najutjecajnije obitelji u tobožnji zakup koji se vremenom pretvorio u vlasništvo, a zakupnina u porez.

Razvitkom robne proizvodnje i uvođenjem klasičnog ropstva razvija se **klasično robovlasničko privatno vlasništvo** koje je bilo osnova na kojoj je nastalo rimsko klasično pravo.

U postklasičnom razdoblju javljaju se elementi feudalnog vlasništva, koji su posebno izraženi u odnosu između veleposjednika i kolona.

Klasično pravo poznavalo je četiri oblika vlasništva, što je bila posljedica dupliciteta pravnih sustava (civilnog i pretorskog), razlike između *res Mancipi* i *res nec Mancipi*, te razlike između Rimljana i peregrina.

Kviritско vlasništvo (*dominium ex iure Quiritium*) bilo je jedini tip vlasništva koje je priznavalo *ius civile*. Mogli su ga stjecati samo rimski građani na načine predviđene civilnim pravom. Predmetom tog vlasništva bile su samo pokretne stvari i italska zemljišta.

Pretorsko (bonitarno) vlasništvo uveli su i zaštitili pretori kako bi u drugoj polovici razdoblja Republike olakšali pravni promet na *res Mancipi*. Formalnosti koje je predviđalo civilno pravo uvelike su otežavale njihov promet u vremenu kada su i te stvari postale predmetom svakodnevnih poslova, posebice kupoprodaje. Sve se češće događalo da stranke, oslanjajući se na međusobno poznanstvo, savjesnost i poštenje, prenesu *res Mancipi* prostom predajom (*traditio*), a ne formalističnim načinima propisanim civilnim pravom (putem *mancipatio* ili *in iure cessio*). Takav prijenos po civilnom pravu nije proizvodio nikakav učinak, što znači da je prodavatelj i dalje ostajao kviritski vlasnik, a da je kupac stjecao samo poštenu posjed na osnovi kojeg će putem dosjelnosti postati kviritski vlasnik.

Problem se javljao ako bi kviritski vlasnik, u vremenu dok još nije istekao rok dosjelnosti, zatražio vlasničkom tužbom stvar natrag, ili bi je ponovno prodao. Stjecatelj ni na koji način nije bio zaštićen protiv takvog nesavjesnog otuđivatelja, zbog čega je pretor, počev od kraja Republike, počeo pružati kupcu zaštitu putem prigovora prijave (*exceptio doli*), koji se u ovom slučaju zove prigovor prodane i predane stvari (*exceptio rei venditae ac traditae*), a protiv trećih osoba, koje bi stjecatelju oduzele posjed stvari, davao je Publicijansku tužbu (*actio Publiciana*) kojom je taj mogao tražiti natrag posjed stvari.

Kako se govorilo da je stvar u imovini stjecatelja (*in bonis*), izveden je termin bonitarno vlasništvo, odnosno pretorsko vlasništvo jer je nastalo zahvaljujući djelatnosti pretora.

Provincijsko vlasništvo je vlasništvo nad zemljištem u provincijama. Od razdoblja kasne Republike smatrano je državnim vlasništvom. Pojedinci su na tom zemljištu mogli steći samo posjed i plodouživanje (*uti frui habere possidere*), koji su po uzoru na rimsko vlasništvo zaštićeni s *actio in rem*.

Peregrinsko vlasništvo je vlasništvo slobodnih stanovnika provincija na zemlji, koju bi im Rimljani nakon osvajanja ostavili, i na ostalim dijelovima imovine. Vlasničke odnose na toj imovini reguliralo je *ius gentium* i lokalni običaji provincije.

Vremenom se u provincijama počeo stvarati jedinstveni sustav vlasništva po uzoru na rimski, što je bila posljedica romanizacije provincija, podjeljivanja rimskog prava građanstva Karakalnim ediktom, stapanja civilnog i honorarnog prava, kao i carskog zakonodavstva koje je vrijedilo najčešće za cjelokupni državni teritorij.

Justinijan je izbrisao sve razlike i stvorio jedan **jedinstveni oblik vlasništva** za cijelu državu (*dominium* ili *proprietas*) za koji je predviđena **neformalna tradicija** kao redoviti način prenošenja i vlasnička tužba ***rei vindicatio*** kao sredstvo zaštite.

§ 38 – Ograničenja vlasništva

Vlasništvo može biti podložno ograničenjima kako s obzirom na druge vlasnike tako i u javnom interesu.

Ograničenja vlasništva s obzirom na druge vlasnike uglavnom se vrše **u interesu susjeda** i pogađaju vlasnike zemljišta. **Ovlasti, dužnosti i zabrane u izvršavanju prava vlasništva na nekretninama koje međusobno graniče, ili se nalaze u neposrednoj blizini, obuhvaćene su zajedničkim nazivom susjedovno pravo.** Većina tih ograničenja predviđena je već Zakonikom XII ploča. Tako je susjed morao trpjeti da vlasnik susjednog zemljišta svakog drugog dana pokupi plodove koji bi pali na njegovo zemljište; morao je trpjeti grane stabala koje su visile nad njegovim zemljištem u visini od najmanje 15 stopa, ali ne i one iznad zgrade; prilaz do groblja, koji je bio moguć samo preko tuđeg zemljišta, morao je uz primjerenu naknadu biti ustupljen kao zakonska služnost (*iter ad sepulchrum*); nijedan susjed bez suglasnosti drugih nije smio mijenjati prirodni tok voda na svom zemljištu, inače je mogao biti tužen na temelju *actio aquae pluviae arcendae*; vlasnik zemljišta, kojem je prijetila šteta zbog manjkavog stanja susjednog zemljišta ili zgrade na njemu, mogao je od vlasnika susjednog zemljišta tražiti osiguranje stipulacijom da će mu naknaditi štetu koja bi mogla nastupiti (*cautio damni infecti*); ili je mogao zahtijevati zabranu daljnje gradnje zgrade (*operis novi nuntiatio*) na susjednom zemljištu koja bi ugrožavala neko njegovo pravo (npr. služnost *altius non tollendi*) ili sigurnost njegove zgrade, odnosno zemljišta.

Od posebne je važnosti uvođenje zabrane štetnih imisija. **Imisije (*immissio*) su utjecaji koje plinovite, krute ili tekuće tvari što dolaze s jedne nekretnine imaju na korištenje susjednih nekretnina.** Nitko nije bio dužan trpjeti sa susjednog zemljišta štetne imisije kao što su dim, voda, neugodni mirisi, čađ, prašina ukoliko bi premašivali uobičajenu mjeru.

Ograničenja vlasništva u javnom interesu postojala su uglavnom na temelju građevno-redarstvenih propisa, te u svrhu održavanja javnih cesta i vodovoda. Vlasnik zemljišta morao je dopustiti kopanje ruda na svom zemljištu uz naknadu 1/10 koristi od toga.

Rimsko pravo poznavalo je i ustanovu oduzimanja vlasništva, tj. eksproprijaciju. **Eksproprijacija (*publicatio bonorum*) je prisilno oduzimanje vlasništva privatnika koje vrši država zbog općih potreba.**

Pored navedenih ograničenja vlasništva, vrijedilo je načelo da se nijedan vlasnik ne smije služiti svojim pravom isključivo zato da bi štetio drugome (*animo nocendi*). Premda rimski pravници nisu razradili problem šikane, vremenom je ipak napušteno shvaćanje da onaj koji se koristi svojim pravom nikoga ne vrijeđa (D.50.17.55: “*Nullus videtur dolo facere, qui suo*

iure utitur) jer je prevladala ideja da se ne treba koristiti svojim pravom sa zlom namjerom (G.1.53: “*Male enim nostro iure uti non debemus*”) i da nema opravdanja za onoga koji upotrebljava svoje pravo samo zato da bi drugome nanio štetu (D.6.1.38: “*Malitiis non est indulgendum*”). Teorijsku zabranu šikane postavila je tek srednjovjekovna znanost pod nazivom djelanja *ad aemulationem*. **Aemulatio** (šikana, šikaniranje) je korištenje vlastitim pravom, tako da se drugome nanosi šteta i prave smetnje, bez ikakve koristi za titulara.

§ 39 – Suvlasništvo (*condominium*)

Suvlasništvo (*condominium, comproprietas*) je vlasništvo više osoba na istoj fizički nepodijeljenoj stvari, po dijelovima koji su alikvotno (idealno) određeni.

Suvlasništvo može nastati pravnim poslovima *inter vivos* (ugovorom, npr. više osoba zajedno kupi određenu stvar) ili *mortis causa* (oporukom, više osoba naslijedi istu stvar); odlukom državnog organa (dodjelom zemljišta dvjema osobama); zakonom (zakonsko nasljeđivanje; miješanje stvari; izrastanje drveta na međi). Suvlasništvo koje nastaje mimo volje suvlasnika naziva se *communio incidens* i spada u kvazikontrakte.

Svaki od suvlasnika ima pravo samo na jedan dio stvari, ali se tu ne radi o stvarnom (realnom ili fizičkom) dijelu, nego o apstraktnom (idealnom ili alikvotnom) dijelu koji se izražava razlomkom ili postotkom. **Alikvotni dio je samostalna stvar u pravnom prometu**, što znači da može biti predmetom pravnih poslova (prodaje, darovanja, zaloge, miraza). Svaki suvlasnik može samostalno raspolagati svojim alikvotnim dijelom, ali ne može sklapati pravne poslove i vršiti stvarna raspolaganja koja se odnose na stvar kao cjelinu. Za takva raspolaganja potrebna je suglasnost svih suvlasnika, što je Justinijan zamijenio većinom, ne prema broju suvlasnika, nego prema veličini udjela. Iznimno, popravak zajedničke zgrade mogao je poduzeti svaki suvlasnik bez prethodne suglasnosti ostalih i tražiti od ostalih suvlasnika naknadu. U razmjeri svog idealnog dijela suvlasnik je sudjelovao u raspodjeli plodova i snošenju troškova. Vlasništvo na plodovima stječe već separacijom.

Za raskid suvlasničke zajednice predviđene su sljedeće tužbe: ***actio familiae erciscundae*** (ako je suvlasništvo nastalo nasljedstvom); ***actio finium regundorum*** (diobna tužba za uređenje međa između susjednih zemljišta) i ***actio communi dividundo*** (ako je nastalo na drugi način). U formuli tužbe *communi dividundo* sadržana je *adiudicatio* na temelju koje je sudac mogao naložiti fizičku diobu stvari i uređenje drugih odnosa između suvlasnika (pitanje plodova, troškova, odgovornosti za štetu).

Treće poglavlje

NAČINI STJECANJA VLASNIŠTVA

§ 40 – Stjecanje vlasništva

Stjecanje vlasništva temelji se na pravnim činjenicama (pravnim poslovima ili drugim ljudskim radnjama i prirodnim događajima) kojima pravni poredak priznaje takav učinak.

Na pitanje kako smo stekli pravo vlasništva na nekoj stvari, najčešće odgovaramo da smo je kupili, dobili na dar, naslijedili, da smo ubrali plodove na našoj njivi, da smo je dobili razmjenom, da je ona već dugo u našem posjedu i slično. Ti odgovori najčešće polaze od pravne osnove (*iustus titulus; iusta causa*) temeljem koje je stvar stečena (kupoprodaje, darovanja, razmjene, vlasništva na plodonosnoj stvari, nasljedstva). Rimsko je pravo poznavalo veći broj načina za stjecanje vlasništva od suvremenoga prava i pridavalo im, posebice u starijem razdoblju, veliki značaj. S obzirom na razliku između *ius civile* i *ius gentium* postoje *acquisitiones civiles* i *acquisitiones naturales*.

Počevši od srednjovjekovnih pravnika uobičajeno je načine stjecanja vlasništva dijeliti na originarne i derivativne.

Originarno (izvorno) stjecanje vlasništva postoji kada stjecatelj svoje pravo vlasništva stječe neovisno o pravu vlasništva prednika, pa čak i bez obzira na to je li stvar u času stjecanja uopće imala vlasnika jer je izvorno ničija ili je napuštena. Pravni poredak veže za određene pravne činjenice mogućnost izvornog stjecanja prava vlasništva (npr. kod dosjelosti). Najvažniji originarni načini stjecanja vlasništva u rimskom pravu bili su: okupacija (*occupatio*), nalaz blaga (*thesaurus*), priraštaj (*accessio*), miješanje stvari (*commixtio* i *confusio*), prerada stvari (*specificatio*), stjecanje plodova, dosjelost (*usucapio*).

Derivativno (izvedeno) stjecanje vlasništva postoji kada stjecatelj svoje vlasništvo izvodi, tj. temelji na pravu prijašnjeg vlasnika. Dosadašnji vlasnik na temelju pravnog posla prenosi pravo vlasništva na novog vlasnika. Stjecatelj će steći pravo vlasništva samo ako je otudivatelj bio vlasnik. Zato **za derivativne načine stjecanja vlasništva vrijedi načelo da nitko na drugoga ne može prenijeti više prava nego što ga sam ima (*Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*).** Najvažniji derivativni načini stjecanja vlasništva bili su: *mancipatio*, *in iure cessio* i *traditio*.

§ 41 – Originarno stjecanje vlasništva

Originarno (izvorno) stječe se pravo vlasništva kada stjecatelj svoje pravo vlasništva ne zasniva na pravu vlasništva prednika.

1. Okupacija (*occupatio*)

Okupacija (*occupatio*) je stjecanje vlasništva na stvari koja ne pripada nikome, uzimanjem stvari u posjed s voljom učiniti je svojom (*res nullius cedit occupanti*).

Okupacija je najstariji originarni način stjecanja vlasništva. Bila je moguća na stvarima koje nisu imale vlasnika (*res nullius*), kao što su divlje životinje, ptice i ribe; biseri i drago kamenje nađeno u moru ili na obali mora; otok nastao u moru (*insula in mari nata*); *res derelictae* (stvari koje su vlasnici odbacili s namjerom odreknuća od prava vlasništva), te na stvarima neprijatelja, kao i sami neprijatelji (*occupatio bellica*).

2. Nalaz blaga (*thesaurus*)

Blago (*thesaurus*) predstavljaju pokretne stvari veće vrijednosti, čiji vlasnik više nije poznat. Od vremena Hadrijana vrijede sljedeća rješenja glede nalaza blaga: blago pronađeno na svom zemljištu u cjelini pripada vlasniku zemljišta; blago koje je slučajno pronađeno na tuđem zemljištu, dijelilo se na jednake dijelove između nalaznika i vlasnika zemljišta. Nalaznik nije imao pravo sudjelovati u raspodjeli blaga ako ga je tražio namjerno ili unatoč zabrani vlasnika zemljišta.

3. Priraštaj (*accessio*)

Priraštaj (*accessio*) je stjecanje vlasništva spajanjem stvari različitih vlasnika u novu cjelinu, pri čemu uzgredna stvar, sjedinjenjem s glavnom stvari, prestaje biti samostalni predmet vlasništva. Vlasnik novonastale cjeline je vlasnik glavne stvari. Koja je stvar glavna, a koja uzgredna određivalo se od slučaja do slučaja, rukovodeći se odnosom “što čemu služi” (“*quid cui servit*”), odnosno glavnom je stvari smatran onaj dio koji je odražavao suštinu i bit cjelokupne nove stvari.

Slučajevi akcesije obuhvaćaju sjedinjenje pokretnih stvari s pokretnim, pokretnih s nepokretnim i spajanje između nepokretne stvari i dijelova druge nepokretne stvari.

Priraštaj pokretnih stvari postoji kada se jednoj stvari kao osnovnoj doda druga, tako da obje stvari pripadnu vlasniku važnije od njih (npr. na tuđem materijalu se nešto naslika ili napiše; tuđom bojom oboji se tkanina; tuđi konac utka se u sukno, zavari se tuđi materijal u vlastitu stvar, i sl.).

Osnovni slučajevi spajanja **pokretnih stvari s nepokretnim** su: *satio* (sijanje na tuđem zemljištu), *implantatio* (sađenje na tuđem zemljištu) i *inaedificatio* (građenje na tuđem zemljištu, ili građenje tuđim materijalom na vlastitom zemljištu). Za navedene slučajeve vrijedi pravilo ***superficies solo cedit***, tj. sve što je posijano, posađeno i sagrađeno na tuđem zemljištu, ili izgrađeno tuđim materijalom na svom zemljištu pripada vlasniku zemljišta jer se zemljište smatra glavnom stvari. Raniji vlasnik građevinskog materijala, koji bi netko ugradio u kuću podignutu na svom zemljištu, nije mogao tražiti njegovo izlučenje putem *actio ad exhibendum* (tužbom kojom raniji vlasnik uzgredne stvari može tužiti vlasnika cjelokupne stvari i tražiti izlučenje), nego je samo s *actio de tigno iuncto* mogao tražiti dvostruku vrijednost ugrađenog materijala.

Priraštaj nepokretne stvari i dijelova druge nepokretne stvari postoji kada rijeka naslaže nanos uz obalu i time uveća zemljište uz obalu (*alluvio*); kada rijeka odnese komad zemljišta zajedno s drvećem, pa ono pusti korijenje u zemljište na koje je taj komad donijet, donijeta zemlja pripada vlasniku zemljišta na koji je donijeta (*avulsio*); kada rijeka napusti svoje korito (*alveus derelictus*) i kada se pojavi otok u rijeci (*insula in flumine nata*) vlasnici priobalnih zemljišta dijele korito, odnosno otok, po liniji povučenoj sredinom rijeke.

4. Miješanje stvari (*commixtio, confusio*)

Miješanje pokretnih tvrdih stvari (npr. žita – *commixtio*) ili **tekućina** (npr. vina, ulja – *confusio*) predstavlja poseban slučaj originarnog stjecanja vlasništva. Miješanjem takvih stvari ne nastaje nova stvar, nego dolazi do suvlasništva ako je do miješanja došlo voljom vlasnika, ili, ako je do miješanja došlo bez njihove volje, svaki od vlasnika zadržava svoje pravo vlasništva na pomiješanom dijelu, te ako je razdvajanje moguće, stajala im je na raspolaganju tužba za izlučenje – *actio ad exhibendum* i vlasnička tužba – *rei vindicatio*, a ako razdvajanje nije bilo moguće, svaki je vlasnik mogao zahtijevati samo odgovarajući dio stvari.

5. Prerada stvari (*specificatio*)

Prerada stvari (*specificatio*) predstavlja poseban slučaj akcesije. Kod prerade stvari dolazi do **sjedinjavanja tuđeg materijala i rada samog prerađivača** (npr. netko od tuđe kože napravi cipele; od tuđeg zlata napravi prsten). Na pitanje treba li nova stvar pripasti vlasniku materijala ili prerađivaču, Sabinovci su odgovarali da treba pripasti vlasniku materijala, ali je vremenom prevladalo mišljenje Prokulovaca koji su davali prednost radu. Prerađivač je uvijek bio obvezan naknaditi vlasniku vrijednost materijala. Rješenje Justinijanovog prava glasi: ako nova stvar može biti vraćena u prijašnje stanje, pripada vlasniku materijala, a ako to nije bilo moguće, pripada prerađivaču ako je bio *bona fide*.

6. Stjecanje plodova

Odvajanjem od plodonosne stvari plodovi postaju samostalne stvari, pa time i predmet samostalnog prava vlasništva, koje je ustanovljeno odvajanjem ploda. Ako se plodonosna stvar nalazila u posjedu vlasnika, vlasnik će već u momentu odvajanja (separacije) steći pravo vlasništva na plodovima. Međutim, drukčije vrijedi ako je vlasnik određenim pravnim poslovima prenio pravo ubiranja plodova na druge osobe (npr. na temelju dugoročnih ili kratkoročnih ugovora o zakupu zemljišta, ugovora o antihrezi, ili na temelju plodouživanja), ili ako je bez svog pristanka bio lišen posjeda stvari, pa time nije bio u mogućnosti koristiti se plodovima stvari.

U slučaju da je zemljište bilo dato u dugoročni zakup sa stvarnopravnim učinkom (*ius in agro vectigali, emphyteusis*), **vektigalist, odnosno emfiteuta stjecali su vlasništvo na plodovima već separacijom ili odvajanjem od plodonosne stvari i pri tome su imali prednost pred vlasnikom**. Slično vrijedi i za **poštenog posjednika** (*possessor bonae fidei*) koji je stjecao vlasništvo na plodovima u momentu separacije kao nagradu za obradu i brigu o zemljištu (I.2.1.35: “*pro cultura et cura*”). U razdoblju postklasičnog prava poštenu je posjednik morao vratiti vlasniku plodove koje još nije potrošio (*fructus extantes*). Nepošteni posjednik (*possessor malae fidei*) nije imao pravo stjecati plodove i vlasniku je odgovarao ne samo za ubrane (*fructus percepti*) i potrošene plodove (*fructus consumpti*) nego i za plodove koje je propustio ubrati (*fructus percipiendi*).

Kratkoročni zakupnici zemljišta, plodouživatelji i ovlaštenici na temelju ugovora o antihrezi stjecali su vlasništvo na plodovima tek percepcijom (uzimanjem plodova u svoju faktičnu vlast).

7. Dosjelost (*usucapio*)

Dosjelost²¹ (usucapio) je originarni način stjecanja vlasništva posjedovanjem određene stvari kroz određeno vrijeme uz pravno priznati naslov i dobru vjeru.

Osnovni cilj ovog instituta je usklađivanje faktičnog stanja koje već duže traje s pravom kako bi se spriječili sporovi oko pitanja prava vlasništva na nekim stvarima. Dakle, na temelju upotrebe stvari (*usucapio* od *usu capere* – steći upotrebom), tj. vršenjem faktične vlasti na stvari, posjednik je mogao steći pravo vlasništva ako je ispunjavao i druge zakonom propisane uvjete. Po starom civilnom pravu ti uvjeti nisu bili strogi: Zakonik XII ploča propisivao je da rimski građani mogu steći pravo vlasništva ako su bez prekida imali pokretnu stvar u svojoj faktičnoj vlasti godinu dana, a zemljišta dvije godine, bez obzira na koji su način došli u posjed tih stvari. Sporno je, je li već Zakonikom XII ploča zabranjena dosjelost na ukradenim i silom otetim stvarima. *Lex Atinia* iz II. st.p.n.e. određuje da na ukradenim stvarima ni kradljivac niti bilo koja treća osoba koja je ukradenu stvar stekla u dobroj vjeri, ne može putem dosjelosti steći pravo vlasništva, a *lex Iulia et Plautia* iz I. st. p.n.e. izuzima od dosjelosti silom otete stvari. Ovako blagi uvjeti razumljivi su u razdoblju starog civilnog prava kada je privatno vlasništvo tek stvarano i kada je trebalo dokazati i učvrstiti pravo vlasništva na zemljištu stečenom prigrabljivanjem gentilnog zemljišta i imovine opljačkane u ratu.

U izmijenjenim prilikama razdoblja klasičnog prava dosjelost ima za cilj spriječiti zloupotrebe koje su omogućavale stjecanje vlasništva putem pljačke i krađa. Osim toga, sve se češće događalo da se *res Mancipi* prenesu prostom tradicijom, ili da se stvar stekne od osobe koja nije imala pravo vlasništva. U oba slučaja nedostaci su trebali biti ispravljeni putem dosjelosti, tj. stjecatelj, koji je postao samo poštenu posjednik, protekom vremena postati će vlasnik stvari. Zbog toga su postavljeni novi uvjeti za dosjelost. To su: ***res habilis***, ***titulus***, ***fides***, ***possessio*** i ***tempus***.

Res habilis. Predmet dosjelosti mogle su biti stvari sposobne za privatno vlasništvo, ukoliko se nije radilo o stvarima na kojima je *usucapio* bila zabranjena. Dakle, dosjelost nije bila moguća na stvarima koje su bile izvan pravnog prometa (*res extra commercium*), na ukradenim stvarima (*res furtivae*), na silom otetim stvarima (*res vi possessae*), na *res Mancipi* koje je žena otuđila bez tutorova odobrenja, na stvarima pupila i minora, na zemljišnim

²¹ Hausmaninger, H., *Die bona fides des Ersitzungsbesitzers im klassischen römischen Recht*, Wien, 1964; Bauer, K., *Ersitzung und Bereicherung im klassischen römischen Recht*, Berlin, 1988; Flume, W., *Rechtsakt und Rechtsverhältnis*, Paderborn, 1990.

međama, na stvarima dobivenim u prekarij, na provincijskim zemljištima, na stvarima brodolomnika.

Titulus (iustus titulus, iusta causa). Posjed je morao biti zasnovan na valjanoj pravnoj osnovi, a to je najčešće pravni posao čiji je cilj prijenos vlasništva. Zbog određenih nedostataka u ovlastima stranke ili u načinu prenošenja taj pravni posao nije rezultirao prijenosom vlasništva, nego samo posjeda (*res Mancipi* nije prenesena na propisan način; stvar je stečena od nevlasnika).

Bona fides. Posjednik mora biti u uvjerenju da je stekao vlasništvo, tj. mora se nalaziti u oprostivoj bludnji o valjanosti pravne osnove stjecanja stvari. Posjednik nije bio svjestan činjenice da su postojali nedostaci u načinu stjecanja zbog kojih nije postao vlasnik stvari. Za stjecanje *res Mancipi* tradicijom nije se tražila bludnja. Pošteni posjednik mogao je putem dosjelosti steći pravo vlasništva premda je znao da *res Mancipi* nije prenesena na propisani način. *Bona fides* mora postojati u času uzimanja stvari u posjed. Za dosjelost nema nikakva značaja ako posjednik kasnije sazna za nevaljanost svog stjecanja, sukladno načelu da kasnije pridobila nesavjesnost ne škodi ("*mala fides superveniens non nocet*"). *Bona fides* uvijek se pretpostavlja, a onaj koji tvrdi suprotno, dužan je to dokazati.

Possessio. *Usucapiens* je morao imati faktičnu vlast na stvari i volju stvar zadržati za sebe (*corpus et animus rem sibi habendi*) sve vrijeme trajanja roka potrebnog za dosjelost. Ako bi izgubio posjed stvari, makar samo jedan dan, nastupio bi tzv. prekid, i do tada proteklo vrijeme bi propalo. Ako bi *usucapiens* ponovno došao u posjed stvari, počeo bi teći novi rok. Pokretanje vlasničke tužbe (*rei vindicatio*) nije dovodilo do prekida dosjelosti. Do prekida dosjelosti dovodila je samo presuda.

Tempus. Rok za dosjelost i po klasičnom pravu iznosio je jednu godinu za pokretne i dvije godine za nepokretne stvari. Već od Zakonika XII ploča vrijeme proteklo za dosjelost bilo je uračunavano univerzalnim sukcesorima, a od klasičnog prava pribrajanje vremena prethodnika (*accessio temporis*) bilo je omogućeno i singularnim sukcesorima.

Kako se institut dosjelosti (*usucapio*) nije mogao primijeniti na provincijska zemljišta, krajem II. stoljeća uvedeno je novo pravno sredstvo – **longi temporis praescriptio**, kojim su zaštićeni dugotrajni posjednici zemljišta. Posjednik zemljišta mogao je odbiti vlasnikovu tužbu ako bi uložio **prigovor** da je u posjedu zemljišta već 10 godina (ako su posjednik i vlasnik živjeli u istoj provinciji), odnosno 20 godina (ako su posjednik i vlasnik živjeli u različitim provincijama). *Longi temporis praescriptio* ima, dakle, **učinak zastare vlasničke tužbe**. Tražila se *iusta causa* i *bona fides*.

U **Justinijanovom pravu** dolazi do stapanja instituta *usucapio* i *longi temporis praescriptio*. **Longi temporis praescriptio** služila je za dosjelost na **nekretninama** uz rokove od 10, odnosno 20 godina, dok je **usucapio** bila dosjelost na **pokretnim stvarima**, za koju se tražio rok od tri godine.

Postoji i *longissimi temporis praescriptio*, kojom je Justinijanovo pravo dopustilo stjecanje prava vlasništva posjednicima koji su, bez pravne osnove, posjedovali zemljište 30 ili 40 godina.

§ 42 – Derivativno stjecanje vlasništva: vlasništvo prednika, *iustus titulus* i *modus acquirendi*

Derivativno (izvedeno) stjecanje vlasništva postoji u slučaju kada stjecatelj svoje pravo vlasništva izvodi iz prava vlasništva svoga prednika. Izvedeno je stjecanje, stjecanje temeljem pravnih poslova, uglavnom ugovora, čiji je cilj (*causa*) stjecanje prava vlasništva.

Međutim, za stjecanje prava vlasništva nije dovoljan samo ugovor (pravna osnova), nego se mora izvršiti i određeni postupak koji pravni poredak zahtijeva da bi se ustanovilo pravo vlasništva na određenoj stvari. Samim ugovorom ne stječe se vlasništvo na stvari, nego samo obveznopravni zahtjev na predaju stvari. Tek nakon predaje stvari stječe se pravo vlasništva ako je **otudivatelj (prednik) bio vlasnik**.

Iustus titulus (iusta causa) je pravni posao u kojem je očitovana volja stranaka da se prenese pravo vlasništva. Uvijek se mora raditi o pravnom poslu čiji je cilj (*causa*) stjecanje prava vlasništva (npr. kupoprodaja, darovanje, razmjena, ali to ne mogu biti poslovi čiji cilj nije stjecanje prava vlasništva, kao što su npr. posudba, ostava, najam, zakup).

Modus acquirendi je postupak koji pravo zahtijeva da bi se ustanovilo pravo vlasništva na određenoj stvari. Danas se većina stvari stječe neformalnom predajom, a samo se za neke stvari (kuće, zemljište, brodove) traži poseban postupak (npr. za nekretnine je potreban upis vlasništva u zemljišnoj knjizi u korist stjecatelja). Dakle, vlasništvo je stečeno tek kada se steknu oba elementa: osnova (*iustus titulus, iusta causa*) i način (*modus acquirendi*).

1. Mancipatio

Mancipacija (*mancipatio*) je najvažniji derivativni način stjecanja vlasništva po propisima civilnog prava. **Mancipacija je svečani formalistični pravni čin koji je služio za prijenos kviritskog vlasništva na res Mancipi.** Poznaje je već Zakonik XII ploča. Kako je postojala u vrijeme kada su kao platežno sredstvo služili komadi bakra, predstavljala je realnu kupoprodaju, tj. neposrednu zamjenu prodane stvari za komade bakra (*aes*). U aktu mancipacije morali su sudjelovati mancipant – otuđivatelj, mancipatar – stjecatelj, osoba koja je držala vagu na kojoj su vagani komadi bakra ili bakarne šipke (*libripens*) i petorica svjedoka – rimskih građana. Na mjestu gdje se vršila mancipacija morao je biti i predmet na kojem se htjelo prenijeti pravo vlasništva, ili njegov simbol (npr. crijep sa kuće; grumen zemlje sa zemljišta). Mancipatar je, držeći rukom predmet, morao izgovoriti svečanu formulu kojom je tvrdio da je stvar postala njegova (*nuncupatio*) i predao bi komad bakra mancipantu kao simboličnu cijenu. Otudivatelj bi šutio i tako priznavao kupčevu tvrdnju.

Kada je polovicom IV. stoljeća uveden kovani novac određene vrijednosti, nije više bilo potrebno vagati bakrene šipke. Mancipacija je od tada postala simbolični akt (*imagitaria venditio*) za koji je civilno pravo vezivalo učinke prijenosa kviritskog vlasništva. Kako je dobila značaj **apstraktnog pravnog čina**, bila je podesna za prijenos vlasništva iz bilo kog naslova (kupoprodaje, miraza, zajma, darovanja); za zasnivanje osobnopravne vlasti: muževljeve vlasti nad ženom (*coemptio*), za zasnivanje (*adoptio*) i oslobađanje od očinske vlasti (*emancipatio*), za oslobađanje od obveze (*solutio per aes et libram*), za oporučivanje (*testamentum per aes et libram*).

Mancipant je morao jamčiti mancipataru za **evikciju**. Ako bi treća osoba podigla vlasničku tužbu tvrdeći da je mancipirana stvar njezino vlasništvo, mancipatar je imao pravo pozvati mancipanta da se upusti u spor s navodnim kviritskim vlasnikom. Ukoliko bi to mancipant odbio, ili ako bi spor izgubio, mancipatar je mogao podići *actio auctoritatis* na temelju koje bi dobio dvostruku vrijednost evinciranog predmeta. Ako je bilo mancipirano zemljište, pa se kasnije pokazalo da je zemljište manje veličine nego što je mancipant tvrdio, mancipatar je mogao na temelju *actio de modo agri* dobiti dvostruku vrijednost nedostajuće površine.

U razdoblju postklasičnog prava mancipacija je izgubila praktičnu važnost da bi u Justinijanovom pravu bila i formalno ukinuta i zamijenjena tradicijom.

2. *In iure cessio*

In iure cessio je derivativni način stjecanja vlasništva po civilnom pravu koji se sastojao u prividnoj parnici (lis imaginaria) radi priznanja vlasništva. Odvijala se uz sudjelovanje pretora, dotadašnjeg vlasnika (*in iure cedens*) i stjecatelja (*vindicans*). Stjecatelj bi izgovorio svečanu formulu prisvajanja (*vindicatio*) kojom je tužitelj u postupku legisakcije *in rem* otvarao postupak. Ako dotadašnji vlasnik ne bi izgovorio formulu protutvrđnje (*contravindicatio*), pretor bi dosudio stvar stjecatelju (*addictio*). Time bi ta fiktivna parnica završila.

Zbog svoje se apstraktnosti *in iure cessio* koristila u različite svrhe. Služila je za prijenos vlasništva na *res Mancipi* i *res nec Mancipi*, te za osnivanje, prijenos i ukidanje prava. Posebice je značajna za osnivanje i ukidanje služnosti, za ustupanje nasljedstva, za oslobađanje robova (*manumissio vindicta*).

Kako *in iure cessio* predstavlja uistinu fiktivnu parnicu o vlasništvu, otuđivatelj nije odgovarao za evikciju, što znači da na osnovi *in iure cessio* nisu nastajale *actio auctoritatis* i *actio de modo agri*. Zbog toga je *in iure cessio* iščezla iz prakse puno ranije nego *mancipatio*.

3. Traditio

Traditio (predaja stvari) je neformalan, kauzalan i derivativan način stjecanja vlasništva po ius gentiumu, koji se vrši predajom posjeda stvari. Tradicijom se prenosilo kviritsko vlasništvo na *res nec Mancipi* i pretorsko (bonitarno) vlasništvo na *res Mancipi*. Kada je u Justinijanovom pravu konačno ukinuta razlika između *res Mancipi* i *res nec Mancipi*, tradicija je postala jedini derivativni način stjecanja jedinstvenog privatnog vlasništva.

Tradicija se vrši ustupanjem faktične vlasti na stvari, tj. predajom posjeda na stvari, za koju nije bila potrebna nikakva posebna forma. Ipak, svaka predaja stvari neće dovesti do zasnivanja prava vlasništva. Da bi putem tradicije došlo do stjecanja vlasništva, moraju se ispuniti **određeni uvjeti**. To su: **1. sposobni subjekti tradicije; 2. volja subjekata o prijenosu, odnosno zasnivanju prava vlasništva; 3. pravna osnova tradicije (*iusta causa traditionis*); 4. predaja stvari.**

Kod svake tradicije moraju postojati dva subjekta: otuđivatelj stvari (*tradens*) i stjecatelj (*accipiens*). Stvar je morala biti u vlasništvu otuđivatelja, da bi stjecatelj putem tradicije stekao pravo vlasništva. Za tradiciju, kao i za druge derivativne načine stjecanja vlasništva vrijedi načelo da nitko na drugoga ne može prenijeti više prava nego što ga sam ima. ***Tradens*, dakle, mora biti vlasnik stvari da bi mogao prenijeti vlasništvo na**

stjecatelja. Subjekti tradicije mogli su biti ne samo rimski građani, nego i ostali slobodni stanovnici rimske države kojima je *ius gentium* priznavalo imovinsku sposobnost.

Subjekti tradicije morali su očitovati volju da žele otuđiti stvar, odnosno steći vlasništvo na njoj. Kod otuđivatelja je morala postojati volja prenijeti vlasništvo na stvari (*animus dominii transferendi*), a kod stjecatelja volja primiti stvar u vlasništvo (*animus dominii adquirendi*).

Da bi tradicija bila valjana, **volja subjekata morala je biti zasnovana na pravnom razlogu (*iusta causa traditionis*).** Kao *causa* vrijedio je svaki pravni akt koji je bio usmjeren na stjecanje vlasništva (kupoprodaja, darovanje, razmjena, obećanje miraza, zajam, namirenje duga).

Za stjecanje vlasništva putem tradicije tražio se sam **akt predaje stvari**, koji je vršen na načine predviđene za derivativno stjecanje posjeda stvari (vidi § 36, t. 4).

Četvrto poglavlje

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA

§ 43 – Vlasničke tužbe

Za zaštitu vlasništva predviđena su mnogobrojna pravna sredstva čiji je cilj zaštititi vlasnika od svakog uznemiravanja i omogućiti mu nesmetano uživanje stvari. Vlasnik može biti ometan u vršenju svojih ovlasti na dva načina: **oduzimanjem posjeda stvari**, kada će podići vlasničku (petitornu) tužbu i putem nje tražiti natrag posjed stvari i **uzurpiranjem nekih prava na korištenje stvari**, koja uistinu ne postoje (npr. prava služnosti), i u tom slučaju vlasniku na raspolaganju stoji *actio negatoria*. Vlasnici su se mogli poslužiti i cijelim nizom drugih pravnih sredstava predviđenih za zaštitu posjednika i detentora, koja su često bila brža i jednostavnija od vlasničkih tužbi.

1. *Rei vindicatio*

*Rei vindicatio*²² je najvažnija tužba za zaštitu kviritskog vlasništva, a od Justinijanova prava, kada je uveden jedinstveni tip vlasništva, to je opća vlasnička tužba. Naziv je dobila po vindikaciji (*vindicatio*), tj. tužiteljevoj tvrdnji o vlasništvu, kojom je započinjao postupak na temelju legisakcije *sacramento in rem*.

Rei vindicatio je tužba kojom je vlasnik, koji nije bio u posjedu stvari, tužio posjednika svoje stvari i tražio priznanje vlasništva i vraćanje posjeda.

U reivindikacijskoj parnici **tužitelj je vlasnik koji je izgubio posjed stvari, a tuženik je posjednik koji vlasniku poriče njegovo pravo na stvar**. Cilj parnice je utvrditi tko je od njih vlasnik. U klasičnom pravu tuženik je mogao biti samo posjednik stvari, a u postklasičnom pravu mogao je biti tužen i detentor. Međutim, ako su se posjed, odnosno detencija temeljili na obveznom odnosu između vlasnika i posjednika, odnosno detentora (npr. najmu, zakupu, ostavi, posudbi) ili na odobrenom stvarnom pravu na tuđoj stvari (npr. *ususfructus*, založno pravo) vlasnik je morao podići tužbu iz onog pravnog odnosa na osnovi kojeg je prepustio posjed, odnosno detenciju (npr. *actio locati*, *actio depositi*, *actio commodati*, *actio pigneraticia*), a ne reivindikaciju jer bi bio odbijen tuženikovim prigovorom.

U **legisakcijskom postupku** obje su stranke morale ustvrditi svoje pravo vlasništva da bi došlo do parnice. Stranka koja je izgubila spor, gubila je i okladu (*sacramentum*), a obveza vraćanja stvari ležala je na jamcima koje je tuženi posjednik imenovao na početku parnice. U **formularnom postupku** presuda je glasila na novčanu protuvrijednost stvari (*condemnatio pecuniaria*), koja je ustanovljivana na temelju procjene samog tužitelja, učinjene pod prisegom (*iusiurandum in litem*; *litis aestimatio*). Tužitelj je ipak mogao na posredan način doći do stvari jer je formula sadržavala tzv. arbitrarnu klauzulu (*clausula arbitraria*) kojom je tuženik pozivan da vrati stvar. Ako tom zahtjevu ne bi udovoljio, osuđivan je na njezinu novčanu protuvrijednost. Za razliku od formularnog, u **ekstraordinarnom je postupku** presuda glasila na vraćanje stvari i izvršavana je prinudnim oduzimanjem stvari od strane državnih organa (*manu militari*) i predajom tužitelju.

U vlasničkoj parnici tužitelj mora dokazati: 1. svoje vlasništvo; 2. tuženikovu faktičnu vlast na stvari; 3. identitet stvari.

Tužitelj dokazuje svoje pravo vlasništva dokazivanjem postojanja pravnih činjenica i pretpostavki potrebnih za stjecanje prava vlasništva. **Ako tvrdi da je vlasništvo stekao originarnim putem, onda mora dokazati postojanje činjenica potrebnih za takav način**

²² Siber, H., *Die Passivlegitimation bei der rei vindicatio*, Leipzig, 1907; Kaser, M., *Restituere als*

stjecanja stvari (npr. ako tvrdi da je vlasništvo stekao dosjelošću, mora dokazati postojanje pretpostavki za dosjelost).

U slučaju da se tužitelj poziva na neki od derivativnih načina stjecanja vlasništva, mora dokazati: a) naslov stjecanja (*titulus*); b) način stjecanja (*modus*); 3) vlasništvo prednika. Najteže je dokazati vlasništvo prednika, posebice ako je i ono stečeno derivativnim putem. Tada treba ići tako daleko u dokazivanju vlasništva prethodnih vlasnika dok se ne nađe onaj koji je vlasništvo stekao originarno. Zato se to dokazivanje naziva *probatio diabolica* (“đavolski dokaz”). Da bi izbjegli tako komplicirano dokazivanje, kviritski su se vlasnici često koristili Publicijanskom tužbom (*actio Publiciana*), koja je bila zasnovana na fikciji da je rok dosjelosti već protekao.

U formularnom i ekstraordinarnom postupku **tuženik ne mora ništa dokazivati jer je teret dokazivanja na tužitelju** (“*actori incumbit probatio*”). Osim toga, sukladno pravilu “*in pari causa melior est condicio possidentis*” (ako se dvojica pozivaju na istu osnovu, u boljem položaju je onaj kod kojeg se stvar nalazi) **u korist posjednika djeluje pretpostavka da je vlasnik, dok se suprotno ne dokaže. Ako tužitelj ne uspije dokazati svoje pravo vlasništva, stvar će ostati kod tuženog posjednika.**

Položaj tuženika ili pasivnu legitimaciju u reivindikacijskom sporu ima posjednik spornog predmeta. Detentori i poštenu posjednici mogli su izbjeći položaj tuženika ako bi imenovali osobu u čije su ime držali stvar, odnosno, osobu od koje su je stekli (*laudatio* ili *nominatio auctoris*). U tim će slučajevima označene osobe imati pasivnu legitimaciju premda u datom momentu nisu bile u posjedu spornog predmeta. Pasivno legitimiranim smatran je i onaj neposjednik (*fictus possessor*) koji se zlonamjerno upustio u spor (*qui liti se obtulit*) kako bi omogućio posjedniku protek roka dosjelosti, kao i onaj koji je zlonamjerno otuđio stvar kada je saznao da će biti tužen (*qui dolo desit possidere*).

Predmetom reivindikacije mogli su biti svi predmeti na kojima se moglo zasnovati kviritsko vlasništvo. U pravilu, stvar je morala biti individualizirana. Tužitelj je morao dokazati da je vlasnik upravo one stvari koja se nalazi kod tuženika. Kako je identitet generičnih stvari teško dokazati, reivindikacijom se mogao tražiti povrat individualno određenih stvari.

Presudom nije odlučivano samo o spornom predmetu, nego i o svim potraživanjima, tzv. “*causa rei*”, koja su se mogla odnositi na: 1. povrat i naknadu plodova (ako se

radilo o plodonosnoj stvari); **2. naknadu štete** (ako je stvar bila potrošena, oštećena ili uništena); **3. naknadu troškova koje je posjednik imao na stvari**.

Ako je predmet spora bila plodonosna stvar, trebalo je riješiti **pitanje naknade plodova** kojih je vlasnik bio lišen jer je stvar bila kod posjednika. **Pošteni posjednik** (*possessor bonae fidei*) odgovara za plodove koji još uvijek postoje (*fructus extantes*) u času litiskontestacije, a nakon litiskontestacije obvezan je naknaditi vrijednost svih plodova koje je ubrao (*fructus percepti*) ili propustio ubrati (*fructus percipiendi*). **Nepošteni posjednik** (*possessor malae fidei*) mora naknaditi vrijednost svih ubranih plodova (*fructus percepti*), kao i onih koje je propustio ubrati (*fructus percipiendi*) i onih koje je potrošio (*fructus consumpti*) za sve vrijeme trajanja posjeda, i prije i poslije litiskontestacije, a nakon litiskontestacije odgovara i za plodove koje bi mogao polučiti samo vlasnik – tužitelj.

Pitanje naknade štete do koje je moglo doći na spornom predmetu rješavano je u ovisnosti o činjenici je li stvar bila kod poštenog ili kod nepoštenog posjednika. **Pošteni posjednik** morao je odgovarati za štetu koju bi stvar pretrpjela tek nakon litiskontestacije. **Nepošteni posjednik** morao je odgovarati za propast i oštećenje stvari za sve vrijeme trajanja posjeda, a nakon litiskontestacije odgovarao je i za slučajnu propast stvari.

Posjednik je mogao istaknuti **protuzahtjeve za naknadu troškova i izdataka** koje je imao na stvari. Treba razlikovati tri vrste troškova: one koji su bili **nužni za održanje stvari** (*impensae necessariae*); **korisne troškove kojima je objektivno povećana vrijednost stvari** (*impensae utiles*) i **troškove radi poljepšanja stvari i u luksuzne svrhe** (*impensae voluptuariae*). I pitanje naknade troškova rješavano je različito. **Pošteni posjednik** mogao je zahtijevati naknadu nužnih i korisnih troškova i imao je pravo zadržati stvar (*ius retentionis*) sve dok mu ih vlasnik ne naknadi. **Nepošteni posjednik** dobio je u Justinijanovom pravu pravo na naknadu nužnih troškova, kao i pravo da ono što je uložio kao *impensae utiles* može odnijeti (*ius tollendi*) ako se time stvari ne nanosi šteta. Vlasnik nije bio obvezan naknaditi troškove učinjene radi poljepšanja stvari ni poštenom ni nepoštenom posjedniku, ali se obojici priznaje *ius tollendi*.

2. Actio negatoria

Actio negatoria služila je za zaštitu kviritskog vlasništva, a podizana je u slučajevima kada kviritski vlasnik nije bio lišen posjeda stvari, niti mu je osporavano njegovo pravo vlasništva, već je neka osoba trajno i neosnovano uznemiravala vlasnika. Najčešće se radilo o svojatanju nekog stvarnog prava na vlasnikovoj stvari (npr. prava

služnosti ili založnog prava) ili je vlasnik nekretnine ometan imisijama. Tužbeni zahtjev upravljen je na prestanak uznemiravanja i daljeg smetanja. Tužitelj je morao dokazati činjenicu uznemiravanja i svoje pravo vlasništva, što mu je puno lakše nego u reivindikacijskoj parnici jer je kod negatorne tužbe tužitelj vlasnik i posjednik. Tužitelj ne mora dokazati da tuženiku ne pripada pravo koje uzurpira. Ako tuženik smatra da ima pravo poduzimati radnje kojima uznemiruje vlasnika, onda je on dužan dokazati pravo koje svojata.

Ako tuženik ne bi uspio dokazati postojanje tog prava (npr. ubirao je plodove kao da ima pravo plodouživanja, počeo je graditi kuću na tuđem zemljištu; prelazio preko tuđe livade kao da ima pravo prolaza i sl.), osuđivan je na temelju negatorne tužbe na uspostavu prijašnjeg stanja (*restitutio*), na naknadu izgubljenih koristi (*commoda*) i učinjene štete, kao i na polaganje kaucije da više neće ometati vlasnika (*cautio de amplius non turbando*).

3. *Actio Publiciana*

***Actio Publiciana*²³ služila je za zaštitu bonitarnog vlasništva, a od razdoblja Justinijanova prava upotrebljavana je za zaštitu poštenih posjednika**, nositelja prava osobnih služnosti i ovlaštenika iz dugoročnih ugovora o zakupu zemljišta. Uvedena je krajem razdoblja Republike kako bi se omogućila pravna zaštita bonitarnom vlasniku u slučaju da izgubi posjed stvari. Spada u **fikticijske tužbe** (*actio ficticia*) jer je pretor u njenoj formuli nalagao sucu da sudi kao da je rok dosjlosti već protekao, te da je zbog toga stjecatelj, koji je bio u položaju uzukapijenta, postao kviritski vlasnik. Zahvaljujući toj fikciji bonitarni je vlasnik mogao zahtijevati stvar od bilo koje osobe, uključujući i kviritskog vlasnika ako mu je taj stvar prodao.

***Actio Publiciana* koristila se i za zaštitu posjednika koji je stvar stekao u dobroj vjeri i na temelju valjanog pravnog naslova (*ex iusta causa*) od nevlasnika**. U tom slučaju način prenošenja bio je valjan, ali vlasništvo nije stečeno jer prednik nije bio vlasnik što stjecatelj nije znao, niti je mogao znati. Ako je izgubio posjed stvari, poštenu je posjednik Publicijanskom tužbom mogao stvar zahtijevati od svakog trećeg slabijeg posjednika, ali ne i od kviritskog vlasnika. Tužitelj (kvalificirani posjednik koji je izgubio posjed stvari) mora dokazati pravnu osnovu stjecanja, činjenicu da se stvar nalazi u tuženikovom posjedu i identitet stvari. Tužbeni zahtjev upravljen je na vraćanje stvari tužitelju. U slučaju spora

²³ DiLella, L., *Formulae ficticiae: contributo allo studio della riforma giudiziaria di Augusto*, Napoli, 1984.

između dva poštena posjednika koji su stvar stekli od istog otuđivatelja, jači je bio onaj kojem je stvar bila prije predana po načelu *prior tempore potior iure*. Međutim, ako su stvar stekli od različitih otuđivatelja, jačim je smatran onaj koji je stvar posjedovao u vrijeme podizanja tužbe (*beati possidentes*).

Peto poglavlje

STVARNA PRAVA NA TUĐIM STVARIMA (*IURA IN RE ALIENA*)

§ 44 - SLUŽNOSTI (*SERVITUDES*)

1. Pojam služnosti

Služnosti (*servitutes*)²⁴ su stvarna prava na tuđoj stvari na temelju kojih se dopušta određeno korištenje tuđom stvari u interesu nekog zemljišta ili neke osobe.

Često je potrebno ograničiti tuđe pravo vlasništva da bismo se mogli koristiti vlastitom stvari (npr. moramo prijeći preko tuđe livade da bismo došli do svoje njive). Zato se javljaju služnosti kao pravna sredstva kojima se uređuju i usklađuju međuvlasnički odnosi. Na temelju prava služnosti ovlaštenik ponekad ima pravo upotrebljavati tuđu stvar na određeni ograničeni način, ponekad ima pravo ubirati plodove i druge koristi od stvari, a nekada ima pravo zabraniti vlasniku služne stvari određene naprave (npr. pravo zabraniti susjedu da podigne kat na svojoj kući).

Već rano u starom se Rimu javila potreba za ustanovljenjem zemljišnih, i to poljskih (seoskih) služnosti, kako bi se omogućio nesmetan prolaz do svog zemljišta, gonjenje, napasanje i napajanje stoke, odvođenje i dovodenje vode i sl. U najstarijem razdoblju Rimljani još nisu shvaćali da se radi o posebnom stvarnom pravu, nego su **najstarije poljske služnosti (*iter, actus, via* i *aquaeductus*) smatrali za *res Mancipi* i zasnivali ih putem mancipacije. Sve ostale zemljišne služnosti** koje su nastale nakon tih, nisu smatrane za *res Mancipi* i **zasnivane su putem *in iure cessio***. Služnosti su često zasnivane i tzv. **pridržajem**, koji je ugovaran uz pravne poslove kojima je vlasnik prenosio pravo vlasništva na određenoj

²⁴ Biondi, B., *La Categoria romana delle "servitutes"*, Milano, 1938; Grosso, G., *Le servitù prediali nel diritto romano*, Torino, 1969; Sanfilippo, C., *Servitutes personales: corso di diritto romano*, Vol. I, Catania, 1960;

stvari zadržavajući za sebe pravo da se tom stvari na određeni način i ubuduće služi (*deductio servitutis*). **Zemljišne služnosti na provincijskim zemljištima zasnivane su neformalnim ugovorima (paktima) koji bi bili potvrđeni stipulacijom (*pactionibus et stipulationibus*).** U postklasičnom razdoblju služnosti su se mogle prenositi i zasnivati **običnom tradicijom i faktičnim vršenjem ukoliko bi vlasnik služne stvari to trpio (*patientia*).**

S porastom urbanizacije, nakon Punskih ratova, javljaju se zemljišne služnosti u korist stambenih objekata, kojima je svrha olakšati održavanje zgrada ili poboljšati upotrebu zgrade i građevinskog zemljišta. To su **gradske služnosti**.

Krajem razdoblja Republike nastaju **osobne služnosti**, koje je klasično pravo smatralo samostalnim pravnim ustanovama. Tek je Justinijan svrstao četiri samostalna prava na tuđoj stvari, ustanovljena u korist određene osobe, u kategoriju osobnih služnosti (*ususfructus, usus, habitatio i operae servorum vel animalium*). **Osobne služnosti osnivane su najčešće putem jednostranih naredbi (*legatom*).**

2. Opća obilježja služnosti

Premda postoji više različitih vrsta služnosti, za sve njih mogu se izvući neke opće značajke i pravila.

Služnosti su **stvarna prava**, što znači da i za njih vrijede osnovna načela i karakteristike stvarnih prava. Zaštićene su **tužbama *in rem*** koje titular prava služnosti može podići protiv bilo koje osobe, uključujući i vlasnika, koja ga sprečava u uživanju njegovih prava. U Justinijanovom pravu uvedena je jedinstvena tužba za zaštitu titulara služnosti nazvana **actio confessoria**. Tužitelj je tražio priznanje prava služnosti (*confessio* – priznanje) i otklanjanje smetnji u vršenju tog prava. Pri tome je morao dokazati postojanje služnosti, a kod zemljišnih služnosti i vlasništvo na gospodujućem zemljištu. Tužbom je postizana uspostava stanja koje odgovara tužiteljevu pravu, naknada štete, kod uzufrukta povratak plodova i davanje sigurnosti da tužitelj ubuduće neće biti smetan (*cautio de non amplius turbando*).

Služnosti su **stvarna prava na tuđoj stvari**. Ne može postojati služnost na vlastitoj stvari (*nemini res sua servit*). Kao rekadentno pravo (*ius recadentiae*), vlasništvo oživljava u punom opsegu čim se služnost ugasi, ili kada nestanu razlozi za njezino postojanje.

Služnost se ne može sastojati u činjenju (*servitus in faciendo consistere nequit*). Vlasnik poslužnog dobra nije obvezan ni na kakvo činjenje. On samo mora trpjeti (*pati*)

radnju titulara prava služnosti (afirmativna služnost), ili mora propuštati ili se suzdržavati (*non facere*) od radnji na vlastitom dobru (negativna služnost). Postoji iznimka od tog načela, a to je *servitus oneris ferendi* (služnost koja se sastoji u pravu nasloniti svoju građevinu na tuđi zid), kod koje je vlasnik služne stvari obvezan držati zid u ispravnom stanju.

Služnost ne može postojati na služnosti (*servitus servitutis esse non potest*). Titular prava služnosti ne smije konstituirati novu služnost u korist trećih osoba.

Služnosti moraju biti korisne (*utilis*). Služnost mora zadovoljavati određenu potrebu i imati razumnu svrhu.

Služnosti se moraju izvršavati obzirno (*civiliter*). Titular prava služnosti smije se koristiti svojim ovlastima tako da što manje opterećuje poslužno dobro, a vlasnik poslužnog dobra ne smije otežavati ili onemogućavati titulara u izvršavanju služnosti.

3. Vrste služnosti

Služnosti se dijele na zemljišne (stvarne, realne) i osobne.

Zemljišne služnosti (*servitutes praediorum*) su stvarna prava koja daju svakodobnom vlasniku jednog zemljišta koje se naziva povlasno ili gospodujuće dobro (*praedium dominans*) određene ovlasti nad susjednim zemljištem koje se naziva poslužno dobro (*praedium serviens*). Zemljišne služnosti su **trajna prava**, što znači da na postojanje i trajanje zemljišnih služnosti ne utječe promjena vlasnika povlasnog ili poslužnog dobra (npr. kupoprodajom, darovanjem, nasljedstvom). Zemljišna služnost je **nerazlučiva od zemljišta** jer leži na poslužnom dobru i postoji u korist svakodobnog vlasnika povlasnog dobra. Zemljišta su morala biti **susjedna** (*praedia debent esse vicinia*), ali u klasičnom pravu ovaj uvjet nije strogo shvaćan jer je veća važnost polagana na **gospodarsku korist** (*servitus fundo utilis esse debet*). Zemljišne služnosti su **nedjeljiva prava**; nisu se mogle stjecati ni gubiti po alikvotnim dijelovima (*per partes servitus neque acquiri neque imponi potest*), npr. nije moguće ustanoviti polovicu prava prelaska preko tuđe njive.

Osobne služnosti (*servitutes personarum*) su stvarna prava na tuđoj stvari koja **ovlašćuju pojedinačno određenu osobu da se na određeni način služi tuđom stvari**. Budući da se konstituiraju u interesu jedne određene osobe, **osobne služnosti vezane su za osobu titulara, ne mogu se prenijeti na drugoga** i gase se najkasnije njegovom smrću. Za razliku od stvarnih služnosti koje su neograničene, osobne služnosti su **ograničenog**

trajanja. Dok zemljišne služnosti mogu postojati samo na nekretninama, osobne služnosti **mogu se ustanoviti na stvari i imovini ma koje vrste** (nekretninama, pokretninama i robovima). Osobne služnosti su **djeljiva prava**; npr. moguće je imati trećinu ili petinu plodouživanja neke stvari.

4. Zemljišne služnosti (*servitutes praediorum*)

Zemljišne služnosti dijele se na poljske ili seoske (*servitutes praediorum rusticorum*) i gradske (*servitutes praediorum urbanorum*). Kriterij razlikovanja je priroda i namjena povlasne nekretnine. Poljske služnosti su one kod kojih je povlasna nekretnina namijenjena poljodjelskom iskorištavanju. Gradske služnosti vezane su za stanovanje.

Poljske služnosti mogu se svrstati u četiri skupine: **služnosti puta, služnosti vode, služnosti ispaše i služnosti vadenja građevinskog materijala.** Najstarije poljske služnosti bile su služnosti puta: ***iter*** (pravo prelaska pješice preko tuđeg zemljišta), ***via*** (pravo prelaska kolima), ***actus*** (pravo gonjenja stoke), te služnost vode ***aqueductus*** (pravo dovođenja ili provođenja vode kanalima preko tuđeg zemljišta u svrhu natapanja). Te su služnosti smatrane za *res Mancipi* i zasnivane su mancipacijom. Sve ostale poljske služnosti koje su nastale nakon spomenutih, nisu više smatrane za *res Mancipi*: pravo crpsti vodu koja izvire na služnom zemljištu ili koja preko njega prelazi; pravo napajati i napasati stoku; pravo praviti kreč; kopati pijesak; vaditi kredu na tuđem zemljištu.

Gradske služnosti mogu se svrstati u tri skupine: jedne **osiguravaju građenje kuća**, druge **osiguravaju svjetlo i pogled**, a treće **odvođenje kišnice i otpadnih voda**.

U skupinu služnosti koje osiguravaju **građenje kuća** spadaju služnosti koje ovlašteniku daju pravo upotrijebiti tuđi zid ili tuđi zračni prostor za potrebe svoje zgrade: *servitus oneris ferendi* (pravo prisloniti zgradu na tuđi zid); *servitus tigni immittendi* (pravo ugraditi u tuđi zid grede ili drugi građevinski materijal); *servitus prociendi* (pravo protegnuti svoj balkon ili terasu u zračni prostor nad tuđim zemljištem); *servitus protegendi* (pravo protegnuti svoj krov nad tuđim zemljištem).

U skupinu služnosti koje **osiguravaju svjetlo, zrak i pogled** spadaju: *servitus altius non tollendi* (vlasnik služnog zemljišta ne smije na tom zemljištu graditi ili podići katove na zgradi preko određene visine); *servitus ne luminibus officiatur* (vlasnik služnog zemljišta ne smije zatvoriti svjetlo gospodujućem zemljištu); *servitus ne prospectui officiatur* (vlasnik služnog zemljišta ne smije zatvoriti pogled gospodujućem zemljištu).

U treću skupinu gradskih služnosti spadaju služnosti koje osiguravaju **pravo odvođenja kišnice** na služno zemljište (*servitus stillicidii*); pravo na **odvođenje vode u većim količinama** (*servitus fluminis*) i **pravo voditi jarke za odvođenje otpadnih voda** preko služnog zemljišta (*servitus cloacae*).

5. Osobne služnosti (*servitutes personarum*)

Osobne služnosti osnivaju se u korist pojedinačno određene osobe na stvarima i imovini ma koje vrste. Klasično pravo poznavalo je četiri samostalna prava na tuđoj stvari koja su u Justinijanovom pravu svrstana u kategoriju osobnih služnosti. To su: ***ususfructus*** (služnost plodouživanja), ***usus*** (služnost upotrebe), ***habitatio*** (služnost stana) i ***operae servorum vel animalium*** (služnost upotrebe radne snage robova i životinja).

a) *Ususfructus* (pravo plodouživanja)

***Ususfructus* (plodouživanje) je osobna služnost na temelju koje plodouživatelj (*usufructuarius*) stječe pravo upotrebe tuđe stvari i ubiranja plodova, uz obvezu vraćanja suštinski neoštećene stvari vlasniku nakon prestanka plodouživanja (Paul. D.7.1.1: *Ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia*).**

Predmetom plodouživanja do razdoblja klasičnog prava mogle su biti samo **nepotrošne stvari**, a od početka Principata dopušten je uzufrukt na svim stvarima koje mogu biti predmetom imovine, pa i na potrošnim, a u Justinijanovom pravu i na netjelesnim. U tom slučaju radi se o **neredovitom plodouživanju** (***ususfructus irregularis; quasiususfructus***) kod kojega plodouživatelj postaje vlasnik potrošnih stvari, uz obvezu vraćanja ne iste stvari, nego druge stvari iste vrste, kvalitete i količine. Inače je plodouživatelj kod **redovitog uzufrukta** stjecao samo **detenciju** na predmetu plodouživanja kako bi ga mogao upotrebljavati i ubirati plodove. Uzufruktuar je imao pravo ubirati i prirodne (*fructus naturales*) i građanske plodove (*fructus civiles*). Vlasništvo na prirodnim plodovima stjecao je percepcijom (uzimanjem u posjed). Uzufruktuar je imao pravo samo na redovite prihode od stvari. Izvanredni prihodi stvari (npr. stabla oborena u oluji; polovica nađenoga blaga) pripadali su vlasniku predmeta plodouživanja.

Ususfructus je najčešće nastajao odredbom posljednje volje, tj. zapisom u svrhu opskrbe pojedinih članova obitelji, najčešće udovice.

Uzufruktuarova prava bila su zaštićena stvarnopravnom tužbom (*actio in rem*) koja se zvala ***vindicatio ususfructus***. Kasnije je plodouživatelj stekao i posjedovnu zaštitu kao tzv.

quasi-possessor. Ukoliko bi vlasnik otuđio stvar na kojoj je postojao uzufrukt, uzufruktuarova prava ostajala su neokrnjena jer su njegove ovlasti imale stvarnopravni karakter.

Uzufruktuar nije mogao prenijeti svoja prava na drugoga jer je pravo plodouživanja strogo osobne prirode. Ipak, mogao je prenijeti na drugu osobu izvršavanje sadržaja prava plodouživanja, što znači da ju je mogao ovlastiti da upotrebljava stvar i ubire njezine plodove (npr. putem zakupa, darovanja, kupoprodaje).

Plodouživatelj nije imao pravo raspolaganja sa stvari, niti je smio promijeniti njezinu supstancu, suštinu i ekonomsku namjenu (npr. iskrčiti šumu i pretvoriti je u njivu). Izmjena suštine stvari (*mutatio rei*) imala je za posljedicu prestanak plodouživanja. Predmetom plodouživanja morao se koristiti kao dobar domaćin (***bonus pater familias***), na što se vlasniku obvezivao stipulacijom prije nego što bi dobio predmet na uživanje, ujedno se obvezujući da će stvar vratiti nakon prestanka plodouživanja (*cautio usufructuaria*). Uzufruktuar je morao snositi nužne troškove održavanja predmeta, kao i javne daće.

Ususfructus je prestajao najkasnije uzufraktuarevom smrću.

b) *Usus* (pravo uporabe)

Usus (pravo upotrebe) je osobna služnost na osnovi koje je titular (*usuarius*, uporabovnik) stjecao osobno pravo upotrebljavati tuđu stvar i ubirati njezine plodove, ali samo u granicama njegovih osobnih potreba i članova njegove uže obitelji. Višak plodova pripadao je vlasniku stvari. Uzuar nije mogao prenijeti svoje pravo na drugoga, kao ni vršenje nekih ovlasti iz njega.

c) *Habitatio* (pravo stanovanja)

Habitatio (pravo stanovanja) je osobna služnost temeljem koje stanovatelj (*habitant*) stječe pravo služiti se tuđom kućom ili stanom. Ovlaštenik je smio prenijeti na drugoga izvršavanje prava, tj. bilo mu je dopušteno stan iznajmiti i za sebe zadržati najamninu.

d) *Operae servorum vel animalium*

Operae servorum vel animalium (pravo upotrebe radne snage tuđih robova i životinja) je osobna služnost na temelju koje je titular stjecao pravo koristiti se radnom snagom tuđih robova i radne stoke. Titular je mogao iznajmiti robove i životinje koji su bili predmetom te služnosti.

6. Prestanak služnosti

Služnosti su prestajale u slučaju propasti predmeta služnosti (npr. kuća, šuma, maslinik, voćnjak izgorjeli su u požaru); iscrpljenjem koristi koja je izvlačena iz opterećene stvari (npr. iscrpljenjem zaliha pijeska, kamena, kreča); odreknućem od strane titulara i njegovom smrću kod osobnih služnosti; gubitkom statusa (*capitis deminutio*) kod uzufrukta i uzusa; stjecanjem prava vlasništva i prava služnosti u jednoj osobi (*confusio*, kod uzufrukta govori se o *consolidatio*); nevršenjem prava služnosti (*usucapio libertatis*) kroz jednu ili dvije godine u ovisnosti je li služnošću bila opterećena pokretna ili nepokretna stvar, a u Justinijanovom pravu kroz deset, odnosno dvadeset godina u ovisnosti jesu li vlasnik i titular živjeli u istoj ili raznim provincijama; promjenom sućanstva stvari (*mutatio rei*) kod uzusa i uzufrukta.

§ 45 – EMFITEUZA (*EMPHYTEUSIS*)

Emfiteuza (*emphyteusis*) je stvarno, otudivo i nasljedivo pravo na tuđem zemljištu, koje ovlašteniku daje pravo na potpuno korištenje zemljišta.

Emfiteuza ima korijene u dugoročnim zakupima zemljišta koje su država, gradovi i latifundisti sklapali sa slobodnim zakupnicima. Već u republikansko i klasično doba u zapadnom dijelu Carstva bili su poznati dugoročni nasljedni zakupni odnosi (***ager vectigalis, ius perpetuum***). Na osnovi tog ugovora zakupnik je dobijao pravo iskorištavati tuđe zemljište uz obvezu plaćanja zakupnine (*vectigal*). Bio je zaštićen stvarnopravnom tužbom (*actio vectigalis*) i posesornim interdiktima. Klasični pravници taj odnos ipak nisu smatrali stvarnim pravom, nego su ga tretirali kao posebnu vrstu ugovora o zakupu.

U orijentalnim područjima bila je razvijena emfiteuza kao oblik dugoročnog ugovora o zakupu zemljišta. Predmet emfiteuze bila su neobrađena zemljišta zbog čega je emfiteuta određeno vrijeme bio oslobođen plaćanja zakupnine. U Justinijanovom pravu stopili su se emfiteuza i *ager vectigalis* u jedinstven institut nazvan *ius emphyteuticarium* ili *contractus emphyteuticarius*. **Osnovne obveze emfiteute** sastojale su se u plaćanju godišnje daće (*canon*), snošenju javnih poreza i tereta i održavanju zemljišta u urednom stanju. Ukoliko je htio otuđiti svoje pravo, morao je obavijestiti vlasnika zemljišta i zatražiti njegov pristanak. Ako se vlasnik nije htio poslužiti svojim pravom prvokupa (*ius protimiseos, ius praelationis*), emfiteuta mu je morao isplatiti 2% od postignutog iznosa (*laudemium*). Emfiteuta je imao pravo na potpuno iskorištavanje zemljišta, što znači da je mogao promijeniti kulturu zemljišta, osnivati služnosti, dati zemljište u zalog i u podemfiteuzu. Vlasništvo na

plodovima stjecao je separacijom. Bio je zaštićen putem *actio in rem vectigalis*, *actio confessoria utilis* i *actio negatoria utilis*, kao i posjedovnim interdiktima.

Prava emfiteute prestajala su samo ako bi kroz tri uzastopne godine zanemario plaćanje zakupnine ili poreznih obveza, ili ako bi pogoršao stanje zemljišta.

§ 46 – SUPERFICIES

Superficies je nasljedivo i otuđivo pravo uživanja zgrade podignute na tuđem zemljištu uz platež godišnje daće (*solarium*).

Superficies je nastao iz potrebe da se ublaže nezgodne posljedice rimskog načela “*superficies solo cedit*” prema kojem je sve ono što je sagrađeno na tuđoj zemlji postajalo vlasništvom vlasnika zemljišta. Budući da se gotovo cjelokupan zemljišni fond nalazio u vlasništvu malog broja građana, a potrebe za građevinskim parcelama bile su veoma izražene, trebalo je naći pravno sredstvo koje bi omogućilo građenje poslovnih prostora i zgrada za stanovanje na tuđem zemljištu bez ugrožavanja prava vlasništva dotadašnjih vlasnika zemljišta. U tu su svrhu, najprije država, a potom i općine i privatnici počeli putem ugovora dopuštati pojedincima podizanje zgrada na tuđem zemljištu priznajući im pravo uživanja tih zgrada uz platež godišnje daće.

Ugovor kojim je zasnivan taj odnos bio je ili *locatio-conductio*, tj. uzimanje zemljišta u zakup, ili *emptio-venditio*, tj. kupnja prava uživanja zgrade. Uživatelj (*superficiarius*) nije stjecao nikakvo stvarno pravo nego samo obvezni zahtjev prema vlasniku zemljišta koji je mogao ostvariti odgovarajućom tužbom (*actio ex conducto*, odnosno *actio ex empto*). No, zahvaljujući djelatnosti pretora superficies je postupno počeo dobijati karakter stvarnog prava. Superficijar je zaštićen posesornim interdiktima, kao i posebnim interdiktom *de superficiei*, a u Justinijanovom pravu priznate su mu kao *utiles* sve tužbe koje pripadaju vlasniku (*utilis rei vindicatio*, *negatoria* i *confessoria*).

Superficies ima u Justinijanovom pravu nedvojbeno narav stvarnog prava. Superficijar je mogao prenositi svoje pravo poslovima *inter vivos* i *mortis causa* i osnivati na superficiesu *quasi ususfructus* i ostale služnosti.

§ 47 – ZALOŽNO PRAVO

1. Pojam, svrha i razvitak založnog prava

Založno pravo²⁵ je stvarno pravo založnog vjerovnika prema imovini dužnika koje služi osiguranju vjerovnikove tražbine.

Subjekti u založnopravnom odnosu su založni vjerovnik i založni dužnik. Taj odnos je **stvarnopravnog karaktera**: založno pravo djeluje prema svakome bez obzira na eventualnu promjenu vlasnika založenog predmeta.

Osnovna svrha založnog prava je da se založni vjerovnik namiri iz založene stvari ukoliko mu dužnik na vrijeme ne vrati dug iz glavne obveze, odnosno ako mu tražbina o dospelosti ne bude podmirena. Založni dužnik je vlasnik predmeta kojim je osigurana tražbina (odnosno dug). Založni vjerovnik ujedno je vjerovnik u obveznopravnom odnosu na osnovi kojeg je nastala tražbina, tj. dug, čije se namirenje osigurava zalogom.

Taj primarni obveznopravni odnos na osnovi kojeg je nastala tražbina, odnosno dug, je najčešće ugovor o zajmu (tražbina treba biti novčana ili takva da joj se vrijednost može izraziti u novcu). U razdoblju postklasičnog prava zemljoposjednici su od sitnih zakupnika (kolona) zahtijevali određeni zalog na ime osiguranja isplate ugovorene zakupnine, a često i kredita koji su davali kolonima u svrhu nabavke poljodjelskog inventara.

Budući da služi osiguranju tražbine iz primarnog obveznopravnog odnosa, nastanak, trajanje i prestanak založnopravnog odnosa zavise od tog glavnog odnosa. Prestankom osnovnog odnosa (npr. vraćanjem duga, poništenjem ugovora o zajmu, oprostom duga), prestaje i založnopravni odnos. **Zato založno pravo ima akcesoran karakter.**

Predmet zaloga mogu biti i pokretne i nepokretne stvari, a od razdoblja klasičnog prava i netjelesne stvari (tražbine, služnosti, pa i samo založno pravo); po Justinijanovom pravu predmetom zaloga moglo je biti sve ono što je moglo biti predmetom prodaje.

Založnopravni odnos u pravilu nastaje ugovorom između vjerovnika i dužnika. U rimskom pravu razvila su se tri oblika založnih ugovora: u najstarijem pravu kao ugovor o zalogu služila je ***fiducia cum creditore***; krajem razdoblja Republike pojavljuje se ***pignus***, a u Principatu je stvoren još jedan oblik zaloga koji je od III. stoljeća nazvan ***hypotheca***.

2. *Fiducia*

²⁵ Wagner, H., *Voraussetzungen, Vorstufen und Anfänge der römischen Generalverpfändung*, Marburg, 1968; Isti, *Die Entwicklung der Legalthypothenen am Schuldnervermögen im römischen Recht*, Marburg, 1974; Bürge, A., *Retentio im römischen Sachen- und Obligationenrecht*, Zürich, 1979; Kaser, M., *Studien zum römischen Pfandrecht*, Napoli, 1982;

Fiducia cum creditore je založni ugovor na temelju kojeg je založni dužnik prenosio u **vlasništvo** založnom vjerovniku određenu stvar obvezujući ga da mu tu istu stvar vrati kada on njemu namiri dug iz primarne obveze.

Ukoliko založni dužnik ne bi uredno i na vrijeme vratio dug iz primarne obveze, založni je vjerovnik imao pravo zadržati založenu stvar. Ta klauzula naziva se ***lex commissoria***. Kako je *lex commissoria* bila jako nepovoljna za dužnike (jer se u pravilu zalaže stvar veće vrijednosti od iznosa duga), u postklasičnom je pravu zabranjena Konstantinovom konstitucijom (C.8.34.3) i zamijenjena pogodbom o prodaji (***pactum de vendendo***).

Od razdoblja postklasičnog prava založni je vjerovnik morao prodati založenu stvar, namiriti svoju tražbinu iz postignute cijene i eventualni višak dobivenog novca (*hyperocha, superfluum pretii*) vratiti založnom dužniku.

U slučaju da založni vjerovnik ne bi htio vratiti založenu stvar nakon podmirenja duga, založni dužnik mogao ga je tužiti s infamirajućom ***actio fiduciae directa*** na vraćanje stvari ili platež njezine vrijednosti. Nedostatak te tužbe je u tome što se radilo o *actio in personam*, zbog čega je založni dužnik mogao tužiti samo založnog vjerovnika, ali ne i treće osobe kod kojih bi se stvar našla.

S nestankom mancipacije i in jure cesije, putem kojih su zalagane *res Mancipi*, u Justinijanovom je pravu nestala iz upotrebe i *fiducia*.

3. ***Pignus***

Pignus (ručni zalog) je založni ugovor (***contractus pignoratitius***) kojim je založni dužnik predavao u **posjed** založnom vjerovniku određenu stvar radi osiguranja vjerovnikove tražbine.

Putem pignusa uklonjene su negativne strane fiducije: založni dužnik nije više prenosio vlasništvo založene stvari na založnog vjerovnika, nego samo posjed; založni dužnik nije više morao biti kviritski vlasnik, nego je bilo dovoljno da ima bonitarno vlasništvo, tj. da je ovlašten podići *actio Publiciana*; stvar se više nije zalagala formalističnim načinima (putem *mancipatio* i *in iure cessio*), već neformalnom predajom.

Osnovna prava založnog vjerovnika su: posjedovanje založene stvari (***ius possidendi***); pravo na njezinu prodaju (***ius distrahendi***) i **pravo naplatiti tražbinu** iz primarne obveze iz postignute cijene.

Premda samo detentor, založni je vjerovnik imao tzv. izvedeni posjed kako bi mu bila osigurana interdiktna zaštita. Na taj je način bio zaštićen od uznemiravanja trećih

osoba i samog založnog dužnika. Tek je kasnije založni vjerovnik stekao stvarnopravnu zaštitu putem *actio quasi Serviana* kada se *pignus* razvio u založno pravo u pravom smislu.

Založni vjerovnik nije smio upotrebljavati založenu stvar niti se koristiti njezinim plodovima; u suprotnom, smatralo se da čini krađu (*furtum usus*). Ipak, mogla se ugovoriti tzv. antihreza, prema kojoj je založni vjerovnik mogao ubirati plodove založene stvari na ime kamata.

U slučaju da dužnik zakasni s vraćanjem duga, založni je vjerovnik počev od I. st.p.n.e. bio dužan prodati založenu stvar i naplatiti tražbinu iz dobivene cijene. U razdoblju postklasičnog prava bila je zabranjena *lex commissoria*, ali su založni vjerovnici mogli tražiti od državnih organa da predmet zaloge ostane u njihovom vlasništvu (*impetratio dominii*) ako su ga bezuspješno pokušali prodati i ako ponovno opominjanje dužnika nije dalo rezultata. Založni dužnik mogao je i nakon dvije godine iskupiti založenu stvar ako bi platio glavnicu i kamate.

Međusobne obveze između založnog dužnika i založnog vjerovnika bile su utužive putem *actio pigneraticia directa i contraria*. Založni dužnik (zalagatelj) mogao je tražiti povrat založene stvari od založnog vjerovnika putem ***actio pigneraticia directa*** ako je vratio dug ili ako je tražbina iz primarne obveze prestala na bilo koji drugi način. Budući da je *actio pigneraticia* tužba iz obveznog odnosa, tj. *actio in personam*, zalagatelj je založenu stvar, ako bi se našla kod trećih osoba, mogao zahtijevati s *rei vindicatio* ili s *actio Publiciana*. Založnom vjerovniku stajala je na raspolaganju ***actio pigneraticia contraria*** kojom je mogao ostvarivati svoja eventualna protupotraživanja prema založnom dužniku (npr. naknadu troškova koji su bili nužni za očuvanje založenog predmeta).

Na osnovi konstitucije cara Gordijana III. iz 239. godine založnom je vjerovniku dopušteno zadržati založenu stvar, čak i u slučaju kada bi založni dužnik podmirio dug čijem je osiguranju služio zalog ako je taj isti dužnik imao prema vjerovniku druge nepodmirene novčane obveze koje nisu bile osigurane zalogom (tzv. ***pignus Gordianum; retentio Gordiana***).

4. *Hypotheca*

a) Pojam i nastanak hipoteke

Hypotheca (pactum hypothecae) je oblik založnog prava koji se temeljio na neformalnom sporazumu između hipotekarnog vjerovnika i hipotekarnog dužnika da

određena stvar, koja ostaje u posjedu hipotekarnog dužnika, treba služiti osiguranju tražbine. Tek ako bi hipotekarni dužnik pao u zakašnjenje s ispunjenjem primarne obveze, hipotekarni je vjerovnik imao pravo zahtijevati posjed založene stvari da bi je prodao i naplatio potraživanje iz dobivene cijene.

Taj oblik založnog prava razvio se u vezi sa zakupom poljoprivrednog zemljišta. Vlasnici zemljišta – zakupodavci zahtijevali su od zakupnika određeni zalog na ime osiguranja isplate zakupnine ili vraćanja kredita koje su zakupci uzimali od zemljoposjednika radi nabavke osnovnog poljodjelskog inventara. Kako siromašni sitni zakupci najčešće nisu imali nikakvu drugu imovinu osim one koja im je bila potrebna za poljodjelstvo, zalaganje te imovine bi onemogućilo obradu zemljišta. Zato je trebalo iznaći novi oblik zalog bez prijenosa posjeda založene stvari na založnog vjerovnika. U tu svrhu razvila se hipoteka. U slučaju da zakupci ne bi ispunili svoje obveze, veleposjednicima su stajala na raspolaganju pravna sredstva kojima su mogli zahtijevati posjed založenih stvari. Početkom Principata pretor je hipotekarnom vjerovniku dopustio *interdictum adipiscendae possessionis*, tj. interdikt za pribavljanje posjeda, nazvan ***interdictum Salvianum***. Kako je taj interdikt bio upravljen samo protiv zakupnika – kolona, hipotekarni vjerovnik time još nije dobio založno pravo kao stvarno pravo koje bi djelovalo *erga omnes*. Tek kada je pretor odobrio *actio in rem*, nazvanu ***actio Serviana*** kojom je hipotekarni vjerovnik mogao tražiti posjed založenih stvari od bilo koje treće osobe, ugovorno založno pravo dobilo je značaj stvarnog prava koje djeluje prema svakome (*erga omnes*). Vremenom je hipoteka postala opće sredstvo za zalaganje stvari svih vrsta, osobito zemljišta. Usporedo s time, proširen je i opseg primjene Servijanske tužbe, nazvane kasnije ***actio quasi Serviana***, odnosno ***actio pignoratitia in rem*** ili ***actio hypothecaria***. Ta tužba protegnuta je i na pignus.

b) Vrste hipoteke

Pored **ugovornih hipoteka** koje su nastajale neformalnim sporazumom (*pactum hypothecae*) stranaka, postojale su **zakonske** ili **legalne hipoteke** koje su ustanovljavane *ipso iure*. Zakonske hipoteke koje su uvedene običajnim putem nazivaju se **prešutne zakonske hipoteke (*pignus tacitum*)**, među koje se ubrajaju založno pravo zakupodavca na stvarima zakupnika poljodjelskih imanja, kao i založno pravo najmodavca stana na najamnikove stvari unesene u stan. Zakonske hipoteke mogle su nastati i na temelju izričitih propisa rimskih careva. Takve hipoteke nazivaju se **izričite zakonske hipoteke**. Najpoznatije su: hipoteka države na imovini dužnika javnih poreza; hipoteka šticenika na imovini tutora i skrbnika;

hipoteka žene na muževljevoj imovini radi povrata miraza; hipoteka investitora na predmetu investicija. Te su hipoteke privilegirane generalne hipoteke jer su imale prednost pred ranijim založnim pravima.

Postojale su tzv. **generalne** ili **opće hipoteke**, koje su imale za predmet cijele imovinske mase, npr. cjelokupnu imovinu određene osobe. Hipoteke koje su za predmet imale točno određeni dio imovine ili određenu stvar, nazivale su se **specijalne** ili **posebne hipoteke**.

c) Kumulacija hipoteka

Sklapanjem hipotekarnog pakta založena stvar nije prelazila u posjed hipotekarnog vjerovnika, što je stvaralo mogućnost ponovnog zalaganja iste stvari kod drugih vjerovnika. U tom slučaju dolazilo je do kumulacije hipoteka ili stjecaja prava više hipotekarnih vjerovnika. Odnos između više hipotekarnih vjerovnika razrješavan je po načelu **prior tempore potior iure** (raniji po vremenu, jači u pravu), što znači da je jače pravo onog hipotekarnog vjerovnika koje je ranije ustanovljeno. To je hipotekarni vjerovnik viši po rangi, za razliku od hipotekarnog vjerovnika nižeg po rangi, čije je založno pravo novijeg datuma.

Prednosti hipotekarnog vjerovnika višeg po rangi bile su sljedeće: hipotekarni vjerovnik niži po rangi bio je izložen založnoj tužbi (*actio hypothecaria*) hipotekarnog vjerovnika višeg po rangi; založna tužba vjerovnika nižeg po rangi djelovala je samo protiv trećih osoba, ali ne i protiv vjerovnika višeg po rangi jer je taj mogao suprotstaviti prigovor jačeg prava; pravo prodaje založene stvari pripadalo je samo vjerovniku višem po rangi, dok je založni vjerovnik nižeg ranga imao pravo samo na eventualni višak postignute cijene. Kako se založni vjerovnici koji su imali pravo prodaje zaloga nisu puno trudili prodati založeni predmet po cijeni većoj od iznosa njihovih tražbina, založni vjerovnici niži po rangi često nisu imali odakle naplatiti svoja tražbine. Zbog toga su bili zainteresirani stupiti na mjesto hipotekarnih vjerovnika viših po rangi da bi oni stekli pravo prodaje zaloga. To su mogli ostvariti podmirenjem tražbine založnih vjerovnika viših po rangi i tako pomaknuti svoje založno pravo sa slabijeg na bolji prvenstveni red (***ius offerendi***).

Načelo *prior tempore potior iure* narušeno je uvođenjem tzv. privilegiranih generalnih hipoteka. Tu se radilo uglavnom o zakonskim hipotekama koje su imale prvenstvo bez obzira na vrijeme kada su ustanovljene.

5. Postanak i prestanak založnog prava

Založno pravo bilo je moguće ustanoviti voljom stranaka, oporukom, odlukom suda i zakonom.

Kao akcesorno pravo, založno je pravo prestajalo ispunjenjem, odnosno prestankom obveze čijem je namirenju služilo. Prestajalo je i prodajom založene stvari; konfuzijom (ako založni vjerovnik postane vlasnik založene stvari); odricanjem hipotekarnih vjerovnika; propašću založenog predmeta; zbog dugotrajnog nevršenja ili zastare (*longi temporis praescriptio*).

PETI DIO

OBVEZNO PRAVO

Prvo poglavlje

OPĆI ELEMENTI OBVEZNOG PRAVA

§ 48 – Pojam obveznog prava i obveznog odnosa

Obvezno pravo je grana prava koja se bavi obveznim odnosima. Rimsko obvezno pravo najvažnija je pravna ostavina starog Rima jer predstavlja preciznu razradu svih bitnih odnosa koji nastaju u oblasti pravnog prometa. Ta grana rimskog prava u najvećoj je mjeri utjecala na pozitivno pravo. Recipirano rimsko obvezno pravo temelj je današnjih građanskih kodifikacija europskokontinentalnog tipa.

Obvezno pravo uređuje one obvezne odnose koji nastaju među ljudima u procesu razmjene dobara i usluga koji je nužan u društvu koje počiva na robnoj proizvodnji i robnonovčanoj razmjeni. Svakodnevno se obvezujemo drugim ljudima (npr. na temelju ugovora, delikta, ili na druge načine) izvršiti određenu činidbu, ili smo ovlašteni zahtijevati od drugih neko davanje, činjenje ili propuštanje (npr. predaju kupljene stvari, vraćanje pozajmljenog novca, izradu portreta od slikara koji se na to obvezao, naknadu štete izvršene deliktom, itd.). U takvim situacijama u kojima je jedna stranka ovlaštena zahtijevati od druge stranke ispunjenje imovinske činidbe, a druga se stranka obvezala ispuniti tu činidbu, radi se o obveznim odnosima.

Obvezni odnos ili obveza (*obligatio*) je pravni odnos između dvije stranke na osnovi kojeg je vjerovnik (*creditor, reus stipulandi*) ovlašten zahtijevati od dužnika (*debitor, reus promittendi*) određenu činidbu, koju je dužnik obavezan izvršiti uz prijetnju sankcijom obveznog prava.

Osnovni elementi obveznog odnosa su:

1. subjekti obveznog odnosa (vjerovnik i dužnik);
2. sadržaj obveznog odnosa (prava vjerovnika i obveze dužnika);
3. predmet obveznog odnosa (obvezna činidba: *dare, facere, praestare*) i
4. pravno relevantna činjenica koja je dovela do zasnivanja obveznog odnosa (izvor obveze).

Obvezni odnos je uvijek **odnos između određenih subjekata**, određenog dužnika i određenog vjerovnika (odnos koji djeluje *inter partes*). Taj odnos nastaje najčešće ugovorom

između stranaka. U tom slučaju govorimo o **ugovornim obvezama**. Za razliku od njih, obveze koje nastaju iz nedopuštenih radnji (delikata) nazivamo **deliktnim obvezama**. Prava vjerovnika i obveze dužnika čine **sadržaj obveznog odnosa**. Sadržaj ugovornih obveza stranke mogu slobodno same odrediti ugovorom i prilagoditi obvezu svojim zahtjevima i potrebama. Zato odredbe obveznog prava spadaju u *ius dispositivum*.

Predmet obveznog odnosa je činidba koju je vjerovnik ovlašten zahtijevati od dužnika, odnosno činidba koju se dužnik obvezao izvršiti vjerovniku. Ako obvezni odnos promatramo sa stajališta vjerovnikova zahtjeva na činidbu, govorimo o **tražbini (*creditum, nomen*)**, a s dužnikova stajališta o **dugu (*debitum*)**. Rimski su pravници označavali sadržaj obvezne činidbe terminima *dare, facere* i *praestare*. **Dare** je značilo prenijeti vlasništvo, prenijeti ili ustanoviti neko drugo stvarno pravo, ili prenijeti posjed stvari; **facere** (uključujući i *non facere*) označava svaku drugu činidbu koja se sastoji u dužnikovu činjenju ili propuštanju, dok se termin **praestare** najčešće odnosi na naknadu štete pričinjene neizvršenjem neke obveze na *dare* ili *facere*.

Ako dužnik ne bi ispunio svoju obvezu, bio bi kažnjen **sankcijom obveznog prava**: obvezom na **naknadu štete** ili na platež **novčane kazne**. Vjerovnik je sudskim putem (tužbom) dobijao iz dužnikove imovine ekvivalent izostale dužne činidbe. Obveza iz koje izvire pravna dužnost koja se može ostvariti prinudnim (sudskim) putem naziva se **utuživa obveza (*obligatio civilis*)**, za razliku od **naravne obveze (*obligatio naturalis*)**, koja se ne može ostvariti procesualnim sredstvima. U najstarije vrijeme posljedice nevraćanja duga vezivane su za dužnikovu osobu, a ne imovinu, na što upućuje i sam termin *obligatio* (od *obligare* – vezivati), kao i termini kojima se označava gašenje obveze (*solutio, liberatio*) koji upućuju na fizičko oslobađanje obvezanika.

Obvezni odnos nastaje kada se dogode određene pravno relevantne činjenice koje služe kao izvor obveznog odnosa. Gaj u svojim Institucijama (3.88) navodi dva izvora obveza: kontrakte i delikte. Već krajem klasičnog razdoblja primijećeno je da postoje obveze koje nisu obuhvaćene ovom dvodiobom, a bile su zaštićene s *actio in personam*. U djelu *Res cottidianae sive aurea* koje se pripisuje Gaju, navodi se skupina obveza koje nastaju *ex variis causarum figuris*. Autor primjećuje da postoje obveze koje nisu izvirale iz kontrakata, ali su bile slične kontraktima (*quasi ex contractu teneri videntur*: poslovodstvo bez naloga; tutela; *legat per damnationem*; obveza na povrat neopravdanog obogaćenja), kao i obveze koje nisu izvirale iz delikata, ali su bile slične deliktima (*quasi ex maleficio teneri*: propust suca; odgovornost za stvorenu opasnost i odgovornost brodarka, gostioničara i vlasnika staja za krađe i štete nastale u njihovim objektima). Na osnovi te diobe u Justinijanovim Institucijama

(3.13.2) izvršena je četverodioba izvora obveza na: kontrakte, kvazikontrakte, delikte i kvazidelikte.

§ 49 - Pravne činjenice

Obveznopравни odnosi nastaju, mijenjaju se i prestaju kada se dogode određene činjenice. **Činjenice za koje pravni poredak veže pravne učinke nazivaju se pravnim činjenicama.** S obzirom na postanak, pravne činjenice dijele se na **prirodne događaje** (*facta naturalia*) i **ljudske radnje** (*acta humana*).

Prirodni događaji postaju pravnim činjenicama kada pravo za njih veže određene pravne učinke (npr. rođenje, smrt, protek vremena). Ti događaji nazivaju se **pravni događaji** jer pravo za njih veže pravne učinke koji nastaju na osnovi propisa pravnog poretka i nezavisno od volje stranaka (*ex lege*).

Ljudske radnje su očitovanja ljudske volje za koja su vezani pravni učinci. Nazivaju se i **pravnim radnjama**. Ljudske radnje mogu biti **dopuštene** (*acta humana iuridica*) i **nedopuštene** (*acta humana prohibita* ili *delicta*).

Među dopuštenim ljudskim radnjama najvažniji su pravni poslovi (*negotia iuridica*). Pravni posao je stranačko očitovanje volje usmjereno na postizanje dopuštenih pravnih učinaka. Ti učinci su postanak, promjena ili prestanak pravnog odnosa.

Nedopuštene ili protupravne ljudske radnje nazivaju se delikti (*delicta*). Dijelev se na kaznena djela (*delicta publica* ili *crimina*) i privatne delikte (*delicta privata*). Pravni poredak veže za delikte pravne učinke koje počinitelj nije htio ili ih nije imao u vidu. Za kazneno djelo (*crimen*) progoni i kažnjava država u javnom kaznenom postupku javnom kaznom (*poena publica*). Privatni delikt progoni oštećeni pojedinac posebnom penalnom tužbom (*actio poenalis*) u redovitom civilnom postupku. Sankcioniran je naknadom pričinjene štete ili platežom privatne novčane kazne (*poena privata*) koju je delinkvent obvezan isplatiti oštećenome. Prema tome, pravni učinci delikata su kazna (*poena publica*) koja se veže za kaznene delikte i obveza na naknadu štete ili platež novčane kazne (*poena privata*) kod privatnih delikata.

§ 50 – Pojam i vrste pravnih poslova

1. Pojam pravnog posla (*negotium*)

Pravni posao (*negotium*) je očitovanje privatne volje usmjereno na postizanje dopuštenih pravnih učinaka. Rimsko pravo nije stvorilo opći pojam pravnih poslova. Terminom *negotium* za oznaku pravnog posla koristi se pandektna znanost, dok su Rimljani tim izrazom označavali različite vrste djelatnosti u pravu.

Pravni posao nastaje očitovanjem privatne volje, odnosno stranačkim očitovanjem volje, što znači da se kao stranka u pravnom poslu mogu pojaviti bilo fizičke, bilo pravne osobe. Građanskopravno načelo stranačke ravnopravnosti ne dopušta da se kod pravnog posla jedna stranka prema drugoj odnosi kao vlast (npr. izdavanje upravnog akta ili donošenje presude nisu pravni poslovi).

Stranačko očitovanje volje mora biti usmjereno na proizvođenje određenih pravnih učinaka. Ti učinci očituju se kao osnivanje, promjena ili prestanak pravnog odnosa. Uvijek se mora raditi o dopuštenim pravnim učincima, po čemu se pravni posao razlikuje od delikta. Sklapajući određeni pravni posao stranke postižu učinke koje su htjele (namjeravani učinci), ali istodobno nastupaju i učinci koje pravni poredak veže za takav tip pravnog posla (nenamjeravani učinci) premda ih stranke nisu imale u vidu, nisu znale za njih ili ih možda nisu željele. Npr. sklapajući ugovor o kupoprodaji prodavatelj želi dobiti određenu cijenu (namjeravani učinak), ali istodobno preuzima odgovornost za pravne i faktične nedostatke prodane stvari, što je predviđeno pravnim poretkom, bez obzira je li on s tim upoznat (nenamjeravani učinci).

2. Vrste pravnih poslova

1. **Negotia unilateralia i negotia bilateralia (jednostrani i dvostrani pravni poslovi).**

Jednostrani pravni poslovi (*negotia unilateralia*) nastaju očitovanjem volje samo jedne osobe (npr. oporuka, okupacija, manumisija, derelikcija). Kod jednostranih pravnih poslova učinak nastupa očitovanjem volje samo jedne strane.

Dvostrani pravni poslovi (*negotia bilateralia*) nastaju suglasnim očitovanjem volje dviju stranaka koje stoje jedna naspram drugoj.

Da bi nastao učinak kod dvostranih pravnih poslova potrebno je suglasno očitovanje volje dviju stranaka. Dvostrani pravni poslovi nazivaju se ugovorima. **Ugovori su dvostrani**

pravni poslovi kod kojih se jedna strana obvezuje drugoj na određenu činidbu (npr. zajam, kupoprodaja, posudba).

S obzirom na učinak, te na raspored prava i obveza koji iz ugovora proistječu, obvezni ugovori dijele se na:

1. jednostrano obvezujuće (*contractus unilaterales*);
2. potpuno dvostrano obvezujuće (*contractus bilaterales aequales*);
3. nepotpuno dvostrano obvezujuće (*contractus bilaterales inaequales*).

Jednostrano obvezujući ugovori su dvostrani pravni poslovi čijim zaključenjem nastaje jedna tražbina i jedna obveza, tj. samo jedna strana postaje vjerovnik, a druga strana samo dužnik (npr. kod ugovora o zajmu zajmodavac je vjerovnik jer je ovlašten zahtijevati povrat duga, dok je zajmoprimac dužnik jer je obavezan vratiti istu sumu novca, odnosno jednaku količinu zamjenljivih stvari iste vrste).

Potpuno dvostrano obvezujući ili **sinalagmatični** su oni ugovori kod kojih od samog zaključenja nužno nastaju uzajamna dugovanja i potraživanja – činidbe i protučinidbe, tako da je svaka strana istodobno i dužnik i vjerovnik druge strane (npr. zaključenjem kupoprodaje obje strane istodobno postaju i dužnik i vjerovnik: prodavatelj je i dužnik i vjerovnik jer je kao dužnik obavezan predati stvar, a kao vjerovnik ovlašten je zahtijevati cijenu; kupac je i dužnik i vjerovnik jer je kao dužnik obavezan platiti cijenu, a kao vjerovnik ovlašten je zahtijevati izručenje stvari).

Nepotpuno dvostrano obvezujući su oni ugovori čijim zaključenjem nastaje samo jedna tražbina i jedna obveza, ali tijekom trajanja obveznog odnosa može nastati obveza i za drugu stranu (npr. zaključenjem ugovora o ostavi uvijek nastaje depozitareva obveza da stvari čuva i da ih na deponentov zahtjev vrati, ali ako je u nekim slučajevima depozitar imao troškove za održavanje i čuvanje stvari ili je pretrpio štetu, onda će nastati deponentova obveza na naknadu troškova i štete).

Razliku između *contractus bilaterales aequales* i *contractus bilaterales inaequales* rimsko je pravo izražavalo putem tužbi. Za zaštitu potpuno dvostrano obvezujućih kontrakata bile su predviđene dvije odvojene tužbe za uzajamna potraživanja (npr. kod kupoprodaje *actio empti* – *actio venditi*; kod najma *actio locati* – *actio conducti*), a za zaštitu nepotpuno dvostrano obvezujućih kontrakata bile su predviđene tužbe *directa* i *contraria*. *Actio directa* služila je za zaštitu glavnog potraživanja, a *actio contraria* za zaštitu eventualnog protupotraživanja druge strane (npr. kod ugovora o ostavi *actio depositi directa* – *actio depositi contraria*; kod posudbe *actio commodati directa* – *actio commodati contraria*).

2. *Negotia inter vivos* i *negotia mortis causa* (pravni poslovi među živima i pravni poslovi za slučaj smrti).

Pravni poslovi među živima (*negotia inter vivos*) su poslovi čiji učinak nastupa za života stranke ili stranaka koje su ga poduzele.

Pravni poslovi za slučaj smrti (*negotia mortis causa*) su poslovi čiji učinak nastupa tek nakon smrti osobe koja ga je poduzela (npr. oporuka).

3. *Negotia onerosa* i *negotia lucrativa* (naplatni i besplatni pravni poslovi).

Naplatni pravni poslovi (*negotia onerosa*) su oni kod kojih se za činidbu traži ekvivalentna protučinidba (npr. kupoprodaja, najam, zamjena).

Besplatni pravni poslovi (*negotia lucrativa*) su oni kod kojih se za činidbu ne traži i ne daje protučinidba (npr. darovanje).

4. *Kauzalni* i *apstraktni* pravni poslovi.

Kauzalni pravni poslovi su oni kod kojih je *causa* (pravni i gospodarski cilj koji stranke žele postići pravnim poslom) neposredno vidljiva iz samog posla (npr. kupoprodaja, najam, zajam, posudba).

Apstraktni pravni poslovi su oni kod kojih kauza nije vidljiva iz samog posla (npr. kod stipulacije dužnik se obvezuje izgovaranjem svečanih riječi, ali iz same forme nije vidljivo u koju svrhu).

5. *Formalni* i *neformalni* pravni poslovi.

Formalni pravni poslovi su poslovi koji moraju biti zaključeni u točno određenoj formi.

Neformalni pravni poslovi su poslovi koji mogu biti sklopljeni u bilo kojoj formi koju stranke izaberu. Dakle, i neformalni pravni poslovi imaju formu, ali je njen izbor prepušten volji stranaka.

§ 51 – Sadržaj pravnog posla

1. Bitni, naravni i slučajni sastojci pravnog posla

Postoje tri vrste elemenata ili sastojaka koji čine sadržaj pravnog posla. To su:

1. bitni sastojci pravnog posla (*essentialia negotii*);
2. naravni sastojci pravnog posla (*naturalia negotii*);
3. slučajni sastojci pravnog posla (*accidentalia negotii*).

Bitni sastojci pravnog posla (*essentialia negotii*) su sastojci koje stranke moraju ugovoriti da bi uopće nastao određeni tip pravnog posla. Budući da se radi o

konstitutivnim elementima pravnog posla, određeni su strogom normom. Ti sastojci čine minimalni nužni sadržaj pravnog posla jer bez njih pravnog posla uopće nema. Npr. da bi nastao ugovor o kupoprodaji stranke se moraju sporazumjeti o predmetu i cijeni; bitni sastojak oporuke je imenovanje nasljednika; bitni sastojci posudbe su predaja nepotrošne stvari na besplatnu upotrebu i obveza vraćanja te iste stvari, itd.

Naravni sastojci pravnog posla (*naturalia negotii*) su takvi sastojci koji su u pravnom poslu sadržani po samoj naravi pravnog posla. Ti elementi uključeni su u redoviti sadržaj određenog tipa pravnog posla po propisima pravnog poretka. Zbog toga te odredbe vrijede i u slučajevima kada stranke o njima nisu ništa ugovorile. One se podrazumijevaju jer proizilaze iz same naravi određenog tipa pravnog posla. Spomenuti elementi nisu nužni za nastanak i postojanje pravnog posla. Njima se dopunjava volja stranaka. Predviđeni su dispozitivnom normom, što znači da stranke njihovu primjenu mogu isključiti svojom voljom i međusobne odnose urediti drukčije nego je predviđeno pravnom normom. Ali, ako stranke njihovu primjenu izričito ne isključe ili o njima ništa ne ugovore, vrijedi ono što je određeno propisom. Npr. najpoznatiji naravni sastojak kupoprodajnog ugovora je odgovornost prodavatelja za pravne i faktične mane stvari. Ta odgovornost predviđena je pravnim propisom i vrijedi ako je stranke izričito ne isključe ili ograniče. Eventualno isključenje te odredbe neće utjecati na postojanje ugovora o kupoprodaji.

Slučajni (uzgredni, samovoljni) sastojci pravnog posla (*accidentalialia negotii*) postoje samo ako ih stranke izričito ugovore. Nikada se ne podrazumijevaju u pravnom poslu. Putem tih elemenata stranke svojom voljom i sporazumom modificiraju redoviti sadržaj pravnog posla prilagođavajući ga konkretnim prilikama i potrebama. Npr. prodavatelj i kupac mogu ugovoriti da će kupoprodajni ugovor biti raskinut ako kupac u određenom roku ne isplati cijenu (tzv. *lex commissoria*); ili da će ugovor biti raskinut ako prodavatelj u određenom roku nađe boljeg kupca (tzv. *in diem addictio*) i slično.

Tipični i najčešći uzgredni sastojci pravnih poslova su: uvjet (*condicio*), rok (*dies*) i namet (*modus*).

2. Uvjet (*condicio*)

Uvjet (*condicio*) je buduća i objektivno neizvjesna okolnost od koje po volji stranaka zavisi učinak pravnog posla. To je uzgredna odredba pravnog posla za čije nastupanje ili nenastupanje stranke vezuju početak ili prestanak učinka pravnog posla.

Uvjetovanje pravnih poslova omogućeno je u rimskom pravu tek s pojavom ugovora *bonae fidei*. Ugovaranje uvjeta i roka u poslovima starog rimskog prava, tzv. *actus legitimi* (npr. *mancipatio*, *in iure cessio*, *acceptillatio*) nije bilo dopušteno.

Stranke mogu na različite načine uvjetovati pravni posao. Nekada će učinak pravnog posla ovisiti o nastupanju ili nenastupanju buduće i objektivno neizvjesne okolnosti, ali se može dogoditi da se učinak pravnog posla veže za događaje kojima nedostaje jedna od bitnih pretpostavki uvjeta (jer su se već dogodili, ili su sigurni, neodređeni, nemogući, pravno ili moralno nedopušteni, predviđeni pravom itd.). Zbog toga je izgrađena teorija o pravim i nepravim uvjetima.

a) Pravi uvjeti

Kod pravih uvjeta početak ili prestanak učinka pravnog posla zavisi od nastupanja ili nenastupanja buduće i objektivno neizvjesne okolnosti. **Bitne pretpostavke pravog uvjeta su budućnost i objektivna neizvjesnost.**

S obzirom da uvjeti mogu na različite načine utjecati na učinak pravnog posla, pravi uvjeti mogu se podijeliti na nekoliko skupina.

Suspenzivni (odgodni) i rezolutivni (raskidni) uvjeti

Ta je podjela izvršena s obzirom na činjenicu zavisi li od ispunjenja uvjeta početak ili prestanak učinka pravnog posla.

Suspenzivni ili **odgodni** je onaj uvjet od čijeg ispunjenja zavisi **početak** učinka pravnog posla. Suspenzivni uvjet **odgađa** učinak pravnog posla do nastupanja ili nenastupanja buduće neizvjesne okolnosti. Ako se uvjet ispuni, nastaje učinak pravnog posla. Ako se uvjet ne ispuni, tj, ako se izjalovi, do učinka predviđenog posla neće doći.

Rimsko pravo detaljno je razradilo samo suspenzivne uvjete.

Rezolutivni ili **raskidni uvjet** je onaj čijim ispunjenjem **prestaje** učinak pravnog posla. Kod rezolutivnog uvjetovanja pravni posao proizvodi učinke već od časa zaključenja, ali će posao biti **raskinut** ako se ispuni uvjetovana okolnost. Dakle, ako se ispuni raskidni uvjet, učinak pravnog posla prestaje, a ako se izjalovi, učinak pravnog posla ostaje trajan.

Pozitivni i negativni uvjeti

Za spomenutu podjelu bitno je treba li se neka okolnost dogoditi ili ne dogoditi, odnosno mijenja li se dosadašnje stanje ili ne mijenja.

Pozitivni ili **afirmativni uvjet** je onaj uvjet koji traži da se nešto dogodi. Kod pozitivnog uvjeta početak ili prestanak učinka pravnog posla zavise od nastupanja budućeg neizvjesnog

dogadaja. Ispunjenjem uvjetovane okolnosti mijenja se dosadašnje stanje (npr. ako brod dođe iz Azije).

Negativni uvjet je onaj koji traži da se nešto ne dogodi, tj. da se ne mijenja dosadašnje stanje. Kod negativnog uvjeta učinak pravnog posla vezan je za nenastupanje budućeg neizvjesnog događaja. Negativni uvjet je ispunjen kada je sigurno da se uvjetovana okolnost neće dogoditi.

Potestativni, kazualni i mikstni uvjeti

Podjela uvjeta izvršena je s obzirom na činjenicu je li nastupanje ili nenastupanje uvjetovane okolnosti ovisno o volji ovlaštenika, djelatnosti trećih ljudi ili slučaju.

Potestativni uvjet je onaj čije nastupanje ili nenastupanje ovisi isključivo o volji ovlaštenika.

Kazualni ili slučajni uvjet (*casus* – slučaj) je onaj kod kojeg nastupanje ili nenastupanje buduće neizvjesne okolnosti zavisi od prirodnih sila ili od djelatnosti ljudi koji nisu zainteresirani u datom pravnom poslu. Ispunjenje kazualnog uvjeta leži izvan ovlaštenikove voljne sfere.

Mikstni ili mješoviti uvjet je onaj uvjet čije ispunjenje ovisi o volji ovlaštenika i o djelovanju prirodnih sila ili radnji treće osobe.

b) Učinak pravnog posla pod pravim uvjetom

Kod uvjetovanog pravnog posla treba razlikovati vrijeme dok još nije sigurno hoće li se desiti uvjetovana okolnost (*condicio pendet*) i vrijeme kada se uvjet ispunio (*condicio existit*), odnosno izjalovio (*condicio deficit*).

condicio pendet

Vrijeme pendencije započinje sklapanjem pravnog posla i traje do ispunjenja, odnosno izjalovljenja uvjeta. To je razdoblje kada se još ne zna hoće li nastupiti uvjetovana okolnost, zbog čega se kaže da uvjet visi (*condicio pendet*).

Vrijeme pendencije izaziva različite posljedice u ovisnosti o tome radi li se o suspenzivnom ili rezolutivnom uvjetu.

Pravni posao sklopljen pod **suspenzivnim uvjetom** je nastao i postoji, ali **ne proizvodi pravne učinke**, što znači da nije došlo ni do kakve promjene u postojećim pravnim odnosima. Uvjetno opterećeni nije postao dužnik prije ispunjenja uvjeta. Ono što je plaćeno prije nastupanja uvjetovane okolnosti, može se tražiti natrag putem *condictio indebiti*. Osoba koja bi prenijela pravo vlasništva na temelju pravnog posla zaključenog pod suspenzivnim

uvjetom i dalje je vlasnik za vrijeme pendencije: ima pravo raspolaganja sa stvari, pripadaju joj plodovi stvari i ovlaštena je na stvarnopravne tužbe.

Iz postojećeg pravnog stanja ipak su nastajale određene obveze za uvjetno opterećenoga: bila su zabranjena sva raspolaganja koja bi onemogućila izvršenje obveze u slučaju ispunjenja uvjeta; ako bi uvjetno opterećeni onemogućio ispunjenje uvjeta, smatralo se da je uvjet ispunjen (fikcija ispunjenja uvjeta); suspenzivno uvjetovane obveze bile su nasljedive i na aktivnoj i na pasivnoj strani; kada se uvjet ispuni, uvjetno ovlašteni odgovara za skrivljeno oštećenje ili uništenje stvari za vrijeme pendencije.

Za razliku od suspenzivno uvjetovanog pravnog posla, pravni posao sklopljen pod **rezolutivnim uvjetom proizvodio je pravne učinke za vrijeme pendencije**. Prava i obveze stranaka nastajali su odmah po zaključenju pravnog posla i trajali su do ispunjenja uvjeta. To znači da je uvjetno ovlašteni već zaključenjem pravnog posla postajao vjerovnik (ili je postajao vlasnik ako se radilo o prijenosu vlasništva), a uvjetno opterećeni dužnik. Ono što je primljeno ili dato za vrijeme pendencije ostaje punovažno.

condicio existit

Stanje pendencije završava ispunjenjem ili izjalovljenjem uvjetovane okolnosti. Pozitivni uvjet je ispunjen ako se dogodila okolnost čije je nastupanje bilo predviđeno kao uvjet (*condicio existit*). Negativni uvjet je ispunjen ako je sigurno da se neće dogoditi okolnost čije je nenastupanje stavljeno kao uvjet (*condicio existit*).

Rimsko je pravo poznavalo fikciju ispunjenja uvjeta, prema kojoj se uvjet smatrao ispunjenim, premda nije ispunjen, ako je ispunjenje uvjetovane okolnosti onemogućio uvjetno opterećeni.

Ako je pravni posao bio sklopljen pod suspenzivnim uvjetom, ispunjenjem uvjeta nastaju svi učinci koje je uvjetni posao trebao proizvesti. Nasuprot tome, ispunjenjem rezolutivnog uvjeta prestaju učinci pravnog posla.

Kod ispunjenja suspenzivnog uvjeta postavlja se pitanje od kojeg momenta nastupaju učinci pravnog posla: tek nakon ispunjenja uvjeta (*ex nunc*), ili ispunjenje uvjeta djeluje retroaktivno, tj. već od časa zaključenja pravnog posla (*ex tunc*). Za razliku od klasičnog prava, Justinijanovo je pravo razradilo i češće primjenjivalo ideju retroaktivnosti, ali do opće primjene načela retroaktivnosti ipak nije došlo.

condicio deficit

Pozitivni ili afirmativni uvjet se izjalovio ako događaj, koji je bio predviđen kao uvjet, nije nastupio i sigurno je da neće nastupiti.

Negativni uvjet izjalovio se ako je nastupio događaj koji je bio postavljen kao uvjet.

Izjalovljenjem suspenzivnog uvjeta ne nastupaju učinci pravnog posla. Ako se izjalovi rezolutivni uvjet, učinci pravnog posla postaju trajni jer je sigurno da više ne može doći do raskida posla.

c) Nepravi uvjeti

U nekim slučajevima stranke uvjetuju pravni posao okolnostima kojima nedostaju bitne pretpostavke potrebne za pravi uvjet. Tada se radi o nepravim uvjetima.

Nužni ili sigurni uvjet (*condicio necessaria*) je takva okolnost kod koje nedostaje jedna od bitnih pretpostavki, a to je neizvjesnost. Uvjetovana okolnost je buduća, ali je sigurno da će nastupiti (npr. ako Ticije umre; ako osvane sutrašnji dan). Takav pravni posao je valjan i smatra se bezuvjetnim. Njegovi učinci su odgođeni do nastupanja predviđene okolnosti, koja u tom slučaju ima učinak roka. Vezivanje pravnog posla za događaj koji mora nastupiti, ima učinak roka.

Nepravi uvjet (*condicio in praesens vel in praeteritum collata*) je takav uvjet kod kojeg se uvjetovana okolnost već dogodila ili se događa, bez obzira je li to strankama bilo poznato (npr. ako je Ticije bio konzul). Takav posao smatra se bezuvjetnim. Dakle, uvjetovana okolnost mora biti objektivno, a ne subjektivno neizvjesna.

Nemogući uvjet (*condicio impossibilis*) postoji u slučaju kada su stranke početak ili prestanak učinka pravnog posla vezale za okolnost koja nije moguća bilo fizički bilo pravno (npr. ako prstom dodirneš nebo; ako kupiš Jupiterov hram). Nemogući uvjeti imali su za posljedicu ništavost pravnih poslova *inter vivos*, a kod pravnih poslova *mortis causa* smatralo se da nisi ni dodani pravnom poslu (*pro non scripto*), te su takvi poslovi smatrani bezuvjetnim i valjanim.

Nemoralni uvjet (*condicio turpis*) je uvjet koji je protivan društvenom moralu. Na pravne poslove je djelovao jednako kao i nemogući uvjet.

Nedopušteni ili protupravni uvjet (*condicio illicita; condicio contra legem*) je uvjet koji je protivan pravnim propisima. Ima jednak učinak kao nemogući i nemoralni uvjet.

Pravni uvjet (*condicio iuris*) postoji u slučaju kada je kao uvjet postavljena okolnost koja je već predviđena pravnim propisom, zbog čega je stranke ne moraju posebno ugovarati (npr. ako nasljednik nadživi ostavitelja).

Perpleksni ili isključujući uvjet je uvjet koji je u proturječju sa suštinom pravnog posla. Ima za posljedicu ništavost pravnih poslova *inter vivos* i *mortis causa*.

3. Rok (*dies*)

Rok (*dies*) je budući sigurni događaj od čijeg nastupanja po volji stranaka zavisi početak ili prestanak učinka pravnog posla.

Stranke mogu učinak pravnog posla ograničiti vremenom, tako da učinak pravnog posla nastaje od određenog vremena ili traje do određenog vremena. Sukladno tome razlikuju se početni i završni rokovi.

Početni rok (*dies a quo; ex die*) je uzgredna stranačka odredba kojom se početak učinka pravnog posla vezuje za nastup određenog vremena.

Budući da kod roka nema neizvjesnosti, obvezni odnos s početnim rokom smatra se već postojećim, samo što je ispunjenje obveze odgođeno do nastupa ugovorenog vremena. Ono što je plaćeno prije nastupa ugovorenog roka, ne može se tražiti natrag putem *condictio indebiti*. Ne smatra se da je plaćeno nešto što se još ne duguje jer je sigurno da bi ta suma morala biti isplaćena nastupom početnog roka.

Završni rok (*dies ad quem; ad diem*) je uzgredna stranačka odredba kojom je određivano vrijeme prestanka učinka pravnog posla. Istekom završnog roka pravni posao prestaje djelovati.

S obzirom na činjenicu postoji li neizvjesnost oko nastupa ugovorenog vremena, rokovi se dijele na proste i složene.

Prosti rokovi su oni kod kojih je sigurno da će i kada će nastupiti ugovoreno vrijeme. To su:

dies certus an certus quando, za koji je sigurno da će se dogoditi i kada (npr. 1.1.2015.) i

dies certus an incertus quando, za koji se zna da će sigurno nastupiti, ali se ne zna kada (npr. na dan smrti određene osobe).

Složeni rokovi su oni kod kojih nije sigurno hoće li ugovoreno vrijeme uopće nastupiti. Oni u sebi sadrže element neizvjesnosti zbog čega se nazivaju rokovi – uvjeti, te na pravni posao djeluju kao uvjeti sukladno načelu *dies incertus pro condicione habetur*. To su:

dies incertus an certus quando, kod kojeg nije sigurno hoće li se dogoditi, ali se zna kada bi se trebalo dogoditi (npr. na 60. rođendan određene osobe) i

dies incertus an incertus quando kod kojeg se ne zna ni hoće li nastupiti ni kada će nastupiti (npr. kada brod dođe iz Azije; kada diplomiraš).

Veoma je važno točno odrediti trajanje ugovorenog roka jer rokovi često dovode do stjecanja, promjene ili gubitka prava. U tu svrhu služila su dva načina računanja: *computatio*

civilis i *computatio naturalis*. Kod ***computatio civilis*** u obzir su uzimani isključivo dani kao cjelina, a računali su se od ponoći do ponoći. Za razliku od današnjeg prava, kao prvi dan roka računat je dan kada je sklopljen pravni posao (odnosno dan kada se dogodila okolnost od koje se rok računa). Kao zadnji dan roka, ako se radilo o stjecanju prava, uziman je početak posljednjeg dana, a ako se radilo o gubitku prava, onda je taj učinak nastupao završetkom posljednjeg dana.

Rok može biti određen točno kalendarskim danima (npr. dug dospijeva 1.7.2016.), ali se često računa s tzv. pomičnim rokovima, gdje se rok određuje kao određeno razdoblje s različitim početkom računanja (npr. od danas kroz 6 mjeseci; kroz 5 godina). U slučaju računanja rokova po mjesecima, svaki mjesec se računa kao vremensko razdoblje od 30 dana, a pri računanju rokova po godinama, godina se određuje kao razdoblje od 365 dana.

Dugi zastarni rokovi računati su kao *tempus continuum* (neprekinuto, kontinuirano vrijeme) i kod njih je uziman u obzir svaki pojedini dan po kalendaru. Kod kraćih rokova (npr. onih koje je predviđalo pretorsko pravo, najčešće u trajanju do jedne godine) dolazilo je u obzir računanje prema *tempus utile* (korisno vrijeme), gdje se računalo samo vrijeme u kojem je stranka mogla poduzeti određenu pravnu radnju.

Samo se iznimno mogao primjenjivati i drugi način računanja vremena – ***computatio naturalis***. Rok se ovdje računa od onog časa kada se dogodila neka činjenica (npr. sklapanje ugovora), a završava u istom trenutku posljednjeg dana (*a momento ad momentum*).

4. Namet (*modus*)

Namet ili nalog (*modus*) je uzgredna odredba dodana besplatnim pravnim poslovima *inter vivos* i *mortis causa* kojom se stjecatelju nameće neka dužnost.

Prihvaćanjem koristi (npr. dara, nasljedstva, legata) obdareni se ujedno obvezuju izvršiti dužnost koja mu je nametnuta nametom ili nalogom (npr. obvezan je predati dio koristi drugoj osobi; podići ostavitelju spomenik; skrbiti se o nekome itd.). U klasičnom je pravu namet imao samo moralnu vrijednost, te je po civilnom pravu bio bez učinka. U postklasičnom i Justinijanovom pravu uvedena su prisilna sredstva za izvršenje nameta: *actio praescriptis verbis* i *condictio causa data causa non secuta*.

§ 52 – Karakteristike obvezne činidbe

Svaka obvezna činidba, bez obzira sastoji li se *in dando*, *in faciendo* ili *in praestando*, mora zadovoljiti određene zahtjeve da bi proizvela pravni učinak. Dužnik se može obvezati samo na činidbu koja je moguća i dopuštena, određena ili odrediva i procjenljiva u novcu.

Činidba mora biti objektivno moguća u času sklapanja ugovora.²⁶ Nitko se ne može obvezati na ono što je nemoguće ispiniti (*Celsus*, D.50.17.185: ***Impossibilium nulla obligatio***). Nemogućnost ispunjenja može biti fizička i pravna, objektivna i subjektivna, te početna i naknadna.

Činidba je **fizički nemoguća** ako se njeno ispunjenje protivi fizičkim zakonima (npr. prodaja stvari koja ne može postojati; ili stvari koja je propala već prije zaključenja ugovora). U takvom slučaju obveza nije uopće zasnovana. Činidba mora biti i **pravno moguća** da bi nastao predviđeni obvezni odnos (npr. pravno je nemoguće ugovoriti prodaju *res extra commercium*).

Objektivna nemogućnost postoji kada se ugovori činidba koju nitko ne može izvršiti (npr. prstom dodirnuti nebo). **Subjektivna nemogućnost** postoji kada je činidba nemoguća samo za određeni subjekt (npr. liječnik se obveže sagraditi kuću). Subjektivna nemogućnost ne dovodi do gašenja obveze, nego je pod određenim pretpostavkama pretvara u odgovornost za štetu.

Početna ili prvobitna nemogućnost postoji u slučaju kada činidba nije bila moguća već u času zasnivanja obveze. **Naknadna nemogućnost** postoji kada je nemogućnost nastupila poslije zaključenja ugovora. Ako je činidba koja je u času zaključenja ugovora bila moguća, naknadno postala nemoguća bez dužnikove krivnje, obveza se gasi. Međutim, ako je dužnik svojom krivnjom naknadno onemogućio ispunjenje činidbe, obveza se pretvara u odgovornost za štetu. U tom slučaju njegova obveza postaje trajna (***perpetuatio obligationis***, npr. dužnik koji se na temelju kupoprodajnog ugovora obvezao predati roba, pa ga nakon zaključenja ugovora usmrti, obvezan je naknaditi štetu).

Predmet obveze mora biti pravno dopušten. Činidba ne smije biti protupravna ili zabranjena pravnim propisima.²⁷ Ipak, klasično pravo nije uvijek poništavalo ugovore zaključene protivno zakonskoj zabrani. Valjanost takvih ugovora zavisila je od toga što je povrijeđen zakon predvidio. Samo je ***lex perfecta* (potpuni zakon)** činio zabranjeni posao ništavim; ***lex minus quam perfecta*** (djelomično nepotpuni zakon) nije predviđao ništavost zabranjenog pravnog posla, nego je propisivao kazne za osobe koje su ga zaključile i ***lex imperfecta*** (nepotpuni zakon) nije predviđao nikakve posljedice ni za stranke ni za ugovor. U

²⁶ Cuena Boy, F., *Estudios sobre la imposibilidad de la prestacion. La imposibilidad juridica*, Valladolid, 1992.

postklasičnom i Justinijanovom pravu proglašene su ništavim sve obveze čije su činidbe bile zakonom zabranjene.

Obveze čije činidbe, doduše, nisu izravno kršile zakon, ali su sklopljene u svrhu zaobilaženja ili izigravanja pravnih propisa (*agere in fraudem legis*) tijekom vremena počele su se smatrati ništavim, a od IV. stoljeća izigravanje zakona izjednačeno je s njegovom povredom.

Obvezna činidba ne smije vrijeđati moralne osjećaje niti biti protiv dobrih običaja (*contra bonos mores*). Takve obveze bile su ništave.

Obvezna činidba mora biti određena ili odrediva. Činidba je određena ako je unaprijed u svim pojedinostima točno označena. U tom slučaju radi se o *obligatio certa*. *Obligatio incerta* postoji kada je činidba odrediva, tj. kada se može utvrditi po objektivnim činjenicama bez naknadnog sporazumijevanja stranaka. Npr. stranke mogu odrediti osobu koja će objektivno odrediti predmet obveze (*arbitrium boni viri*), ili kod kupoprodajnog ugovora sporazume se da će stvar biti prodana po cijeni po kojoj se ta stvar bude prodavala na tržnici na dan predaje stvari kupcu i slično.

Među obveze s neodređenim, ali ipak odredivim činidbama spadaju alternativne i generične obveze.

Kod **obveze sa alternativno određenim činidbama** radi se o **dvije ili više činidaba**, od kojih je dužnik obavezan izvršiti **samo jednu** kako bi se oslobodio obveze (*duae sive plures res in obligatione, una in solutione*). Npr. dužnik je obavezan predati ili roba Stiha ili Pamfila; predajom jednoga od njih oslobađa se obveze. Izbor činidbe kojom će se osloboditi obveze pripada dužniku ako nije izričito pridržan vjerovniku ili trećoj osobi. Dužniku pripada tzv. *ius variandi*, što znači da može promijeniti svoj izbor sve do časa potpunog izvršenja jedne činidbe. Vjerovnik svoje pravo izbora ostvaruje u pravilu pokretanjem spora (litiskontestacijom). Tužbenim zahtjevom mora obuhvatiti sve alternative. U suprotnom, ako bi utužio samo jednu činidbu smatralo bi se da je prekoračio svoje ovlasti i da je tražio više nego što mu pripada (*plus petitio*), zbog čega bi izgubio spor.

Za razliku od alternativnih obveza, postoje **fakultativne obveze** kod kojih dužnik duguje **samo jednu činidbu**, ali mu je dopušteno osloboditi se obveze izvršenjem neke **druge određene činidbe** (*una res in obligatione, duae res in solutione*). Ta dužnikova ovlast naziva se alternativna ovlast ili *facultas alternativa*. Npr. *pater familias* obavezan je platiti novčanu

²⁷ Kaser, M., *Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im römischen Recht*, Wien, 1977.

kaznu za delikte podčinjenih osoba (noksalna odgovornost), ali se može osloboditi plaćanja kazne izručenjem počinitelja delikta u vlast oštećenoga (*noxae deditio*).

Obveze mogu biti individualno i generično određene.

Individualno određene obveze su obveze čije činidbe glase na individualno određene stvari. Za te obveze vrijedi da se dužnik oslobađa obveze ako predmet obveze propadne uslijed slučaja (*casus*), dakle, bez dužnikove krivnje, u skladu s pravilom da individualno određena stvar propada onome kome se duguje (*species perit ei cui debetur*), odnosno da rizik za slučajnu propast stvari snosi vjerovnik (*periculum est creditoris*).

Generički određene obveze su obveze čije činidbe glase na generički određene stvari. Za njih vrijedi načelo *genus non perit* (generične stvari ne mogu propasti), odnosno *casus sentit dominus* (slučaj pogađa vlasnika). To znači da ukoliko uslijed slučaja (*casus*) propadnu generične stvari koje je dužnik odredio za ispunjenje obveze, njegova obveza neće se ugasiti jer mora nabaviti drugu količinu stvari iste vrste.

Jedna od bitnih karakteristika obvezne činidbe je njezin **imovinski karakter**. **Svaka činidba mora biti procjenljiva u novcu**. Ispunjenjem činidbe ostvaruju se ekonomski interesi stranaka u obveznom odnosu, što znači da se izvršenje činidbe izravno ili neizravno odražava na njihovoj imovini. Npr. izvršenjem činidbe na *dare* neposredno se uvećava vjerovnikova imovina, ali postoje i obveze čije neispunjenje nema neposrednog odraza na imovini stranaka (npr. obveza nastavnika stranog jezika na poduku). Imovinska vrijednost takvih obveza sastoji se u tome što se može izmjeriti i naknaditi novcem šteta koju vjerovnik pretrpi zbog neizvršenja dužne činidbe.

Činidba mora biti procjenljiva u novcu i zbog zahtjeva vezanih za formularni postupak. Budući da je u formularnom postupku svaka presuda glasila na određenu sumu novca (*omnis condemnatio pecuniaria*), svaka obvezna činidba bila je u krajnjem svedena na novčani izraz putem presude.

Obvezna činidba mora se sastojati od čovjekove radnje ili propuštanja. Obvezni odnos je društveni odnos, zbog čega se predmet obveze mora sastojati od ljudske radnje.

§ 53 – Očitovanje volje i tumačenje pravnih poslova

Pravni posao je očitovanje privatne volje usmjereno na postizanje dopuštenih pravnih učinaka. Iz definicije je vidljivo da su osnovni elementi pravnog posla **volja** kao unutarnji akt i **očitovanje volje** kao vanjska manifestacija.²⁸ Da bi nastao učinak pravnog posla po civilnom pravu, očitovanje je moralo biti izvršeno u unaprijed propisanoj formi. Staro rimsko pravo smatralo je da forma čini suštinu stvari (*forma dat esse rei*). Pravni učinak nadovezivao se na formalni akt koji se sastojao u izgovaranju svečanih formula i vršenju simboličnih gesta pred propisanim brojem svjedoka ili magistratom. Sporazumi zaključeni na neformalan način nisu bili izvor obveza i nisu rađali tužbe (*ex nudo pacto obligatio non nascitur*). Zbog takvog shvaćanja izgovorene riječi i geste tumačene su doslovno i strogo. U civilnom pravu vrijedila je **teorija očitovanja** (*interpretatio secundum verba*) prema kojoj je mjerodavno samo ono što je stranka očitovala. Na takav način tumačeni su obvezni odnosi koji su nastali po propisima starog rimskog prava (*ius strictum*). Kod suđenja za obveze starog prava (*obligationes stricti iuris*) sudac je donosio presudu samo na osnovi vanjskog očitovanja volje, ne ispitujući slaže li se očitovanje s istinskom voljom stranke, kao ni činjenicu jesu li stranke ostvarile cilj (*causa*) zbog kojeg su zaključile posao. Sučeva zadaća bila je samo utvrditi je li posao zaključen u propisanoj formi i koliko je potraživanje vjerovnika.

S pojavom ugovora *bonae fidei* u rimskom se pravu postupno javlja **teorija volje** (*interpretatio secundum voluntatem*) prema kojoj volja stranke ima prednost pred očitovanjem. Do nastanka teorije volje došlo je zahvaljujući poslovima *ius gentium* koji su bili oslobođeni formalizma. Vodeći se načelom *bonae fidei* pretori su nalogali sucu da presudu povodom obveza *bonae fidei* donese tek nakon što utvrdi što su stranke zaista htjele postići zaključenjem konkretnog ugovora. Pretorsko pravo zaštitilo je volju stranaka pravnim sredstvima kojima je oduziman učinak pravnim poslovima koji nisu odgovarali pravoj volji stranaka. Tako je tuženik mogao uložiti prigovor (***exceptio doli***) ako je tužitelj pri zaključenju ugovora postupao prijevarno i na štetu tuženika. Osim toga, pretorsko je pravo dalo učinak prigovora i neformalnim paktima, koji u početku nisu bili utuživi, i kojima je tuženik mogao istaknuti da je naknadno, nakon zaključenja osnovnog posla i kao dodatak tom poslu, sklopljen poseban neformalan posao kojim su izmijenjene neke odredbe osnovnog posla (***exceptio pacti conventi***; npr. tuženik istakne da je nakon zaključenja zajma sklopljen

²⁸ Wunner, S. E., *Contractus: sein Wortgebrauch und Willensgehalt im klassischen römischen Recht*, Köln, 1964; Baldus, Ch., *Regelhafte Vertragsauslegung nach Parteirollen im klassischen römischen Recht*, Frankfurt a. M., 1998.

neformalni *pactum de non petendo ad tempus* kojim se vjerovnik obvezao da dug neće potraživati do određenog roka).

Ipak, teorija volje primjenjivala se u klasičnom pravu samo u slučajevima kada očitovana volja nije bila potpuno jasna. Tek je u Justinijanovom pravu teorija volje postala vladajuća pri čemu je u utvrđenju pravog sadržaja ugovornih obveza trebalo uzeti u obzir ne samo istinsku volju stranaka nego i cijeli niz okolnosti koje su pratile zaključenje ugovora (da nije bilo bludnje, prijevara ili prinude; jesu li stranke ostvarile cilj zaključene obveze; kakvi su bili njihovi međusobni odnosi; postoje li neki sporedni sporazumi i sl.). Zbog toga se mijenjaju ili nestaju formalni poslovi od opće važnosti: *mancipatio* i *in iure cessio* u potpunosti iščezavaju, a formalnosti stipulacije popuštaju tako da od V. stoljeća svi neformalni usmeni sporazumi dobijaju učinak stipulacije. Po Justinijanovom pravu volja se mogla očitovati u bilo kom obliku i na bilo koji način, a samo su iznimno bili propisani određeni oblici za neke poslove.

Ako forma pravnog posla nije bila unaprijed propisana, volja se u rimskom pravu mogla očitovati na bilo koji način: izričito i posredno.

Izričito se volja mogla očitovati usmeno, pismeno, znacima (mimikom, kimanjem glavom). Za razliku od izričitog očitovanja, volja se u nekim situacijama može utvrditi iz nedvojbenog ponašanja osobe, dakle na **posredan** način (npr. pozvani nasljednik uselio se u kuću, počeo obrađivati vrt i sl., što znači da se ponaša kao nasljednik premda nije izričito prihvatio nasljedstvo). U takvim slučajevima radi se o **konkludentnim radnjama** ili o **prešutnom očitovanju volje**. **Konkludentne radnje** spadaju u posredna očitovanja volje, a sastoje se u tome da se iz određenog ponašanja osobe može zaključiti da je na neizravan način htjela očitovati određenu volju.

Rimski pravници raspravljali su pitanje može li se **šutnja** smatrati očitovanjem volje. Vrijedilo je pravilo da onaj koji šuti, doduše, time se ne slaže, ali se i ne protivi: *qui tacet, non utique fatetur, sed tamen verum est eum non negare* (Paulus, D.50.17.142). U nekim situacijama i pod određenim uvjetima šutnja se mogla shvatiti kao konkludentna radnja (npr. *pater familias* postavi sina u vlasti za poslovođu trgovine do određenog roka, pa ako i nakon isteka tog roka i dalje priznaje sinovljeve poslove, smatra se da je prešutno produžio sinovljeve ovlasti).

Na temelju navedene Paulove izreke o šutnji glosatori i kanonsko pravo izveli su pravilo *qui tacet consentire videtur* (tko šuti smatra se da odobrava).

§ 54 – Nesklad između volje i očitovanja

U skladu s načelom *bonae fidei* ugovori zaključeni pod prinudom, kao i ugovori kod kojih stranke nisu bile svjesne o čemu se doista radi, smatrani su nevažećim. U takvim slučajevima volja je formirana na pogrešan način ili postoji nesklad između volje i očitovanja. Taj nesklad može biti svjestan i nesvjestan.²⁹ Svjestan nesklad postoji kod mentalne rezervacije (*reservatio mentalis*) i simulacije (*simulatio*), a nesvjestan kod bludnje (*error*). Pod pojmom mana volje obuhvaćeni su i prijevara (*dolus*) i sila i strah (*vis ac metus*) kod kojih je volja formirana na pogrešan način zbog nedopuštenih utjecaja.

1. Svjestan nesklad između volje i očitovanja

Svjestan nesklad između volje i očitovanja najčešće ima svrhu prijave. O tom neskladu govori se u slučajevima mentalne rezervacije i simulacije.

Mentalna rezervacija (*reservatio mentalis*) ili očitovanje s tajnim pridržajem postoji u slučaju kada stranka očituje nešto, što uistinu neće, a to prikrivanje ne priopći suugovaratelju. Stranka koja daje očitovanje s tajnim pridržajem svjesno prešućuje da se njeno očitovanje ne slaže s njenom voljom kako bi prevarila drugu osobu. Takav nesklad između očitovane i prave volje ne uzima se u obzir, što znači da vrijedi ono što je očitovano. Pravni posao je nastao i izaziva pravne učinke bez obzira na očitovanje s tajnim pridržajem.

Simulacija (*simulatio*) je prividno sklapanje pravnih poslova. Stranke se dogovore da će samo prividno sklopiti neki pravni posao, koji uistinu ne žele kako bi dovele u bludnju treće osobe.

Simulacija može biti apsolutna i relativna.

Apsolutna simulacija postoji kada stranke prividno ili fiktivno sklope pravni posao kako bi prevarile treće osobe, a **uistinu nisu željele zaključiti nikakav posao** (npr. dužnik prividno prodaje stvari prijatelju da bi prikratio vjerovnike). Ta simulacija ne proizvodi nikakav pravni učinak između suugovaratelja jer oni uopće nisu htjeli ništa poduzeti, ali je mogla imati za posljedicu solidarnu odgovornost simulanata prema trećim osobama koje su se u dobroj vjeri pouzdale u prividni posao i zbog toga pretrpjele štetu.

Relativna simulacija postoji kada stranke prividno sklope jedan ugovor, a **stvarno su željele zaključiti drugi**. Prividnim pravnim poslom prikriva se neki drugi posao. Kod

relativne simulacije radi se o dva posla: simuliranom i disimuliranom. **Simulirani posao** je prividno sklopljeni posao koji stranke ne žele. **Disimulirani posao** (*negotium dissimulatum*) je drugi, prikriveni posao koji odgovara pravoj volji stranaka. Do relativne simulacije najčešće dolazi u svrhu izigravanja neke pravne zabrane ili radi izbjegavanja nepovoljnijih propisa (npr. stranke prividno sklope kupoprodaju kako bi prikrile darovanje). U tom slučaju simulirani posao je ništav jer ga stranke uistinu nisu htjele, a disimulirani posao mogao je biti valjan ako su postojale pretpostavke za njegovu valjanost, sukladno pravilu: *plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur* (više vrijedi što se stvarno radi od onoga što se simulira).

2. Nesvjestan nesklad između volje i očitovanja

Nesvjestan nesklad između očitovanja i prave volje može postojati, a da stranka toga uopće ne bude svjesna. U tom slučaju radi se o bludnji (*error*).

Bludnja (*error*) je pogrešna predodžba o činjenici koja je bila važna za zaključenje pravnog posla.

Svaka bludnja nije pravno značajna. **Da bi dovela do nevaljanosti pravnog posla bludnja mora biti neskrivljena, bitna i mora se odnositi na nepoznavanje činjenica, tj. biti ispričiva.**

Za pravne poslove zaključene u bludnji vrijedilo je pravilo da je volja osobe u bludnji ništava (*nulla voluntas errantis*).

Bludnja je **neskrivljena** ili **podnošljiva** (*error iustus* ili *error tolerabilis*) ako se ne može pripisati krajnjoj nemarnosti osobe koja se nalazila u bludnji.

Bludnja mora biti **bitna** (*error essentialis*) da bi dovela do nevaljanosti pravnog posla, tj. mora se odnositi na nepoznavanje bitnih činjenica vezanih za sadržaj pravnog posla. Bludnja o nebitnim činjenicama nije bila pravno relevantna u skladu s načelom *de minimis non curat praetor* (pretor se ne bavi sitnicama).

Kao **slučajevi bitne bludnje** smatrani su: *error in negotio*, *error in corpore*, *error in persona* i *error in substantia*.

Error in negotio je bludnja o suštini i sadržaju pravnog posla. Do takve bludnje dolazi kada stranke ne preciziraju u potpunosti sve elemente ugovora, tako da dođe samo do

²⁹ Wolf, J. G., *Error im römisches Vertragsrecht*, Köln, 1961; Winkel, L. C., *Error iuris nocet*, Amsterdam, 1983.

prividne suglasnosti (npr. jedna stranka misli na zajam, a druga na darovanje). U tom slučaju pravni posao nije nastao.

Error in corpore je bludnja o predmetu pravnog posla. Do te bludnje dolazi kada stranke prilikom zaključenja ugovora nisu mislile na isti predmet (npr. jedna je stranka mislila na roba Stiha, a druga na Pamfila). Takva bludnja ima za posljedicu ništavost pravnog posla. Međutim, ako su stranke mislile na isti predmet, ali su ga nazvale različitim imenima, nije se radilo o bludnji o predmetu u skladu s načelom da pogrešno opisivanje predmeta ne škodi (*falsa demonstratio non nocet*).

Error in persona je bludnja o osobi suugovaratelja ili njegovim bitnim osobinama. Ta je bludnja dovela do ništavosti pravnog posla samo ako je individualitet određene osobe bio od osobite važnosti za pravni posao. U takvim slučajevima radi se o ugovorima **intuitu personae**, tj. ugovorima kod kojih su bitni identitet i određene osobine suugovaratelja (npr. kod izrade portreta, određivanja nasljednika, sklapanja braka, darovanja, zajma, i sl.).

Error in substantia je bludnja o materiji od koje je napravljen predmet (npr. prsten za koji kupac misli da je od zlata, samo je pozlaćen). Ta bludnja mogla je dovesti do nevaljanosti pravnog posla.

Bludnja je morala biti **ispričiva** da bi dovela do ništavosti pravnog posla. Ispričiva je bila samo **bludnja koja se odnosila na činjenice** koje su bile važne za zaključenje ugovora (**error facti**) u skladu s načelom da nepoznavanje činjenica ne škodi (*error facti non nocet*). Naprotiv, nepoznavanje pravnih propisa nije moglo biti razlogom poništenja pravnog posla u skladu s načelom da nepoznavanje prava škodi (*ignorantia iuris nocet*).

Error in motivo ili bludnja u motivu postoji kada je pogrešna predodžba navela stranku na sklapanje pravnog posla. Kod te bludnje volja se slaže s očitovanjem, ali je sama volja izazvana krivim motivom. Bludnja u motivu ne utječe na valjanost pravnog posla, osim na području nasljednog prava (npr. za nasljednika je postavljena treća osoba zbog pogrešnog uvjerenja da su bliži srodnici umrli).

Od navedenih slučajeva bludnje treba razlikovati slučajeve u kojima ne postoji nesklad između volje i očitovanja, ali je sama volja formirana na nedopušten način, pod utjecajem prijevare (*dolus*) i sile i straha (*vis ac metus*).

Prijevара (dolus ili dolus malus) je namjerno dovođenje ili održavanje suugovaratelja u bludnji kako bi se od njega izvukla protupravna korist. Prijevара nije utjecala na valjanost pravnih poslova po civilnom pravu. Tek je pretorsko pravo predvidjelo pravna sredstva za zaštitu prevarene osobe: *actio doli*, tužbu kojom je prevareni dobijao naknadu štete i *exceptio doli*, prigovor protiv tužbe iz pravnog posla sklopljenog pod

utjecajem prijevare. Taj se prigovor mogao uvijek podići kod ugovora *bonae fidei* (*exceptio doli inest bonae fidei iudiciis*), dok je kod ugovora *stricti iuris* morala biti ugovorena posebna *clausula doli* kako bi se osigurala zaštita od prijevare.

Sila i strah (*vis ac metus*) postoji u slučaju kada jedna stranka izvršavanjem akata nasilja (*vis*) nad drugom strankom ili prijetnjom da će joj učiniti neko zlo prinudi drugu stranku na sklapanje za nju nepovoljnog pravnog posla. U teoriji se razlikuju materijalna ili fizička sila (*vis absoluta* ili *vis physica*) i moralna ili psihička sila (*vis compulsiva*). *Vis absoluta* postoji kod primjene radnji fizičke prinude, a *vis compulsiva* u primjeni radnji psihičke prinude. Rimski pravници bavili su se samo učincima psihičke prinude. Da bi strah bio pravno relevantan, zapriječeno zlo moralo je biti protupravno, teško i opasno, tako da se ozbiljan i razborit čovjek mora bojati za život, tijelo ili drugo značajno dobro. Pravni poslovi zaključeni pod utjecajem sile i straha mogli su biti poništeni pomoću *actio quod metus causa*, *exceptio quod metus causa* i *restitutio in integrum ob metum* (povrat u prijašnje stanje kakvo je bilo prije učinka straha). *Actio quod metus causa* bila je arbitrarna (*actio arbitraria*) što znači da je osoba koja je izvršila prisilu mogla izbjeći osudu *in quadruplum* ako bi vratila uzete stvari ili naknadila štetu. Ta je tužba bila i *actio in rem scripta* jer ju je oštećeni mogao podići ne samo protiv onoga koji je izvršio radnje fizičke ili psihičke prinude, nego i protiv treće osobe koja je stekla koristi iz takvog posla.

Dolus* i *vis ac metus su delikti honorarnog prava.

§ 55 – Nevaljanost pravnih poslova

Da bi pravni posao bio valjan moraju se poštovati pretpostavke koje se odnose na: pravnu i djelatnu sposobnost stranaka, predmet i formu pravnog posla, te volju i očitovanje volje. Nedostatak neke od navedenih pretpostavki dovodio je do **ništavosti** (teži stupanj nevaljanosti) i **poboynosti** (blaži oblik nevaljanosti) pravnog posla.

Ništavi pravni posao (*negotium nullum*) ne proizvodi pravne učinke, te se smatra da nije nikada zaključen. To znači da ništavost djeluje uvijek unatrag (*ex tunc*), tj. od časa zaključenja pravnog posla. Ništav pravni posao sadrži takve mane o kojima sud mora voditi računa po službenoj dužnosti (npr. stranke nisu imale pravnu ili poslovnu sposobnost; nije poštovana propisana forma; činidba je bila nemoguća, nedopuštena ili nemoralna). Na ništavost pravnog posla mogu se pozvati stranke koje su ga sklopile, kao i svaka treća osoba.

Pravni posao koji je bio zahvaćen ništavošću nije bilo potrebno uvijek u **potpunosti poništavati**. Trebalo je ispuniti one dijelove pravnog posla koji nisu bili pogođeni ništavošću

i koji su mogli samostalno postojati, sukladno načelu da ništavo ne poništava valjano, odnosno, da se korisno štetnim ne kvari (*utile per inutile non vitiatur*). U tom slučaju radi se o **djelomičnoj ništavosti** (npr. nije trebalo u cijelosti poništiti oporuku koja je sadržavala nemogući ili nemoralni uvjet, nego samo njezine dijelove pogođene ništavošću).

Ništavost je mogla biti početna i naknadna. Kod **početne ništavosti** pravni je posao već u času zaključenja imao nedostatke koji su onemogućili njegovu valjanost. Kod **naknadne ništavosti** pravni posao, koji je u času zaključenja bio valjan, postaje naknadno ništav (u slučaju ako pravni posao nije trebao odmah proizvesti učinke, a razlog ništavosti pojavi se prije nego što nastanu učinci posla).

Blaži oblik nevaljanosti pravnih poslova je pobjnost ili oborivost.

Pobjni pravni posao izaziva pravne učinke sve dok zainteresirana stranka ili treća osoba koja je tim poslom pogođena ne zatraži njegovo poništenje (npr. osoba koja je ugovor zaključila u bludnji, pod utjecajem prijevara ili straha; malodobna osoba, a od postklasičnog prava i prodavatelj koji je pretrpio *laesio enormis*, tj. bio prikraćen preko polovice vrijednosti stvari). Na taj oblik nevaljanosti sud ne pazi po službenoj dužnosti. Ukidanje pobjnog posla djeluje samo za ubuduće (*ex nunc*).

Pravna sredstva putem kojih je naknadno oduziman učinak pravnim poslovima, bila su: uskraćivanje tužbe (*denegatio actionis*), isticanje raznih prigovora (*exceptiones*) i povrat u prijašnje stanje (*restitutio in integrum*). Ta sredstva predviđena su pretorskim pravom. Civilno pravo nije poznavalo pravna sredstva kojima se pravni posao mogao naknadno poništiti.

§ 56 – Konvalidacija i konverzija

Nevaljani pravni posao po rimskom pravu nije mogao naknadno osnažiti (konvalidirati). Vrijedilo je pravilo da **ono što je u početku nevaljano, ne može protekom vremena postati valjano** (*Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere*). Navedeno pravilo nastalo je uopćavanjem Paulovog teksta (D.50.17.29) koji se prvobitno odnosio na problem tutorstva, kao i Katonova pravila (*regula Catoniana*, D.34,7) koje je određivalo da ništav legat neće osnažiti ako naknadno otpadnu razlozi njegove ništavosti.³⁰

³⁰ Flume, W., *Die regula catoniana – ein Exempel römischer Jurisprudenz*, Heidelberg, 1991; Kacprzak, A., *La ratihabito nel diritto romano classico*, Napoli, 2002.

Ipak, u iznimnim je slučajevima navedeno pravilo bilo ublaženo jer je nevaljani pravni posao mogao konvalidirati putem naknadnog odobrenja (*ratihabitio*) ili na osnovi promijenjenih okolnosti, tj. ako bi naknadno otpao razlog ništavosti.

Konvalidacija (*convalidatio*) je naknadno osnaženje nevaljanog pravnog posla.

Pravni posao zaključen za vrijeme malodobnosti mogao je konvalidirati ako bi ga bivši malodobnik odobrio nakon stjecanja punodobnosti; zabranjena darovanja između bračnih drugova mogla su konvalidirati ako ih darovatelj ne bi opozvao do smrti; zajam zaključen protivno *SC Macedonianumu* postajao je valjan ako bi ga naknadno odobrio *pater familias* ili sin nakon emancipacije. U Justinijanovom pravu mogao je konvalidirati svaki ništavi posao putem naknadnog odobrenja, osim u slučaju nepoštivanja propisanog oblika.

U nekim slučajevima stranke su mogle putem **konverzije**³¹ ostvariti ciljeve koje su htjele postići ništavim poslom. Ni konverzija nije bila općeprihvaćena kod rimskih pravnika. Ipak, zabilježeni su slučajevi u kojima je načelno potvrđena. Tako *SC Neronianum* nevaljani *legatum per vindicationem* održava na snazi kao *legatum per damnationem*; nevaljani otpust duga putem akceptilacije (*acceptilatio*) mogao je biti tumačen kao neformalni sporazum o oprostima duga (*pactum de non petendo*). **Bitno je da nevaljani posao sadrži sve pretpostavke za drugi posao kojim stranke mogu postići namjeravane učinke.**

Konverzija (*conversio*) je pretvaranje ništavog pravnog posla u neki drugi pravno valjani posao ako u ništavom poslu postoje pretpostavke za drugi posao kojim će stranke ostvariti ciljeve koje su htjele prvobitnim (ništavim) poslom.

§ 57 – Zastupanje u pravnim poslovima

Zastupanje³² **je sklapanje pravnog posla za drugoga.** Zastupnik je osoba koja vlastitim očitovanjem volje sklapa pravni posao za drugoga.

Zastupanje može biti neposredno i posredno.

Neposredni zastupnik sklapa pravni posao vlastitim očitovanjem volje **u ime i za račun zastupanoga.** Učinci pravnog posla sklopljenog po zastupniku nastaju **neposredno za zastupanoga (gospodara posla).** To znači da zastupana osoba neposredno stječe prava i preuzima obveze kao da je ona sama sklopila taj posao.

³¹ Krampe, Ch., *Die Konversion des Rechtsgeschäfts*, Frankfurt a. M., 1980.

Posredni zastupnik sklapa pravni posao u svoje ime, ali za račun zastupanoga. Učinci tako zaključenog pravnog posla nastupaju za zastupnika jer on stječe prava i preuzima obveze prema trećoj osobi (sukontrahentu) koja ne mora ni znati da je pravni posao sklopljen za račun zastupanoga. Sukontrahent i zastupani (gospodar posla) ne stupaju ni u kakve pravne odnose. Zastupnik će prenijeti učinke pravnog posla na zastupanoga tek naknadno, na temelju posebnog internog odnosa koji postoji između zastupnika i zastupanoga. Zastupani (gospodar posla) mora osloboditi zastupnika svih obveza koje je preuzeo u svoje ime, a za račun zastupanoga.

Kod zastupanja postoje dva odnosa: jedan je između zastupnika i zastupanog, a drugi je odnos između zastupnika i sukontrahenta (treće osobe).

Unutarnji (interni) odnos između zastupnika i zastupanoga može biti uređen na temelju ugovora o nalogu (*mandatum*, kojim se zastupnik – mandatar obvezuje izvršiti neki posao za račun zastupanoga, tj. nalogodavca - mandanta), posloводства bez naloga (u slučaju kada zastupnik preuzme poslove zastupanja po vlastitoj volji i bez prethodnog sporazuma sa zastupanim, zbog čega su njihovi odnosi regulirani na temelju kvazikontrakta - *negotiorum gestio*), tutorstva i skrbništva.

Zastupanje može biti nužno (zakonsko) i dobrovoljno (ugovorno).

Kod **zakonskog zastupanja** pravni poredak daje ovlast za zastupanje druge osobe. U tim slučajevima radi se o tutorstvu i skrbništvu.

Kod **ugovornog zastupanja** zastupnikove ovlasti temelje se na ugovoru o nalogu (*mandatum*) ili na poslovodu bez naloga (*negotiorum gestio*).

Ukoliko je dobrovoljni zastupnik poduzeo poslove bez punomoći, takvi poslovi mogu steći učinak za zastupanoga ako ih on naknadno odobri, sukladno načelu ***ratihabito mandato comparatur*** (odobrenje se izjednačava s mandatom). **Punomoć** je nalogodavčeva izjava, upućena trećim osobama, kojom se daje ovlast punomoćniku da sklapa pravne poslove u ime i za račun opunomoćitelja.

Rimsko pravo nije poznavalo neposredno zastupanje jer tijekom cijele svoje pravne povijesti nije, u načelu, dopustilo sklapanje pravnog posla putem slobodne treće osobe koja bi umjesto stranke očitovala volju potrebnu za sklapanje pravnog posla, tako da bi se učinak pravnog posla izravno odnosio u korist i na teret nenazočne stranke. Vrijedila su pravila da se ništa ne može steći putem slobodne osobe koja nije podčinjena vlasti stjecatelja (***per liberam***

³² Claus, A., *Gewillkürte Stellvertretung im Römischen Privatrecht*, Berlin, 1973; Aubert, J.-J., *Business Managers in Ancient Rome*, Leiden/New York/Köln, 1994; Schäfer, Ch., *Spitzenmanagement in Republik und Kaiserzeit*, St. Katharinen, 1998.

personam nihil nobis adquiri potest) i da se nitko ne može obvezivati za drugoga (*alteri stipulari nemo potest*). Takav stav rimskog prava prema zastupanju posljedica je strogog formalizma starog civilnog prava prema kojem su stranke same, osobno morale zaključiti pravni posao, rimskog shvaćanja o strogo osobnoj prirodi obveznih odnosa, te specifičnosti rimskog procesnog prava zbog kojih je tužitelj mogao tužiti samo ako je imao financijski interes koji je sudac mogao ustanoviti (smatralo se da vjerovnik nema imovinski interes za ispunjenje ugovora prema trećemu).

Veliki utjecaj na rimsko shvaćanje zastupanja imala je i sama struktura rimskog društva. *Pater familias* mogao se pri sklapanju svojih poslova služiti kućnom djecom i robovima. Međutim, te osobe nisu bile zastupnici u pravom smislu nego su samo smatrane produženom rukom obiteljskog starješine. Podčinjeni i robovi mogli su svojim poslovima samo popraviti ekonomski i pravni položaj imatelja vlasti, ali ga nisu mogli obvezivati. Takvo shvaćanje starog prava postalo je velikom smetnjom za nesmetano odvijanje poslovnog života jer s tim osobama više nitko nije htio sklapati pravne poslove. Zato je pretorsko pravo u određenim slučajevima dopustilo trećem sukontrahentu, koji bi sklopio pravni posao s podčinjenim ili robom, tužbe protiv imatelja vlasti (*actiones adiecticiae qualitatis*). Za razvitak instituta zastupanja od posebne su važnosti *actio exercitoria* i *actio institoria* koje su u klasičnom razdoblju dobile širu primjenu jer su se mogle podići protiv vlasnika poduzeća, odnosno broda za obveze slobodnih osoba koje nisu ulazile u krug podčinjenih, a vlasnik ih je postavio za kapetana broda ili poslovođu radnje.

Tužba s istim učinkom u kasnije klasično doba davala se protiv vlasnika za obveze koje bi u granicama ovlasti preuzeo *procurator omnium bonorum* (upravitelj cjelokupne imovine) i koja je u tom proširenom obliku nazvana *actio ad exemplum institoriae actionis*, odnosno *actio quasi institoria*. Ipak, ni u tim slučajevima ne može se govoriti o zastupanju u modernom smislu jer se preuzete obveze nisu odnosile samo na vlasnika, tj. zastupanoga, nego su istodobno obvezivale i kapetana broda, institora ili prokuratora koji su odgovarali zajedno s vlasnikom.

Justinijanovo je pravo ostalo na načelnom stanovištu da je neposredno zastupanje nemoguće.

§ 58 – Naknada štete (*reparatio damni; interesse*)

Ako dužnik svojom krivnjom ne izvrši obećanu činidbu, obvezan je vjerovniku naknaditi štetu.³³ Budući da se radi o osobama koje su se već nalazile u ugovornom odnosu i o šteti koju vjerovnik pretrpi zbog neispunjenja ugovora, govorimo o **ugovornoj odgovornosti**. Za razliku od ugovorne odgovornosti postoji **deliktna odgovornost** do koje dolazi kada netko pričinu štetu osobi s kojom nije bio u ugovornom obveznom odnosu.

Ukoliko je dužnik bio obvezan dati određenu stvar (*dare certam rem*) kod *iudicia stricta*, sudac je bio obvezan procijeniti vrijednost stvari u trenutku litiskontestacije. Ako se radilo o *negotia bonae fidei*, trebalo je procijeniti cjelokupnu vjerovnikovu subjektivnu štetu (*id quod creditoris interest*); otuda tehnički termin za naknadu štete *interesse*.

Kako je u rimskom klasičnom postupku svaka presuda glasila na novac, tužitelj je dobijao samo novčani ekvivalent izostale činidbe. Zato **naknada štete predstavlja oblik popravljanja štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu**.

Odgovornost za neispunjenje činidbe razvijala se postupno, počev od starog prava u kojem je povreda ugovorne obveze kažnjavana kao delikt, da bi se došlo do ugovorne odgovornosti s naknadom štete. Teorija o naknadi štete kao samostalnom predmetu obveze razvila se tek u Justinijanovom pravu.

Uzrokovanje štete dovodi do nastanka obveznog pravnog odnosa naknađivanja štete. U tom obveznom odnosu jedna strana (dužnik – štetnik) obvezna je drugoj strani (vjerovniku – oštećenome) naknaditi prouzročenu štetu, a druga je strana ovlaštena zahtijevati takav postupak. Naknada štete je izvedena obveza koja zamjenjuje izostalu činidbu. Svrha naknade štete je da se oštećenik stavi u takvo imovinsko stanje u kojem bi se nalazio da nije bilo štetne radnje.

Da bi došlo do odgovornosti za štetu, tj. za odštetni zahtjev, moraju se ispuniti određene pretpostavke. **Pretpostavke odgovornosti za štetu su: šteta, protupravnost štetne radnje, uzročna veza i krivnja.**

³³ Medicus, D., *Id quod interest: Studien zum römischem Recht des Schadensersatzes*, Köln, 1962; Below, K.-H., *Die Haftung für lucrum cessans im römischem Recht*, München, 1964; Honsell, H., *Quod interest im bonae-fidei-iudicium: Studien zum römischem Schadensersatzrecht*, München, 1968; Tafaro, S., *La interpretatio ai verba "quanti ea res est" nella giurisprudenza romana: l'analisi di Ulpiano*, Napoli, 1980; Reichard, I., *Die*

1. Šteta (*damnum*)

Šteta je umanj enje nečije imovine (obična šteta – *damnum emergens*) i sprečavanje njezina povećanja (izmakla korist – *lucrum cessans*).

Kada se govori o naknadi štete u rimskom pravu ima se uvidu samo šteta na materijalnim dobrima. Šteta na nematerijalnim pravnim dobrima (povreda časti, ugleda, slobode, tjelesna i duševna bol) u rimskom je pravu povlačila delikt nu odgovornost i kažnjavana je novčanom privatnom kaznom (*poena privata*) kao zadovoljštinom za osobnu povredu. Za razliku od rimskog prava, pojam štete u suvremenom pravu obuhvaća i idealna (nematerijalna) dobra (nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha).

Materijalna (imovinska) šteta pojavljuje se u dva oblika, i to kao: **obična šteta** (pozitivna, stvarna šteta – *damnum emergens*) i **izmakla korist** (negativna šteta – *lucrum cessans*).

Obična šteta (*damnum emergens*) sastoji se u umanj enju imovine koju je oštećenik već imao (npr. izgorjela je kuća).

Izmakla korist (*lucrum cessans*) je korist (dobitak) za koju je izvjesno da bi je oštećenik ostvario prema redovitom tijeku stvari da nije bilo štetne radnje (npr. izgorjela je kuća koja je bila data pod najam: vrijednost kuće predstavlja stvarnu štetu, a novčani iznos koji bi vlasnik dobijao kao najamninu – izmaklu korist). Dakle, izmakla dobit sastoji se u sprečavanju povećanja imovine oštećenoga.

Naknada štete ostvarivana je davanjem novčanog iznosa koji je predstavljao ekvivalent nastale štete, zbog čega se mogla odnositi samo na imovinsku štetu.

2. Protupravnost

Da bi došlo do obveznog odnosa odgovornosti za štetu, radnja kojom je šteta nan esena mora biti u suprotnosti s pravnim propisima. U nekim slučajevima ne može se postaviti odštetni zahtjev jer su nastupile činjenice koje su isključile protupravnost štetne radnje. Te su činjenice u rimskom pravu nužna obrana i krajnja nužda. Po shvaćanju nekih rimskih pravnika te okolnosti isključuju ujedno i krivnju.

Nužna obrana (*inculcata tutela*) je radnja koju netko poduzima da bi od sebe ili od drugoga odbio istodobni protupravni i neskrivljeni napad koji potječe od druge osobe.

Štetna radnja koja je izvršena u granicama nužne obrane nema obilježja protupravnosti jer je protupravno napadnuta osoba imala pravo odbiti napad silom, ako nije bila u mogućnosti obratiti se državnim organima za zaštitu. Međutim, samoobrana je uvijek morala ostati u granicama prijeko potrebne zaštite, što znači da se za štetu učinjenu u prekoračenju nužne obrane moralo odgovarati. Šteta nanescena u obrani ne smije biti puno veća od štete koja je pretrpljena napadom.

Krainja nužda je situacija u kojoj učinitelj vrši štetnu radnju da bi od sebe ili od drugoga otklonio istodobnu neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla ukloniti. Pri tome je bitno da je vrijednost spašenog dobra nerazmjerno veća od vrijednosti žrtvovanoga. Napad ne smije dolaziti od čovjeka, nego od životinje ili elementarne sile (npr. ugrožena osoba ruši susjedovu kuću koju je zahvatio požar da bi spriječila da požar zahvati i njezinu).

3. Uzročna veza

Uzročna veza (kauzalni nesus) postoji kada je dužnikovo djelo (ili propuštanje) **uzrok nastale štete**. Uzročnost je veza između štetne radnje kao uzroka i štete kao posljedice.

Uzročna veza može biti izravna i neizravna. **Izravna uzročna veza** postoji u slučaju kada je štetnikovo djelo jedini i neposredni uzrok štete. Kod **neizravne uzročne veze** na štetnikovu radnju nadovežu se još neke okolnosti i posljedice, pa cijeli taj lanac zajedno dovede konačno do štete.

Akvilijev zakon o šteti (*lex Aquilia de damno*) iz 286. god. p.n.e. uvažavao je samo štetu nanescenu izravnim djelovanjem koje se uvijek moralo očitovati u aktivnom činjenju dužnika (npr. prodavatelj ubije roba kojeg je bio obvezan predati). U klasičnom pravu probija se shvaćanje da šteta ne mora biti izravna posljedica štetne radnje, te da i skrivljeno propuštanje može biti uzrok štete (npr. liječnik propusti dati bolesniku lijek).

Ukoliko se ne utvrdi uzročna veza između štetne radnje i štetne posljedice, ne može se postaviti pitanje štetnikove odgovornosti za štetu.

4. Krivnja

Krivnja je subjektivni (psihički) odnos počinitelja prema štetnom uspjehu.

Krivnja je jedan od najvažnijih instituta u pravu. Procjenjuje se prema određenim kriterijima, odnosno standardima ponašanja na tržištu. Aktivnost dužnika uspoređuje se sa zamišljenim obrascem da bi se utvrdilo je li se u konkretnom obveznom odnosu ponašao onako kako je redovito i uobičajeno u pravnom prometu, odnosno na način predviđen ugovorom (npr. uspoređuje se s ponašanjem svakog prosječnog čovjeka; s ponašanjem idealno dobrog domaćina; kriterij može biti i ponašanje tog istog dužnika u vlastitim poslovima, itd.). Ako se utvrdi da je naknadna nemogućnost ispunjenja obveze skrivljena dužnikovim djelovanjem ili propustom, njegova obveza i odgovornost ne prestaju, nego se primarna obveza zamjenjuje sekundarnom obvezom na naknadu štete prema pravilu da krivnja dužnika čini obvezu trajnom (*culpa debitoris perpetuatur obligatio*).

Staro rimsko pravo smatralo je da je dužnik obavezan naknaditi vjerovniku štetu nastalu zbog neizvršenja dužne činidbe bez obzira na razloge koji su ga spriječili u izvršenju obveze. Nije uzimalo u obzir subjektivni odnos dužnika prema šteti nego je njegovu odgovornost zasnivalo na samoj činjenici da je prouzrokovao štetu. Vrijedilo je načelo **objektivne (kauzalne) odgovornosti**, dakle, dužnik je odgovarao za samo uzrokovanje štete **bez obzira na krivnju**.

Zahvaljujući djelatnosti pretora i pravne znanosti, pod utjecajem načela *bonae fidei* i filozofskih shvaćanja, Rimljani su rano počeli izgrađivati pojam i oblike krivnje. Tijekom klasičnog razdoblja načelo objektivne odgovornosti postupno je zamijenjeno **načelom subjektivne (kulpozne) odgovornosti** koja se temelji na **krivnji**. Dužnik treba odgovarati za naknadu štete samo ako je svojom krivnjom onemogućio ispunjenje dužne činidbe.

U Justinijanovom pravu u potpunosti su razrađena načela o odgovornosti dužnika za naknadu štete zbog neizvršenja ugovornih obveza. Dužnici su obvezni naknaditi štetu kada se neizvršenje obveze moglo pripisati nekom od sljedećih oblika oblika krivnje.

Dolus (namjera; odgovara umišljaju u kaznenom pravu) **postoji kada je štetnik namjerno i svjesno nanio štetu, kada je znao što radi, kakve će posljedice izazvati i kada je želio takve posljedice**. Štetnik postupi znajući i hotimice: on hoće uzrok – štetnu radnju i hoće posljedicu – štetu kod druge osobe (npr. dužnik svjesno i namjerno uništi stvar koja mu je ostavljena na čuvanje; ili, namjerno otruje konja kojeg je nakon zaključenja kupoprodaje obavezan predati). Bilo je zabranjeno ugovoriti *pactum de dolo non praestando*, tj. isključiti odgovornost za *dolus*, jer se za *dolus* uvijek odgovara (*dolus semper praestatur*). Pod

utjecajem načela *bonae fidei* pojam dolusa je proširen, tako da se kod *negotia bonae fidei* pod dolusom shvaća svaka radnja koja je protivna savjesnom i poštenom odnosu između ugovornih stranaka. Kod tih poslova odgovornost za *dolus* se pretpostavljala, dok se kod *negotia stricti iuris* morala ugovoriti posebnom stipulacijom.

Culpa (nepozornost, nemarnost; odgovara nehatu u kaznenom pravu) **postoji kada dužnik ne postupa s potrebnom pozornošću.** Ponašanje štetnika uspoređuje se s ponašanjem drugih ljudi da bi se ustanovilo je li dužnik upotrijebio dužnu pozornost, tj. onu pozornost koja je redovita i uobičajena u pravnom prometu u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa.

Postoji nekoliko stupnjeva nehata.

Culpa lata (krajnja nepozornost, gruba nemarnost) je takvo postupanje kod kojeg dužnik nije upotrijebio ni onu pozornost koju bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Krajnja nepozornost je tako težak stupanj krivnje da se u praktičnim posljedicama izjednačuje s dolusom: *culpa lata dolo aequiparatur* (krajnja nepažnja izjednačuje se s namjerom).

Culpa levis (obična nepozornost) je blaži vid nemarnosti, a pojavljuje se u dva oblika, i to kao *culpa levis in abstracto* i *culpa levis in concreto*.

Culpa levis in abstracto je oblik krivnje koji se procjenjuje apstraktnim kriterijem jer kao mjerilo pozornosti služi **ponašanje nekog zamišljenog idealno savjesnog dobrog domaćina** (*diligens pater familias, bonus pater familias*). Npr. s pozornošću dobrog domaćina mora postupati založni vjerovnik prema založenoj stvari; najamnik prema stvari koju je uzeo u najam, itd.

Culpa levis in concreto ili **diligentia quam in suis** je još blaži oblik krivnje koji se procjenjuje konkretnim mjerilom. Dužnik mora postupati s onom pozornošću koju redovito primjenjuje u **vlastitim stvarima i poslovima**. Tako moraju postupati suvlasnik i sunasljednik, muž u vezi s mirazom, ortak, tutor, kurator.

Objektivna odgovornost dužnika zadržana je i u klasičnom pravu u nekim obveznim odnosima. Ta odgovornost nazivala se **custodia** ili odgovornost za čuvanje stvari. Za nju su odgovarali neki obrtnici (osobe koje su glačale i popravljale tuđu odjeću), posudovnik, vlasnik skladišta (*horrearius*), najamnik iz nekih oblika ugovora o najmu, te brodari, gostioničari i vlasnici staja (*nautae, caupones, stabularii*) za stvari njihovih gostiju, odnosno putnika. Navedene osobe odgovarale su bez obzira na svoju krivnju za svaki nestanak i propast povjerenih im stvari, osim ako bi se to dogodilo višom silom. To znači da su ti dužnici odgovarali za tzv. **casus minores**, npr. ako bi im stvar bila ukradena ili bi je netko treći oštetio. Odgovornost za kustodiju tumačena je u Justinijanovom pravu kao ***culpa in***

eligendo ili *culpa in custodiendo*. Budući da se Justinijanovo pravo zasniva na načelu subjektivne odgovornosti, ti su termini uvedeni kako bi se i *custodia* pretvorila u odgovornost na osnovi krivnje. Ipak, termin **culpa in custodiendo** (manjkavo, nedovoljno pažljivo čuvanje) i dalje podrazumijeva pooštrenu odgovornost bez krivnje sve do više sile kod brodarka, gostioničara i vlasnika staja.

Culpa in eligendo (nemarnost u izboru) je pooštrena odgovornost osoba koje se pri ispunjenju obveze služe radom i uslugama namještenika i pomoćnika. Premda se neizvršenje obveze nije moglo pripisati u njihovu krivnju, dužnici su morali odgovarati zbog greške u izboru namještenika ili pomoćnika koji su prouzrokovali štetu svojom nesposobnošću (npr. krojač mora odgovarati za štetu koju je napravio njegov pomoćnik).

Ako je do neizvršenja ugovorne obveze došlo bez dužnikove krivnje, dužnikova odgovornost prema vjerovniku je prestajala, tj. dužnik je razrješavan obveze (npr. *species* je propala bez dužnikove krivnje). Neizvršenje obveze pripisuje se tada slučaju (*casus*). Za štetu nastalu uslijed slučaja načelno se ne odgovara u skladu s pravilom ***casus sentit dominus*** (slučaj pogađa vlasnika), odnosno ***casus a nullo praestatur*** (za slučaj nitko ne odgovara). Iznimno su za tzv. *casus minores* odgovarale osobe koje su po klasičnom pravu odgovarale za kustodiju ili čuvanje stvari. Za štetu nastalu uslijed više sile (*vis maior*) nisu bili odgovorni.

Casus (casus minores, slučaj) je štetan događaj ili ljudska radnja koji se ne može pripisati krivnji određene osobe. To su **nepredvidljive i nepredviđene okolnosti čije bi posljedice bilo moguće otkloniti da su bile predviđene** (npr. bjekstvo roba ili životinje; oštećenje stvari od strane treće osobe).

Vis maior (casus maiores, viša sila) je buduća neizvjesna okolnost koja se nije mogla predvidjeti, a čak i da je predviđena, nije se mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti (npr. erupcija vulkana, zemljotres, poplava, oluja, brodolom, ratno stanje).

Premda je teško odrediti preciznu granicu između slučaja i više sile, smatra se da je kod slučaja težište na nepredvidivosti, a kod više sile na neotklonjivosti.

5. Utilitetno načelo

Odgovornost³⁴ za štetu prouzročenu neispunjenjem ugovornih obveza određivana je dugo vremena kazuistički (od slučaja do slučaja) jer nije bilo nekih općih pravila. U skladu s načelom autonomije volje, stranke su mogle predvidjeti ugovorom za koji oblik krivnje će odgovarati. Ako nije bilo ništa ugovoreno, krajem klasičnog razdoblja počelo se primjenjivati tzv. **utilitetno načelo**, prema kojem se **odgovornost procjenjuje prema gospodarskim koristima koje proizilaze iz ugovora**. Tako će **strože odgovarati ona stranka koja je imala koristi iz ugovora**, što znači da će odgovarati s povećanim stupnjem odgovornosti (*culpa levis*). Stranka koja iz ugovora nije imala koristi, odgovarala je samo ako je postupala doložno i s grubom nemarnošću (*dolus* i *culpa lata*).

Npr. ugovor o posudbi, kao besplatni pravni posao, zaključuje se u interesu posudovnika, zbog čega posuditelj odgovara samo za *dolus* i *culpa lata*, dok posudovnik odgovara za svaku krivnju, pa i za slučajnu propast stvari po klasičnom pravu; ugovor o ostavi je u interesu deponenta zbog čega on odgovara za *culpa levis*, dok depozitar, koji je besplatno čuvao stvar, odgovara samo za *dolus* i *culpa lata*; kod sinalagmatičnih ugovora, kao što su npr. kupoprodaja i najam, obje stranke odgovaraju podjednako (za *culpa levis in abstracto*) jer i jedna i druga imaju korist iz ugovora.

U svim slučajevima dužnik odgovara za *dolus* i *culpa lata*. Za *culpa levis in concreto* i *culpa in custodiendo* odgovaralo se samo iznimno, kada je takva odgovornost izričito zahtijevana.

Utilitetno načelo ipak nije dosljedno provođeno jer su mandatar i *negotiorum gestor* odgovarali za *culpa levis in abstracto* premda nisu imali koristi od obveze.

§ 59 - Osiguranje ispunjenja obveza

Ako dužnik ne izvrši obećanu činidbu, vjerovnik ga na to može prinuditi putem suda (tužbom). U tom slučaju dužnik mora naknaditi vjerovniku štetu koju taj pretrpi zbog neispunjenja ili lošeg ispunjenja obveze. Međutim, mogu nastupiti situacije u kojima vjerovnik ostaje gotovo bez zaštite: ako dužnik nema imovine za podmirenje duga, ili ako je vjerovnik pretrpio štetu koju je teško dokazati (npr. prodavatelj nakon zaključenja kupoprodaje ponovno proda i preda stvar trećoj osobi i tako izigra vjerovnika). U takvim slučajevima pokazalo se da zakonska sredstva prinude nisu dovoljna garancija za naplatu

³⁴ Arangio-Ruiz, V., *Responsabilità contrattuale in diritto romano*, Napoli, 1933; Robaye, R., *L' obligation de garde: essai sur la responsabilité contractuelle en droit romain*, Bruxelles, 1987; De Robertis, F. M., *La responsabilita contrattuale nel diritto romano: dalle origini a tutta l' età postclassica*, Bari, 1994.

potraživanja. Zbog toga se pribjeglo dopunskim ugovornim sredstvima osiguranja ispunjenja obveze.

Ugovorni oblici osiguranja ispunjenja obveze mogu biti stvarni (realni) i osobni (personalni).

Stvarno osiguranje ispunjenja obveze vrši se tako što dužnik ili treća osoba unaprijed preda vjerovniku određenu stvar kao garanciju za potraživanje. Među najvažnija stvarna sredstva osiguranja spadaju zalog (o kojem je bilo riječi u okviru stvarnog prava) i kapara.

Osobno osiguranje ispunjenja obveze postoji kada se dužnik ili netko treći obveže vjerovniku da će mu dati određenu stvar ako mu tražbina ne bude namirena. Najvažnija sredstva osobnog osiguranja su ugovorna kazna i jamstvo.

1. Ugovorna kazna (*stipulatio poenae*)

Ugovorna kazna (*stipulatio poenae*) je ugovorom unaprijed određeni iznos novca ili druga imovinska korist koju se dužnik obvezuje predati vjerovniku ako ne ispuni svoju obvezu ili zakasni s njezinim ispunjenjem.

Ugovorna kazna (penal)³⁵ jedno je od sredstava koje mogu ugovoriti vjerovnik i dužnik radi pojačanja sigurnosti ispunjenja dužnikove obveze. Ugovaranjem ugovorne kazne vjerovnik se oslobađa tereta dokazivanja nastanka i opsega pretrpljene štete jer ugovorna kazna predstavlja **unaprijed utvrđeni iznos naknade štete**. Na taj način vjerovnik će dobiti naknadu štete bez obzira na dužnikovu krivnju, što znači da ugovorna kazna povećava dužnikovu odgovornost do *custodia*.

Ugovorna kazna zaključivana je u obliku stipulacije. Vjerovnik nije mogao zahtijevati plaćanje i ugovorne kazne i ispunjenje činidbe; njegov zahtjev mora biti alternativan jer je morao utužiti ili osnovnu obvezu ili ugovornu kaznu.

2. Jamstvo

Jamstvo je ugovor kojim se treća osoba – jamac, obvezuje prema vjerovniku da će ispuniti dužnikovu obvezu ako to dužnik ne učini.

³⁵ Knütel, R., *Stipulatio poenae*, Köln, 1976.

Jamstvo je najvažniji oblik osobnog (personalnog) pojačanja ugovora. Sklapanjem ugovora o jamstvu povećava se broj subjekata na dužničkoj strani, čime jača sigurnost vjerovnika za naplatu potraživanja.

Osnovne značajke jamstva su akcesornost, supsidijarnost i pravo na regres.

Akcesornost jamstva znači da ugovor o jamstvu nema samostalno pravno postojanje, nego je ovisan o postojanju i valjanosti obveze čijem osiguranju služi. Jamčeva obveza je sporedna, ovisna ili akcesorna jer dijeli sudbinu obveze glavnog dužnika. Prestankom obveze glavnog dužnika, prestaje i jamčeva obveza; zastarijevanjem obveze glavnog dužnika zastarijeva i obveza iz jamstva; jamac se ne može obvezati na više od glavnog dužnika, niti pod strožijim uvjetima; jamcu pripadaju prigovori koje glavni dužnik ima protiv vjerovnika.

Supsidijarnost jamstva znači da vjerovnik može zahtijevati ispunjenje obveze od jamca, tek onda kada sudskim putem ne uspije namiriti tražbinu od glavnog dužnika. U suprotnom, jamac je bio ovlašten upotrijebiti *beneficium excussionis sive ordinis*, kojim je mogao odbiti ispunjenje obveze vjerovniku.

Pravo na regres je pravo jamca koji je isplatio vjerovnika, da zahtijeva od glavnog dužnika naknadu onoga što je isplatio, a, u slučaju ako ima više jamaca, da zahtijeva od ostalih da mu svaki naknadi dio koji ga tereti.

Navedene značajke vrijede tek za jamstvo Justinijanova prava. Po starom civilnom pravu jamac je tretiran kao samostalni dužnik. Jamstvo nije imalo supsidijarni karakter. Da bi se poboljšao položaj jamca i proširila primjena jamstva, uvedeni su novi oblici jamstva. Jamstvo je sklapano usmenim ugovorom (stipulacijom) i prošlo je kroz tri oblika u rimskom pravu.

Sponsio je najstariji oblik jamstva pristupačan samo rimskim građanima.

Fideipromissio je drugi oblik jamstva kojim su se mogli služiti i peregrini.

Sponsio i *fideipromissio* služili su samo za osiguranje obveza iz stipulacije. Da bi se mogle osigurati i različite druge obveze, uveden je i treći oblik jamstva – *fideiussio*.

Fideiussio je oblik jamstva kojim su se mogli služiti i Rimljani i peregrini. Obveza fidejusora prelazila je na njegove nasljednike i nije bila vremenski ograničena. Samo je taj oblik jamstva prešao u Justinijanovo pravo.

Svi oblici jamstva obuhvaćeni su terminom **adpromissio**, a jamstveni dužnik nazivom **adpromissor**.

Sve do Justinijanova prava vjerovnik je po svom izboru mogao tužiti ili glavnog dužnika ili jamca. Tek je Justinijanovo pravo uvelo načelo supsidijarnosti jamstva i dopustilo jamcu *beneficium excussionis sive ordinis*.

Ukoliko je bilo više jamaca, njihov međusobni odnos do klasičnog prava ravnao se po načelu solidariteta, što znači da je svaki pojedini jamac mogao biti tužen za cjelokupni iznos potraživanja, čime bi ostali bili oslobođeni. U klasičnom razdoblju uveden je *beneficium divisionis*, pa je svaki jamac odgovarao samo za dio koji je na njega otpadao.

Justinijanovo pravo dopustilo je jamcu koji je platio dug *beneficium cedendarum actionum*, tj. pravo zahtijevati od vjerovnika ustup vjerovnikove tražbine i tužbe protiv glavnog dužnika.

Pored navedenih oblika formalističnog jamstva, osiguranju tuđe obveze služili su i neki neformalni poslovi.

Mandatum pecuniae credendae (mandatum qualificatum) je vrsta ugovora o nalogu (*mandatum*) kojim nalogodavac (mandant) nalaže nalogoprimcu (mandataru) da pozajmi novac trećoj osobi, pri čemu nalogodavac ima položaj jamca i odgovara s *actio mandati contraria*.

Constitutum debiti alieni je neformalno obećanje o platežu tuđeg duga, utuživo s pretorskom *actio de pecunia constituta*.

Receptum argentarii je pakt kojim se bankar (*argentarius*) obvezivao platiti dug svog klijenta, zaštićen pretorskom *actio recepticia*.

3. Kapara (*arrha*)

Kapara (odustatnina, *arrha*) je određena imovinska korist koju jedna strana daje drugoj u trenutku sklapanja ugovora i koja služi kao znak da je ugovor zaključen i kao sigurnost da će ugovorna obveza biti ispunjena.

Kapara je u klasičnom pravu služila samo kao vanjski vidljivi znak da je ugovor zaključen (*arrha confirmatoria*). U Justinijanovom pravu stranke su mogle ugovoriti kaparu sa značajem odustatnine (*arrha poenitentialis*), što znači da je stranka mogla slobodno odustati od ugovora ako bi prepustila predanu kaparu, ili ako bi vratila primljenu kaparu (u dvostrukom ili višestrukom iznosu).

Kapara je mogla imati i funkciju ugovorne kazne (*arrha poenalis*) kojom se osigurava izvršenje već sklopljenog ugovora (*arrha pacto perfecto data*) i u tom je slučaju strana koja ne bi izvršila ugovor gubila predanu kaparu, odnosno vraćala dvostruku primljenu kaparu kao naknadu štete.

§ 60 – Zakašnjenje (*mora*)

Do neispunjenja obveze može doći i u situacijama kada dužnik u vrijeme dospelosti duga neće da udovolji svojoj obvezi, premda je to još uvijek moguće, ili zbog toga što vjerovnik bez opravdanog razloga odbije primiti dužnu činidbu. Tada govorimo o dužnikovom, odnosno vjerovnikovom zakašnjenju.

Zakašnjenje dužnika (*mora debitoris, mora solvendi*) postoji kada dužnik u vrijeme dospelosti ne ispuni obvezu svojom krivnjom.

Justinijanovo pravo razradilo je **pretpostavke dužnikove odgovornosti**. Tražbina je morala biti **pravovaljana, utuživa i dospjela**. Vrijeme dospelosti moglo je biti ugovoreno kalendarskim rokom i u tom slučaju dužnik pada u zakašnjenje ako ne ispuni obvezu o roku. Glosatori su stvorili pravilo da rok označen kalendarski opominje umjesto čovjeka (*dies interpellat pro homine*). Vrijeme ispunjenja moglo je biti određeno svrhom i naravi posla (npr. obveza na izgradnju kuće). Ako vrijeme ispunjenja nije bilo nikako određeno, vrijedilo je načelo da se ispunjenje može zahtijevati odmah pri nastanku obveze (*quod sine die debetur, statim debetur*: što se duguje bez roka, duguje se odmah).

Po rimskom pravu **dužnik je morao biti kriv za zakašnjenje i vjerovnik ga je morao opomenuti (*interpellatio*) na platež nakon dospelosti**.

Dužnikovo zakašnjenje izaziva značajne **pravne posljedice** koje se sastoje u **pooštrenju dužnikove odgovornosti i u obvezi na naknadu štete**.

Jedina posljedica dužnikova zakašnjenja kod *negotia stricti iuris* na *dare certam rem* bila je *perpetuatio obligationis*. To znači da je kod obveza čiji je predmet bila individualno određena stvar (*species*), dužnik od časa zakašnjenja odgovoran i za slučajnu (neskrivljenu) propast stvari, zbog čega njegova obveza postaje trajna. Dužnik u zakašnjenju oslobađan je odgovornosti za slučajnu propast stvari ako bi dokazao da bi ona propala na isti način da je bila kod vjerovnika.

Kod *negotia bonae fidei* dužnik je bio obvezan naknaditi svu štetu koju vjerovnik pretrpi zbog zakašnjenja, predati mu plodove koje stekne od dana zakašnjenja (ako se radi o plodonosnoj stvari) i platiti zatezne kamate (moratorni interes) kod novčanih dugova.

Dužnikovo zakašnjenje prestaje (*purgatio morae*) ako dužnik ponudi valjano ispunjenje činidbe.

Vjerovnikovo zakašnjenje (*mora creditoris, mora accipiendi*) nastupa kada vjerovnik bez opravdanog razloga odbije primiti činidbu koju je dužnik ponudio.

Dužnik mora ponuditi ispunjenje činidbe u pogodno vrijeme i na pogodnom mjestu. Vjerovnik mora prihvatiti valjano ponuđenu činidbu i prije dospelosti. Ne traži se vjerovnikova krivnja za odbijanje činidbe.

Glavne posljedice vjerovnikova zakašnjenja ogledaju se u smanjenju dužnikove odgovornosti i obvezi na naknadu troškova dužniku.

Od časa vjerovnikova zakašnjenja dužnik odgovara samo za štetu koju je prouzrokovao svojom doloznom radnjom, bez obzira na pozornost koju je do tada morao posvećivati stvari. Dužnik je imao pravo naplatiti od vjerovnika troškove koje je imao oko čuvanja stvari. Dugovani novac mogao je deponirati na javnom mjestu (npr. u hramu) i tako se osloboditi obveze.

Vjerovnikovo zakašnjenje prestaje (*purgatio morae*) kada izjavi da je spreman primiti dužnu činidbu.

§ 61 – Pluralističke obveze

Obvezni odnos je uvijek odnos između dvije strane: dužnika i vjerovnika. Ako na svakoj strani obveznog odnosa postoji samo po jedan subjekt, onda se radi o **dualističkoj** ili **jednostavnoj obvezi**. Moguće je da na dužničkoj, odnosno vjerovničkoj strani, ili na obje strane, bude više subjekata (dužnika, odnosno vjerovnika) zbog čega nastaje **pluralistička obveza**. U tim slučajevima mora se odrediti međusobni odnos tih subjekata (npr. sunasljednici duguju vjerovniku ostavitelja; ostaviteljev dužnik duguje sunasljednicima; više osoba napravi štetu na stvari koja je u suvlasništvu). Rješenje spomenutih odnosa ovisi prvenstveno o tome je li činidba djeljiva ili nedjeljiva.

Ako se ispunjenje činidbe može rastaviti na dijelove, a da se pri tome ne promijeni bit i ne umanja vrijednost cjelokupne činidbe, radi se o djeljivoj činidbi, odnosno djeljivoj obvezi (*obligatio divisibilis*). Kod pluralističkih obveza tada, u pravilu, **nastaje razdijeljena obveza**.

Ako se ispunjenje činidbe ne može rastaviti na više alikvotnih dijelova, a da se pri tome ne promijeni bit i ne umanja vrijednost cjelokupne činidbe, radi se o nedjeljivoj činidbi, odnosno nedjeljivoj obvezi (*obligatio indivisibilis*). U tom slučaju dolazi, u pravilu, do **solidarne obveze**.

1. Razdijeljene obveze

Razdijeljena obveza postoji ako na dužničkoj, odnosno vjerovničkoj strani ima više subjekata, a činidba je djeljiva, tako da je svaki vjerovnik ovlašten tražiti, odnosno svaki od sudužnika obavezan je ispuniti samo jedan dio cjelokupne činidbe (*pars virilis*).

Čim je činidba djeljiva, a radi se o pluralističkoj obvezi pretpostavlja se da nastaje razdijeljena obveza ukoliko nije izričito ugovorena solidarnost. Kod razdijeljene obveze postoji toliko pojedinačnih samostalnih obveza na dio koliko ima dužnika, odnosno vjerovnika (*obligatio plurium pro parte rata*). Tražbina se između više vjerovnika dijeli na jednake dijelove (ako nije drukčije ugovoreno) tako da svaki od njih može zahtijevati samo svoj dio tražbine, jednako kao što se i dug između više dužnika dijeli na jednake dijelove, tako da je svaki od dužnika odgovoran samo za svoj dio obveze (npr. dva brata naslijede dug od 100 zlatnika; svaki je vjerovniku obavezan platiti po 50).

Budući da se radi o **više samostalnih obveza**, sudbina jedne od njih ne utječe na sudbinu ostalih. Vjerovnik koji naplati svoj dio potraživanja, zadržava taj iznos za sebe i ne tiče ga se hoće li ostali suvjerovnici moći naplatiti svoja potraživanja. Dužnik koji plati svoj dio duga, oslobađa se potpuno obveze, bez obzira jesu li drugi sudužnici isplatili svoje dijelove. Ako vjerovnik oprostí dug jednome od sudužnika, to ne utječe na visinu duga ostalih.

Premda se radi o više samostalnih obveza, djeljive obveze tretiraju se kao cjelina jer imaju zajedničko podrijetlo, tj. potječu iz jedne iste pravne osnove.

2. Solidarne obveze

Ako na dužničkoj, odnosno vjerovničkoj strani ima više subjekata, a činidba je nedjeljiva, nastaje solidarna obveza.

Predmet tih obveza su činidbe koje su glasile na nedjeljive stvari (npr. dva dužnika obvežu se predati roba, živu životinju, umjetničku sliku), kao i činidbe čiji je sadržaj *facere* (npr. izrada slike). Solidarnost može nastupiti i kod djeljivih činidbi, ali samo ako je izričito ugovorena.

Solidarne obveze nastajale su u pravilu ugovorom i tada se nazivaju **korealne solidarne obveze** jer su nastajale putem stipulacije zaključene između više subjekata na dužničkoj (*conreus* – dužnik u stipulaciji) ili vjerovničkoj, ili obje strane. Od razdoblja klasičnog prava solidarnost se kod *negotia bonae fidei* i kod zajma (*mutuum*) mogla ugovoriti na neformalan način.

Solidarnost može biti pasivna i aktivna.

Pasivna solidarnost postoji kada na **dužničkoj strani ima više subjekata**, tako da je svaki od sudužnika obvezan isplatiti vjerovniku cio iznos duga (*in solidum*), a vjerovnik je ovlašten zahtijevati od svakog od dužnika isplatu cjelokupnog iznosa (*solidum*).

Aktivna solidarnost postoji kada na **vjerovničkoj strani ima više subjekata**, tako da je svaki od suvjerovnika ovlašten zahtijevati od dužnika izvršenje cjelokupne činidbe.

Ako činidbu izvrši jedan od sudužnika (kod pasivne solidarnosti), ili tražbinu naplati jedan od suvjerovnika (kod aktivne solidarnosti), obveza se gasi za sve ostale sudužnike, odnosno suvjerovnike, prema načelu: Ako jedan plati, svi ostali oslobađaju se obveze (*Ulpianus, D.45.2.3.1: Si unus solvat omnes liberantur*).

Ta solidarnost naziva se **elektivna solidarnost** (od *eligere* – izabrati) jer vjerovnik može izabrati od kojeg će od više sudužnika zahtijevati ispunjenje cjelokupne činidbe, odnosno, dužnik može odrediti kojem će vjerovniku isplatiti dug, sve dok neki od vjerovnika ne zatraži namirenje.

Jedna od posljedica takvog učinka solidarnih obveza bila je u tome što je litiskontestacija, izvršena temeljem tužbe protiv samo jednoga od sudužnika, ili podignuta od strane samo jednoga od suvjerovnika, gasila obvezu, čime su svi ostali sudužnici oslobađani obveze, a svi ostali suvjerovnici onemogućeni ponovno sudskim putem tražiti naplatu duga. To je bilo nezgodno ako bi bio utužen platežno nesposoban dužnik, zbog čega je Justinijanovo pravo ukinulo konsumptivan učinak litiskontestacije. Vjerovnik je mogao i nakon utuženja jednoga od dužnika, utužiti i ostale, a obveza je prestajala tek vjerovnikovim namirenjem. Za ostale načine gašenja obveza vrijedilo je pravilo da oni koji izazivaju gašenje *ipso iure* djeluju prema svima, a oni koji su izazivali gašenje *ope exceptionis* imali su učinak samo prema dužniku koji je mogao istaknuti odnosni prigovor.

Justinijanovo pravo uvelo je i tzv. *beneficium divisionis*, kojim je utuženi dužnik dobio pravo zahtijevati od vjerovnika da utuži i ostale solventne dužnike i da svaki od njih odgovara samo za alikvotni dio obveze. Time je solidarna obveza gotovo izjednačena s razdijeljenom obvezom.

Postklasično pravo uvelo je za pasivne solidarne obveze tzv. *beneficium cedendarum actionum*, na osnovi kojeg je dužnik – platac dobio pravo regresa od ostalih sudužnika, tako što mu je vjerovnik morao ustupiti svoje tužbe protiv ostalih sudužnika. Do tada je pravo regresa (i diobe naplaćenoga među suvjerovnicima) moglo biti zasnovano samo na posebnom pravnom odnosu među suvjerovnicima, odnosno sudužnicima (ugovoru o ortaštvu, ugovoru o nalogu, slučajnoj zajednici, poslovodstvu bez naloga).

Postojale su i **kumulativne ili neprave solidarne obveze** koje su nastajale **počinjenjem delikata koji su vrijeđali osobna ili idealna dobra rimskih građana**. Ti delikti povlačili su penalne tužbe (*actiones poenales*), čiji je cilj kažnjavanje počinitelja. Zbog toga, u slučaju kada je delikt izvršilo više osoba, **svaki od suizvršitelja bio je obvezan platiti cio iznos kazne** (*poena privata*), a isplata jednog od dužnika nije oslobađala ostale, kao što ni naplatom kazne od strane jednog vjerovnika (kod delikata kod kojih je bio povrijeđen pravno zaštićeni interes više osoba) nisu prestajala potraživanja ostalih. U takvim slučajevima dolazilo je do **kumulativne solidarnosti**.

Međutim, delikti, kojima je prouzročeno oštećenje imovine, povlačili su reipersekutorne tužbe (*actiones rei persecutoriae*) koje su dovodile do elektivne solidarnosti.

U navedenim oblicima pluralističkih obveza (razdijeljenim i solidarnim) subjekti koji sačinjavaju dužničku, odnosno vjerovničku stranu imaju isti gospodarski i pravni interes, što znači da je njihov međusobni odnos koordiniran. Međusobni odnos više dužnika i vjerovnika može biti akcesoran ako jednima pripada glavna tražbina, odnosno dug, a drugi nastupaju samo kao sporedni vjerovnici (*adstipulatio*), odnosno sporedni dužnici (jamstvo, koje je obrađeno u lekciji o osiguranju obveza).

3. *Adstipulatio*

Adstipulatio je dodatna stipulacija kojom je dužnik obećavao da će obvezu iz glavne stipulacije izvršiti trećoj osobi (adstipulatoru) ako glavni vjerovnik umre ili bude odsutan. Sklapana je u svrhe zastupanja, te da bi se osigurao prijenos tražbine na nasljednika ili ugovoranja u korist nasljednika. Adstipulatorova prava su akcesorna jer nije mogao zahtijevati naplatu ako bi se glavna tražbina ugasila na bilo koji način.

Međutim, ako bi glavni vjerovnik umro, adstipulator je mogao naplatiti potraživanje. Premda samo uzgredni vjerovnik, adstipulator je mogao i naplatiti i oprostiti dug, i tužiti dužnika, ali nije smio učiniti ništa protiv interesa glavnog vjerovnika, inače bi odgovarao za naknadu štete po *lex Aquilia*. Kada su u Justinijanovom pravu proglašene valjanim sve stipulacije u korist nasljednika, *adstipulatio* je nestala iz upotrebe.

§ 62 – Učinak obveza prema trećim osobama

Obveza (*obligatio*) u rimskom je pravu shvaćana kao odnos strogo osobne naravi (*intuitu personae*) zbog čega nitko treći koji nije sudjelovao u zaključenju obveznog odnosa nije mogao steći ni prava ni obveze iz njega. Takav stav najbolje odražavaju tekstovi rimskih pravnika u kojima se kaže da se ništa ne može steći putem slobodne osobe koja nije podčinjena našoj vlasti: *per extraneam (liberam) personam nobis adquiri non posse* (G.2.95; I.2.9.5), te da nitko nije ovlašten za drugoga zaključivati obveze: *alteri stipulari nemo potest* (*Ulpianus*, D. 45.1.38.17).

Izvjесne iznimke od tog shvaćanja poznaо je već Zakonik XII ploča koji je predvidio odgovornost imatelja vlasti za deliktne obveze robova i podčinjenih osoba (tzv. noksalna odgovornost). Kasnije je uvedena odgovornost gospodara za neke ugovorne obveze podčinjenih osoba na temelju *actiones adiecticiae qualitatis*, a tijekom klasičnog razdoblja omogućena je utuživost ugovora u korist trećih dodavanjem ugovorne kazne (*stipulatio poenae*). Ali, i pored navedenih iznimki, pravilo *alteri stipulari nemo potest* vrijedilo je i u Justinijanovom pravu.

1. Ugovori u korist i ugovori na teret trećih osoba

Premda je u rimskom pravu vrijedilo načelo da treće osobe ne mogu steći prava niti preuzeti obveze iz tuđeg ugovora (*Res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest*: ugovor zaključen između jednih, drugima ne može ni škoditi ni koristiti), postojale su određene iznimke kojima je omogućeno ugovaranje u korist trećega.

Ugovor u korist trećega (*pactum in favorem tertii*)³⁶ postoji kada se jedna osoba (obecavatelj, promitent) obveže drugoj osobi (*stipulator*, stipulant, promisar) da će ispuniti određenu činidbu u korist trećega (korisnik, beneficijar, destinatar) koji nije sudjelovao u zaključenju ugovora.

Tim ugovorom promitent – dužnik obećaje stipulantu – vjerovniku da će izvršiti određenu činidbu u korist treće osobe (npr. kupac se obveže prodavatelju da će cijenu isplatiti trećoj osobi; zajmoprimac se obveže da će periodično trećemu isplaćivati ugovorene kamate; roditelj plati nastavniku stranih jezika ili glazbe da podučava njegovo dijete).

³⁶ Wesenberg, G., *Verträge zugunsten Dritter*, Weimar, 1949; Bayer, W., *Der vertrag zugunsten Dritter*, Tübingen, 1995.

Osnovni problem kod tih ugovora je može li treća osoba (beneficijar) samostalno od dužnika zahtijevati ispunjenje obećane činidbe i može li ga tužiti. Zbog načela *alteri stipulari nemo potest* staro rimsko pravo negativno je odgovaralo na ta pitanja: promitent je mogao odbiti beneficijarov zahtjev jer s njim nije zaključio ugovor. Ni stipulant nije mogao tužiti jer nije imao neposredni materijalni interes na ispunjenje činidbe trećemu. Rješenje je pronađeno u klasičnom pravu **dodavanjem ugovorne kazne** (*stipulatio poenae*) za slučaj da dužnik - promitent ne ispuni svoju obvezu. Time je vjerovnik – stipulant dobio imovinski interes, pa time i mogućnost podizanja tužbe.

Postklasično i Justinijanovo pravo priznavali su valjanost ugovora u korist trećega uvijek kada je vjerovnik – stipulant imao imovinski interes na ispunjenje obveze trećemu.

Ugovori na teret trećih osoba postoje kada jedna osoba obeća drugoj da će joj netko treći nešto dati ili učiniti. Ti ugovori nisu proizvodili pravni učinak. Justinijan je dopustio jednu iznimku, a to je ugovor na teret nasljednika.

§ 63 – Promjena subjekata u obveznim odnosima

Staro rimsko pravo nije poznavalo prijenos obveza pojedinačnim ili singularnim načinima nego jedino putem univerzalne sukcesije. *Ius civile* nije dopuštalo promjenu subjekata u obveznom odnosu zbog strogo osobnog karaktera obveza. Vremenom su ipak pronađena pravna sredstva kojima je postizana promjena subjekata u obvezi. Stranke koje su željele izvršiti prijenos tražbine, odnosno dugovanja koristile su se u starije vrijeme novacijom i mogućnošću zastupanja u sporu, da bi se došlo do posebnih instituta kojima je vršena promjena osobe vjerovnika (*cessio*), odnosno dužnika (*expromissio*).

1. *Cessio*

Ustup ili cesija (*cessio*) je ugovor kojim vjerovnik (ustupitelj, cedent) prenosi svoju otuđivu tražbinu na drugoga (cesionara).

Promjena vjerovnika vršena je najprije novacijom, tj. tako što bi novi ugovor s istim sadržajem bio zaključen između novog vjerovnika i dužnika, dok bi se stara obveza ugasila. Za takav prijenos tražbine bila je potrebna suglasnost dužnika. Ovdje se još uvijek ne može govoriti o cesiji u pravom smislu.

Sljedeći korak ka uvođenju cesije bilo je procesualno zastupanje. Novi vjerovnik, tj. osoba na koju je trebalo prenijeti tražbinu, utužio bi tražbinu kao vjerovnikov zastupnik u

sporu (*cognitor*, ili kasnije *procurator in rem suam*), pa bi pomoću pretorske formule s premještajem subjekata postigao da presuda glasi na njegovo ime. Ali, ni u tom slučaju ne radi se o ustupanju tražbine, nego o ustupanju tužbe.

Tek je u klasičnom pravu omogućeno ugovorom odrediti novog vjerovnika, s tim što je cedent morao obavijestiti dužnika o promjeni. Nakon te obavijesti (*denuntiatio*; *notificatio*) ustupljeni dužnik (*debitor cessus*) nije više mogao valjano platiti dug cedentu, niti ga je on mogao više tužiti.

Cesionar je stjecao tražbinu u istom opsegu i s istim uzgrednim pravima (zalogom, jamstvom) kako je ono pripadalo cedentu. Ustupljeni dužnik ne smije cesijom biti stavljen u gori položaj prema novom vjerovniku zbog čega je mogao protiv cesionara upotrijebiti sve prigovore koje je mogao upotrijebiti protiv cedenta (izuzev prigovora strogo osobne naravi), npr. prigovor zastare ili prigovor ništavosti pravnog posla iz kojeg potječe tražbina.

Cedent je odgovarao cesionaru za *dolus* (i *culpa lata*) ako se pravni razlog cesije sastojao u darovanju. Ako se radilo o kupoprodaji tražbine, cedent je odgovarao za veritet ili istinitost tražbine (*nomen verum esse*), tj. da tražbina uistinu postoji, a nije morao jamčiti za bonitet (*nomen bonum esse*), tj. za njezinu naplativost ili likvidnost.

U postklasičnom pravu donošeni su razni propisi kojima se nastojalo spriječiti špekulativne poslove s cesijama. Koristeći teške financijske prilike sitnih vjerovnika, bogataši su od njih kupovali potraživanja po niskoj cijeni, a zatim ih naplaćivali od dužnika u punom iznosu zgrćući tako ogromno bogatstvo. Zbog toga je bilo zabranjeno ustupanje potraživanja od *humiliores* na *potentiores*, kao i ustupanje spornih tražbina (*res litigiosae*), a s *lex Anastasiana* propisano je da cesionar ne smije naplatiti od dužnika više od onoga što je kao naknadu za ustupljenu tražbinu platio cedentu.

2. *Expromissio*

Pravna sredstva kojima je postizana promjena osobe dužnika u obveznom odnosu bila su novacijska stipulacija i procesualno zastupanje. Za promjenu dužnika uvijek se tražila suglasnost vjerovnika jer vjerovniku nije svejedno kakvu će osobu dobiti za dužnika.

Promjena dužnika putem novacijske stipulacije vršena je ugovorom kojim se treći obvezivao vjerovniku na istu obvezu. Time bi stara obveza prestala zajedno sa svim svojim akcesorijima, a nastala bi nova obveza.

Promjenu dužnika bilo je moguće izvršiti putem **procesualnog zastupanja**, tako što bi dužnik ovlastio preuzimatelja duga da se kao njegov zastupnik (*cognitor* ili *procurator in rem*

suam) upusti u spor s vjerovnikom. Zahvaljujući formuli s premještajem subjekata osuda bi glasila na novog dužnika i protiv njega se vodila ovrha.

Drugo poglavlje

PRESTANAK OBVEZA

Obveza je vremenita jer u pravilu kratko traje. Obvezni odnosi vezani su za brzu cirkulaciju i razmjenu dobara i usluga. Zbog toga je cilj svake obveze da sva potraživanja budu zadovoljena i svi dugovi namireni, kako bi obveza bila izvršena i time ugašena.

S obzirom na njihov učinak načini prestanka obveza dijele se na one koji su dovodili do **prestanka obveze po civilnom pravu (*ipso iure*)** i na one koji su svoju osnovu imali u pretorskom pravu i koji su davali dužniku pravo uložiti **prigovor protiv vjerovnikovog zahtjeva kojim je isticao da postoje određene činjenice koje mu daju pravo ne izvršiti činidbu iz postojeće obveze (*ope exceptionis*)**.

§ 64 – Prestanak obveza *ipso iure*

1. Svečani načini prestanka obveza starog prava (*solutio per aes et libram; acceptilatio*)

Rimski su pravnici isticali da ništa nije prirodnije nego da se obveze ugase na način sličan onome na koji su nastale (D.50.17.35). Tako su obveze koje su nastale u formi *per aes et libram* gašene uz iste formalnosti putem ***solutio per aes et libram***, a obveze koje su nastale iz verbalnog kontrakta stipulacije, putem akceptilacije (***acceptilatio***) koja je vršena na način analogan stipulaciji: svečanim pitanjem dužnika i odgovorom vjerovnika da je primio dugovano. Obveza je prestajala izvršenjem propisanih formalnosti bez obzira je li dužnik zaista izvršio dugovanu činidbu.

2. *Solutio* (ispunjenje)

Solutio (ispunjenje) je redoviti način prestanka obveze *ipso iure*. Već od razdoblja Republike nisu više tražene nikakve formalnosti vezane za ispunjenje obveze. Solucijom se gase sve obveze bez obzira na njihov izvor i bez obzira na njihov sadržaj.

***Solutio* (ispunjenje) je prestanak obveznog pravnog odnosa pravilnim i urednim ispunjenjem dužne činidbe.**

Kod ispunjenja obveze postavljaju se pitanja: tko, kome, gdje, kada i što treba izvršiti.

Tko može ispuniti obvezu?

Dugovanu činidbu treba ispuniti sam dužnik. Međutim, ako se ne radi o obvezama strogo osobne naravi (*intuitu personae*), vjerovnik je dužan primiti ispunjenje i od treće osobe, bez obzira na dužnikovo znanje, pa i protiv njegove volje.

Kome se može ispuniti obveza?

Obvezu treba ispuniti vjerovniku ili osobi koja je ovlaštena primiti ispunjenje (tutor, prokurator, mandatar, adstipulator, ili *solutionis causa adiectus* – osoba ovlaštena primiti činidbu i primljeno predati vjerovniku). Obveza se ne može ispuniti neovlaštenoj osobi (*negotiorum gestor*), osim ako to vjerovnik naknadno ne odobri (*ratihabitio*).

Kako se mora ispuniti obveza?

Dužnik je obavezan ispuniti činidbu pravilno i uredno, na određenom mjestu u određeno vrijeme i na određeni način.

Gdje treba izvršiti obvezu? (mjesto ispunjenja)

Obvezu treba ispuniti na ugovorenom mjestu ili na mjestu gdje sama narav obveze ili svrha posla nalažu (npr. izgradnja kuće). Ako nije ništa ugovoreno, obvezu treba ispuniti u mjestu domicila dužnika.

Kada treba izvršiti obvezu? (dospjelost)

Obvezu treba izvršiti kada bude dospjela. Dospjelost je trenutak od kojega vjerovnik može zahtijevati ispunjenje dužne činidbe. Vrijeme dospelosti obveze može biti određeno ugovorom (ugovorni rok), zakonom (zakonski rok) i odredbom mjerodavnog tijela. Dužnik može izvršiti dugovanu činidbu i prije dospelosti, osim ako je rok ispunjenja u interesu vjerovnika. Ako rok nije određen, trebalo je uzeti u obzir prirodu obveze i svrhu posla, kao i ostale okolnosti koje bi zahtijevale stanovito vrijeme za postizanje cilja obveze. U tim slučajevima radi se o prirodnom roku kod kojeg je dužnikova obveza dospijevala tek istekom roka potrebnog za ostvarenje cilja obveze. Ako bi vjerovnik tužio dužnika prije protoka prirodnog roka, mogao je biti odbijen s obrazloženjem da je potraživao prije dospelosti (*pluspetitio tempore*). Ako se dospelost obveze ne može odrediti ni na ovakav način, vrijedilo je pravilo da dužnikova obveza nastaje u času zaključenja ugovora, što znači da je vjerovnik mogao zahtijevati ispunjenje obveze odmah po njezinu nastanku.

Što treba ispuniti? (predmet ispunjenja)

Dužnik je obavezan izvršiti činidbu na koju se obvezao i koja se mogla sastojati u davanju, činjenju, propuštanju ili trpljenju. Činidba je morala biti ispunjena u cijelosti. Tek je Justinijanovo pravo propisalo da vjerovnik pod određenim okolnostima mora prihvatiti djelomično ispunjenje. Dužnik nije mogao svojevóljno izvršiti zamjenu dugovane obveze

nekom drugom. Ipak, u klasičnom je pravu bilo dopušteno ugovoriti da se dužnik može osloboditi obveze ako vjerovniku, umjesto onoga što je stvarno dugovao, preda neku drugu stvar (*datio in solutum voluntaria*). U postklasičnom pravu uvedena je *datio in solutum necessaria* u korist prezaduženih vlasnika zemljišta. Oni su, prema pravičnoj procjeni, mogli ponuditi vjerovnicima svoje nekretnine umjesto novca, što su vjerovnici morali prihvatiti.

Može se dogoditi da dužnik vjerovniku duguje **više istovrsnih obveza** (npr. duguje više novčanih obveza iz kupoprodaje i zajma), a ono što ispuni nije dovoljno za podmirenje svih dugova. Tada dužnik treba odrediti koje je dugove time isplatio. Ako dužnik to ne odredi, odlučuje vjerovnik imajući u vidu dužnikove interese. Ako ni vjerovnik ne bi ništa odredio, vrijedila su sljedeća pravila: kamate se podmiruju prije glavnice; dospjele obveze prije nedospjelih, a ako su sve jednako dospjele, namiruju se one koje su po dužnika tegotnije; ako su sve jednako teške, podmiruje se dug koji je nastao iz starije obveze. Ako se navedena pravila ne mogu primijeniti, podmiruju se svi dugovi srazmjerno njihovoj visini, što znači da se dugovi isplaćuju samo djelomice, pa djelomice i ostaju.

dokaz ispunjenja

Dužnik je putem svjedoka ili upisom u knjige (kod pisane akceptilacije) mogao dokazati da je ispunio obvezu, a od klasičnog razdoblja uobičajilo se da vjerovnik izda dužniku priznanicu (*apocha*) o vraćenom dugu. *Apocha* je dobijala punu dokaznu moć tek trideset dana nakon izdavanja. U tom je roku vjerovnik mogao pobijati njezinu valjanost s *querella non numeratae solutionis* (tužbom kojom je tvrdio da mu nije vraćen dugovani iznos, odnosno da mu nije izvršena dugovana činidba).

3. *Novatio* (obnova obveze)

***Novatio* (obnova obveze) je ugovor između vjerovnika i dužnika kojim se postojeća obveza gasi i zamjenjuje novom, koja sadrži neki novi element (*aliquid novi*).**

Sklapanjem novacijskog ugovora stara obveza gasi se zajedno sa svim akcesornim pravima (realnim i personalnim sredstvima osiguranja, kamatama). Novacija je uvijek vršena u formi stipulacije (novacijska stipulacija).

Pretpostavke za novaciju su: novi element (*aliquid novi*), forma i volja stranaka (*animus novandi*).

Nova obveza mora se razlikovati od stare promijenjenim subjektima, promijenjenom osnovom ili nekim drugim novim važnim elementom.

Najčešća novina sastojala se u **promjeni subjekata obveznog odnosa** i tada se radi o **novatio inter novas personas** ili **novatio qualificata**. Promjena osobe vjerovnika vršena je aktivnom delegacijom (*delegatio nominis* ili *crediti*). Na temelju upute starog vjerovnika dužnik bi sklopio s novim vjerovnikom ugovor istog sadržaja, čime se stara obveza gasila. Ovdje se radi, u stvari, o ustupanju tražbine (*cessio*).

Promjena osobe dužnika mogla je biti izvršena pasivnom delegacijom (*delegatio debiti*), kada je dužnik upućivao drugu osobu da se novacijskom stipulacijom obveže da će postojeći dug platiti istom vjerovniku. Ako je do promjene dužnika došlo bez dužnikova pristanka, radi se o *expromissio*.

Novacija između istih subjekata (**novatio inter easdem personas** ili **novatio simplex**) vršena je promjenom sadržaja (npr. dodavanjem novog roka, mjesta ili uvjeta plaćanja, jamstva, zalog, itd.) ili promjenom pravne osnove (npr. dug iz delikta ili ugovora *bonae fidei* pretvoren je u dug iz stipulacije, što je za vjerovnika povoljnije).

Sve do Justinijanovog prava stara i nova obveza morale su imati isti predmet (*idem debitum*). Justinijanovo pravo proširilo je mogućnost novacije tako što je dopustilo promjenu predmeta obveze. Također je propisalo da je za novaciju potrebna i izričito očitovana volja stranaka (*animus novandi* ili *voluntas novationis*) kako bi se izbjegla dvojba o pitanju jesu li stranke zaista htjele proizvesti učinak novacije.

Za razliku od navedenih oblika novacije do kojih je dolazilo pravnim poslom (*novatio voluntaria*), postojala je i *novatio necessaria* koja je bila vezana za učinak litiskontestacije i presude.

4. *Confusio*

Obveza se gasi sjedinjenjem (*confusio*) ako se tražbina i dug steknu u istoj osobi. Do sjedinjenja dolazi univerzalnom sukcesijom (nasljeđivanjem, adrogacijom, sklapanjem *manus-braka*).

5. Naknadna nemogućnost ispunjenja

Obveze koje glase na individualno određene stvari (*species*) gase se ako dužna stvar propadne uslijed slučaja (*casus*) po načelu *species perit ei cui debetur* (*species* propada onome kome se duguje). Ako je *species* propala dužnikovom krivnjom, ili je dužnik u zakašnjenju, primarna dužnikova obveza zamjenjuje se obvezom na naknadu štete.

6. Smrt

Ugovorne obveze se, u načelu, ne gase smrću, nego prelaze na nasljednike. Ugovorne obveze su imovinske naravi zbog čega se ne gase smrću. Smrću se gase samo ugovorne obveze *intuitu personae*, tj. one obveze koje su zaključene zbog individualnih osobina suugovaratelja (obveze iz ugovora o ortaštvu, iz ugovora o nalogu, iz ugovora o djelu: npr. obveza slikara na izradu portreta, obveza pjevača i sl.).

Deliktne obveze po starom pravu nisu bile ni aktivno ni pasivno nasljedive. Po klasičnom pravu **deliktني zahtjevi na aktivnoj strani nisu prestajali smrću vjerovnika – oštećenoga**, nego su prelazili na nasljednike, izuzev ako se radilo o deliktним tužbama strogo osobnog karaktera (*actiones vindictam spirantes*).

Deliktne obveze na pasivnoj strani (tj. na strani dužnika – delinkventa) i dalje su ostale nenasljedive, tj. **gasile su se delinkventovom smrću**, s tim što su se protiv nasljednika mogle dopustiti tužbe na povratak eventualnog obogaćenja.

7. *Capitis deminutio*

Svaka promjena ili gubitak statusa (*capitis deminutio*) povlačila je odgovarajuću promjenu ili gubitak pravne i poslovne sposobnosti. Po rimskom shvaćanju ugovorne obveze vezane su za pravnu sposobnost, a deliktни dugovi za fizičku osobu. Zbog toga su se **ugovorne obveze gasile zajedno s gašenjem pravne sposobnosti, a deliktne je obveze počinitelj nosio sa sobom sve dok je živ, bez obzira na eventualne promjene statusa.**

Osoba koja bi pretrpjela *capitis deminutio maxima* (izgubila slobodu) ili *capitis deminutio media* (izgubila rimsko pravo građanstva) nije više mogla naplatiti svoje tražbine, niti su je mogli tužiti njezini vjerovnici. *Capitis deminutio minima* (gubitak statusa u obitelji) također je dovodila do prestanka ugovornih obveza, ali je pretor u tom slučaju dopuštao *restitutio in integrum* i fikticijske *actiones utiles* i tako omogućavao vjerovnicima da se naplate iz dužnikove imovine koja je sada pripadala onome u čiju je korist nastupila *capitis deminutio* (mužu pri zaključenju braka s manusom; usvojitelju kod adrogacije).

§ 65 – Prestanak obveza *ope exceptionis*

Uvrštenjem prigovora u formulu pretor je omogućavao tuženiku da odbije tužiteljev zahtjev premda je obveza postojala po civilnom pravu i vjerovnik imao pravo zahtijevati isplatu duga. Tuženik je isticao u prigovoru da postoje određene činjenice ili razlozi koje su mu davale pravo ne isplatiti postojeći dug.

1. *Pactum de non petendo* (oprost duga)

***Pactum de non petendo* je neformalni sporazum kojim se vjerovnik odricao prava zahtijevati od dužnika vraćanje duga.**

Ukoliko bi se vjerovnik predomislio i ipak zatražio isplatu, dužnik je mogao istaknuti prigovor sklopljenog sporazuma o oprostima duga (*exceptio pacti conventi*) i time zauvijek odbiti tužbu (*exceptio peremptoria*).

Ako je obveza potjecala iz pravnog posla *bonae fidei*, taj je sporazum djelovao *ipso iure*, što znači da ga je sudac uzimao u obzir po službenoj dužnosti (*pacta conventa inesse bonae fidei iudiciis*).

Vjerovnik je mogao oprostiti dug u cijelosti ili djelomično, trajno ili privremeno. Ako se vjerovnik odrekao svog prava trajno i zauvijek, radi se o *pactum de non petendo in perpetuum*. Privremeni oprost duga značio je samo priček – *pactum de non petendo in tempus* i dužnik je kroz određeno vrijeme mogao odbiti vjerovnikovu tužbu dilatornom ekscepcijom.

Neformalni sporazum o oprostima duga mogao se odnositi samo na određenog dužnika (*pactum de non petendo in personam*), ili na sve sudionike u obveznom odnosu, kao što su solidarni dužnici, jamci, nasljednici (*pactum de non petendo in rem*).

2. *Compensatio* (prijeboj)

***Compensatio* (prijeboj) je način prestanka obveze međusobnim obračunavanjem tražbina koje postoje između dviju osoba.**

Npr. osoba A duguje osobi B iz kupoprodaje, a osoba B osobi A iz zajma; njihove međusobne tražbine se obračunaju i tako prestanu.

Prijeboj može biti potpun ako tražbina i protutražbina glase na iste svote, ili djelomičan, kada se manji dug ugasi i za toliko umanjuje veći dug, tako da se strani s većim potraživanjem plaća samo razlika.

U razdoblju starog prava do kompenzacije je moglo doći samo dragovoljnim sporazumom stranaka jer staro civilno pravo nije dopuštalo prijeboj. U klasičnom pravu

uvedena je kompenzacija kao opće načelo u poslovima *bonae fidei*, a od II. st.n.e. proširena je mogućnost prijeboja i na poslove *stricti iuris*. Klasično pravo poznavalo je dragovoljnu, zakonsku i sudsku kompenzaciju.

Justinijanovo pravo postavilo je određena pravila za prijeboj. **Tražbine su morale biti uzajamne, dospjele, istovrsne i utužive.**

Kompenzacija je mogla biti izvršena **samo između stranaka koje su uzajamno vjerovnik i dužnik**. Postojale su neke iznimke od zahtjeva uzajamnosti: jamac je mogao protiv vjerovnika kompenzirati tražbine glavnog dužnika; solidarni dužnik mogao je staviti u prijeboj prema vjerovniku potraživanja sudužnika; ustupljeni dužnik (*debitor cessus*) mogao je potraživanju novog vjerovnika (cesionara) staviti u prijeboj potraživanje koje je imao prema starom vjerovniku (cedentu).

Tražbine moraju biti dospjele. Nisu se mogle kompenzirati utužene dospjele obveze s nedospjelim protupotraživanjem.

Tražbine koje se međusobno obračunavaju moraju biti istovrsne. To znači da oba potraživanja moraju glasiti na stvari istog roda i kvalitete (npr. može se kompenzirati novac za novac; žito za žito; vino za vino).

Tražbine moraju biti utužive, jasne i lako odredive, tako da se mogu ostvariti sudskim putem i da ih sudac može utvrditi bez dugotrajnog dokazivanja. Nije dopušteno staviti u prijeboj sporno potraživanje, tj. potraživanje o kojem teče parnica (*res litigiosa*) s nespornim protupotraživanjem, niti uvjetnu obvezu s bezuvjetnom.

Kada su bile ispunjene navedene pretpostavke, dolazilo je do gašenja tražbine i protutražbine *ipso iure*.

Treće poglavlje

OBVEZE IZ KONTRAKTA (*OBLIGATIONES EX CONTRACTU*)

§ 66 – Pojam i klasifikacija kontrakata

Kontrakt (*contractus*)³⁷ je obvezni ugovor iz kojeg po civilnom pravu nastaje utuživa obveza.

Termin *contractus* rimski su pravnici ograničavali na područje obveznog prava označavajući njime obvezni ugovor (za razliku od stvarnopravnih, obiteljskopравnih, nasljednopravnih, međunarodnih itd. ugovora) utuživ po civilnom pravu. Ugovori koji nisu bili utuživi po civilnom pravu označavani su terminima *pactum*, *pactio* (*ex nudo pacto obligatio non nascitur*: iz golog sporazuma ne nastaje obveza). Dok je po suvremenom pravu sporazum volja ugovornih stranaka (*consensus*) odlučujuća okolnost koja utemeljuje obvezu, rimsko je pravo polagalo veću važnost na objektivni element forme. **Kontrakt je postojao samo ako je suglasnost volja izražena u određenoj formi i ako je postojala unaprijed predviđena tužba za zaštitu ugovornog odnosa.** Vremenom su zahtjevi vezani za formu popuštali, tako da se u postklasičnom i Justinijanovom pravu termin kontrakt približava današnjem shvaćanju ugovora.

Najvažnija klasifikacija kontrakata izvršena je s obzirom na način zaključenja upravo zbog velikog značaja forme u rimskom pravu. Vanjski, objektivni element forme sastojao se ili u izgovaranju svečanih riječi, putem kojih su nastajali **verbalni kontrakti**; ili upotrebom određene pisane forme, kako su nastajali **literalni kontrakti**; ili u predaji stvari, što je bilo potrebno za **realne kontrakte**, a za kategoriju **konsenzualnih kontrakata**, koji su se pojavili posljednji, bio je dovoljan neformalni sporazum stranaka.

§ 67 – Verbalni kontrakti

Verbalni kontrakti nastajali su izgovaranjem propisanih svečanih riječi. Najvažniji verbalni kontrakt bila je **stipulacija (*stipulatio*)** koja je imala široku primjenu tijekom cijele rimske pravne povijesti. Ostali verbalni kontrakti bili su manje značajni: ***vadiatura*** i ***praediatura*** bili su najstariji formalistični verbalni kontrakti o jamstvu; ***dotis dictio*** je ugovor o mirazu zaključivan svečanom izjavom datom budućem mužu; ***iusiurandum liberti*** je

svečano obećanje oslobođenog roba da će za svog patrona besplatno raditi određeni broj dana ili da će mu vršiti druge činidbe i davanja. Smatra se da je u verbalne kontrakte spadao i *nexum*.

Nexum je kontrakt o zajmu zaključivan u formi *per aes et libram* uz izgovaranje svečane formule. Ukoliko ne bi vratio dug, dužnik je bio izložen mjerama tzv. osobne ovrhe, što znači da ga je vjerovnik mogao prodati u ropstvo, ostaviti u svojoj kući da radom otplati dug, ili usmrтити. Zbog tako teških posljedica *nexum* je zabranjen zakonom iz 326. god. p.n.e. (*lex Poetelia Papiria de nexis*). Time je ukinuto dugovinsko ropstvo i vjerovnici upućeni samo na dužnikovu imovinu.

1. *Stipulatio*

Stipulacija (*stipulatio*)³⁷ je jednostrano obvezujući formalistični apstraktni kontrakt *stricti iuris* koji je zaključivan svečanim pitanjem budućeg vjerovnika (*stipulator*) i neposrednim sukladnim odgovorom budućeg dužnika (*promissor*).

Prvobitni oblik stipulacije zvao se *sponsio* po glagolu *spondere* koji su stranke morale upotrijebiti. Vjerovnik je pitao dužnika: “*Spondesne mihi dare centum?*” (“Obvezuješ li se dati mi stotinu?”), na što je dužnik odmah morao odgovoriti “*spondeo*” (“Obvezujem se.”). Nije bila potrebna nazočnost svjedoka niti nekog državnog organa jer se smatralo da je izgovaranjem svečane formule dužnik preuzeo obvezu pred bogovima i da će ga bogovi kazniti ako ne ispuni obećano.

Dužnikova obveza nastajala je izgovaranjem propisanih riječi. Cilj (*causa*) obvezivanja nije navođen ni u pitanju niti u odgovoru kojim je zaključivana stipulacija, niti ga je na sudu bilo potrebno navoditi (npr. iz same forme zaključenja ne vidi se obvezuje li se dužnik vratiti pozajmljeni novac, ili se obvezuje platiti cijenu za kupljenu stvar, ili obećaje miraz i sl.). Zato je stipulacija bila **apstraktni pravni posao**. Upravo zbog svoje apstraktnosti stipulacija je bila opći oblik za preuzimanje obveze. Imala je široku upotrebu jer su se putem nje zaključivali poslovi raznih vrsta, posebice oni koji još nisu bili zaštićeni posebnim tužbama. Tako se pomoću stipulacije osiguravala pravna zaštita onim pravnim odnosima koji su tek nastajali.

³⁷ Voci, P., *La dottrina romana del contratto*, Milano, 1946; Klami, H. T., *Studies on the roman law of contract*, Helsinki, 2000.

³⁸ Riccobono, S., *Stipulation and the theory of contract*, Amsterdam, 1957; Pastori, F. *Appunti in tema di sponsio e stipulatio*, Milano, 1961; Simon, D., *Studien zur Praxis der Stipulationsklausel*, München, 1964;

Vjerovnik je za zaštitu svoje tražbine po klasičnom pravu mogao podići ***condictio certae creditae pecuniae***, odnosno ***condictio certae rei*** ako se radilo o *stipulatio certa*, tj. ako se stipulacija odnosila na plaćanje određene sume novca, odnosno davanje određene stvari. Ako se predmet dužnikove obveze sastojao u činjenju ili propuštanju, radilo se o *stipulatio incerta*, kod koje se upotrebljavala ***actio incerti ex stipulatu***.

Vremenom su formalnosti stipulacije ublažene, pa se javljaju oblici pristupačni i peregrinima. Za valjanost stipulacije više nije bilo bitno kojim je riječima i na kojem je jeziku sklopljena.

Počev od razdoblja klasičnog prava sve se češće događalo da dužnik ne prizna ono što je obećao. Zato se uz stipulaciju počeo sastavljati **pisani dokument** (*cautio* ili ***instrumentum stipulationis***) kao dokaz da su izvršene sve usmene formalnosti. Od razdoblja Dominata usmena forma nije ni izgovarana, a pisani dokument postao je srž posla. **Tako je stipulacija od verbalnog postala literalni kontrakt.**

Apstraktnost stipulacije omogućila je razne zloupotrebe od strane vjerovnika. Događalo se da dužnik izgovori propisanu formulu i tako zasnuje svoju obvezu, a da vjerovnik uopće ne pozajmi novac zbog kojeg je zaključena stipulacija. Takvog dužnika najprije je zaštitio pretor dopustivši prigovor prijevare (*exceptio doli*) kojim je dužnik mogao odbiti vjerovnikovu tužbu ako bi dokazao da mu novac nije dobrojan. Kasnije je položaj dužnika koji od vjerovnika nije primio novac zbog kojeg je zaključena stipulacija popravljen uvođenjem prigovora da mu novac nije dobrojan (*exceptio non numeratae pecuniae*) ako bi ga vjerovnik tužio da vrati ono što nije primio, kao i tužbom (*querella non numeratae pecuniae*) koju je mogao podići dužnik protiv vjerovnika da bi se utvrdilo da mu novac nije predan.

Justinijanovo pravo propisalo je da vjerovnik uvijek mora dokazati postojanje pravne osnove ako je želio dobiti ono što je dužnik obećao. **Tako je stipulacija od apstraktnog postala kauzalan pravni posao.**

§ 68 – Literalni kontrakti

Literalni kontrakt³⁹ (*expensilatio, nomen transcripticum*) nastajao je jednostranim upisom tražbine u vjerovnikove poslovne knjige. Pisani dokument je formalni zahtjev za nastanak ovog kontrakta.

Rimsko pravo nije bilo sklono pisanoj formi ugovaranja jer se radije koristilo stipulacijom. Poznavalo je samo jedan literalni kontrakt (*expensilatio*), a i on je već u razdoblju klasičnog prava nestao iz upotrebe. Kasnije, u razdoblju Justinijanova prava, u rimsko pravo prodrli su *chirographa* i *syngraphae*, literalni kontrakti koji su u grčkom pravu imali široku primjenu.

1. *Expensilatio (nomen transscripticum)*

***Expensilatio (nomen transscripticum)* je kontrakt koji je nastajao upisom tražbine u vjerovnikove poslovne knjige.** Kontrakt je nastajao tek onda kada bi vjerovnik u svoju blagajničku knjigu upisao ime dužnika i iznos duga. Bez tog upisa kontrakt nije mogao nastati bez obzira što bi se stranke prethodno sporazumjele o svim elementima ugovora. Pisana forma imala je, dakle, konstitutivno značenje (*forma ad solemnitatem*).

Kontrakt je dobio naziv ***expensilatio*** po posebnoj rubrici za izdatke (*expensa*) u vjerovnikovoj blagajničkoj knjizi (*codex accepti et expensi*) u koju je svaki uredan *pater familias* prepisivao krajem mjeseca rezultate financijskog poslovanja iz knjige tekućih izdataka i primitaka (*adversaria* ili *ephemeria*).

U rubrici izdataka mogle su biti izvršene dvije vrste upisa: *nomina arcaria*, kod kojih je navođen razlog upisa i koji su služili samo kao dokaz (*forma ad probationem*) i evidencija o dužnikovoj obvezi (npr. Ticiju isplaćeno 100 asa po osnovi zajma) i *nomina transscripticia* kod kojih nije navođen razlog upisa (npr. Ticiju isplaćeno 100 asa). Kontrakt *expensilatio* nastajao je tek u drugom slučaju, apstraktnim upisivanjem bez navođenja osnove. Dobio je naziv i *nomen transscripticum* po aktu prepisivanja iz jedne knjige u drugu. Smatra se da je taj kontrakt zaključivan u posebnim slučajevima kada je trebalo izvršiti novaciju već postojeće obveze tako što bi bio promijenjen dužnik (*transscriptio a persona in personam*) ili pravna osnova duga (*transscriptio a re in personam*, npr. obveze *bonae fidei* pretvarane su u

römischen Recht, Zürich, 1987.

³⁹ Thilo, R. M., *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht*, Göttingen, 1980; Wolff, H. J., *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens*, München, 2002.

obveze *stricti iuris*). Vjerovnik je za zaštitu tražbine imao na raspolaganju ***condictio certae creditae pecuniae***. Taj kontrakt nestao je iz upotrebe prije razdoblja Justinijanova prava.

2. *Chirographa* i *syngraphae*

Hirografa i singrafe su literalni kontrakti kojima su se služili peregrini u istočnim provincijama Carstva.

Chirographum je literalni kontrakt koji je nastajao sastavljanjem i potpisivanjem zadužnice od strane dužnika. Zadužnicu nije morao napisati dužnik, ali ju je morao potpisati i predati vjerovniku. Time je nastajala apstraktna obveza jer nije bilo potrebno navesti pravni razlog (*iusta causa*) obveze.

Syngrapha je literalni kontrakt koji je nastajao sastavljanjem zadužnice od strane javnih pisara ili bankara u nazočnosti svjedoka koji su morali potpisati dokument. U zadužnici je navođeno tko, kome i koliko duguje, ali također apstraktno, ne navodeći pravnu osnovu.

§ 69 – Realni kontrakti

Realni kontrakti zaključuju se neformalnom predajom stvari (*re contrahitur obligatio*) u imovinu dužnika. Justinijanovo pravo poznaje četiri realna kontrakta kod kojih je obveza nastajala neformalnim prijenosom stvari. To su: zajam (*mutuum*), posudba (*commodatum*), ostava (*depositum*) i ručni zalog (*pignus*).

Nakon zabrane neksuma neformalni zajam dobio je u III. st. p.n.e. pravnu zaštitu s *condictio certae creditae pecuniae*. Neformalna predaja stvari kao forma zaključenja kontrakata priznata je u klasičnom i postklasičnom pravu u još nekoliko slučajeva: kada bi stvar bila predana dužniku na besplatnu upotrebu; u slučaju kada bi stvar bila predana u svrhu pohrane i u slučaju kada je stvar bila predana radi osiguranja potraživanja.

Postojao je još jedan realni kontrakt koji Justinijanovo pravo ne spominje jer je nestao iz upotrebe u razdoblju postklasičnog prava. Bila je to *fiducia* koja je u najstarije vrijeme sklapana kada je trebalo predati stvar na čuvanje, ili korištenje, ili kao garanciju za dug.

1. *Fiducia*

Fiducia⁴⁰ je formalistični ugovor starog prava putem kojeg se stjecatelj (fiducijar) obvezivao prenositelju (fiducijantu) da će mu vratiti stvar u vlasništvo po ispunjenju dogovorene svrhe.

Fiducia se sklapala u staro vrijeme uvijek kada je netko htio dati stvar na posudbu, čuvanje ili u zalog vjerovniku. Ako se radilo o *res Mancipi*, vlasništvo se moralo prenijeti putem *manipatio* ili *in iure cessio*, a za *res nec Mancipi* bila je dovoljna *traditio*. Sve do pred kraj razdoblja Republike, fiducijant se morao oslanjati samo na fiducijarevo poštenje i savjesnost (*fides*) da će mu vratiti stvar. Kada se pokazalo da zaštita moralnom sankcijom nije dovoljna, uvedena je *actio fiduciae*. Budući da je *fiducia* nepotpuno dvostrano obvezujući kontrakt (***contractus bilateralis inaequalis***), prava vjerovnika - fiducijanta zaštićena su s ***actio fiduciae directa***, dok je dužniku – fiducijaru stajala na raspolaganju ***actio fiduciae contraria*** za naplatu eventualnih troškova oko održavanja povjerene stvari. Osuda po *actio fiduciae directa* povlačila je infamiju jer se smatralo da je fiducijar iznevjerio poseban odnos povjerenja na kojem je počivala *fiducia*.

S obzirom na svrhu radi koje je izvršen fiducijarni prijenos vlasništva, razlikovala se ***fiducia cum creditore***, zaključena radi osiguranja duga i ***fiducia cum amico***, zaključena s ciljem predaje stvari na čuvanje ili besplatnu upotrebu drugome.

Zaključenjem ugovora nastajala su prava za fiducijanta i obveze za fiducijara. Fiducijant je bio ovlašten zahtijevati da fiducijar stvar čuva i vrati je neoštećenu. Fiducijar je morao stvar čuvati kao i svoje stvari (odgovarao je za *culpa levis in concreto*), koristiti se njome u dopuštenim granicama i vratiti je neoštećenu u ugovoreno vrijeme ili na fiducijantov zahtjev.

Fiducia je imala široku primjenu i izvan područja obveznog prava, posebice u obiteljskom pravu. S nestankom *manipacije* i *in iure cessio* u III. st. nestala je i *fiducia* koja je u praksi već bila zamijenjena prikladnijim pravnim sredstvima: *pignus*om i hipotekom, odnosno posudbom i ostavom.

2. Zajam (*mutuum*)

Zajam (*mutuum*)⁴¹ je realni jednostrano obvezujući kontrakt *stricti iuris* koji je zaključivan tako što je jedna stranka – zajmodavac (vjerovnik – *creditor*) predavala u

⁴⁰ Belocci, N., *La struttura della fiducia*, Vol. I-II, Napoli, 1983.

⁴¹ Longo, C., *Corso di diritto romano/Il mutuo*, Milano, 1947; von Lübtow, U., *Die Entwicklung des Darlehensbegriffs*, Berlin, 1965; Giuffrè, V., *La "Datio mutui": prospettive romane e moderne*, Napoli, 1989; Lucrezi, F. *Senatusconsultum Macedonianum*, Napoli, 1992; Isti, *Il problema del mutuo di denaro erogato al*

vlasništvo drugoj stranci – zajmoprimcu (dužnik – debitor) besplatno određenu sumu novca ili određenu količinu zamjenljivih stvari, čime je nastajala zajmoprimčeva obveza vratiti u određenom roku jednaku količinu stvari iste vrste i kvalitete.

U najstarije vrijeme zajam je zaključivan u formi neksuma, stipulacije i ekspensilacije. U tim slučajevima bila je osigurana pravna zaštita, kao i pravo na naplatu kamata. Takav oblik zajma uz kamatu nazivao se *fenus*. Imao je teške posljedice po dužnika jer je dovodio do osobne ovrhe (*manus iniectio*). Usporedo s *fenusom* postojao je još jedan oblik zajma – *mutuum*, koji se zasnivao na prijateljskim i susjedskim odnosima i koji je sklapan neformalnom predajom stvari. Budući da se radilo o prijateljskoj usluzi, takav zajam nije davao pravo na tužbu niti pravo na naplatu kamata. Vremenom se pokazalo da moralna obveza nije dovoljna da prinudi dužnika na vraćanje duga, pa je *mutuum* dobio pravnu zaštitu s *condictio certae creditae pecuniae* (uvedene vjerojatno u III. st.p.n.e. s *lex Silia*) ako se radilo o novčanom zajmu, odnosno *condictio certae creditae rei* (uvedene vjerojatno u II. st. p.n.e. s *lex Calpurnia*) ako su predmet zajma bile druge zamjenljive stvari.

Sve razvijeniji robonovčani odnosi razdoblja kasne Republike također su nametali potrebu iznalaženja jednostavnijeg oblika zajma, što je bio još jedan važan razlog da *mutuum* dobije pravnu zaštitu i time postane poseban i priznat realni kontrakt.

zaključenje mutuuma

Mutuum je zaključivan prostom predajom (*traditio*) stvari. Nisu bile potrebne nikakve posebne formalnosti jer se radilo o prijenosu vlasništva zamjenljivih stvari koje spadaju u *res nec Mancipi*. Mogle su ga zaključiti sve osobe koje su imale poslovnu sposobnost. Bio je pristupačan i peregrinima. Zajmodavac mora biti vlasnik stvari kako bi mogao prenijeti pravo vlasništva na zajmoprimca.

U I. st. n.e. donesen je *SC Macedonianum* kojim je propisano da osobe *alieni iuris* moraju dobiti suglasnost svog *pater familiasa* prije nego što uzmu zajam. Zajam zaključen protivno ovoj senatskoj odluci rađao je samo naravnu obvezu (*obligatio naturalis*), što znači da je vjerovnik nije mogao prinudnim putem ostvariti, ali je dužnik mogao platiti dug, ili ga priznati kada postane *sui iuris*.

predmet mutuuma

Predmet zajma su zamjenljive stvari (*genus, res fungibiles*). Zajmoprimac na pozajmljenim stvarima stječe pravo vlasništva.

značajke mutuuma

“*filius familias*”; Napoli, 1993; Mrozek, S., *Faenus: Studien zu Zinsenproblemen zur Zeit des Prinzipats*,

Mutuum je realni kontrakt, što znači da je obveza iz zajma nastajala tek **predajom** zamjenljivih stvari u vlasništvo dužniku s namjerom da se ustanovi dužnikova obveza na povrat jednake količine stvari iste vrste i kvalitete.

Mutuum je strogi ugovor (*negotium stricti iuris*), što se tumači činjenicom da je stupio na mjesto starog formalističnog neksuma.

Mutuum je kauzalni ugovor: cilj zajma (*causa credendi*) je ostvarenje kredita. Putem ugovora o zajmu omogućuje se korištenje tuđeg kapitala ili tuđih zamjenljivih stvari.

Mutuum je jednostrano obvezujući kontrakt (*contractus unilateralis*). Zaključenjem zajma uvijek nastaje jedna obveza: za dužnika da vrati istu količinu stvari iste vrste i kvalitete; i jedna tražbina: vjerovnik je ovlašten zahtijevati vraćanje duga. Zajmodavac – vjerovnik ni u momentu zaključenja niti tijekom trajanja obveznog odnosa nema nikakve obveze prema dužniku.

Mutuum je u načelu besplatan ugovor, što se objašnjava njegovim podrijetlom iz prijateljske usluge. Ako su se uz zajam htjele ugovoriti i kamate, onda je o njima trebalo sklopiti posebnu stipulaciju (*stipulatio usurarum*). Neformalni uglavak o kamatama nije bio utuživ kondikcijom. Budući da je *mutuum negotium stricti iuris*, dužnik je bio obavezan samo vratiti dužnu glavnice.

Kamate (*usurae*) su naknada za korištenje tuđih zamjenljivih stvari, najčešće novca. Kamatna obveza može nastati ugovorom (*usurae conventionales*) ili neposredno na temelju zakona (*usurae legales*). Ako se glavnica dugovala iz obveze *stricti iuris*, ugovor o kamatama morao je biti zaključen u obliku stipulacije, a kamate su se utuživale posebnom tužbom. Kod *negotia bonae fidei* kamate su se mogle ugovoriti putem dodatnog pakta (*pactum adiectum de usuris*). Visina kamatne stope bila je propisivana od Zakonika XII ploča do Justinijana. Od razdoblja klasičnog prava zabranjen je anatocizam – naplaćivanje kamata na dospjele i još neplaćene kamate, kao i dalje ubiranje kamata ukoliko su zaostale kamate dosegle visinu glavnice.

prava i obveze stranaka

Zaključenjem zajma nastajala je zajmoprimčeva obveza na povrat jednake količine stvari iste vrste i kvalitete. Sukladno načelima *res perit domino* i *casus sentit dominus* zajmoprimac je snosio rizik za slučajnu propast pozajmljenih stvari jer je aktom predaje postajao njihovim vlasnikom. Ako bi dužnik namirio jednaku količinu istovrsnih stvari s namjerom vraćanja

duga, pa te stvari propadnu uslijed slučaja, zajmoprimčeva obveza nije prestajala prema načelu *genus non perit*.

Zajmoprimac je morao vratiti dug na vjerovnikov zahtjev ili kada istekne rok koji je mogao biti ugovoren posebnom klauzulom ili paktom (*constitutum debiti*) kojim je dužnik neformalno obećavao da će platiti dug u određenom roku i na određenom mjestu.

Zajmodavac – vjerovnik imao je pravo nakon dospelosti potraživanja zahtijevati od dužnika vraćanje jednake količine istovrsnih stvari.

zaštita

Mutuum je dobio pravnu zaštitu koja se temeljila na ideji pravno neosnovanog obogaćenja. Budući da *mutuum* u početku nije smatran pravnim poslom, pošlo se od toga da se u dužnikovoj imovini nalazi novac ili druge zamjenljive stvari bez pravne osnove (*sine causa*). Zato su za zaštitu neformalnog zajma iskorištene tužbe iz pravno neosnovanog obogaćenja (*condictiones sine causa*). Vjerovnik je putem ***condictio certae creditae pecuniae*** mogao zahtijevati samo onu sumu novca koju je pozajmio dužniku, odnosno s ***condictio certae creditae rei (condictio triticaria)*** samo jednaku količinu zamjenljivih stvari.

Vjerovnikova tužba bila bi u cjelini odbijena zbog **uvećanog zahtjeva (*pluspetitio*)** ako bi zahtijevao nešto što nije bilo dugovano ili više nego što je dužniku predao (*pluspetitio re*); ako bi tražio vraćanje duga prije dospelosti (*pluspetitio tempore*); ili na drugom mjestu (*pluspetitio loco*); ili po osnovi po kojoj nije bilo dugovano (*pluspetitio causa*).

Poseban oblik zajma bio je pomorski zajam.

Pomorski zajam (*fenus nauticum; pecunia traiectica*) je zajam s elementima osiguranja za koji su vrijedili posebni propisi. Kod te vrste zajma dužnik, a to je najčešće bio kapetan broda ili trgovac, uzimao je zajam uz visoke kamate radi prekomorske trgovine i bio je obvezan vratiti ga samo ako pomorski pothvat uspije. Ako brod ili roba propadnu uslijed slučaja (oluje, gusarskog napada), nije bio dužan vratiti ni glavnici ni kamate. Zato je taj zajam predstavljao neku vrstu pomorskog osiguranja. Zbog velikog rizika za zajmodavca kamatna stopa uz pomorski zajam sve do Justinijanova prava nije podlijegala nikakvim ograničenjima (*usurae infinitae*), kada je ograničena na 12 % godišnje, dvostruko više nego kod običnog zajma. Od razdoblja klasičnog prava kamate uz pomorski zajam mogle su se ugovoriti paktom.

3. Posudba (*commodatum*)

Posudba (*commodatum*)⁴² je realni nepotpuno dvostrano obvezujući kontrakt *bonae fidei* koji se zaključuje tako što jedna stranka (posuditelj – komodant) predaje drugoj stranci (posudovnik – komodatar) nepotrošnu stvar na besplatnu upotrebu, čime nastaje posudovnikova obveza vratiti istu stvar nakon određenog vremena ili dogovorene upotrebe.

Posudba je dugo vremena bila prijateljska usluga zasnovana na načelu dobre vjere (*bona fides*) i nije imala samostalnu pravnu zaštitu. Ako se htjelo osigurati pravo na tužbu, morala se sklopiti *fiducia cum amico*. Pretor je zaštitio posudbu s *actio in factum*, da bi krajem razdoblja klasičnog prava posudba bila priznata kao poseban kontrakt zaštićen civilnom *actio commodati* (*directa* i *contraria*).

Osnovni cilj (*causa*) posudbe je omogućiti posudovniku besplatnu upotrebu stvari.

predmet posudbe

Predmet posudbe su **nepotrošne stvari (*res non consumptibiles*)**. Posudovnik mora vratiti **istu stvar (*in specie*)** koju je dobio na besplatnu upotrebu. Iznimno se mogu posuditi potrošne stvari, ali ne u svrhu njihove uobičajene upotrebe, nego samo radi pokazivanja (*ad pompam vel ostentationem* ili *dicis gratia*; npr. preda se i vrati određena novčanica samo da bi se pokazala drugima; boca vina ili torta stave se u izlog i onda vrate posuditelju). Posudovnik na posuđenoj stvari stječe samo **detenciju**.

značajke posudbe

Posudba (*commodatum*) je kontrakt *bonae fidei*. Međusobne obveze stranaka ravnaju se prema načelu savjesnosti, poštenja i povjerenja. To je **nepotpuno dvostrano obvezujući kontrakt**. Zaključenjem ugovora uvijek nastaje komodatareva obveza vratiti posuđenu stvar, a, iznimno, u nekim situacijama, može nastati i komodantova obveza na naknadu izvanrednih troškova ili štete. Posudba je uvijek **besplatna**.

prava i obveze stranaka

Posudovnik smije upotrebljavati stvar na uobičajeni način ili u skladu s ugovorom; u suprotnom, čini *furtum usus* (krađu upotrebe), što povlači deliktну odgovornost. Budući da je ugovor isključivo u njegovom interesu, **odgovara za *omnis culpa***, kao i **za čuvanje stvari (*custodia*)**, ali ne i za višu silu (*vis maior*). Dužan je snositi **redovite troškove** oko održavanja stvari. Nakon isteka ugovorenog roka ili po završenoj upotrebi **mora vratiti istu stvar** zajedno sa svim plodovima koji nisu bili predmetom upotrebe. Obvezan je **naknaditi štetu** do koje na stvari dođe zbog prekoračenja ugovorene ili uobičajene upotrebe.

⁴² Zannini, P., *Spunti critici per una storia del commodatum*, Milano, 1983; Pastori, F., *Il commodato in diritto*

Posuditelj je obvezan snositi **izvanredne troškove** (npr. liječenje oboljelog roba ili životinje; izmjena dotrajalih dijelova stvari). Mora naknaditi štetu koju posudovnik pretrpi uslijed njegove **dolozne** radnje (npr. namjerno posudi bolesnog konja da bi se zarazile i posudovnikove životinje).

zaštita

Commodatum je *contractus bilateralis inaequalis*. **Komodant** je imao na raspolaganju **actio commodati directa**, kojom je mogao zahtijevati vraćanje stvari sa svim priraštajima i plodovima, kao i naknadu štete do koje je došlo uslijed propasti ili pogoršanja stvari.

Komodatar je mogao podići **actio commodati contraria** i tom tužbom ostvariti svoje eventualne tražbine prema komodantu. Ako bi mu treće osobe oduzele ili oštetile stvar, komodatar se morao za pomoć obratiti komodantu, jer se kao detentor nije mogao koristiti ni tužbama ni interdiktima protiv trećih.

4. Ostava (*depositum*)

Ostava (*depositum*)⁴³ je realni nepotpuno dvostrano obvezujući kontrakt *bonae fidei* kojim jedna stranka – deponent predaje pokretnu stvar drugoj stranci – depozitaru na besplatno čuvanje, čime nastaje depozitareva obveza stvar čuvati i po isteku roka ili na deponentov zahtjev vratiti.

Ostava je najprije dobila pravnu zaštitu putem pretorske *actio in factum*, a samostalan kontrakt postala je u razdoblju klasičnog prava kada je zaštićena civilnom *actio depositi* (*directa* i *contraria*).

predmet ostave

Predmet ostave su **pokretne stvari**. Za čuvanje nekretnina i dalje je trebalo sklopiti fiduciju. Deponent ne mora biti vlasnik stvari koju je ostavio na čuvanje.

Depozitar na povjerenoj stvari stječe **detenciju**.

značajke ostave

Depositum je **ugovor *bonae fidei***, zasnovan na odnosu prijateljstva, poštenja i povjerenja. Nastao je kao institut *ius gentiuma*, iz kojeg je kasnije preuzet u civilno pravo.

Depositum je nepotpuno dvostrano obvezujući ugovor (***contractus bilateralis inaequalis***). Zaključenjem ostave uvijek nastaje depozitareva obveza da stvar čuva i na deponentov

romano, Bologna, 1995.

zahtjev vrati. U nekim situacijama može nastati i deponentova obveza na naknadu eventualnih troškova ili štete, ali to nije uvijek slučaj.

prava i obveze stranaka

Depozitar je obvezan čuvati stvar i vratiti je po isteku roka ili na deponentov zahtjev. Prema utilitetnom načelu odgovara samo za *dolus* i *culpa lata* (jer iz ugovora nema koristi). Ne smije se koristiti povjerenom stvari, inače odgovara za krađu upotrebe (*furtum usus*).

Deponent ima pravo zahtijevati od depozitara vraćanje stvari. Ukoliko je depozitar imao troškove oko čuvanja stvari, ili mu je stvar nanijela štetu, deponent ih je morao naknaditi.

Deponent odgovara za svaku krivnju (*omnis culpa*) jer je ugovor u njegovom interesu.

zaštita

Kao *contractus bilateralis inaequalis*, *depositum* je zaštićen s ***actio depositi directa i contraria***. **Deponent** može podići ***actio depositi directa*** ako depozitar ne vrati stvar, ili je doložno oštetiti ili uništi. Osuda po toj tužbi dovođila je do infamije jer se smatralo da je depozitar iznevjerio odnos prijateljstva i povjerenja.

Svoje eventualne tražbine prema deponentu **depozitar** je mogao ostvariti s ***actio depositi contraria***. Depozitar nije imao pravo na posjedovnu zaštitu jer je na povjerenoj stvari stjecao samo detenciju.

posebni oblici ostave

Depositum miserabile ili ***necessarium*** je pohrana koja se zaključuje u posebno teškim okolnostima (ratne prilike; politički progoni; elementarne nepogode). To je ostava u nuždi jer je deponent prinuđen ostaviti stvari na čuvanje, bez mogućnosti izbora povjerljive osobe. Ako bi depozitar odbio vratiti povjerene stvari, bio bi osuđen na dvostruki iznos (*in duplum*).

Depositum irregulare (neredoviti depozit) postoji kada je predmet ugovora o ostavi novac ili druge zamjenljive stvari (npr. novac se daje bankaru na čuvanje; žito vlasniku skladišta). U tom je slučaju depozitar postajao vlasnik povjerenih stvari i smio ih je potrošiti. Morao je vratiti istu sumu novca, odnosno jednaku količinu istovrsnih stvari. Odnos je sličan zajmu, samo što se *depositum* sklapa u deponentovom interesu. Klasični pravnici primjenjivali su na njega odredbe i načela zajma, ali postklasično i Justinijanovo pravo smatraju ga depozitom.

Depositum in sequestrem (sequestratio) ili sudski depozit je ostava kod koje se stvar, oko koje se vodi vlasnički spor, povjerava trećoj osobi – sekvestru (*sequester*) do okončanja

⁴³ Longo, C., *Corso di diritto romano/Il deposito*, Milano, 1946; Gandolfi, G., *Il deposito nella problematica della giurisprudenza romana*, Milano, 1971; Litewski, W., *Studien zur Verwahrung im römischen Recht*, Kraków, 1978.

parnice. Sekvestar je obvezan predati stvar pobjedniku u sporu, na što ga se može prinuditi putem *actio depositi sequestaria*. Predmet tog ugovora mogle su biti i pokretne i nepokretne stvari. Budući da se još uvijek nije znalo kome pripada vlasništvo na stvari, sekvestar je, za razliku od običnog depozitara, uživao posjedovnu zaštitu kako stvar ne bi u potpunosti bila bez pravne zaštite.

5. Ugovor o zalogu (*pignus, contractus pigneraticius*)

Ugovor o zalogu (*pignus, contractus pigneraticius*)⁴⁴ je realni nepotpuno dvostrano obvezujući kontrakt *bonae fidei* koji nastaje tako što založni dužnik (zalagatelj) predaje u posjed založnom vjerovniku (zalogoprimcu) pokretnu ili nepokretnu stvar radi osiguranja isplate duga, a zalogoprimac se obvezuje istu stvar vratiti kada mu dug bude namiren.

Zaključenjem ugovora o ručnom zalogu nastaje i stvarnopravni odnos (o kojem je bilo riječi u okviru stvarnog prava) i obveznopravni odnos.

U **stvarnopravnom pogledu** založni vjerovnik (zalogoprimac) stječe stvarno pravo nazvano ručnim zalogom (*pignus*), koje se sastoji u ovlasti da posjeduje založenu stvar (*ius possidendi*) i da je proda ako mu dužnik ne vrati dug (*ius distrahendī*). U stvarnopravnom odnosu vjerovnik je onaj kojem je stvar založena (založni vjerovnik - zalogoprimac), a dužnik je ona osoba koja je stvar predala u zalog (založni dužnik - zalagatelj).

U **obveznopravnom pogledu** vjerovnik je zalagatelj jer zaključenjem ugovora o zalogu nastaje njegovo pravo zahtijevati stvar natrag kada vrati dug, a dužnik je zalogoprimac jer je obvezan vratiti založenu stvar kada dug bude isplaćen. Predajom stvari u zalog nastaje, dakle, i obveznopravni odnos koji djeluje samo između stranaka.

predmet pignusa

Predmetom pignusa mogu biti i **pokretne i nepokretne stvari**, tj. svaka stvar koja se može vratiti *in specie*. Zalogoprimac na založenoj stvari stječe **detenciju koja je izjednačena s posjedom** kako bi imao interdiktnu zaštitu i ostala posjedovna prava. **Posjednikom se smatra i zalagatelj** da bi mu, ukoliko nije bio kviritski vlasnik, tekao rok dosjelnosti putem koje će steći kviritsko vlasništvo.

značajke pignusa

⁴⁴ Kaser, M., *Studien zum römischem Pfandrecht*, TR 44 (1976), 233; Isti, *Besitzpfand und "besitzloses" Pfand*, SDHI 45 (1979), 29, Isti, *Studien zum römischem Pfandrecht II*, TR 47 (1979), 229.

Contractus pignoratitius je nepotpuno dvostrano obvezujući kontrakt (***contractus bilateralis inaequalis***), zasnovan na **načelu dobre vjere** (*bona fides*). Zaključenjem ugovora uvijek nastaje obveza zalogoprimca vratiti založenu stvar kada mu dug bude namiren, a eventualno može nastati i zalagateljeva obveza na naknadu štete i izdataka koje je pretrpio zalogoprimac.

prava i obveze stranaka

Založni vjerovnik (zalogoprimac) kao dužnik u obveznompravnom odnosu obvezan je čuvati stvar kao ***diligens pater familias***, što znači da odgovara za svaku krivnju, a po klasičnom pravu odgovarao je i za nestanak ili oštećenje stvari bez krivnje (***custodia***), sve do više sile. Ne smije upotrebljavati založenu stvar, niti se koristiti njezinim plodovima jer tada čini *furtum usus*. Stranke su mogle sklopiti *pactum antihreticum*, kojim je stjecao pravo ubirati plodove na ime kamata.

Založni dužnik (zalagatelj) kao vjerovnik u obveznompravnom odnosu ovlašten je zahtijevati vraćanje založene stvari, čim prestane založno pravo, odnosno višak od postignute cijene (*superfluum, hyperocha*) ako je došlo do prodaje zaloga. Obvezan je naknaditi zalogoprimcu troškove oko održavanja stvari i štetu koju bi zalogoprimac pretrpio. Budući da je ugovor podjednako u interesu objiju stranaka, i založni dužnik je odgovarao za svaku krivnju (***omnis culpa***).

zaštita

Contractus pignoratitius je najprije zaštićen pretorovom *actio in factum*, a krajem klasičnog razdoblja priznat je kao civilnopravna obveza i zaštićen civilnom *actio pignoratitia directa* i *contraria*.

Actio pignoratitia directa stajala je na raspolaganju založnom dužniku, kojom je mogao tražiti povratak stvari, odnosno višak postignute cijene ako je došlo do prodaje zaloga.

Actio pignoratitia contraria pripadala je založnom vjerovniku za ostvarenje eventualnih protuzahtjeva na naknadu troškova i štete. Založni vjerovnik mogao se poslužiti i retencijom (*retentio*, tzv. *pignus Gordianum*) u cilju ostvarenja svojih protuzahtjeva. Imao je pravo zadržati založenu stvar i nakon što mu je podmiren dug koji je bio osiguran zalogom, ako je prema istom dužniku imao druge nepodmirene tražbine.

§ 70 – Konsenzualni kontrakti

Konsenzualni kontrakti (*consensus* – suglasnost volja) nastaju prostom suglasnošću volja suugovaratelja o bitnim elementima kontrakta.

Za zaključenje tih kontrakata nije bilo potrebno izgovaranje svečanih riječi, niti sastavljanje pisane isprave, niti predaja stvari. Nije bila potrebna nikakva posebna forma ni kao uvjet za nastanak kontrakta (*forma ad solemnitatem*), niti kao dokazno sredstvo (*forma ad probationem*). Stranke su svoju volju mogle očitovati na bilo koji način: izričito i prešutno, konkludentnom radnjom, putem pisma ili preko glasnika.

Konsenzualni kontrakti predstavljaju **iznimku** od rimskog načela *ex nudo pacto obligatio non nascitur* (iz običnog sporazuma ne rađa se obveza). Osnovni razlog zbog kojeg su priznati za civilne kontrakte je taj što su kupoprodaja (*emptio venditio*), najam (*locatio conductio*), ortaštvo (*societas*) i mandat (*mandatum*) najvažniji ugovori pravnog i gospodarskog prometa, a sve razvijeniji promet i trgovina razdoblja kasne Republike zahtijevali su jednostavnost i efikasnost. Nastali su kao instituti *ius gentium*a. Pravnu zaštitu dobili su najprije pred tribunalom peregrinskog pretora. Krajem razdoblja Republike preuzeti su u *ius civile*. Ispunjenje tih ugovora u početku je počivalo samo na poštenju i povjerenju stranaka, zbog čega svi spadaju u ***iudicia bonae fidei***. Svi su, **izuzev mandata, potpuno dvostrano obvezujući kontrakti**, kod kojih se jedna stranka obvezuje drugoj na ispunjenje određene činidbe, a druga se stranka obvezuje na ispunjenje protučinidbe.

1. Kupoprodaja (*emptio venditio*)

Kupoprodaja (*emptio venditio*)⁴⁵ je konsenzualni potpuno dvostrano obvezujući kontrakt *bonae fidei* kojim se jedna stranka (prodavatelj, *venditor*) obvezuje prepustiti drugoj strani (kupac, *emptor*) mirno uživanje neke stvari, a druga strana se obvezuje platiti kupovnu cijenu.

Neformalna kupoprodaja sklapana je između Rimljana i peregrina još od starih vremena, a za civilni kontrakt priznata je u II. st. p.n.e.

Zaključenjem kupoprodaje nastaje obveza za prodavatelja da prenese stvar, a za kupca da isplati cijenu. Predaja stvari i kupovnine vrši se posebnim aktom - tradicijom nakon

⁴⁵ Arangio-Ruiz, V., *La compravendita in diritto romano*, Napoli, 1956; Daube, D. (izd.), *Studies in the Roman Law of Sale in memory of Francis de Zulueta*, Oxford, 1959; Peters, F., *Die Rücktrittsvorbehalte des römischen*

zaključenja kupoprodaje i spada u izvršenje ugovora. Kupoprodaja je samo pravni razlog (*causa*) za tradiciju. Budući da zaključenjem kupoprodaje nastaju samo obveze za stranke na predaju stvari, odnosno cijene, kupoprodaja ima samo obveznopravne, ali ne i stvarnopravne učinke. Sve dok mu stvar ne bude predana, kupac na stvari nema nikakvo stvarno pravo jer je zaključenjem ugovora dobio samo pravo zahtijevati od prodavatelja činidbu koja se sastoji u predaji stvari. Dakle, samom kupoprodajom ne prenosi se vlasništvo, nego ugovor o kupoprodaji predstavlja pravnu osnovu (*titulus acquirendi*) stjecanja. Da bi se prenijelo vlasništvo, potreban je i način stjecanja (*modus acquirendi*) što je kod tjelesnih stvari predaja stvari (*traditio*), a kod prava ustupanje (*cessio*).

Kupoprodaja je sklopljena čim se stranke sporazumiju o bitnim elementima ugovora, a to su predmet i cijena.

predmet kupoprodaje

Predmet kupoprodaje može biti **svaka stvar koja je u pravnom prometu**, tjelesna ili netjelesna (prava na tuđoj stvari, tražbine, pravo na nasljedstvo). Pokretne tjelesne stvari nazivaju se roba ili *merx*. Predmetom kupoprodaje mogle su biti i stvari koje nisu bile u vlasništvu prodavatelja u momentu zaključenja ugovora.

Stvar nije morala postojati u času zaključenja ugovora jer je bila moguća i prodaja budućih stvari, gdje se razlikuju dva slučaja: *emptio rei speratae* i *emptio spei*.

Emptio rei speratae (kupnja stvari kojima se nadamo) je **uvjetna kupnja** jer je kupac dužan platiti cijenu samo ako stvari nastanu i u onoj količini u kojoj nastanu (npr. kupi se budući urod s njive ili voćnjaka po unaprijed utvrđenoj cijeni po jedinici proizvoda).

Emptio spei (kupnja nade na dobitak) je **bezuwjetna kupnja** jer se kupac obvezuje platiti stvar za unaprijed određenu sumu premda stvar ne nastane ili nastane u manjoj količini od očekivane (npr. kupnja budućeg ulova ribe: kupac mora platiti cijenu i ako ništa ne bude ulovljeno). Kupac preuzima rizik za postanak stvari nadajući se da će stvar nastati u količini i kvaliteti većoj od plaćene cijene. Ugovori koji nose rizik nazivaju se aleatorni (*alea* – kocka).

cijena (*pretium*)

Cijena (*pretium*) je vrijednost stvari izražena u novcu.

Cijena mora biti **izražena u novcu (*numerata pecunia*)** da bi se radilo o kupoprodaji jer davanje stvari za stvar predstavlja razmjenu ili trampu (*permutatio*).

Kaufrechts, Köln, 1973, Ernst, W., Das klassische römische Recht der Gefahrtragung beim Kauf: periculum est emptoris, Bonn, 1981; Isti, Rechtsmängelhaftung, Tübingen, 1994.

Kupovna mora biti **određena** (*pretium certum*) ili **odrediva** po objektivnim sigurnim kriterijima tako da se o njenoj visini ne mora sklapati nova pogodba (npr. stranke mogu ugovoriti da će vrijediti cijena koja bude na tržištu određenog dana za tu vrstu robe).

Cijena mora biti **ozbiljno mišljena** (*pretium verum*), tj. ne smije biti fiktivna ili simulirana.

Klasično pravo nije zahtijevalo da cijena bude pravična (*pretium iustum*), tj. da odgovara pravoj vrijednosti stvari. Strankama je bilo prepušteno ugovoriti cijenu koju žele. Smatralo se prirodnim da svatko želi prodati što skuplje i kupiti što jeftinije. Takav stav počeo se mijenjati vjerojatno od Dioklecijana koji je, u nastojanju da spriječi osiromašenje seljaka i njihovo pretvaranje u kolone, odobrio prodavatelju nekretnine raskid kupoprodajnog ugovora ako nije dobio ni polovicu vrijednosti zemljišta. Tako je nastao institut **laesio enormis** (prekomjerno oštećenje, prikrata preko polovice vrijednosti). Justinijanovo pravo proklamiralo je načelo da cijena ne smije biti manja od polovice prave vrijednosti predmeta, inače je prodavatelj imao pravo raskinuti ugovor, tj. tražiti natrag stvar uz povrat kupovnine. Kupac je mogao održati ugovor ako bi nadoplatio razliku cijene do prave vrijednosti.

značajke kupoprodaje

Kupoprodaja je **neformalan konsenzualni kontrakt** jer je nastajao prostom suglasnošću stranaka o predmetu i cijeni. To je **kontrakt bonae fidei** jer se međusobne dužnosti stranaka prosuđuju po načelima poštenja i povjerenja u prometu. Ispunjenje obveza iz ugovora, u vrijeme kada neformalna kupoprodaja još nije bila pravno zaštićena, počivalo je samo na povjerenju stranaka i rimskoj *fides* koja nalaže da se ispuni ono što je obećano, te da se ugovori moraju poštovati (*pacta sunt servanda*).

Kupoprodaja je **potpuno dvostrano obvezujući (sinalagmatični) kontrakt** (*contractus bilateralis aequalis*). Sklapanjem ugovora obje stranke istodobno postaju i vjerovnik i dužnik, obvezujući se na ispunjenje određenih činidbi.

To je **naplatan pravni posao** jer se za činidbu traži ekvivalentna protučinidba, tj. za predmet se traži ekvivalent u novcu.

Kupoprodaja je **kauzalan pravni posao**. Gospodarski cilj (*causa*) kupoprodaje je stjecanje prava vlasništva.

prava i obveze stranaka

Zaključenjem kupoprodaje nastaju prava i obveze za obje stranke jer je kupoprodaja potpuno dvostrano obvezujući kontrakt. Iz načela *bonae fidei* i sinalagmatičnosti ugovora izvedeno je pravilo da su obveze stranaka zavisne jedna o drugoj. To znači da nijedna stranka nije mogla zahtijevati izvršenje protučinidbe od druge stranke ako sama nije svoju činidbu

već izvršila ili je barem bila spremna izvršiti je. Na tom temelju stavljeni prigovor nazvan je *exceptio non adimpleti contractus* (prigovor neispunjenog ugovora).

obveze kupca

Najvažnija kupčeva obveza sastoji se u **plaćanju kupovnine** koju je, ukoliko vrijeme isplate nije određeno ugovorom, dužan predati odmah prilikom primitka stvari. Za tu obvezu kupac odgovara do visine *culpa levis in abstracto*, što znači da je odgovoran za naknadu štete koju prodavatelj pretrpi zbog zakašnjenja u isplati cijene prouzrokovane njegovom krivnjom.

Kupac je obvezan **preuzeti stvar** i platiti kamate od dana kada mu je predan predmet ako nije odmah isplatio kupovninu. Dužan je **naknaditi prodavatelju nužne troškove oko održavanja stvari** koje je taj imao od momenta sklapanja ugovora.

Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora rizik za slučajnu propast stvari snosi **kupac**, što izražava načelo “*perfecta emptione periculum est emptoris*”. Premda još uvijek nije postao vlasnik kupljenog predmeta, kupac je, suprotno načelu *casus sentit dominus*, snosio štetu zbog **slučajne propasti stvari** (*species* jer generične stvari ne mogu propasti) od časa zaključenja ugovora do predaje. Protivno načelu sinalagmatičnosti kupac mora platiti stvar premda je nije dobio, ili ako ju je već platio, ne može tražiti povrat novca (npr. ako grom ubije konja koji je prodan, ali još nije predan, kupac mora platiti cijenu, ili ako ju je već platio ne može tražiti njeno vraćanje premda mu konj neće biti predan). Na taj način htjelo se potaknuti kupca da što prije preuzme stvar. Osim toga, od zaključenja ugovora do predaje, kupcu su pripadali svi plodovi stvari sukladno načelu *commodum eius esse debet, cuius est periculum* (korist od stvari treba pripasti onome na kome je rizik). To je pravilo posljedica pravila *periculum est emptoris*.

obveze prodavatelja

Osnovna obveza prodavatelja sastoji se u **predaji stvari** u ugovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu. Ako nije ništa ugovoreno, obveza prodavatelja na predaju stvari nastajala je odmah. Obvezan je predati i plodove koje je stvar dala od momenta zaključenja do momenta izvršenja ugovora. Dužan je čuvati stvar kao *bonus pater familias*, pa odgovara za štetu na stvari do visine *culpa levis in abstracto*.

Prodavatelj je bio obvezan osigurati kupcu **nesmetan posjed i uživanje stvari**, što znači da nijedna osoba nije mogla pravnim sredstvima oduzeti kupcu posjed stvari. Nije morao prenijeti kviritsko vlasništvo na kupca. Takvo rješenje posljedica je podjele rimskog vlasništva na kviritsko i bonitarno i posebnog režima koji je vrijedio za *res Mancipi*. Ako se radilo o tim stvarima, bilo je dovoljno osigurati bonitarno vlasništvo koje će putem uzukapije dovesti do zasnivanja kviritskog vlasništva.

Zaključenjem kupoprodajnog ugovora prodavatelj je preuzimao **odgovornost za pravne i faktične nedostatke stvari**. Navedena odgovornost podrazumijeva se po samoj naravi pravnog posla (*naturalia negotii*) zbog čega je stranke nisu morale posebno ugovarati.

Nakon predaje stvari kupcu prodavatelj je morao jamčiti za **pravne nedostatke**. **Pravni nedostaci** postoje u slučaju ako stvar nije bila u prodavateljevu vlasništvu, ili ako su na stvari konstituirani realni tereti (npr. založno pravo, pravo služnosti). Prodavatelj mora garantirati kupcu da mu stvar nitko ne može redovitim putem oduzeti iz posjeda, odnosno evincirati (*evincere* – pobijediti u sporu), odnosno da ga nitko neće uznemiravati i ometati u mirnom posjedovanju i uživanju stvari. Ako treća osoba putem tužbe (*rei vindicatio*; *actio hypothecaria*; *actio confessoria*) ili interdikta oduzme kupcu stvar iz posjeda, prodavatelj je dužan štiti ga tako što će preuzeti spor na sebe ili će pomagati kupcu u parnici. Ta prodavateljeva dužnost naziva se **odgovornost za evikciju**. Evikcija može biti potpuna (kada je kupcu stvar putem suda oduzeta iz posjeda) ili djelomična (kada je kupčevo pravo umanjeno ili ograničeno pravima trećega na toj stvari). Ukoliko stvar ipak bude oduzeta, kupac je imao na raspolaganju ***actio auctoritatis*** kojom je mogao tražiti povrat dvostruke cijene, a putem ***actio empti*** imao je pravo tražiti naknadu štete za ostale slučajeve evikcije.

Prodavatelj je morao odgovarati za **faktične nedostatke stvari** u slučaju ako se radilo o ozbiljnim i prikrivenim manama koje su postojale u času prodaje zbog kojih se stvar ne može uredno upotrebljavati, ili joj je bitno umanjena vrijednost i koje kupac uz uobičajenu pozornost nije mogao uočiti. Kupac je mogao raskinuti ugovor u roku od šest mjeseci putem ***actio redhibitoria***, ili u roku od godine dana tražiti razmjerno sniženje kupovnine s ***actio quanti minoris***. Kupcu je stajala na raspolaganju i ***actio empti*** koja nije bila vezana za rok (*actio perpetua*) i kojom je mogao tražiti naknadu cjelokupne štete koju bi pretrpio zbog prodavateljeva nepoštenog ponašanja.

zaštita

Pored navedenih pravnih sredstava, za zaštitu prava ugovornih stranaka služile su *actiones bonae fidei*: ***actio empti*** za zaštitu svih prava kupca, prvenstveno za ostvarenje zahtjeva na predaju stvari i ***actio venditi*** za zaštitu prava prodavatelja, posebice zahtjeva na platež kupovnine i troškova koje je prodavatelj pretrpio ako bi kupac zakasnio s preuzimanjem stvari. Tužbu je mogla podići samo ona strana koja je svoju obvezu već izvršila ili je bila pripravna izvršiti je. Sudac je morao voditi računa o svim okolnostima vezanim za ugovor.

uzgredni uglavci uz kupoprodaju (*pacta adiecta*)

Stranke su mogle prilagoditi osnovni učinak kupoprodaje ugovaranjem posebnih uglavaka (*pacta adiecta*) koji su bili zaštićeni istim pravnim sredstvima kao i ostale obveze proistekle iz ugovora. Tipični su:

Lex commissoria – pakt kojim je prodavatelj dobijao pravo raskinuti ugovor ako kupac ne plati u ugovorenom roku. To je kupnja pod raskidnim uvjetom s učinkom povrata u prijašnje stanje. Svi učinci kupoprodaje raskidaju se unatrag i kupac mora vratiti stvar sa svim ubranim plodovima.

In diem addictio – uglavak koji je prodavatelju davao pravo raskinuti ugovor ako u određenom roku nađe boljeg kupca. Prvi kupac mogao je održati ugovor ako ponudi koliko i novi kupac.

Lex commissoria i *in diem addictio* imaju **stvarnopravni učinak**, što znači da je raskidom ugovora vlasništvo *ipso iure* prelazilo natrag na prodavatelja, te je prodavatelj mogao reivindikacijom stvar zahtijevati od svakoga kod koga bi se našla.

Uzgredni sporazumi koji imaju **obveznopravni učinak**, te se mogu ostvarivati samo među suugovarateljima putem osobnih tužbi su:

Pactum displicentiae – sporazum kojim je kupac dobijao pravo upotrebljavati stvar određeno vrijeme i odustati od ugovora ako mu se ne svidi (kupnja na ogled ili probu).

Pactum degustationis – pakt koji je kupcu davao pravo prethodno ustanoviti ima li roba potrebne kvalitete (npr. degustirati vino; provjeriti kvalitetu brašna) i odbiti robu koja mu ne odgovara.

Pactum de retrovendendo – uglavak u korist kupca temeljem kojeg je kupac stjecao pravo zahtijevati od prodavatelja da unutar određenog vremena otkupi stvar po istoj cijeni (pridržaj nazadprodaje).

Pactum de retroemendo – sporazum koji je prodavatelju davao pravo tražiti od kupca da mu unutar određenog roka, istu stvar koju je prethodno od njega kupio, natrag proda po prvobitnoj cijeni, ako nije drukčije ugovoreno (pridržaj nazadkupnje).

Pactum protimiseos - pakt kojim je prodavatelj zadržavao pravo preče kupnje u slučaju ako kupac odluči prodati stvar (pridržaj prava prvokupa).

2. Najam (*locatio conductio*)

Najam (*locatio conductio*)⁴⁶ je konsenzualni potpuno dvostrano obvezujući kontrakt *bonae fidei* kojim se jedna stranka obvezuje prepustiti drugoj stranci stvar na upotrebu (*locatio conductio rei*), ili joj staviti na raspolaganje svoju radnu snagu (*locatio conductio operarum*), ili joj izvršiti neko djelo (*locatio conductio operis*), a druga se stranka obvezuje platiti za to određenu naknadu.

Terminom *locatio conductio* u rimskom su pravu obuhvaćena tri ugovora koji, premda različitog ekonomskog sadržaja, imaju dosta zajedničkih crta: ugovor o najmu ili zakupu stvari (*locatio conductio rei*), ugovor o najmu radne snage (*locatio conductio operarum*) i ugovor o djelu (*locatio conductio operis*).

a) *Locatio conductio rei* (ugovor o najmu ili zakupu)

***Locatio conductio rei* (ugovor o najmu, odnosno zakupu) je konsenzualni sinalagmatični kontrakt kojim se jedna strana (najmodavac, zakupodavac – *locator*) obvezuje predati na privremenu upotrebu neku svoju stvar, a druga strana (najamnik, zakupnik – *conductor*) obvezuje se platiti određenu naknadu (najamninu, zakupninu – *merces*).**

bitni sastojci najma (zakupa)

Bitni sastojci ugovora o najmu (zakupu) su: **stvar** koja je predmet ugovora, **najamnina** (zakupnina) i **vrijeme** trajanja ugovora.

predmet najma ili zakupa

Predmet najma su nepotrošne stvari, pokretne i nepokretne, kao i neka prava (*ususfructus*, *superficies*, *emfiteuza*).

najamnina (zakupnina)

Najamnina (zakupnina) je naknada koju se najamnik (zakupnik) obvezuje dati najmodavcu (zakupodavcu) za upotrebu i korištenje stvari. Ukoliko naknada ne bi bila ugovorena, radilo bi se o posudbi.

Ako se jedna stranka obvezuje prepustiti drugoj samo upotrebu stvari, radi se o najmu (npr. najam stana), a ako se obvezuje prepustiti upotrebu i uživanje plodova, postoji zakup (npr. zakup poljodjelskog zemljišta). Predmet zakupa može biti samo plodonosna stvar. Terminološki se ta razlika u rimskom pravu očitovala samo u nazivu najamnika, odnosno

⁴⁶ Mayer-Maly, Th., *Locatio conductio*, Wien, 1956, Ries, P., *Bauverträge im römischen Recht*; München, 1989; Palazzolo, N., *Saggi in materia di locazione*, Catania, 1995; Fiori, R., *La definizione della locatio conductio*,

zakupnika (*conductor*): najamnik stana zvao se *inquilinus*, svaki drugi najamnik – *conductor*; dok je zakupnik nazivan *colonus*.

Conductor dobija stvar samo u **detenciju**, pa nema posjedovnu ni stvarnopravnu zaštitu. Ako *locator* proda iznajmljeni (zakupljeni) predmet, ugovor o najmu (zakupu) je prestajao, što izražava srednjovjekovno načelo *emptio tollit locatum* (kupnja poništava zakup). Ipak, ako se radilo o zakupu zemljišta, kolon je trebao ostati na zemljištu, što je propisano konstitucijom Aleksandra Severa iz 234. godine. Također je i najamnik stana bio zaštićen jer se *locator*, koji bi prodao zgradu, trebao pobrinuti da se stanaru osigura stanovanje, inače ga je taj mogao tužiti.

značajke najma ili zakupa

Locatio conductio rei je konsenzualni potpuno dvostrano obvezujući (sinalagmatični) kontrakt *bonae fidei*. Zaključenjem ugovora istodobno nastaju prava i obveze za obje stranke.

Ugovor se najčešće zaključuje na određeno vrijeme, a ako rok nije ugovoren, svaka je stranka ovlaštena raskinuti ugovor kada želi, poštujući načelo *bonae fidei*, tj. pazeći da drugoj strani ne nanese štetu. Ako nakon isteka ugovorenog vremena stranke ne bi ništa poduzele, smatralo se da je došlo do prešutnog produženja ugovora na isti rok (***relocatio tacita***).

prava i obveze stranaka

***Locator* (najmodavac, zakupodavac)** je obvezan predati stvar u ispravnom stanju i omogućiti najamniku njeno korištenje. Dužan je održavati stvar u upotrebljivom stanju i jamčiti za pravne i fizičke nedostatke kako bi najamnik mogao ostvariti ciljeve zbog kojih je zaključio ugovor. Najmodavac snosi nužne i korisne troškove i druge terete (javne poreze). *Locator* ne mora biti vlasnik stvari koju je dao u najam (zakup). Obvezan je štititi najamnika od trećih osoba koje bi ga uznemiravale ili mu oduzele stvar (npr. vlasnik ili založni vjerovnik oduzmu stvar najamniku) i naknaditi mu štetu.

Ako *conductor* ne plati naknadu za iznajmljeni stan ili zakupljeno zemljište, najmodavac ima pravo zaloga na najamnikovim stvarima.

Locator snosi rizik za slučajnu propast stvari (*periculum est locatoris*).

***Conductor* (najamnik, zakupnik)** je obvezan platiti ugovorenu najamninu, odnosno zakupninu (*merces*) i vratiti neoštećenu stvar po isteku predviđenog vremena. Najamnina se u pravilu sastojala u novcu i morala je biti određena ili određiva (*certa*) i istinita (*vera*). Kod zakupa poljodjelskih zemljišta zakupnina se u cijelosti ili djelomično mogla platiti u naravi (dijelom plodova – *colonia partiaria*). Najamnik ne mora platiti odgovarajući dio najamnine

ako je stvar propala uslijed slučaja ili ako uslijed najmodavčeve krivnje nije mogao upotrebljavati stvar. Načelo *periculum est locatoris* vrijedi i za zakup poljodjelskih površina jer zakupnik ima pravo tražiti odgovarajuće sniženje zakupnine ako je žetva bila slaba zbog nepovoljnih prirodnih uvjeta. Dakle, rizik je i u tom slučaju snosio zakupodavac.

Najamnik mora upotrebljavati stvar kao dobar domaćin (*bonus pater familias*) pa odgovara do visine ***culpa levis in abstracto***. Nije dužan snositi štetu do koje dođe uslijed redovite upotrebe stvari. Ima pravo dati stvar u podnajam (*sublocatio*).

zaštita

Za zaštitu prava ugovornih stranaka predviđene su *actiones bonae fidei*: ***actio locati*** za zaštitu prava najmodavca (*locator*) i ***actio conducti*** za ostvarenje prava i zahtjeva najamnika (*conductor*).

prestanak

Locatio conductio rei prestaje istekom ugovorenog roka. Ako se stranke nisu dogovorile o vremenu trajanja ugovora, mogle su ga raskinuti u bilo koje vrijeme poštujući načelo *bonae fidei*. Za zakup poljodjelskog zemljišta podrazumijevao se rok od pet godina.

Locator je mogao otkazati ugovor i prije isteka ugovorenog roka ako *conductor* ne plaća najamninu, ne ponaša se kao *bonus pater familias* ili upotrebljava stvar suprotno ugovoru. Kontrakt je prestajao ako je stvar propala ili postala nesposobna biti predmetom ugovora, te u slučajevima ako je najmodavac stvar otuđio ili mu je bila potrebna.

Conductor je mogao otkazati ugovor prije roka ako *locator* ne održava stvar u upotrebljivom stanju i ne osigurava njeno normalno korištenje.

Obje stranke mogle su tijekom prve godine odustati od ugovora bez obrazloženja i naknade (*ius poenitendi*).

b) *Locatio conductio operarum* (ugovor o najmu radne snage)

***Locatio conductio operarum* (ugovor o najmu radne snage ili ugovor o službi) je konsenzualni sinalagmatični kontrakt kojim se jedna strana (najamni radnik – *locator*) obvezuje staviti na raspolaganje za određeno vrijeme svoju radnu snagu, a druga se strana (poslodavac – *conductor*) obvezuje za to platiti naknadu (*merces*).**

Spomenuti ugovor imao je u starom Rimu razmjerno ograničenu primjenu zbog obilja jeftine robovske radne snage. Osim toga, smatralo se da najamni rad ponižava slobodnog

čovjeka. Ipak, bilo je siromašnih slobodnih ljudi koji su za naknadu obavljali grube fizičke poslove. Zemljovlasnici su se koristili radom slobodnih najamnika na nezdravim mjestima kako se njihovi robovi ne bi razboljeli i umrli i za sezonske poljodjelske poslove.

Bitni elementi ugovora su rad (*operae*) i najamnina (*merces*).

predmet ugovora o najmu radne snage

Predmet ugovora su ***operae*** (rad). Najčešće se radilo o ručnom radu niže vrste koji su obično obavljali robovi (tzv. ***operae illiberales***). Rad za koji je trebalo određeno znanje i obrazovanje obavljali su viši staleži (tzv. ***artes liberales***). Taj rad nije bio predmetom najma za novac jer se formalno davao besplatno u vidu mandata (*mandatum*). U stvari, liječnici, odvjetnici, geometri, učitelji primali su velike počasti, tj. novac pod nazivom *honoraria* ili *munera*, koji su postali utuživi u ekstraordinarnom postupku.

značajke ugovora

Locatio conductio operarum je konsenzualni sinalagatični kontrakt *bonae fidei*. To je **ročni posao** jer se najamnik obvezivao staviti svoju radnu snagu na raspolaganje za određeno vrijeme. Naknada se nije mogla ugovoriti za razdoblje kraće od jednog dana.

prava i obveze stranaka

Najamni radnik – *locator* (locira, plasira, nudi svoju radnu snagu) je obvezan staviti na raspolaganje poslodavcu svoju radnu snagu. Mora raditi savjesno, sukladno ugovoru i uputama poslodavca kroz ugovoreno vrijeme. Posao mora obavljati osobno. Nije dužan garantirati za rezultat rada jer je njegova glavna obveza staviti radnu snagu na raspolaganje, a poslodavac odlučuje kako će je upotrijebiti. Poslove je morao obavljati s pažnjom dobrog domaćina, što znači da je za propuste odgovarao do visine ***culpa levis in abstracto***. Bio je odgovoran i za svoju stručnu nesposobnost (*imperitia*). Nije imao pravo na naknadu za ono vrijeme u kojem je svojim krivnjom ili zbog bolesti bio spriječen raditi.

Poslodavac – *conductor* je obvezan platiti najamniku naknadu (*merces*) koja je određivana u jednom iznosu za sve ugovoreno vrijeme, ili za svaku vremensku jedinicu (dnevno, tjedno, mjesečno). Najamnina je isplaćivana unatrag. Poslodavac je dužan platiti ugovorenu naknadu i za ono vremensko razdoblje u kojem najamnik nije radio, ako je do nemogućnosti korištenja najamnिकove radne snage došlo uslijed poslodavčevog propusta ili iz drugih razloga (npr. vremenskih neprilika). *Conductor* je snosio rizik za obustavljanje radova uslijed slučaja. Za svoje obveze prema najamniku odgovara do visine ***culpa levis in abstracto***.

zaštita

Za ostvarivanje međusobnih prava i zahtjeva strankama su stajale na raspolaganju *actiones bonae fidei*: najamni radnik (*locator*) ostvarivao je putem ***actio locati*** svoje zahtjeve prema poslodavcu, dok je zaštita prava poslodavca (*conductor*) bila osigurana s ***actio conducti***.

c) *Locatio conductio operis* (ugovor o djelu)

***Locatio conductio operis* (ugovor o djelu) je konsenzualni sinalagmatični kontrakt kojim se jedna strana (izvođač – *conductor*) obvezuje drugoj strani (naručitelj – *locator*) izvršiti određeno djelo, a taj se obvezuje za to platiti ugovorenu naknadu.**

Bitni elementi ugovora su djelo (*opus*) i naknada (*merces*).

predmet ugovora o djelu

Predmet ugovora o djelu je izvršenje točno određenog fizičkog posla (npr. sašiti odijelo; očistiti odjeću; prevesti robu iz jednog mjesta u drugo; napraviti prsten). Za razliku od ugovora o najmu radne snage, kod kojeg je suština ugovora u iznajmljivanju radne snage, za ovaj je ugovor bitan **rezultat rada, tj. samo djelo (*opus*)**.

značajke ugovora o djelu

Locatio conductio operis je konsenzualni sinalagmatični kontrakt *bonae fidei*. To je ročni posao jer je djelo trebalo izvršiti i predati u određenom roku. Ako rok nije ugovoren, djelo je trebalo završiti u razumnom roku koji je uobičajen za izvršenje poduzetog posla.

prava i obveze stranaka

Naručitelj – *locator* (locira, predaje materijal potreban za izvršenje djela) je obvezan predati materijal na kojem treba obaviti određeni rad. Dužan je pravodobno preuzeti izvršeno djelo i pri primopredaji isplatiti naknadu (*merces*).

Izvođač – *conductor* je obvezan savjesno izvršiti preuzeti posao i predati djelo naručitelju u ugovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu. Ako se ne radi o strogo osobnoj činidbi (*intuitu personae*), može se prilikom izvršenja djela poslužiti radom svojih pomoćnika ili zamjenika. Odgovara za svaku krivnju, pod kojom se podrazumijeva i njegova stručna nesposobnost (*imperitia*), kao i za krivnju i propuste svojih pomoćnika (*culpa in eligendo*). Neki obrtnici odgovarali su i za *custodia*, sve do više sile (osobe koje su krpile, popravljale, čistile, glačale tuđu odjeću).

zaštita

Za ostvarenje svojih zahtjeva prema izvođaču naručitelj – *locator* imao je na raspolaganju ***actio locati***, dok je izvođač – *conductor* mogao podići ***actio conducti*** za zaštitu svojih prava.

Lex Rhodia de iactu

Posebna pravila, predviđena u Rodskom zakonu o havarijama (*lex Rhodia de iactu*), vrijedila su u slučaju ako je predmet ugovora bio prijevoz robe morem. Budući da rimsko pravo nije izgradilo poseban ugovor o pomorskom transportu, svi brodski ugovori i vozarski ugovori u pomorstvu zaključivani su u formi *locatio conductio*.

Lex Rhodia de iactu sadrži pravila o izbacivanju dijela brodskog tereta u more kako bi se sačuvao preostali teret i sam brod. Ako je zbog vremenskih nepogoda ili napada gusara kapetan broda bio prinuđen baciti dio prevožene robe u more, tako nastalu štetu snosili su vlasnik broda i vlasnici spašenog tereta razmjerno njihovoj vrijednosti. To je **načelo opće havarije**, recipirano iz pomorskih zakona otoka Rodosa.

Kako je ugovor o prijevozu zaključen kao kontrakt *locatio conductio*, vlasnici žrtvovanog tereta upućuju se na **actio locati** protiv kapetana broda, dok je kapetan broda mogao protiv vlasnika spašenog tereta podići **actio conducti** i tražiti razmjerno namirenje štete. U tu svrhu zapovjedniku broda dopušta se pravo zadržavanja (*retentio*) robe.

3. Ortaštvo (societas)

Ortaštvo (društvena pogodba, societas)⁴⁷ je konsenzualni sinalagmatični kontrakt bonae fidei kojim se dvije ili više osoba (socii) međusobno obvezuju zajedničkim sredstvima i radom ostvariti imovinsku dobit.

cilj, elementi i vrste ortaštva

Osnovni cilj društvene pogodbe je udruživanje radi obavljanja određenih poslova kojima će se ostvariti imovinska dobit. U tu svrhu ortaci (*socii*) formiraju zajedničku imovinu u koju svaki od njih unosi svoj ulog. Ulozi ne moraju biti jednaki po vrijednosti. Mogu se sastojati u novcu, radu, pravima, vlasništvu i korištenju stvari (npr. poslovnom prostoru, alatu, materijalu). Tako stvorena imovina ne pripada društvu kao cjelini jer **societas nije pravna osoba**, nego pojedinim članovima društva koji na njoj stječu **suvlasništvo**.

Ortaci su u društvo mogli unijeti svoju cjelokupnu imovinu i zajednički obavljati sve svoje poslove (*societas omnium bonorum*); ili se obvezati da će gospodariti samo imovinom koju steknu poslovnom djelatnošću (*societas quaestus*); udružiti se radi obavljanja određene poslovne grane (*societas negotiationis*, npr. otvoriti obrtničku radionicu, trgovati robljem,

⁴⁷Guarino, A., *La società in diritto romano*, Napoli, 1988.

pružati bankarske usluge); ili udružiti dio imovine radi izvršenja jednog posla (*societas unius rei*, npr. izgraditi određeni objekat).

značajke ugovora o ortaštvu

Društvena pogodba je konsenzualni sinalagmatični kontrakt *bonae fidei*. Podrijetlo joj je u *ius gentium*, a već krajem II st. p.n.e. je potpuno formirani konsenzualni kontrakt s posebnom tužbom *bonae fidei (actio pro socio)*. Zaključuje se prostom suglasnošću volja. Justinijanovo pravo zahtijevalo je da volja da se zaključi ortaštvo (*affectio societatis*) bude izričito izražena. Ako se stranke ne bi očitovale o vrsti ortaštva kojeg su osnovale, vrijedila je pretpostavka da se radi o *societas quaestus*.

Ortaštvo je ugovor *intuitu personae* jer se zasniva na posebnom odnosu povjerenja. Budući da se radi o sinalagmatičnom kontraktu, među ortacima nužno nastaju uzajamna prava i obveze. Na jednoj strani u ulozi vjerovnika ili dužnika javlja se jedan član zajednice, a na drugoj svi ostali.

Societas nije pravna osoba jer nema svojstvo subjekta prava s posebnom imovinom različitom od imovine pojedinih članova.

prava i obveze stranaka

Ortaštvo je uzajamno obvezan ugovor. Osnovna obveza svakog ortaka bila je unijeti ugovoreni dio imovine u društvo i sudjelovati u diobi dobiti i gubitka zajednice. Dioba dobiti i gubitka određivana je ugovorom, a ako ništa nije ugovoreno, dijeli se na jednake dijelove bez obzira na visinu udjela. Ugovor o ortaštvu koji bi nekog ortaka isključio iz diobe dobiti, bio bi ništav jer bi se radilo o lavovskom ortakluku (*societas leonina*).

Svaki ortak imao je pravo sudjelovati u vođenju poslova ortaštva. Pri tome bi nastupao kao **posredni zastupnik ostalih članova**, što znači da je učinke pravnih poslova sklopljenih s trećima morao interno prenijeti na ostale članove razmjerno njihovim udjelima. Pri tome je odgovarao za ***culpa levis in concreto***. Prava i obveze iz zaključenih poslova nisu pripadali društvu kao cjelini jer ono nema pravni subjektivitet, nego uvijek pojedinim članovima.

prestanak ortaštva

Kao odnos *intuitu personae societas* prestaje smrću bilo kojeg člana ili uslijed *capitis deminutio*, jednostranim otkazom pojedinog člana (*renuntiatio*), dogovorom svih članova o razvrgnuću (*dissensus*), te otvaranjem stečaja nad imovinom nekog člana. Ako bi preostali članovi ostali u zajednici, smatralo se da je osnovano novo ortaštvo.

Društvena pogodba prestajala je i postizanjem svrhe, protekom roka i propašću cjelokupne imovine.

zaštita

Za ostvarenje uzajamnih zahtjeva i priznatih prava ortacima je stajala na raspolaganju **actio pro socio**. To je tužba *bonae fidei* pa je presuda zasnivana na načelima pravičnosti i dobre vjere. Osuda na temelju *actio pro socio* povlačila je infamiju jer se smatralo da je iznevjeren poseban odnos prijateljstva i povjerenja na kojem počiva *societas*. Sudac je mogao osuditi ortake na plaćanje u granicama stvarnih mogućnosti vodeći računa da im ostane minimum sredstava potrebnih za život (*beneficium competentiae*).

Dioba zajedničke imovine, odnosno raskid ortaštva postizan je putem **actio communi dividundo**.

4. Ugovor o nalogu (*mandatum*)

Ugovor o nalogu (*mandatum*)⁴⁸ je konsenzualni nepotpuno dvostrano obvezujući kontrakt *bonae fidei* kojim jedna stranka (nalogodavatelj, mandant) nalaže drugoj stranci (nalogoprimalci, mandatar) da u svoje ime, a za račun mandanta obavi neki posao, a mandatar se obvezuje to besplatno izvršiti.

predmet ugovora o nalogu

Predmet ugovora o nalogu može biti obavljanje bilo faktičnih bilo pravnih poslova. Svi poslovi koji mogu biti predmet ugovora o djelu (*locatio conductio operis*) ako se obavljaju bez naknade spadaju u mandat. To su **faktični poslovi**, odnosno fizički materijalni akti (npr. popravak kuće; liječenje bolesnika; davanje nastave). Poslovi koji su zahtijevali viši stupanj naobrazbe i stručnosti nisu bili predmetom najma za novac, nego su svrstavani u mandat i formalno obavljani besplatno. Predmet ugovora o nalogu je i obavljanje **pravnih poslova** (npr. mandatar se obveže nešto kupiti ili prodati za račun mandanta, zastupati ga pred sudom, ili zaključiti neki drugi ugovor). U tom slučaju mandatar nastupa kao mandantov **posredni zastupnik** jer sklapa pravni posao u svoje ime, a za račun mandanta.

Posao koji se mandatar obvezao izvršiti ne mora biti samo u mandantovom interesu, nego može biti od koristi mandataru ili trećoj osobi, ali ne može biti isključivo u mandatarevom interesu (*mandatum tua gratia*). Ugovor o nalogu je ništav ako je posao isključivo u mandatarevom interesu jer se tada radi samo o savjetu (*consilium*).

značajke ugovora o nalogu

Mandatum je konsenzualni nepotpuno dvostrano obvezujući kontrakt (*contractus bilateralis inaequalis*) *bonae fidei*. To je ugovor koji počiva na **odnosu osobnog povjerenja**

i prijateljstva. Iz navedenoga proizilaze važne posljedice: *mandatum* je **besplatan** jer je smatrano neprimjerenim uzimati naknadu za obavljenju prijateljsku uslugu; osuda na temelju *actio mandati directa* povlačila je infamiju; mandatar je preuzeti posao morao obaviti kao dobar domaćin. Ako bi bila ugovorena naknada, ne bi se radilo o mandatu nego o najmu (*locatio conductio*). Ipak, u praksi su mandatar primali nagrade i darove (*honor*) koje nije bilo moguće ostvariti s *actio mandati* nego u ekstraordinarnom postupku (*extraordinaria cognitio*). Besplatnost je i u Justinijanovom pravu smatrana bitnom karakteristikom mandata.

prava i obveze stranaka

Osnovne obveze mandatar su pravodobno i savjesno izvršiti povjereni posao u granicama ovlasti i uputa dobivenih od mandanta i, po završenom poslu, podnijeti račun mandantu. Budući da je posao sklopio u svoje ime, mora sve posljedice i učinke izvršenog posla prenijeti na mandanta. Ukoliko prekorači granice dobivenih ovlasti i preuzetu dužnost izvrši pod uvjetima težim od propisanih (npr. kupi stvar po višoj cijeni), mandant ne mora prihvatiti posao. Ovo gledište Sabinijanske škole bilo je prihvaćeno u klasičnom pravu. Justinijanovo pravo preuzelo je stav Prokulijanske škole prema kojem je mandant obavezan prihvatiti posao ako mandatar namiri razliku između predviđene i ostvarene cijene.

Izvršenje preuzetog posla mandatar je mogao povjeriti nekoj drugoj osobi (submandatar), ostajući pri tome obavezan za sve posljedice učinjene zamjene, osim u slučajevima kada je mandat podijeljen određenoj osobi zbog njenih stručnih sposobnosti, kvaliteta i iskustva (ugovor *intuitu personae*). Preuzetu obvezu mandatar je morao ispuniti s pažnjom dobrog domaćina, što znači da je odgovarao za ***culpa levis in abstracto***.

Osnovna obveza mandanta je prihvatiti posao koji je mandatar izvršio sukladno nalogu. U nekim slučajevima mandant je obavezan naknaditi mandataru troškove i štetu koje je taj pretrpio izvršavajući povjereni posao i osloboditi ga svih primljenih obveza.

prestanak mandata

Mandatum prestaje smrću bilo koje stranke jer je zasnovan na osobnom odnosu prijateljstva i povjerenja. Prava i obveze nastali za života stranaka prelaze na nasljednike. Ako bi mandatar, ne znajući za mandantovu smrt, nastavio s izvršenjem preuzetog posla, obvezivao je mandantove nasljednike. Mandat prestaje i jednostranim otkazom (*renuntiatio*) mandatar, kao i opozivom (*revocatio*) mandanta.

zaštita

⁴⁸ Arangio-Ruiz, V., *Il mandato in diritto romano*, Napoli, 1949; Watson, A., *Contract of mandate in Roman law*, Oxford, 1961; Nörr, D. (izd)/Nishimura, Sh. (izd.), *Mandatum und Verwandtes*, Berlin, 1993.

Međusobna prava i obveze stranaka zaštićeni su s ***actio mandati***. Mandant je svoja prava mogao ostvariti putem ***actio mandati directa***. Osuda po toj tužbi povlačila je infamiju jer se smatralo da je mandatar iznevjerio poseban odnos prijateljstva i povjerenja.

Svoje eventualne protuzahtjeve prema mandantu mandatar je mogao ostvariti putem ***actio mandati contraria***.

§ 71 - Inominatni kontrakti

Inominatni (neimenovani, bezimeni)⁴⁹ kontrakti su sinalagmatični obvezni ugovori koji nastaju tako što je jedna strana ispunila svoju činidbu pa je zbog toga druga strana obvezna ispuniti neku drugu činidbu koju je obećala.

Kategorija inominatnih kontrakata pojavila se u razvijenom pravnom prometu kada se veliki broj neformalnih ugovora kod kojih bi se stranke dogovorile o davanju činidbe za neku protučinidbu i kod kojih bi jedna stranka svoju činidbu već izvršila, nije mogao svrstati ni u jedan postojeći tipizirani ugovor.

Za nastanak inominatnog kontrakta potrebna je **suglasnost volja stranaka** iz kojeg nastaju uzajamne obveze stranaka i **ispunjenje obveze od strane jedne stranke**.

Slični su konsenzualnim i realnim kontraktima, ali se ipak ne mogu svrstati u te kategorije. Od konsenzualnih kontrakata razlikuju se po tome što za njihovo zaključenje nije dovoljna prosta suglasnost volja stranaka, nego je potrebno da jedna od stranaka ispuni svoju činidbu, a od realnih time što se činidba ne mora sastojati samo u predaji stvari, nego i u nekom činjenju, propuštanju ili pružanju usluga.

S obzirom na narav činidbe i protučinidbe svrstani su u četiri skupine:

1. **do ut des**: stranke su obvezne na uzajamna davanja, tj. prijenos vlasništva (npr. kod trampe);
2. **do ut facias**: jedna stranka nešto daje da bi joj druga stranka nešto učinila (npr. jedna stranka daje knjigu da bi je druga stranka podučavala u sviranju glazbala);
3. **facio ut des**: sadržaj činidbe je *facere*, a sadržaj protučinidbe je *dare* (slučaj suprotan od prijašnjeg);
4. **facio ut facias**: činidbe obje stranke sastoje se u činjenju (*facere*).

Zaštitu su dobili putem pretorske ***actio in factum*** koju je mogla podići strana koja je izvršila svoju činidbu i tužiti stranu koja ne izvrši svoju obvezu. U Justinijanovom pravu

dobila je naziv ***actio praescriptis verbis*** i u njoj je samo opisivano činjenično stanje iz kojeg je tužitelj izvodio svoj zahtjev. Stranka koja je ispunila svoju činidbu bila je zaštićena i putem ***condictio ob rem dati*** na povrat onoga što je dala, a ako je izvršila činidbu koja se sastojala u činjenju (*facere*), mogla je tražiti odštetu putem ***actio doli***. Pored navedenih pravnih sredstava mogla je podići i ***condictio ex poenitentia*** (kondikciju zbog pokajanja) ako bi htjela tražiti natrag ono što je dala i jednostrano raskinuti ugovor premda suugovaratelj još nije u zakašnjenju i pripravan je izvršiti svoju činidbu.

Važniji inominatni kontrakti vremenom su ipak dobili posebne nazive.

a) ***Permutatio*** (mijena; razmjena; trampa) je najvažniji bezimeni kontrakt tipa *do ut des*. Jedna stranka predavala je drugoj stranci neku stvar u vlasništvo, a druga se obvezivala da će u zamjenu dati vlasništvo neke druge stvari.

b) ***Aestimatum*** (nalog prodaje) je ugovor kojim je dosadašnji vlasnik predavao drugome svoje stvari uz određenu cijenu s nalogom da ih proda i da za sebe zadrži eventualnu razliku koju je postigao prilikom prodaje. Najčešće se radilo o ugovoru između trgovca na veliko ili proizvođača i trgovca na malo kojim se preprodavatelj obvezivao prodati robu, isplatiti vlasniku ugovorenu cijenu, a za sebe je mogao zadržati višak postignute cijene. Ako u određenom roku ne bi izvršio preuzetu obvezu, morao je primljenu robu vratiti neoštećenu. Taj ugovor zaštićen je posebnom *actio in factum aestimatoria*.

c) ***Precarium*** je ugovor o opozivom posjedovanju stvari kojim se dužnik obvezivao da će na vjerovnikov zahtjev odmah vratiti stvar koju je dobio na besplatnu upotrebu. Od posudbe se razlikuje po tome što su predmet prekarija bila uglavnom zemljišta i što nije ugovaran rok u kojem se dužnik mogao koristiti tuđom stvari. U klasičnom pravu zaštićen je interdiktom *de precario* koji se mogao upotrijebiti protiv prekariste koji je odbijao vratiti stvar. U Justinijanovom pravu smatran je bezimenim kontraktom, pa se vraćanje stvari moglo tražiti putem *actio praescriptis verbis*.

⁴⁹ MacCormack, G., *Contractual Theory and the Innominate Contracts*, SDHI 51 (1985), 131; Burdese, A.,

§ 72 – Pakti (*Pacta*)

Pakt (*pactum*)⁵⁰ je neformalni sporazum volja iz kojeg nije nastajala utuživa obveza po civilnom pravu.

Vrijedilo je načelo *ex nudo pacto obligatio non nascitur* (iz golog sporazuma ne nastaje obveza). Da bi nastala utuživa obveza, ugovor je morao biti zaključen u pravom propisanoj formi. Sporazumi koji nisu bili zaodjenuti u pravom propisanu formu, smatrani su golim, odnosno nezaštićenim paktima (*pacta nuda*). Spomenuti sporazumi mogli su stvoriti samo pravo na prigovor kojim je tuženik, u čiju je korist zaključen neformalni pakt, mogao odbiti tužiteljev zahtjev, ali nisu stvarali i pravo na tužbu (*nudum pactum non parit actionem sed parit exceptionem*). Najvažnije odstupanje od navedenog pravila učinjeno je kod konsenzualnih kontrakata kojima je priznata utuživost po civilnom pravu premda su zaključivani prostom suglasnošću volja.

Da bi se zadovoljile potrebe pravnog i gospodarskog prometa, priznata je posebna pravna zaštita i nekim drugim paktima. Zahvaljujući djelatnosti pretora, pravnika i careva izdvojeni su pakti koji su dobili pravnu zaštitu i tako postali izvori obveza. Ti pakti nazvani su *pacta vestita*, tj. u tužbu obučeni ili zaštićeni sporazumi.

Postojale su tri skupine zaštićenih neformalnih sporazuma: *pacta adiecta* (dodatni pakti kojima je modificiran sadržaj ugovora *bonae fidei*, najčešće ugovora o kupoprodaji); *pacta praetoria* (pretorski pakti zaštićeni pretorskim tužbama) i *pacta legitima* (zakonski ili carski pakti zaštićeni pravnim sredstvima uvedenim carskim konstitucijama).

1. *Pacta praetoria*

Najvažniji neformalni sporazumi koji su zaštićeni pretorskim tužbama bili su sporazumi o preuzimanju određenih obveza (*recepta*); obećanje da će se u određenom roku platiti dug i sporazum o polaganju prisega.

Receptum arbitrii je neformalni sporazum koji su stranke u sporu sklapale s nekim građaninom i kojim se on obvezivao riješiti njihov spor. Pretor je mogao prisiliti građanina na ispunjenje preuzete dužnosti putem *actio in factum*, uzimanjem zaloga ili novčanom kaznom.

Ancora in tema di contratti innominati, SDHI 52 (1986), 442.

⁵⁰ Magdelain, A., *Le consensualisme dans l'édit du pretor*, Paris, 1958; Mellilo, G., *Contrahere, pacisci, transigere: contributo allo studio del negozio bilaterale romano*, Napoli, 1994.

Receptum nautarum, cauponum et stabulariorum je sporazum između vlasnika brodova, gostionica i staja i osoba koje su se koristile njihovim uslugama da će za stvari koje budu unesene u navedene objekte njihovi vlasnici odgovarati bez obzira na krivnju, sve do više sile. Putnici, odnosno gosti mogli su zahtijevati naknadu štete s *actio ex recepto*. Kasnije se ta odgovornost za kustodiju pretpostavljala i bez posebnog pakta. Brodari, gostioničari i vlasnici staja bili su i deliktno odgovorni *in duplum* na temelju *actio furti et damni adversus nautas, caupones et stabularios* za krađe i štete koje bi na stvarima gostiju izvršile njima podređene osobe.

Receptum argentarii je neformalni sporazum između bankara i klijenta kojim se bankar obvezivao isplatiti dug svog klijenta, za što je odgovarao putem *actio recepticia*.

Constitutum debiti je sporazum kojim jedna stranka obećaje da će u određenom roku isplatiti svoj (*constitutum debiti proprii*) ili tuđi dug (*constitutum debiti alieni*). Zaštićen je s *actio de pecunia constituta*. *Constitutum debiti alieni* imao je učinak jamstva.

Pactum iurisiurandi je sporazum kojim su se stranke dogovarale da će spor riješiti prisegom. Onaj koji je dobio spor putem prisege, mogao je podići *actio iurisiurandi* i zahtijevati isplatu duga ili predaju sporne stvari.

2. *Pacta legitima*

Carevi su u svojim konstitucijama predvidjeli pravnu zaštitu putem *actio ex lege* za tri neformalna sporazuma. To su: *compromissum*, *pollicitatio dotis* i *donatio*.

Compromissum je sporazum kojim su se stranke u sporu dogovarale da će rješenje spora povjeriti građaninu kojeg same izaberu i s kojim će kasnije zaključiti *receptum arbitrii*.

Pollicitatio dotis je neformalni pakt o obećanju miraza, utuživ kondikcijom *ex lege*.

Pollicitatio donationis (donatio)⁵¹ je neformalno obećanje darovanja. **Darovanje (donatio)** je besplatna i dragovoljna namjena imovinske koristi kojom se povećava obdarenikova imovina, a umanjuje darovateljeva.

Po klasičnom pravu darovanje nije bilo poseban tip pravnog posla, nego je bilo samo *causa* poslova kojima se prenosilo vlasništvo: stipulacije, mancipacije, tradicije, ustupanja tražbine, otpusta duga. Sve do razdoblja postklasičnog prava neformalni sporazum o darovanju kojim je darovatelj obećavao da će dio svoje imovine *cum animo donandi* prenijeti na obdarenoga, nije bio pravno zaštićen. Ako se htjela osigurati pravna zaštita, taj sporazum

⁵¹ Radovčić, V., *Pravna problematika i razvitak instituta darovanja*, Zagreb/Čakovec, 1983.

morao je biti zaodjenut u neku od zaštićenih formi. U Justinijanovom pravu neformalni sporazum o darovanju priznat je kao *pactum legitimum*. Očitovanje volje o darovanju i o prihvatanju darovanja dobilo je pravnu zaštitu i postalo izvor obveza. Obdareni je dobio pravo zahtijevati izvršenje darovanja od darovatelja.

Rimsko pravo nastojalo je ograničiti i regulirati darovanja između određenih osoba. Tako *lex Cincia de donis et muneribus* iz 204. god. p.n.e. zabranjuje davati darove odvjetnicima, uz prijetnju četverostrukom kaznom; darove iznad određene vrijednosti, učinjene osobama izvan obitelji, proglašava naravnim obvezama. *Lex Calpurnia* iz 149. god. p.n.e. zabranjuje magistratima primati darove od građana. U klasičnom pravu zabranjeni su darovi između bračnih drugova. Spomenuta ograničenja donesena su da bi se spriječile različite zloupotrebe. U razdoblju postklasičnog prava (počev od IV. stoljeća) potrebno je sastaviti ispravu o darovanju, izvršiti tradiciju pred susjedima kao svjedocima i izvršiti upis u javne knjige.

U Justinijanovom pravu darovi u vrijednosti ispod 500 solida nisu morali biti registrirani. Za njihovu utuživost bila je dovoljna prosta suglasnost volja. Darovi u vrijednosti iznad 500 solida morali su biti upisani u zapisnik kod nadležnih organa (*insinuatio*).

Četvrto poglavlje

OBVEZE IZ KVAZIKONTRAKATA (*OBLIGATIONES QUASI EX CONTRACTU*)

Kvazikontrakti su obvezni odnosi, zaštićeni posebnom tužbom, koji su nastali iz dopuštenih radnji, bez prethodne suglasnosti volje stranaka.

Budući da su nastali **bez prethodne suglasnosti volja stranaka**, ti obvezni odnosi ne mogu se svrstati ni u kontrakte ni u pakte. Justinijanove Institucije (3,27) poznaju sljedeće kvazikontrakte: poslovodstvo bez naloga (*negotiorum gestio*), stjecanje bez pravne osnove (*condictio sine causa*), slučajnu zajednicu (*communio incidens*), obveze iz tutorstva (*tutela*) i obveze nasljednika prema legataru postavljenom *per damnationem* (*legatum per damnationem*).

§ 73 – Poslovodstvo bez naloga (*negotiorum gestio*)

Poslovodstvo bez naloga (*negotiorum gestio*)⁵² je obvezni odnos koji nastaje tako što jedna stranka (poslovođa bez naloga – *negotiorum gestor*) obavlja fizičke ili pravne poslove druge stranke (gospodar posla – *dominus negotii*) bez prethodnog naloga i sporazuma.

predmet poslovodstva bez naloga

Predmetom poslovodstva bez naloga može biti obavljanje kako **fizičkih** (npr. skloni se susjedovo sijeno s livade da ne pokisne), tako i **pravnih poslova** (npr. sklopi se ugovor u korist gospodara posla), a iznimno i **upravljanje cjelokupnom imovinom**.

Bitno je da se radi o obavljanju **tudjeg posla** (*negotium alienum*), što je procjenjivano po objektivnim kriterijima, a od postklasičnog razdoblja traži se i subjektivna svijest da se radi o tuđem poslu (*animus aliena negotia gerendi*). Budući da se radi o izvanugovornom obveznom odnosu, poduzeti posao ne smije biti rezultat nekog prethodnog sporazuma stranaka jer bi se tada radilo o ugovoru o nalogu (*mandatum*).

Obavljanje posla mora biti **korisno** (*utiliter*) za gospodara posla. Korist se računa prema času kada je posao započet, što znači da se ne traži da i konačan rezultat bude uspješan (npr. poslovođa može tražiti naknadu troškova liječenja roba premda je taj umro). Pored objektivne koristi ponekad se uzima u obzir i subjektivno gledanje gospodara posla ako je poslovođa za

⁵² Seiler, H. H., *Der Tatbestand der negotiorum gestio*, Köln, 1968, Finazzi, G., *Ricerche in tema di Negotiorum gestio*, Napoli, 1999; De Filippi, M., *Ratihabitio*, Bari, 2002.

njega znao ili morao znati (npr. poslovođa popravlja kuću koju je vlasnik napustio, što nije subjektivno korisno za gospodara posla).

Ako bi *dominus negotii* odobrio posao koji je poduzeo *negotiorum gestor*, nastajalo je stanje slično mandatu (*ratihabitio mandato comparatur*). Poslovi koji su poduzeti do odobrenja, rješavani su tužbom iz posloводства (*actio negotiorum gestorum*), dok se na poslove poduzete nakon odobrenja mogla upotrijebiti i *actio mandati*.

Ako netko obavi tuđi posao unatoč izričitoj zabrani gospodara posla (*negotiorum gestio prohibente domino; negotiorum gestio contra voluntatem domini*), po Justinijanovom pravu nije imao pravo na naknadu troškova, izuzev u slučajevima kada se radilo o sahrani člana obitelji odsutnog gospodara posla ili plaćanju tuđih javnih obveza (npr. plaćanje poreza).

prava i obveze stranaka

Poslovođa bez naloga (*negotiorum gestor*) obavezan je započeti posao savjesno i uredno završiti. Po svršetku posla mora položiti račun gospodaru posla i prenijeti na njega sve što je stekao obavljajući tuđi posao (plodove, kamate). Ima pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova, ali ne i luksuznih. Nema pravo tražiti nagradu za izvršenu uslugu jer je *negotiorum gestio* besplatan pravni posao (*negotium lucrativum*). Premda od poduzetog posla nema nikakve koristi, mora ga obaviti kao *bonus pater familias*, što znači da odgovara za *culpa levis in abstracto*. Ako bi spriječio nenadoknadivu štetu koja je mogla zadesiti gospodara posla, odgovarao je samo za *dolus i culpa lata*.

Gospodar posla (*dominus negotii*) obavezan je poslovođi bez naloga naknaditi nužne i korisne troškove i osloboditi ga svih preuzetih obveza.

zaštita

Prava i obveze stranaka zaštićeni su s ***actio negotiorum gestorum***. *Dominus negotii* je za ostvarenje svojih prava i zahtjeva prema poslovođi bez naloga imao na raspolaganju ***actio negotiorum gestorum directa***, dok je *negotiorum gestor* mogao ostvariti svoje zahtjeve prema gospodaru posla putem ***actio negotiorum gestorum contraria***.

§ 74 - Stjecanje bez pravne osnove (*condictio sine causa*)

Stjecanje bez pravne osnove (*condictio sine causa*)⁵³ postoji ako netko bez pravne osnove (*sine causa*) stekne nešto iz imovine drugoga.

Obveza na povrat onoga što je stečeno bez pravne osnove (jer pravna osnova nije ni postojala ili je postala ništava) uvrštena je u kvazikontrakte jer se povrat bezrazložno stečenoga nije mogao tražiti temeljem bilo kojeg ugovora, kao ni temeljem delikta. U tu je svrhu tužitelju omogućeno koristiti se kondikcijama, apstraktnim tužbama kod kojih se ne navodi pravni razlog obveze.

Različiti slučajevi stjecanja bez pravne osnove u postklasičnom pravu svrstani su u pet skupina. Za njih postoje kondikcije s posebnim nazivom, a sve su nazvane zajedničkim imenom *condictiones sine causa*.

Condictio indebiti (vraćanje nedugovanog) postoji kada netko u ispričivoj bludnji isplati drugome sumu novca ili preda druge stvari, premda dug uistinu ne postoji, ili ne postoji prema osobi kojoj je isplaćeno. Ako primatelj zna da dug ne postoji, čini krađu (*furtum*), pa će biti tužen s *condictio furtiva*. Svjestan platež nedugovanog smatran je darovanjem.

Condictio causa data causa non secuta ili condictio ob causam datorum (stjecanje s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila) postoji kada se traži povrat onoga što je netko dao u očekivanju nekog budućeg događaja koji je izostao (npr. dalo se miraz, a do braka nije došlo; predana je stvar u zalogu očekujući zajam, a do zajma ne dođe).

Spomenuta kondikcija korištena je i u slučaju inominatnih kontrakata kod kojih jedna strana ispuni svoju obvezu, a druga odbije izvršiti ono što je obećala.

Condictio ob causam finitam (stjecanje po osnovi koja je kasnije otpala) može se upotrijebiti u slučaju kada se traži povrat činidbe izvršene temeljem valjane pravne osnove koja je kasnije otpala (npr. povrat onoga što je darovano ako je darovanje poništeno zbog nezahvalnosti; povrat unaprijed plaćene zakupnine ako je raskinut ugovor o zakupu; povrat predane kapare po prestanku ugovora o kupoprodaji).

Condictio ob turpem vel iniustam causam (stjecanje po nemoralnoj ili zabranjenoj osnovi) ima za cilj vraćanje isplaćenoga po nemoralnoj (*turpis causa*) ili pravno zabranjenoj osnovi (*iniusta causa*). Nemoralnost mora postojati na strani primatelja, ali ne i onoga koji je isplatio (npr. deponent mora nešto platiti depozitaru da bi dobio svoje stvari natrag). Ako je

⁵³ Niederländer, H., *Die Bereicherungshaftung im klassischen römischen Recht*, Weimar, 1953; Kupisch, B., *Ungerechtfertigte Bereicherung*, Heidelberg, 1987.

posao obostrano nemoralan ili zabranjen, ne može se kondikcijom tražiti povrat datoga (npr. podmićivanje suca; davanje u svrhu da se izvrši zločin ili bludne radnje).

Condictio sine causa može se upotrijebiti u različitim slučajevima bezrazložnog obogaćenja koji se nisu mogli svrstati ni u jednu od navedenih skupina (npr. povrat onoga što je dato temeljem ništavog pravnog posla).

§ 75 – Slučajna zajednica (*communio incidens*)

Slučajna zajednica (*communio incidens*) je obvezni odnos koji nastaje kada dvije ili više osoba bez svoje volje postanu suvlasnici neke stvari ili imovine.

Do slučajne zajednice najčešće dolazi kada više osoba zajedno naslijede ostavitelja; ili im zajednički bude darovana neka stvar; ili kada se stvari različitih vlasnika spoje i pomiješaju (*commixtio, confusio*). Pored suvlasničkih odnosa koji su regulirani pravilima stvarnog prava, stranke u slučajnoj zajednici nalaze se u obveznom odnosu iz kojeg proizilaze različita prava i obveze. Kako je ovaj **obvezni odnos nastao bez prethodnog sporazuma stranaka** (bez ugovora), a iz dopuštene radnje, svrstan je u kvazikontrakte.

Svaki suvlasnik imao je pravo upotrebljavati zajedničku stvar, pravo na razmjerni dio prihoda i razmjernu naknadu troškova. Ukoliko bi nanio štetu na zajedničkoj stvari, odgovarao je do visine ***culpa levis in concreto***. Obvezan je poštivati ista prava drugih zajedničara.

Svaki slučajni zajedničar mogao je u bilo koje vrijeme zahtijevati diobu zajedničke stvari. Ako je do zajednice došlo nasljedstvom, raskidana je putem ***actio familiae erciscundae***; diobna tužba za uređenje međa između susjednih zemljišta bila je ***actio finium regundorum***, a u svim drugim slučajevima kada je trebalo raskinuti slučajnu zajednicu, korištena je ***actio communi dividundo***.

Navedene tužbe spadaju u *actiones mixtae* jer su njima razrješavani i stvarnopravni i obveznopravni odnosi između stranaka. To su i *actiones duplices* jer se svaka stranka pojavljuje u ulozi i tužitelja i tuženika, tj. svaka stranka dobija svoj dio, ali se ujedno osuđuje na odgovarajuća davanja. Diobne tužbe sadržavale su široke ovlasti za suca koji je, ako se radilo o nedjeljivoj stvari, mogao odlučiti da se stvar proda i dobivena cijena podijeli, ili dosuditi cijelu stvar jednom od suvlasnika, uz obvezu da ostalim suvlasnicima isplati odgovarajuću naknadu.

§ 76 – Obveze iz tutorstva (*tutela*)

Prestankom tutorstva nastaje **obvezni odnos između tutora i pupile** koji je, budući da je nastao **bez volje pupile i bez ugovora između tutora i pupile**, svrstan u kvazikontrakte.

Tutor je obvezan vratiti štićeniku imovinu, položiti račun o upravljanju imovinom, naknaditi štetu do koje je došlo njegovom krivnjom i prenijeti tražbine koje je za njega stekao.

Pupila je dužan preuzeti na sebe obveze proistekle iz tutorova poslovanja i naknaditi tutoru troškove koje je tutor pretrpio upravljajući njegovom imovinom.

Taj obvezni odnos zaštićen je s ***actio tutelae***. Pupila je svoja potraživanja prema tutoru mogao ostvariti s *actio tutelae directa*, dok je tutor mogao podići *actio tutelae contraria*.

§ 77 – Obveze iz legata *per damnationem* (*legatum per damnationem*)

Na osnovi legata *per damnationem* u momentu ostaviteljeve smrti nastaje **obvezni odnos između nasljednika i legataru**. Nasljednik je obvezan predati legiranu stvar legataru, što legatar može zahtijevati s ***actio ex testamento***. Budući da je taj obvezni odnos nastao bez prethodne suglasnosti volja stranaka, svrstan je u kvazikontrakte.

Sličan obvezni odnos nastajao je i na osnovi legata *sinendi modo*.

Peto poglavlje

OBVEZE IZ DELIKATA I KVAZIDELIKATA

§ 78 – Obveze iz delikta (*obligationes ex delicto*)

Delikti⁵⁴ su protupravne povrede tuđih pravnih dobara sankcionirane kaznom propisanom protiv delinkventa.

S obzirom na sankciju i postupak u kojem se sankcija ostvaruje razlikuju se *delicta publica* i *delicta privata*.

⁵⁴ Jaramaz-Reskušić, I., *Kaznenopravni sustav u antičkom Rimu*, Zagreb, 2003.

Delicta publica ili crimina (javni delikti) su protupravna djelanja koja progoni i kažnjava država javnom kaznom (*poena publica*) po posebnom javnom kaznenom postupku (*iudicium publicum*) bez obzira na prijedlog ili zahtjev oštećenog pojedinca.

U starijem pravu samo je mali broj kaznenih djela, kod kojih je javni interes bio teško pogođen, ulazio u krug javnih delikata (veleizdaja – *perduellio*; umorstvo *pater familias* – *parricidium*). Predviđene kazne bile su: smrt, progonstvo, tjelesne kazne, globe, konfiskacija imovine, osuda na rad u rudnicima. S jačanjem funkcija državnog aparata država preuzima u svoje ruke represiju za sve veći broj protupravnih djela.

Delicta privata ili maleficia (privatni delikti) su protupravne radnje na osnovi kojih je nastajao obveznopravni zahtjev oštećenoga prema počinitelju delikta na platež novčane kazne ili na naknadu štete.

Ta nedopuštena djela smatrana su manje društveno opasnim zbog čega nisu povlačila represiju državnog aparata. Na osnovi privatnih delikata nastajao je **obvezni zahtjev** koji je sam oštećeni ostvarivao tužbom u redovitom građanskom postupku (*iudicium privatum*) kao i svaki drugi privatnopravni zahtjev. Dakle, **privatni delikti su izvori obveza kod kojih je deliktom oštećeni vjerovnik, a počinitelj delikta dužnik.**

Ideja o naknadi štete kao sankciji privatnih delikata postupno se razvijala u rimskom pravu. U najstarije vrijeme vrijedilo je načelo taliona (oko za oko, zub za zub), koje je običajnim putem zamijenjeno sustavom dragovoljne ili fakultativne kompozicije; delinkvent se mogao otkupiti od prava na osvetu predajom materijalnih dobara oštećenom ili njegovoj društvenoj skupini. Privatni delikti postali su izvori obveza tek kada je uveden sustav tzv. legalne kompozicije, tj. kada je država unaprijed propisala koliko delinkvent mora platiti oštećenome.

Pojam naknade štete uz kaznu ili umjesto kazne kod deliktne tužbe razvija se tek kasnije, tako da se konačno, u Justinijanovom pravu, razlikuju deliktne tužbe koje idu samo za kaznom (*actiones poenales*), ili samo za naknadom štete (*actiones rei persecutoriae*), ili, i za kaznom i za naknadom štete (*actiones mixtae*).

Deliktne zahtjevi na pasivnoj strani su nenasljedivi, tj. delinkventovom smrću deliktne zahtjev se gasi. Ipak, od delinkventovih nasljednika moglo se tražiti da vrate ono što je delinkvent stekao deliktom pa je prešlo na njih. **Deliktne zahtjevi na aktivnoj strani su nasljedivi**, što znači da nasljednici oštećenoga imaju pravo na utjerivanje novčane kazne i nakon smrti oštećenoga. Iznimka su tzv. *actiones vindictam spirantes*, tj. tužbe koje se temelje na strogo osobnim deliktima (npr. povredi – *iniuria*).

Civilno pravo poznavalo je samo četiri tipična delikta koji su predstavljali samostalni razlog postanka obveze i koji su bili zaštićeni svojim civilnim deliktnim tužbama. To su: *furtum* (krađa), *rapina* (razbojnička krađa), *iniuria* (povreda) i *damnum iniuria datum* (protupravno oštećivanje).

Vremenom je i pretor počeo reprimirati određena protupravna djelanja kao delikte, među kojima su najvažniji: *dolus* (prijevara), *vis ac metus* (nasilje i zastrašivanje) i *alienatio in fraudem creditorum* (prijevara na štetu vjerovnika).

1. Privatni delikti civilnog prava

a) *Furtum* (krađa)

***Furtum* (krađa) je namjerno (*animus furandi*) protupravno prisvajanje tuđe pokretne stvari učinjeno iz koristoljublja (*animus lucri faciendi*).**

Furtum je najstariji imovinski delikt civilnog prava. Rimsko shvaćanje krađe šire je od današnjeg jer obuhvaća ne samo protupravno prisvajanje tuđe pokretne stvari (*furtum rei*), nego i protupravno korištenje s tuđom stvari (*furtum usus*), kao i protupravno oduzimanje posjeda stvari od osoba koje su imale pravo posjedovati stvar (*furtum possessionis*).

Postojalo je više oblika krađe koji su različito kažnjavani.

Furtum manifestum je očita krađa. Postoji kada je kradljivac zatečen na djelu. Vlasnik stvari bio je ovlašten temeljem propisa Zakonika XII ploča noćnog i naoružanog kradljivca ubiti, samo je trebao vikom sazvati susjede. Uhvaćenog kradljivca magistrat bi dosudio okradenome u dugovinsko ropstvo. Kasnije je ta kazna zamijenjena kaznom u četverostrukom iznosu vrijednosti ukradene stvari.

Slično je kažnjavana i krađa otkrivena poslije svečane pretrage koju bi vršio okradeni vlasnik u kući osumnjičenog, držeći zdjelu u ruci i opasan samo pregačom (***furtum lance et licio***).

Furtum nec manifestum je potajno zlonamjerno odnošenje tuđe pokretne stvari u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi kod kojeg počinitelj nije zatečen na djelu. Za tajnu (neočitu) krađu bila je predviđena novčana kazna u visini dvostruke vrijednosti ukradene stvari, koja je ostvarivana redovitom parnicom, kao i svaka druga obvezna tužba.

Furtum conceptum ili otkrivena krađa postojala je u slučajevima kada je ukradena stvar pronađena kod neke osobe nakon pretrage izvršene pred svjedocima. Temeljem *actio furti concepti* ta je osoba kažnjavana na trostruku vrijednost ukradene stvari.

Furtum oblatum ili podmetnuta krađa postojala je kada je ukradena stvar bila nekome podmetnuta i kod njega pronađena. Gospodar kuće u kojoj je pronađena podmetnuta stvar imao je pravo na regresnu *actio furti oblata* protiv osobe koja mu je podmetnula stvar, također na trostruku vrijednost.

Furtum prohibitum je delikt koji je uveo pretor, a sastojao se u protivljenju kućnoj pretrazi. Takva osoba kažnjavana je po *actio furti prohibiti* na četverostruku vrijednost ukradene stvari.

Furtum non exhibitum je također delikt uveden pretorskim pravom, koji bi počinila osoba koja bi odbila predati pronađenu stvar. Temeljem *actio furti non exhibiti* kažnjavana je na četverostruku vrijednost.

Justinijanovo pravo poznaje dva oblika krađe: *furtum manifestum* i *furtum nec manifestum*, za koje su bile predviđene kazne u četverostrukom, odnosno dvostrukom iznosu vrijednosti ukradene stvari. Na kraju razvitka rimskog prava pojam krađe sužen je na oduzimanje pokretne tjelesne stvari (*furtum rei*).

zaštita

Po klasičnom i Justinijanovom pravu penalnu *actio furti* protiv kradljivca, te njegovih pomagača i podstrekača mogao je podići ne samo vlasnik, nego i svaka osoba kojoj je bilo u interesu da stvar bude sačuvana (npr. najamnik, posudovnik, osobe koje su čistile, krpile i glačale tuđu odjeću, tj. osobe koje su odgovarale za *custodia*).

Akcijom *furti* okradeni nije dobijao stvar natrag, kao ni naknadu štete, nego je samo postizao novčanu kaznu. Da bi dobio stvar natrag, okradeni vlasnik morao je podići i *rei vindicatio*. Umjesto reivindikacijom mogao se poslužiti s reipersekutornom *condictio furtiva* kod koje nije morao dokazivati svoje pravo vlasništva, nego samo činjenicu krađe. Spomenutu tužbu bilo je moguće upotrijebiti i u slučaju kada bi stvar propala kod kradljivca bez njegove krivnje, po načelu *fur semper in mora* (kradljivac je uvijek u zakašnjenju), kao i protiv onog kradljivca kod kojeg se stvar više ne nalazi, te protiv njegovih nasljednika.

b) Rapina (razbojstvo)

Rapina (razbojstvo; razbojnička krađa) je nasilno oduzimanje stvari učinjeno od strane naoružane skupine ili pojedinaca.

Taj delikt predstavlja kvalificirani oblik krađe iz koje je izdvojen krajem razdoblja Republike. Protiv počinitelja razbojničke krađe okradeni je mogao podići *actio vi bonorum*

raptorum, kojom bi u roku od godine dana postigao četverostruku, a nakon tog roka jednostruku vrijednost oštećene stvari.

c) *Damnum iniuria datum* (protupravno oštećivanje)

***Damnum iniuria datum* je protupravno oštećenje tuđih stvari.**

Poznat je već Zakoniku XII ploča koji ne daje jedinstveno obilježje delikta nego predviđa pojedinačne slučajeve oštećenja, karakteristične za mentalitet primitivnog poljodjelskog naroda: paljevinu tuđe kuće ili zaliha žita, napasanje stoke na tuđem pašnjaku, sječu tuđeg stabla, štetu počinjenu vradžbinama na tuđim usjevima i plodovima.

Taj delikt jedinstveno je i općenito reguliran Akvilijevim zakonom o šteti (*lex Aquilia de damno*) donesenim 287. ili 286. god. p.n.e. Zakon je obuhvaćao tri poglavlja u kojima su regulirana pitanja o naknadi štete: prvo poglavlje propisuje da se za ubojstvo roba ili radne stoke mora naknaditi najveća vrijednost koju su rob ili životinja imali tijekom posljednje godine; drugo poglavlje određuje da dodatni vjerovnik (*adstipulator*), koji namjerno otpusti dug i tako ošteti glavnog vjerovnika, mora platiti vrijednost oproštenog duga, dok treće poglavlje regulira odgovornost za ostale vrste šteta, za koje je predviđena naknada u visini najveće vrijednosti koju je stvar imala u proteklih trideset dana.

Po propisima Akvilijeva zakona tražilo se da postoji neposredna uzročna veza između radnje i posljedice, da je delikt nastao pozitivnim činjenjem (*delictum in commissione*), a ne propuštanjem neke radnje (*delictum in ommissione*), da je radnja kojom je nanesena šteta protupravna, te subjektivni element krivnje koja je shvaćana vrlo široko jer je obuhvaćala ne samo *dolus*, nego i svaku najmanju nemarnost i nepažnju (*Ulp. D.9.2.44: In lege Aquilia et levissima culpa venit*). Iz ovako širokog pojma kulpe (*culpa Aquiliana*) razvio se u kasnijem pravu pojam kulpe u tehničkom smislu.⁵⁵

Tijekom klasičnog razdoblja zahtjevi Akvilijeva zakona su ublaženi, pa se počinje uvažavati i posredna uzročna veza, kao i šteta izazvana propuštanjem.

Vlasnik oštećene stvari mogao je putem ***actio legis Aquiliae*** dobiti naknadu cjelokupne štete (*damnum emergens* i *lucrum cessans*), tj. obuhvaćen je cjelokupni vlasnikov interes (*id quod interest*).

d) *Iniuria* (povreda)

Iniuria je namjerna povreda tuđe osobnosti.

Obuhvaća napad na tjelesni integritet (realna *iniuria*) i povredu časti i ugleda (verbalna *iniuria*).

Zakonik XII ploča predviđa tri oblika napada na tjelesni integritet: oštećenje nekog od dijelova tijela (*membrum ruptum*) za koji je predviđena kazna taliona ako se stranke ne nagode; prijelom kosti (*os fractum*), kažnjavan s 300 asa ako se radilo o slobodnom čovjeku, a sa 150 asa ako je oštećeni bio rob; svi ostali oblici lakših tjelesnih povreda kažnjavani su s 25 asa.

Vremenom je taj delikt pretrpio velike promjene: teški slučajevi injurije (*iniuria atrox*) postali su javni delikti (*crimina*); ubojstvo i povreda roba prelaze u imovinske delikte protiv gospodara; talionsko načelo i fiksirane novčane kazne zamijenjene su drugim načinima kažnjavanja.

Zahvaljujući djelatnosti pretora *iniuria* u klasičnom pravu obuhvaća svako djelovanje i držanje kojim se namjerno (*animus iniurandi*) vrijeđa tuđa osoba.

Za sve slučajeve napada na tuđu osobnost učinjene s namjerom vrijeđanja, predviđena je pretorska ***actio iniuriarum aestimatoria*** (tužba s procjenom), temeljem koje je sudac bio ovlašten prema okolnostima slučaja i prema pravičnosti odrediti koliku naknadu delinkvent treba platiti. Tužba se mogla podići u roku od godine dana, povlačila je infamiju i nije prelazila na nasljednike ni na pasivnoj ni na aktivnoj strani (spada u *actiones vindictam spirantes*).

2. Delikti honorarnog prava

a) *Dolus* (prijevara)

Dolus (prijevara) je svako namjerno postupanje, protivno savjestnosti, poštenju i dobrim običajima, kojim se drugome nanosi šteta.

Staro civilno pravo nije davalo zaštitu protiv prijevare. Tek je u I. st. p.n.e. pretor *Gaius Aquilius Gallus* omogućio prevarenome da u roku od godine dana putem ***actio doli*** naplati iznos za koji je oštećen. Tuženik je na temelju arbitrarne klauzule pozivan da dragovoljno

⁵⁵ Cursi, M. F., *Iniuria cum damno: antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno Aquiliano*, Milano,

izvrši naturalnu restituciju, tj. da vrati ono što je stekao pravnim poslom izvršenim pod prijevarom, čime je izbjegavao infamiju.

Ako bi prevareni bio tužen na izvršenje primljene obveze, mogao je odbiti tužbeni zahtjev prigovorom prijevare (*exceptio doli*).

b) *Metus* (prinuda)

***Metus* (prinuda)** je delikt honorarnog prava koji se sastojao od protupravnih radnji fizičke prinude (*vis absoluta*) ili izazivanja straha stavljanjem u izgled nekog zla (*vis compulsiva*) s ciljem da se određena osoba navede na sklapanje po nju štetnog pravnog posla, ili na poduzimanje ili propuštanje djela kojim će pretrpjeti štetu.

Staro civilno pravo priznavalo je valjanost iznuđenih poslova. Tek je pretor *Octavius* krajem razdoblja Republike uveo penalnu tužbu na četverostruki iznos protiv onoga tko bi protupravnom prijetnjom prisilio drugoga na štetni čin (*actio quod metus causa* ili *formula Octaviana*). Tužba se mogla upotrijebiti i protiv trećih osoba koje bi iz tako sklopljenog posla stekle korist, makar bile u dobroj vjeri. *Actio quod metus causa* imala je stvarnopravni učinak, pa se zato zove *actio in rem scripta*.

Oštećeni je bio zaštićen i sa *restitutio in integrum ob metum* i *exceptio quod metus causa*.

c) *Alienatio in fraudem creditorum* (prikrata vjerovnika)

***Alienatio in fraudem creditorum* (prikrata vjerovnika)** je delikt honorarnog prava koji je postojao u slučaju kada bi dužnici svjesno pokušali izigrati vjerovnike i onemogućiti naplatu tražbina zaključujući simulirane ugovore ili darujući imovinu.

Dugovi prezaduženog dužnika naplaćivani su prodajom njegove cjelokupne imovine (*venditio bonorum*) ili, kasnije, prodajom pojedinih dijelova imovine (*distractio bonorum*). Međutim, već prije dospelosti tražbina ili prije ovrhe, dužnik je mogao onemogućiti naplatu dugova raznim oblicima raspolaganja imovinom i tako prijevarno oštetiti vjerovnike (npr. proda ispod cijene ili fiktivno tjelesnu stvar; oprosti dug; propusti rok za podizanje tužbe; oslobodi roba). Takvo otuđivanje imovine kako bi se spasila od ovrhe, smatra se izigravanjem i prikratom vjerovnika (*fraus creditorum*).

Protiv nepoštenog postupanja dužnika vjerovnici su imali na raspolaganju sljedeća pravna sredstva: ***interdictum fraudatorium***, ***restitutio in integrum ob fraudem*** i ***actio Pauliana***.

Interdictum fraudatorium je pravno sredstvo putem kojeg je u klasičnom pravu svaki vjerovnik mogao zahtijevati da otuđene tjelesne stvari budu ponovno uključene u imovinu dužnika.

Justinijanovo pravo uvelo je poboju tužbu nazvanu **actio Pauliana**, kojom se moglo pobijati otuđenje kako tjelesnih stvari, tako i raspolaganja netjelesnim stvarima (pravima) putem kojih je vjerovnicima nanesena šteta i onemogućeno njihovo namirenje. Tužbu je mogao podići upravitelj stečajne mase (*curator bonorum*) i svaki pojedini vjerovnik koji je otuđenjem oštećen. Tuženik je mogao biti ne samo dužnik, nego i svaka treća osoba koja je nešto stekla iz dužnikove imovine. Svrha je tužbe da se uspostavi onakvo imovinsko stanje kakvo je bilo prije otuđenja.

Dužnik je morao biti svjestan (*consciūs fraudis*) da ima vjerovnike i da mu zbog pogoršanja imovinskog stanja prijeti insolventnost. Treća osoba odgovarala je samo ako je znala za dužnikovu namjeru da ošteti vjerovnike, osim ako je stvar stekla besplatno, kada se tužba davala bez obzira na spomenuti zahtjev. Ako je bila u dobroj vjeri (*bonae fidei*), treća osoba odgovarala je samo do visine obogaćenja.

Paulijanska tužba vezana je za rok od jedne godine, nakon čega se davala samo do iznosa obogaćenja.

§ 79 – Obveze iz kvazidelikata (*obligationes quasi ex delicto*)

Justinijanove Institucije (IV,5) nabrajaju četiri obvezna odnosa koji nastaju iz radnji sličnih deliktima (*quasi ex delicto*), koji se ne mogu svrstati u delikte jer im nedostaje neki od bitnih elemenata delikata. To su: *iudex qui litem suam fecit*; *actio de deiectis vel effusis*; *actio de positis et suspensis* i *actio furti et damni adversus nautas caupones stabularios*.

Iudex qui litem suam fecit (nesavjesnost suca; sudac koji je učinio spor svojim) postoji u slučaju kada sudac namjerno ili iz nehata ne donese presudu u roku ili krivom presudom ošteti stranku. Protiv takve presude nije se mogao upotrijebiti nikakav pravni lijek jer u starom rimskom pravu nije postojala ustanova žalbe (*appellatio*). Zato je sudac osobno morao naknaditi štetu koju je prouzrokovao zlonamjerno, iz nepažnje ili neznanja (*imperitia*), zbog čega se govorilo da je učinio spor svojim (*litem suam fecit*).

Actio de deiectis vel effusis (povreda prolaznika) je tužba koju je mogao podići građanin koji je povrijeđen nekom stvari koja je izbačena ili prosuta iz kuće. U tom slučaju objektivna

odgovornost (bez obzira na krivnju) teretila je sve stanare kuće. Za oštećenu stvar trebalo je platiti dvostruku vrijednost; ako je bio povrijeđen čovjek, sudac je procjenjivao iznos naknade, a ako je slobodan čovjek ubijen, plaćalo se 50 000 sestercija u klasično doba, a 50 zlatnika u postklasično.

Actio de positis et suspensis (ugrožavanje prolaznika) je tužba koju je mogao podići svaki građanin protiv vlasnika ili stanara kuće na kojoj je primijetio predmete od kojih je prijetila opasnost da padnu i povrijede prolaznike. Osuđeni je bio obvezan platiti 10 000 sestercija ili 10 zlatnika.

Actio furti et damni adversus nautas caupones stabularios (odgovornost brodara gostioničara i vlasnika staja) je tužba ne temelju koje su brodari, gostioničari i vlasnici staja, bez obzira na svoju krivnju, morali putnicima i gostima naknaditi dvostruku vrijednost stvari koju su im ukrali ili oštetili članovi njihovog osoblja.

ŠESTI DIO

NASLJEDNO PRAVO

Prvo poglavlje

OPĆI ELEMENTI NASLJEDNOG PRAVA

§ 80 – Pojam i osnovni elementi nasljednog prava

Nasljedno pravo (u objektivnom smislu) je skup pravnih normi kojima se reguliraju imovinskopravni odnosi poslije smrti.

Nasljedno pravo (u subjektivnom smislu) ili pravo nasljeđivanja je ovlaštenje određene osobe stupiti u imovinskopravne odnose umrloga.

Nasljedno pravo⁵⁶ zajedno sa stvarnim i obveznim pravom spada u imovinsko pravo (*ius quod ad res pertinet*). Stvarno i obvezno pravo obuhvaćaju pravila imovinskog prava s učinkom *inter vivos*, što znači da ih karakteriziraju poslovi *inter vivos* i singularne sukcesije (*successio in singulas res*, tj. stjecanje pojedinih stvari ili prava). Nasljedno pravo čine pravna pravila s učinkom *mortis causa*, što znači da obuhvaća pravne poslove za slučaj smrti (*negotia mortis causa*) i da se bavi pitanjima univerzalne sukcesije.

Imovinska prava i imovinske obveze ne prestaju smrću njihova nositelja nego prelaze na nasljednike. Stupanje nasljednika u sva prava koja je imao umrli naziva se **univerzalna sukcesija** (*successio in universum ius; successio in universitatem*). Društveno-gospodarska zadaća nasljednog prava je osigurati kontinuitet pravnih odnosa nakon smrti njihova nositelja. Predmetom nasljeđivanja ne mogu biti strogo osobna prava koja prestaju smrću: javna prava, prava iz statusnih i obiteljskih odnosa, neka stvarna prava (važnije osobne služnosti), ugovori *intuitu personae*, deliktne obveze na pasivnoj strani.

Nasljedstvo (hereditas) predstavlja skup imovinskih prava i obveza koje prelaze od umrle osobe na nasljednika. S obzirom na umrloga (ostavitelja) taj skup prenosivih imovinskih prava i obveza naziva se **ostavina**, a s obzirom na nasljednika zove se **nasljedstvo**. Termin *hereditas* obuhvaća i ostavinu i nasljedstvo.

⁵⁶ Grosso, G. *I legati*, Torino, 1953; Voci, P., *Diritto ereditario romano II*, Milano, 1963; Giodice-Sabbatelli, V., *La tutela giuridica dei fedecommissi fra Augusto e Vespasiano*, Bari, 1993; Pulitanò, F. *Ricerche sulla bonorum possessio ab intestato nell' età tardo-romana*, Torino, 1999; Desanti, L., *La sostituzione fedecommissaria*, Torino, 1999; Treggiari, F., *Minister ultimae voluntatis: esegesi e sistema nella formazione del testamento*, Napoli, 2002.

Ostavitelj je označavan izrazima **de cuius** (*de cuius successionem agitur* – onaj o čijem se nasljeđivanju radi) i **defunctus** (*de fungere* – onaj koji je prestao biti aktivan), a **nasljednik po civilnom pravu** izrazom **heres**.

Pravne osnove za stjecanje nasljedstva (vrste nasljeđivanja ili načini pozivanja na nasljedstvo) su **zakon** i **oporuka**. U slučaju **zakonskog** (intestatnog ili neoporučnog) nasljednog prava određeni krug osoba već po samom zakonu ima pravo na nasljedstvo. Kod **oporučnog** (testamentarnog) nasljeđivanja pozivanje nasljednika prepušteno je volji ostavitelja. Vremenom je stvoreno i tzv. **nužno nasljedno pravo** kojim je ograničena široka sloboda oporučnog raspolaganja tako što je najbližim srođnicima zakonom priznato pravo na nužni dio.

Bitno obilježje rimskog klasičnog nasljednog prava je usporedno postojanje nasljednog prava po civilnom pravu i nasljednog prava po pretorskom pravu. Taj duplicitet institucija odražavao se kako u zakonskom tako i u oporučnom nasljeđivanju.

Dok su po starom civilnom pravu na nasljeđivanje pozivani prvenstveno agnatski srođnici, u razdoblju klasičnog prava pretor poziva na nasljedstvo i osobe izvan agnatskog kruga, dakle, i agnate i kognate, te priznaje jednostavnije oblike oporuke; postklasično i Justinijanovo pravo na nasljedstvo pozivaju isključivo kognate.

Nasljeđivanje po pretorskom pravu naziva se **bonorum possessio** jer je pretor dopustio određenim osobama koje nisu mogle postati nasljednici po civilnom pravu, da uđu u posjed ostavinske imovine i tako ih u pogledu nasljeđivanja izjednačio s civilnim nasljednicima. Nasljednik po pretorskom pravu naziva se **bonorum possessor**.

§ 81 – Stjecanje nasljedstva

Da bi došlo do nasljeđivanja, morale su se ispuniti određene pretpostavke:

1. smrt ostavitelja;
2. sposobnost ostavitelja imati nasljednika;
3. postojanje imovine koja je mogla biti predmetom nasljedstva;
4. postojanje nasljednika i njegova sposobnost biti nasljednikom;
5. način pozivanja na nasljedstvo (*vocatio heredum*);
6. pripad nasljedstva (*delatio*);
7. prihvrat nasljedstva (*acquisitio*).

Do ostvarivanja nasljednopravnog odnosa i stjecanja nasljedstva dolazilo je kada bi pravilno pozvani nasljednik, koji je sposoban biti nasljednikom, prihvatio nasljedstvo, čime je stupao u sva prava i obveze ostavitelja.

Ostavitelj (*de cuius; defunctus*) je **fizička osoba** koja je za života bila nositelj otuđivih prava i obveza. Ako se radilo o oporučnom pozivanju na nasljedstvo, ostavitelju je moralo biti priznato **pravo putem oporuke raspolagati imovinom** (*testamenti factio activa*). *Testamenti factio activa* bila je priznata rimskim građanima koji su imali pravnu i poslovnu sposobnost.

Svojstvo **nasljednika** mogla je dobiti samo osoba koja je bila živa u momentu ostaviteljeve smrti (u momentu delacije, tj. otvaranja nasljedstva). Jedina iznimka predviđena je za ostaviteljevo posmrče (*postumus*), za koje vrijedi pravilo *postumi agnatione testamentum rumpitur* (rođenjem posmrčeta oporuka se ukida) izvedeno iz načela *nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur*. Za oporučne nasljednike mogle su biti imenovane samo osobe koje su imale **testamenti factio passiva** (**sposobnost biti imenovan za nasljednika**). Pasivnu testamentifikaciju imali su rimski građani i robovi rimskih građana, kao i neke pravne osobe (rimska država, municipiji i u postklasično doba crkvene organizacije).

Ostavina (*hereditas*) je **ukupnost prava i obveza koji su objekt nasljeđivanja**. Kada se taj skup prava i obveza koji prelazi na nasljednika promatra sa stajališta ostavitelja, naziva se **ostavinom**; taj isti skup prava i obveza promatran sa stajališta nasljednika, naziva se **nasljedstvom**. U rimskom pravu smatra se skupinom stvari (*universitas iuris*) sastavljenom od svih nasljeđivih imovinskih prava i obveza koja je ostavitelj imao u času smrti. Nasljeđiva stvarna prava i obvezne tražbine čine aktivu ostavine, dok nasljeđiva obvezna dugovanja čine pasivu ostavine.

Za stjecanje nasljedstva, pored navedenih pretpostavki, potrebno je da dođe do **pozivanja na nasljedstvo** (*delatio*) ili **pripada nasljedstva**. Osnova delacije (način pozivanja na nasljedstvo) može biti zakonski nasljedni red, oporuka i nužno nasljedno pravo. Delacija nastupa u času fizičke smrti ostavitelja.

Samom delacijom pozvani nasljednik još uvijek ne stječe nasljedstvo jer je potreban još i **prihvat nasljedstva** (*acquisitio*). Tu se razlikuju *heredes necessarii* i *heredes voluntarii*.

Heredes sui et necessarii bile su osobe koje su se nalazile pod neposrednom vlašću ostavitelja u trenutku njegove smrti (osobe *alieni iuris* i robovi). Te osobe stjecale su nasljedstvo *ipso iure* već časom delacije. Nisu mogle odbiti nasljedstvo, čak ni kada je bilo prezaduženo. Pretor im je kasnije dodijelio **ius abstinendi**, pravo odreći se prezaduženog

nasljedstva, kao i **beneficium inventarii**, pravo sastaviti popis naslijeđenih dobara i odgovarati vjerovnicima ostavine samo do visine naslijeđene aktive.

Heredes voluntarii ili **heredes extranei** su nasljednici koji u času ostaviteljeve smrti nisu bili pod njegovom očinskom vlašću. Oni nisu morali prihvatiti nasljedstvo. Zato se tražilo da očituju volju o prihvatu nasljedstva (**acquisitio hereditatis**), što su mogli učiniti na tri načina: svečanim formalističnim usmenim prihvatom (**cretio**); neformalnim prešutnim putem, kada se iz ponašanja nasljednika može zaključiti da je prihvatio nasljedstvo (**pro herede gestio**, npr. useli se u naslijeđenu kuću; naplaćuje ostavinska potraživanja) i izričitom neformalnom izjavom volje (**aditio nuda voluntate**). Izjava o prihvatu nasljedstva nije se mogla povući: **semel heres, semper heres** (jednom nasljednik, uvijek nasljednik).

Civilno pravo nije propisivalo rok za prihvrat nasljedstva, ali je pretor, najčešće na zahtjev ostavinskih vjerovnika, određivao nasljedniku rok za razmišljanje (**spatium deliberandi**), koji je obično iznosio sto dana. Ako se nasljednik ni u tom roku ne bi očitovao, smatralo se da je odbio nasljedstvo. Suprotno je rješenje Justinijanovog prava, po kojem se pretpostavlja da ga je prihvatio.

Odbijanje nasljedstva (**repudiatio**) moglo se izvršiti na bilo koji način i bilo je neopozivo.

Da bi se nasljednika potaknulo da što prije prihvati nasljedstvo, uvedena je ustanova **usucapio pro herede**, na osnovi koje je bilo koja osoba, koja bi posjedovala ostavinu kroz godinu dana, stjecala dosjelošću ostavinu i položaj nasljednika. Nije se tražila ni *iusta causa* ni *bona fides*. Kasnije je ta ustanova ograničena, pa je *usucapiens* mogao dosjesti samo one predmete iz ostavine koje je posjedovao. U II. st. n.e. nepošteno zaposijedanje tuđe ostavine proglašeno je zločinom (**crimen expilatae hereditatis**), a ustanova **usucapio pro herede** podvrgnuta je pravilima redovite dosjelošti.

Pravo na prihvrat nasljedstva nije se moglo prenijeti na drugoga, čak ni u slučaju smrti pozvanog nasljednika. Ako pozvani nasljednik ne prihvati nasljedstvo, njegov dio prirasta razmjerno dijelovima ostalih sunasljednika (**ius adcrescendi**). Tek je pretor postupno počeo dopuštati prijenos delacije (**transmissio delationis**) na nasljednike pozvanoga, ako bi on umro, a bez svoje krivnje nije prihvatio nasljedstvo. Justinijanovo pravo dopustilo je unutar određenog roka transmisiju svake delacije nasljedstva koje još nije prihvaćeno.

U razdoblju između pripada i prihvata ostavina je bez gospodara, pa se naziva **ležeća ostavina** (**hereditas iacens**). Pravna konstrukcija ležeće ostavine bila je sporna. Po mišljenjima nekih pravnika ostavina na neki način još uvijek predstavlja ostavitelja, ali je

postupno izgrađeno shvaćanje da prihvrat nasljedstva djeluje unatrag, počev od trenutka ostaviteljeve smrti.

§ 82 – Posljedice stjecanja nasljedstva

Nasljednik je, kao univerzalni sukcesor, stupao u sva nasljediva prava i obveze umrloga. To znači da je obvezan platiti ostaviteljeve nasljedive dugove. Budući da prihvaćanjem nasljedstva dolazi do spajanja naslijeđene imovine s njegovom vlastitom imovinom (*aditio bonorum; confusio bonorum*), nasljednik je odgovorao za ostavinske dugove ne samo naslijeđenom, nego cjelokupnom imovinom. Isto tako, iz naslijeđene imovine mogu se sada naplatiti nasljednikovi vjerovnici, što je moglo dovesti u nepovoljan položaj ostavinske vjerovnike ako je nasljednik bio prezadužen. Zato je spajanje imovine nasljednika s naslijeđenom imovinom moglo pogoditi kako interese nasljednika (ako je ostavina bila prezadužena), tako i interese njegovih, odnosno ostavinskih vjerovnika.

Da bi razriješio takvu situaciju, pretor je uveo određena pravna sredstva: već spomenute ***beneficium abstinendi*** i ***beneficium inventarii***, te ***beneficium separationis***.

Beneficium separationis je pravno sredstvo uvedeno radi zaštite ostavinskih vjerovnika u slučaju nasljednikove prezaduženosti. Ostavinski vjerovnici mogli su u roku od pet godina po stjecanju nasljedstva tražiti razlučenje ostavine od nasljednikove imovine, pa su imali prednost pred nasljednikovim vjerovnicima prema razlučenoj ostavini.

Pretor je uveo još jedan institut u svrhu zaštite interesa nasljednika – *descendenata*. Budući da se po pretorskom pravu na nasljedstvo poziva i emancipirani sin, trebalo je sve nasljednike dovesti u isti položaj. Potomci koji su ostali pod ostaviteljevom očinskom vlašću, privređivali su za imatelja vlasti i tako povećavali obiteljsku imovinu, dok je emancipirani sin stjecao samo za sebe. Zato je emancipirani sin, ako je htio dobiti *bonorum possessio*, morao u ostavinsku masu unijeti imovinu stečenu nakon emancipacije. Ta obveza emancipiranog sina naziva se **collatio bonorum**. U početku je vršena realnim unošenjem imovine u ostavinsku masu, a kasnije uračunavanjem u nasljedni dio. Vremenom se jednako počelo postupati i sa imovinom koja je dana u svrhu miraza (*collatio dotis*), raznih oblika darovanja (*collatio donationis*), da bi u postklasičnom pravu bila stvorena opća obveza kolacije, po kojoj je svaki descendent morao izvršiti kolaciju (uračunavanje) znatnijih primanja koja je dobio od ostavitelja, dok je taj bio živ.

§ 83 – Pravna zaštita nasljednika

Nasljedniku kao univerzalnom sukcesoru pripadaju sve **pojedinačne tužbe** koje bi *de cuius* mogao podići da je živ. To su tzv. **singularne ili specijalne tužbe** (npr. može reivindikacijom zahtijevati ostavinske stvari koje treći neovlašteno posjeduje; ili naplatiti tražbinu onom obveznom tužbom koju je imao ostavitelj). Te tužbe podižu se u slučajevima kada tuženik priznaje nasljedniku svojstvo nasljednika.

Ako treća osoba odbija predati ostavinsku imovinu nasljedniku jer mu osporava nasljedno pravo i svojstvo nasljednika, civilni nasljednik mora podići tzv. ***hereditatis petitio***, sličnu reivindikaciji. Tužitelj mora samo dokazati svojstvo nasljednika.

Nasljednik po pretorskom pravu (*bonorum possessor*) imao je na raspolaganju ***interdictum quorum bonorum***, kojim je mogao zahtijevati posjed ostavinskih stvari. Justinijanovo pravo priznalo mu je *hereditatis petitio* kao *actio utilis*.

Nužni nasljednici koji su bili mimoideni u oporuci ili nisu dobili svoj zakonski dio, mogli su podići ***querella inofficiosi testamenti***. Ta tužba bila je strogo osobne naravi (*actio vindictam spirans*), pa nije bila nasljediva i zastarijevala je u roku od dvije godine (pet godina po Justinijanovom pravu). Od razdoblja postklasičnog prava imali su i tužbu za dopunu nužnog nasljednog dijela (***actio ad supplendam legitimam***).

Podjela ostavine među sunasljednicima i raskid njihovog suvlasničkog odnosa obavljani su putem ***actio familiae erciscundae***.

Drugo poglavlje

INTESTATNO (ZAKONSKO) NASLJEĐIVANJE

Intestatno ili zakonsko nasljedno pravo (*successio ab intestato*) je nasljeđivanje na temelju određenih činjenica koje propis predviđa kao osnove u slučaju kada nije moglo doći do oporučnog nasljeđivanja. Tada imovina umrle osobe prelazi na određene osobe koje već po samom zakonu imaju pravo na nasljedstvo.

Kod svih naroda starog vijeka isprva je postojalo samo intestatno (zakonsko) nasljeđivanje. Uz zakonsko nasljeđivanje kod Rimljana rano se javlja i oporučno (testamentarno) nasljeđivanje, koje poznaje već Zakonik XII ploča. Zakonski red nasljeđivanja, kao i pravo oporučnog raspolaganja zavise od konkretnih društvenih i ekonomskih prilika i iz njih proisteklih obiteljskih i srodničkih odnosa.

Rimsko nasljedno pravo prilagođavano je promjenama u obiteljskim, gospodarskim i društvenim odnosima, tako da se razlikuju četiri faze njegova razvitka: nasljeđivanje po starom civilnom pravu, pretorski nasljedni sustav, nasljeđivanje po carskom pravu i Justinijanovo nasljedno pravo.

Do intestatnog nasljeđivanja dolazi samo ako ostavitelj nije napravio oporuku (*si intestato moritur*), ili je oporuka iz bilo kojeg razloga nevaljana, ili oporučno postavljeni nasljednici nisu htjeli ili nisu mogli postati nasljednicima. Intestatno (zakonsko) nasljeđivanje pretrpjelo je tijekom vremena velike promjene, počev od Zakonika XII ploča, preko pretorskog i carskog prava, do završnog oblika u Justinijanovom pravu.

§ 84 – Intestatno nasljeđivanje po civilnom pravu Zakonika XII ploča

Zakonski nasljedni red starog civilnog prava zasnovan je na agnatskom srodstvu. Krvno srodstvo nije uzimano u obzir. Premda Zakonik XII ploča poznaje oporuku, još uvijek ne postoji oporuka sa slobodom izbora nasljednika. Nasljednikom nije mogla biti imenovana treća osoba (*extraneus*) ako su postojali *sui heredes*. Imovina je trebala ostati obiteljskom kolektivu.

Intestatni ili zakonski nasljedni red starog civilnog prava utvrđen je Zakonikom XII ploča (*Tab. V, 4-5*) i glasi: ***sui heredes, proximus agnatus, gentiles***.

Sui heredes su najbliži agnatski srodnici ostavitelja koji njegovom smrću postaju osobe *sui iuris*. To su: ostaviteljeva djeca, adrogirani i adoptirani, te ostaviteljeva žena ako je bila u braku *cum manu*. *Sui heredes* ne mogu odbiti nasljedstvo, čak ni kada je prezaduženo. Nasljeđuju *in stirpes* (*successio in stirpes*), što znači da ako ima više “svojih”, bliži srodnik isključuje iz nasljeđivanja svoje potomke, npr. sin u vlasti isključuje od nasljeđivanja svoju djecu, ali ako je sin prethodno umro, po načelu predstavljanja (*ius representationis*) njegova djeca imaju ista prava u nasljeđivanju svoga djeda koja bi imao njihov otac da je živ.

Načelo predstavljanja ili reprezentacije (*ius representationis*) znači da pretka koji je umro prije ostavitelja predstavlja njegov živi potomak. Dio ostavine koji bi pripao pretku da je preživio ostavitelja, nasljeđuje njegov potomak.

Proximus agnatus je najbliži agnat izvan kruga *sui heredes*. To su ostaviteljeva braća i sestre, stričevi i njihovi potomci. Ako nema braće i sestara, na nasljedstvo se poziva samo muški *agnatus proximus*. Bliži srodnici isključivali su iz nasljeđivanja daljnje srodnike. Nije se primjenjivalo načelo reprezentacije. Nasljednici iz ovog reda mogli su odbiti nasljedstvo.

Ako bliži srodnici ne bi prihvatili nasljedstvo, nisu pozivani daljnji (nije postojala tzv. *successio graduum*), nego bi ostavina kao vakantna (*hereditas vacans* – ostavina bez nasljednika) pripala državi.

Gentiles su pripadnici istog roda. Ostavina je ulazila u imovinu gentilne zajednice ako ne bi bilo nikoga iz prvog i drugog nasljednog reda.

§ 85 – Intestatno nasljeđivanje po pretorskom pravu (*bonorum possessio intestati*)

Krajem razdoblja Republike dolazi do velikih promjena u obiteljskim i imovinskim odnosima, što je posljedica uvođenja robne proizvodnje i klasičnog ropstva. Nestaju pretpostavke na kojima je počivala agnatska obitelj. Ogromno materijalno bogatstvo omogućilo je opstanak izvan obiteljske zajednice. Sve više slabi *patria potestas*, zbog čega agnatsko srodstvo gubi značaj. Krvno srodstvo (*cognatio*) dobiva sve veću ulogu u obiteljskom i nasljednom pravu. Propisi starog civilnog prava nisu više odgovarali promijenjenim prilikama, pa ih je pretor prilagodio posluživši se institutom *bonorum possessio*. Pretor je davao posjed ostavinskih dobara i štitio kao nasljednike one osobe koje su po novim shvaćanjima o blizini srodstva bile najbliže umrlome. Zato **na nasljedstvo poziva pored agnatskih i krvne srodnike**. Rezultat pretorove djelatnosti bio je novi intestatni nasljedni red koji se primjenjivao kada nije bilo oporuke, zbog čega se naziva *bonorum possessio sine tabulis* ili *ab intestato*.

Nasljedni redovi po pretorskom pravu su:

Liberi – ostaviteljeva djeca, s tim što se na nasljedstvo pozivaju i ona krvna djeca koja u momentu ostaviteljeve smrti nisu bila pod njegovom vlašću (djeca koja su udata, emancipirana ili data u adopciju). Emancipirani sin morao je u ostavinu unijeti ono što je stekao nakon emancipacije (*collatio bonorum*). *Liberi* nasljeđuju tek prihvatom nasljedstva. Potomci umrle djece dobijali su dijelove nasljedstva po načelu reprezentacije.

Legitimi su osobe koje su imale pravo nasljedstva po civilnom pravu. Budući da su osobe iz kruga *sui heredes* već pozvane kao *liberi*, taj nasljedni red odnosi se na agnate koji nisu pripadali među *sui heredes* (*agnatus proximus*).

Cognati – krvni srodnici do šestog stupnja srodstva, a od sedmog stupnja unuci po braći i sestrama.

Vir et uxor – bračni drug. Ako nije bilo agnatskih ni kognatskih srodnika iz prva tri razreda, na nasljedstvo je pozivana i žena iz braka *sine manu*.

Pretor je uveo *successio ordinum* i *successio graduum*. Ako osobe iz jednog nasljednog reda ne bi zatražile *bonorum possessio*, na nasljedstvo su pozivani ovlaštenici iz sljedećeg nasljednog reda (***successio ordinum***). U trećem nasljednom redu uvedena je tzv. ***successio graduum***, temeljem koje je na nasljedstvo pozivan kognat daljnjeg stupnja, u slučaju da bliži krvni srodnik propusti zatražiti posjed ostavinskih dobara.

§ 86 – Carsko pravo

Dalji razvitak nasljednog prava u razdoblju Principata i Dominata obilježen je još većim značajem krvnog srodstva. Posebnim senatskim odlukama regulirano je nasljeđivanje između majke i djece.

Senatus consultum Tertullianum ustanovljava nasljedno pravo majke koja je imala *ius liberorum* (ako je u slobodi rođena – *ingenua* rodila bar tri puta, odnosno oslobođenica – *libertina* četiri puta) prema imovini bračnog ili izvanbračnog djeteta koje je umrlo bez oporuke, a nije imalo svojih potomaka, niti oca ili punokrvnu braću.

Senatus consultum Orphitianum izjednačuje nasljedna prava bračne i izvanbračne djece prema imovini majke, dajući im prednost ispred svih agnatskih srodnika.

§ 87 – Intestatno nasljeđivanje Justinijanovog prava

Justinijan je stvorio potpuno nov sustav nasljeđivanja zasnovan **isključivo na krvnom srodstvu**. Novelama 118. i 127. ukinuti su i posljednji ostaci nasljeđivanja po agnatskom načelu. Prestaje razlikovanje osoba po tome jesu li *sui iuris* i *alieni iuris*; potpuno se izjednačuju muški i ženski srodnici.

Justinijan je ustanovio četiri nasljedna reda:

Descendentes – potomci ostavitelja po muškoj i ženskoj liniji; u taj red ulaze i djeca ranije umrlih sinova i kćeri koja nasljeđuju po načelu reprezentacije, kao i adrogirani i adoptirani. Oca su mogla naslijediti samo bračna djeca, a izvanbračna majku i njezine srodnike.

Ascendentes – preci, punorodna braća i sestre (germanes) i djeca ranije umrle braće i sestara sačinjavaju drugi nasljedni red.

Polubraća i polusestre (consanguinei i uterini) i njihovi potomci prvog stupnja ulaze u treći nasljedni red.

Pobočni srodnici (collaterales) do zaključno šestog stupnja srodstva nasljeđuju ako nema nikoga iz prethodnih redova.

U pomanjkanju svih navedenih rođaka ostavina pripada bračnom drugu, određenim korporacijama ili državi. Siromašna udovica (*vidua inops*) koja nije imala ni miraza (*mulier indotata*) ni darovanja u vezi s brakom, dobijala je četvrtinu nasljedstva, a ako je nasljeđivala sa svojom djecom dobijala je određeni dio na uživanje (*ususfructus*).

Treće poglavlje

OPORUČNO NASLJEĐIVANJE

§ 88 - Pojam i oblici oporuke u starom civilnom pravu

Oporuka (testamentum) je jednostrani formalistični pravni posao za slučaj smrti kojim oporučitelj imenuje nasljednika i raspodjeljuje imovinu.

Imenovanje nasljednika (heredis institutio) je bitni element oporuke. Moralo je biti izvršeno na latinskom jeziku, posebnim svečanim riječima uz upotrebu imenice *heres* i glagola *esse*. Nasljednik je morao biti određen odmah na početku oporuke. Sve što bi stajalo ispred te odredbe, smatrano je nepostojećim.

Oporučno nasljeđivanje ima prednost pred zakonskim. Budući da u rimskom pravu vrijedi načelo isključivosti pravnih osnova, nije postojala mogućnost nasljeđivanja i po oporuci i po zakonu. Ako bi ostavitelj raspodijelio u oporuci samo dio imovine, imenovani oporučni nasljednik dobija i ostali dio imovine, a zakonski nasljednici ne dobijaju ništa, što se izražava načelom *Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest* (Nitko ne može naslijediti dijelom po oporuci, dijelom po zakonu).

Osnovni cilj oporuke bio je odrediti nasljednika (*heres*) koji će sačuvati obiteljsku imovinu i nastaviti kult obiteljskih božanstava. Zbog toga je nasljednikom mogao biti imenovan samo ostavitelj *suus*.

Najstarije forme rimske oporuke bile su *testamentum calatis comitiis* (oporuka pred kurijatskim narodnim skupštinama) i *testamentum in procinctu* (vojnička oporuka objavljena u bojnem poretku).

Nedostaci oporuke objavljivane pred kurijatskim skupštinama bili su očiti: skupštine su se sastajale samo dva puta godišnje i to u Rimu; građani koji nisu imali pristupa pred

kurijatske komicije (plebejci i žene) nisu mogli praviti oporuku; sadržaj oporuke morao se javno objaviti.

To su bili razlozi zbog kojih je komicijalna oporuka ustupila mjesto **mancipacijskoj “oporuci” starijeg tipa (*mancipatio familiae*)**. Učinci oporuke na zaobilazan način postizani su putem mancipacije. Ostavitelj bi pred libripensom i petoricom svjedoka prenio vlasništvo svoje imovine na osobu od povjerenja (*familiae emptor*) uz nalog na koji će je način raspodijeliti nakon njegove smrti. *Familiae emptor* (tobožnji kupac nasljedstva) nije bio nasljednik nego samo izvršitelj oporučiteljeve volje. Zbog toga se u tom slučaju ne radi o oporuci u pravom smislu nego o fiducijarnom poslu (*fiducia cum amico*), odnosno imaginarnoj prodaji.

Vremenom se *mancipatio familiae* pretvorila u pravu formalnu oporuku ***testamentum per aes et libram*** pred sedmoricom svjedoka (*familiae emptor*, libripens i pet svjedoka mancipacije), najprije u usmenom, potom u pisanom obliku. Kod usmene oporuke *per aes et libram* najveća važnost polagana je na ostaviteljevu izjavu (***nuncupatio***) koja je sadržavala imenovanje nasljednika i sve elemente oporuke. Usmenu oporuku potisnula je pismena. Bilo je dovoljno da ostavitelj pred svjedocima pri nunkupaciji samo pokaže pločice i izjavi da je na njima napisana njegova posljednja volja (*voluntas ultima*). Na vanjske strane pločica trebalo je staviti potpise i pečate oporučitelja i svjedoka. Tako je oporuka postala **tajna i opoziva**.

§ 89 – Oporučno nasljeđivanje po pretorskom pravu

Pretor je u potpunosti zanemario formalnosti mancipacije i od I. st. p.n.e. počeo štititi kao nasljednika osobu koja bi donijela pismenu oporuku ovjerenu pečatima oporučitelja i sedmorice svjedoka. Posjed ostavinske imovine koji se dodjeljivao nasljedniku na temelju takve oporuke nazivan je ***bonorum possessio secundum tabulas*** – *bonorum possessio* prema pločicama.

§ 90 – Oporuka u postklasičnom i Justinijanovom pravu

Stapanje civilnog i pretorskog prava odrazilo se i na području nasljednog prava gdje nestaju razlike između civilnog i pretorskog nasljeđivanja. Oporuka se oslobađa formalnosti, tako da ni imenovanje nasljednika nije više vezano ni za kakve forme. Postklasično pravo proširilo je načine oporučivanja priznavajući kao oporuke sve forme koje su mogle osigurati

dokaz o ostaviteljevoj posljednjoj volji. Priznata je valjanost vlastoručno napisanih oporuka, čak i bez svjedoka, kao i valjanost usmenih oporuka ako bi ostavitelj usmeno očitovao posljednju volju pred sedmoricom svjedoka. Oporučitelj je mogao izdiktirati oporuku u zapisnik kod municipalnog službenika.

Justinijanovo pravo nadovezalo se na propise postklasičnog zakonodavstva, dalje oslobađajući oporuku od formalnosti. Imenovanje nasljednika nije više moralo stajati na početku oporuke; priznaje se valjanost zapisa postavljenih prije određenja nasljednika.

Justinijanovo pravo razlikuje privatne i javne oporuke.

Privatne oporuke mogle su biti **usmene** i **pismene**. **Usmena oporuka** morala je biti priopćena pred sedmoricom svjedoka. **Pismena oporuka** mogla je biti **holografška** i **alografška**. **Holografšku oporuku** oporučitelj bi vlastoručno napisao i potpisao, uz pečate sedmorice svjedoka. Ostaviteljev potpis nije bio potreban ako bi u oporuci istaknuo da ju je vlastoručno napisao. **Alografšku oporuku** ostavitelj bi nekome izdiktirao, a potom ju je morao potpisati, uz pečate sedmorice svjedoka.

Javne oporuke postojale su u slučajevima kada je posljednja volja očitovana pred državnim organom i zabilježena u zapisnik kod suda ili municipalnog službenika (*testamentum apud acta conditum*), te kada bi pismena oporuka bila deponirana u carskom uredu (*testamentum principi oblatum*).

Pored navedenih **redovitih** oblika oporuke, postojali su **izvanredni** oblici oporuke za koje su se tražile veće ili manje formalnosti (oporuke u slučaju epidemije; oporuke slijepih i nepismenih; oporuka na selu; oporuka kojom su samo descendenti imenovani nasljednicima). Posebne pogodnosti vrijedile su za vojnike. *Testamentum militis* – vojnička oporuka bila je oslobođena svih formalnosti, uz jedini uvjet da je oporučiteljeva volja ozbiljna i jasna.

§ 91 – Formalno i materijalno nužno nasljedno pravo

Premda sloboda oporučivanja čini jedan od temelja rimskog privatnog prava, ostavitelj u starom Rimu nije nikada imao potpunu slobodu u izboru nasljednika. Ta je sloboda na različite načine ograničavana od najstarijeg, pa sve do Justinijanova prava. Ustanovljenje nužnog nasljeđivanja najvažniji je način ograničenja slobode raspolaganja oporukom. Nastalo je u vrijeme kada su ostavitelji počeli imenovati nasljednicima i osobe izvan kruga obitelji (*extranei heredes*).

Ako ostavitelj ne bi spomenuo člana obitelji u oporuci, taj bi bio lišen sudjelovanja u raspodjeli obiteljske imovine. Da bi se zaštitili interesi bližih srodnika, propisano je da

ostavitelj u oporuci mora spomenuti sve članove obitelji. Ako je htio iznaslijediti (*exheredare*) sina u vlasti, morao je to uraditi poimenično (*nominatim*), a za sve ostale ukućane, uključujući i kćeri, bila je dovoljna opća formula “ostali neka budu lišeni nasljedstva” (“*ceteri exheredes sunt*”). Ako ostavitelj ne bi imenovao sina u vlasti nasljednikom, ili ga ne bi poimenično iznaslijedio, oporuka je bila u cijelosti nevaljana i dolazilo bi do intestatnog nasljeđivanja.

Pravo određenog kruga osoba koje su ulazile u skupinu *sui heredes* da budu spomenute u oporuci naziva se formalno nužno nasljedno pravo.

Pretor je proširio pravo na pominjanje u oporuci na sve osobe koje su sačinjavale prvi nasljedni red pretorskog prava (*liberi*). Ako bi te osobe bile šutke mimođene (*praeterire*, *praeteritio*), pretor bi ih štitio dodjeljujući im posjed ostavinskih dobara uprkos oporuci – *bonorum possessio contra tabulas*.

Propisi o formalnom nužnom nasljednom pravu nisu štitili od nepravičnog isključivanja iz nasljedstva. Zato se vremenom ustalilo shvaćanje da najbliži srodnici u oporuci moraju biti ne samo spomenuti, nego imenovani nasljednicima na određeni dio ako nije bilo opravdanog razloga za iznasljeđenje (*exhereditio*).

Materijalno nužno nasljedno pravo je skup pravnih pravila kojima se određuje krug osoba kojima je oporučitelj dužan ostaviti određeni dio svoje imovine (*legitima portio*). Taj dio koji nužni nasljednici moraju dobiti od ostavitelja naziva se nužni dio, a to je dio onog dijela (tj. zakonskog dijela) koji bi nužni nasljednici dobili kao zakonski nasljednici da nema oporuke.

Krug osoba s pravom na nužni dio obuhvaćao je potomke, pretke, braću i sestre, te polubraću i polusestre ako je za nasljednika postavljena nedostojna osoba (*turpis persona*, npr. glumci, podvodači). Ako te osobe bez opravdanog razloga ne bi dobile ni četvrtinu zakonskog dijela, imale su pravo protiv oporučnog nasljednika podići tužbu zbog nemoralne oporuke – *querella inofficiosi testamenti* i tražiti pobijanje oporuke. Sud je po slobodnoj ocjeni određivao kada je iznasljeđenje bilo nepravično, a u Justinijanovom pravu (Nov. 115) taksativno su nabrojani motivi za isključenje koji se smatraju pravičnim (odnose se uglavnom na napade na život, tijelo i čast roditelja; zanemarivanje brige o roditeljima u bolesti i zarobljeništvu; nemoralan život nasljednika; otpadništvo od katoličanstva; zabranu roditeljima da naprave oporuku; tužbu protiv roditelja u kaznenim stvarima koje se ne odnose protiv cara i države). Ako bi uspio s tužbom, nužni nasljednik dobijao je sve ono što bi mu pripadalo kao intestatnom nasljedniku. Dijelovi oporuke u kojima se nije diralo u pravo nužnog nasljednika, ostajali su na snazi.

Nužni nasljednik kojem je testator barem nešto ostavio, po Justinijanovom pravu mogao je zahtijevati samo nadopunu do nužnog dijela putem ***actio ad supplendam legitimam***.

Justinijan je odredio da nužni dio iznosi trećinu ako je ostavitelj imao do četvoro djece, odnosno, preko tog broja, polovicu neoporučnog nasljednog dijela djeteta. Nužnim nasljednicima smatrani su samo descendenti i ascendenti (samo ako nije bilo potomaka).

§ 92 – Supstitucije

Testator (oporučitelj) mogao je odrediti u oporuci nasljednikova zamjenika u slučaju ako prvoimenovani nasljednik (*heres institutus*) ne prihvati nasljedstvo, ili umre prije nego što je stekao sposobnost za pravljenje oporuke (*testamenti factio activa*).

Eventualni nasljednik naziva se supstitut (*heres substitutus, heres secundus*), a ustanova – supstitucija (***substitutio***). Postojale su dvije vrste supstitucije: vulgarna i pupilarna.

Vulgarna supstitucija (*substitutio vulgaris*) ili obična, redovita supstitucija postoji kada ostavitelj odredi osobu koja će biti nasljednik u slučaju ako prvoimenovani nasljednik ne doživi delaciju ili odbije nasljedstvo, ili iz bilo kojeg razloga ne postane nasljednik. Supstitucija je, u stvari, postavljanje nasljednika pod odgovornim uvjetom - ako prvoimenovani ne postane nasljednik. Ostavitelj je mogao imenovati i supstitute supstitutima.

Pupilarna supstitucija (*substitutio pupillaris*) postoji kada *testator* imenuje nasljednikom svog maloljetnog sina, istodobno mu određujući zamjenika, za slučaj da umre prije nego što je postao sposoban napraviti oporuku.

Justinijanovo pravo uvelo je **kvazipupilarnu supstituciju (*substitutio quasi pupillaris*)** kod koje oporučitelj svom duševno bolesnom descendentu određuje nasljednika. Kvazipupilarna supstitucija nije uzimana u obzir ako bi duševno bolesni ozdravio, ili ako bi imao potomka koji je duševno zdrav.

Četvrto poglavlje

ZAPISI (LEGATI I FIDEIKOMISI) I DAROVANJE ZA SLUČAJ SMRTI

§ 93 – Legati (*legatum*)

Legat (*legatum*) je odredba posljednje volje kojom ostavitelj naređuje nasljedniku (*oneratus*) da iz imovine stečene nasljedstvom preda trećoj osobi (zapisovnik; *legatarius*; *honoratus*) neko pravo ili neku stvar.

Legat je formalna jednostrana izjava volje ostavitelja priznata po civilnom pravu. Mora biti naređen u oporuci svečanim riječima i zapovjednim načinom (*imperativis verbis*), odmah nakon imenovanja nasljednika. Počev od razdoblja Principata uobičajilo se legate naređivati u odvojenim pločicama, nazvanim kodici (codicilli).

Legatar je singularni sukcesor jer dobija samo točno određeno pojedinačno pravo ili stvar, za razliku od nasljednika koji je univerzalni sukcesor jer stupa u ukupnost ostaviteljevih prava i obveza. Da bi se spriječilo ostavitelja da veći dio ostavine raspodijeli u obliku legata i time ošteti nasljednike, doneseni su zakonski propisi o ograničenju legata, od kojih je najvažniji *lex Falcidia* iz I. st. p.n.e. kojim je zabranjeno da se legatima iscrpi više od tri četvrtine ostavine, tj. nasljedniku je morala ostati najmanje četvrtina ostavine (*quarta falcidia*).

Kod stjecanja legata bitna su dva momenta: *dies cedens* i *dies veniens*. ***Dies cedens*** pada u čas delacije (ostaviteljeve smrti) i tim momentom legatar stječe pravo na stjecanje legata. ***Dies veniens*** pada u čas prihvata nasljedstva (*aditio hereditatis*) i od tada legatar može vršiti sva prava iz stečenog legata.

Veću praktičnu važnost u klasičnom pravu imala su dva oblika legata: *legatum per vindicationem* sa stvarnopravnim i *legatum per damnationem* s obveznopravnim učinkom.

Legatum per vindicationem ima **stvarnopravni učinak**, što znači da legatar već u momentu delacije (ostaviteljeve smrti) postaje vlasnik legirane stvari. Zato može nasljednika ili bilo koju treću osobu kod koje se nalazi legirana stvar odmah tužiti reivindikacijom i drugim stvarnopravnim tužbama. Sličan učinak ima i ***legatum per praeceptionem***.

Legatum per damnationem ima za posljedicu stvaranje **obveznog odnosa** između opterećenog nasljednika (*onerata*) i legatara (*honorata*). Budući da je taj obvezni odnos nastao bez njihove prethodne suglasnosti volja, svrstan je u kvazikontrakte. U momentu

ostaviteljeve smrti legatar stječe pravo da od opterećenog nasljednika traži ispunjenje legata putem ***actio ex testamento***. Sličan učinak imao je i ***legatum sinendi modo***.

Postklasično pravo izbrisalo je razlike između navedenih vrsta legata. Nisu više bile potrebne svečane riječi jer se legat mogao ostaviti bilo kojim riječima.

Justinijanovo pravo stvorilo je jedan tip legata koji je s obzirom na sadržaj proizvodio realne ili obveznopravne učinke, a legatar je bio zaštićen tužbom *in rem* ili *in personam*.

§ 94 – Fideikomisi (*fideicommissum*)

Fideikomis (*fideicommissum*) je neformalna molba koju je ostavitelj upućivao osobama koje su nešto stekle iz ostavine (*fiduciarius*) da izvrše neku imovinsku namjenu u korist trećeg (*fideicommissarius*).

Ispunjenje molbe koja je najčešće upućivana nasljedniku ili legataru, zavisilo je samo od njihove savjesnosti i poštenja (*fides*). Tek od razdoblja Principata fideikomisar je mogao sudskim putem zahtijevati ispunjenje ostaviteljeve molbe. Justinijanovo pravo izjednačilo ih je s legatima i u pogledu učinka i u pogledu pravne zaštite.

Predmet fideikomisa mogle su biti pojedine stvari, oprost duga, a iznimno i cijela ostavina (univerzalni fideikomis – *fideicommissum hereditatis* ili *hereditas fideicommissaria*). *Senatus consultum Pegasianum* dopustio je fiducijaru da zadrži čistu četvrtinu ostavine (*quarta pegasiana*).

Putem fideikomisarne supstitucije (*supstitutio fideicomissaria*) bilo je moguće odrediti supstituta prvoimenovanom fideikomisaru koji je, najčešće nakon svoje smrti, morao ustupiti imovinu drugoimenovanom fideikomisaru itd. Tako je stvoren obiteljski fideikomis kojim se nalagalo da će uvijek ubuduće nepodijeljenu ostavinu dobiti određeni član obitelji kao fideikomisar, koji će je ustupiti daljem fideikomisaru itd. Ni prvi nasljednik (fiducijar) ni kasniji fideikomisari nisu smjeli otuđiti dobivenu imovinu ni raspolaganjima *inter vivos* ni *mortis causa*. Taj institut često je upotrebljavan u feudalnom pravu.

§ 95 – Darovanje za slučaj smrti (*donatio mortis causa*)

Darovanje za slučaj smrti (*donatio mortis causa*) je darovanje koje zaključuje darovatelj koji se nalazi u smrtnoj opasnosti, čiji će učinak nastupiti tek ako obdareni preživi darovatelja.

Takvo darovanje zaključivala je osoba koja se nalazila u smrtnoj opasnosti zbog odlaska u rat ili na opasan put, teške bolesti i sl. Sklapano je u obliku uvjetnih poslova jer je učinak darovanja nastupao tek ako obdareni preživi darovatelja, tj. darovanje je gubilo važnost ako bi darovatelj ozdravio ili izbjegao opasnost.

Moglo se zaključiti na dva načina: u formi pravnog posla pod rezolutivnim i u formi pravnog posla pod suspenzivnim uvjetom.

Ako bi darovatelj prenio vlasništvo darovane stvari na obdarenog uz uvjet da je vrati ako darovatelj preživi opasnost, radi se o pravnom poslu pod rezolutivnim (raskidnim) uvjetom. Vraćanje stvari moglo se tražiti putem *condictio causa data causa non secuta*.

Drugi način na koji je bilo moguće sklopiti darovanje za slučaj smrti je **sporazum pod suspenzivnim uvjetom prema kojem će obdareni postati vlasnik stvari tek ako darovatelj ne preživi opasnost.**

Već u razdoblju klasičnog prava na darovanje za slučaj smrti počela su se primjenjivati pravila o legatima, da bi u Justinijanovom pravu ti instituti bili izjednačeni.

